

Derecho Tributario

INTRODUCCIÓN

¿Por qué existe el derecho tributario, y en general los tributos? Vemos que en sociedad, existe una necesidad económica tendiente a la implementación de medidas que permitan alcanzar o propender al bien común. Así, desde el punto de vista ontológico, el bien común es la *ultima ratio* del derecho tributario; el impuesto existe para, en definitiva, satisfacer el bien común.

Se podría decir que los tributos se utilizan en medidas que no son de por sí tendientes al bien común (por ejemplo, armamento). Pero, tenemos que entender que el Estado tiene necesidades también, necesidades que le permiten existir. A su vez, el Estado existe para satisfacer el bien común. Luego, la satisfacción de necesidades del Estado que permiten que exista, es también tendiente al bien común.

La actividad financiera del Estado tiene tres estadios:

- Ingresos
- Gastos
- Gestión de recursos
 - Política
 - Económica
 - Técnica
 - Estas tres ramas anteriores se conocen como “finanzas públicas”
- Jurídica, que se conoce como derecho financiero.

Sobre este **derecho financiero**, se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del estado y sus diversos organismos en varios aspectos, como órganos que la ejercen, medios en que se exteriorizan las actividades financieras, y el contenido de las normas que la originan.

Podemos destacar del derecho financiero el que (1) solo se preocupa de la actividad financiera del Estado (de la actividad financiera de los particulares lo regula el derecho civil y comercial); (2) solo se preocupa de los aspectos jurídicos, y no de los elementos políticos y técnicos.

Dentro del derecho financiero, hay tres subramas:

1. Derecho presupuestario. Guarda relación con los gastos del Estado.
2. Derecho administrativo. Guarda relación con los ingresos del Estado.
3. **Derecho tributario.** Guarda relación con los ingresos de los particulares.

El Estado puede obtener ingresos de diversas **fuentes**. Así, endeudamiento (e.g bonos soberanos, bonos generales del banco central, etc...), tributos (e.g impuestos, como el IVA, el impuesto a la renta), multas, explotación de bienes del Estado (empresas del Estado). Estas fuentes pueden ser **originarias**, cuando provienen de bienes que pertenecen al Estado, o **derivativas**, cuando provienen de riquezas que el Estado quita a los particulares. De esta última (fuente derivativa), la fuente más importante son los tributos.

Podemos analizar brevemente la fuente *tributo*:

IVA: grava el hecho de la venta, y el sujeto pasivo es el vendedor. El contribuyente de hecho es el consumidor final, por el fenómeno de la traslación del impacto económico (por el cual quién soporta el impacto económico no es el sujeto pasivo de la obligación tributaria).

Impuesto a la renta: renta es un aumento patrimonial.

- Global complementario (“IGC”): impuesto a la renta que afecta los incrementos patrimoniales de las **personas naturales**¹ con domicilio o residencia para efectos tributarios en Chile.²
- Primera categoría (“IDPC”): grava las **rentas** señaladas en el art. 20 del DL 824. El contribuyente puede ser persona natural o jurídica.
- Impuesto adicional a la renta (“IA”): grava a las rentas que tienen su fuente en Chile y que perciben personas que no tienen su domicilio o residencia tributaria en Chile. Tiene una tasa del 35%.

Ejemplo de impuesto a la renta.

Copac paga, por sus utilidades, impuesto a la renta de primera categoría con una tasa proporcional de 27%. La junta ordinaria aprueba los estados financieros que dan cuenta de las utilidades financieras de la empresa.³ A la determinación de la utilidad financiera se le practican ajustes de acuerdo a la legislación tributaria para llegar a determinar el resultado tributario. Aquí existe una suerte de iteración. Si se determina que existe una utilidad tributaria, ello implicará una pérdida financiera. De la utilidad financiera que se determinó antes, habrá que restar un monto para pagar los impuestos. Lo que da derecho a distribuir

¹ Nunca va a afectar a una persona jurídica ni sociedad de hecho. La que sí podría verse afectada es la criatura que está por nacer.

² El CT define qué significa tener domicilio o residencia tributaria en Chile (art. 8°). No se puede estar domiciliado en dos partes para efectos tributarios.

En cuanto a la nacionalidad, ésta ha dejado de ser un factor importante para determinar la tributación de una determinada actividad. Solo se considera en una norma del Código (art. 3° inc. 2°).

³ La utilidad financiera tiene su propia forma de determinarse y no es sinónimo de utilidad tributaria. Gran parte de los países utilizan el sistema y lenguaje contable conocido como IFRS. Antes cada país tenía sus propios GAAP (General Accepted Accounting Principles).

dividendos es la existencia de utilidad financiera. En definitiva, hay que entender que existe un juego o relación entre las utilidades financieras y tributarias, pero estas no son lo mismo, de manera que pueden darse todo tipo de combinaciones.

El accionista persona natural A que recibe dividendos pagará IGC (con tasa progresiva). A podrá usar como un crédito en contra del IGC el impuesto de primera categoría pagado por la utilidad en su fuente.

La accionista Scarlett Johansson pagará IA, porque no está domiciliada o residiendo en Chile, pero recibe una utilidad de fuente chilena. Este impuesto es un *withholding tax* (w/h)⁴ con una tasa proporcional de 35%. Copec deberá retener, declarar y enterar el impuesto por cuenta de Scarlett. Dado que ella podrá usar el impuesto de primera categoría efectivamente pagado por las utilidades de Copec como crédito, terminará pagando un 8%. Luego, Copec, al enterar el monto en arcas fiscales, realizará primero la operación de descontar el crédito ($35\% - 27\% = 8\%$).

¿Qué pasa con el dividendo que percibe el accionista Antar Chile SA de las utilidades financieras de Copec? Se presenta el problema que se podría gravar la misma renta dos veces con el mismo impuesto (doble tributación). Por esto, la ley señala que el contribuyente de primera categoría está exento de IDPC por una renta que ya pagó dicho impuesto. Es muy importante que esto conste en un **registro**,⁵ ya que ello será necesario si se quiere usar el impuesto de primera categoría que efectivamente se pagó como un crédito contra el impuesto final (Angelini lo quiere usar contra el IGC que tiene que pagar al retirar sus utilidades).

Al analizar este ejemplo, uno podría decir que en realidad existe un solo impuesto, que sería el IGC para el contribuyente persona natural con residencia o domicilio tributario en Chile, y el IA para los contribuyentes con domicilio fuera de Chile para efectos tributarios. Esto es lo que se conoce como un **sistema integrado**, que permite imputar como créditos el impuesto de primera categoría efectivamente pagado.

⁴ *Withholding tax*: **impuesto de retención**.

⁵ S.A.C.: saldo acumulado de créditos (el *curriculum vitae* de la renta).

TRIBUTOS

Podemos definirlos como *una prestación obligatoria, comúnmente exigida en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, y que da lugar a relaciones de derecho público*. Esta definición amerita ciertos comentarios.

(1) “Prestación obligatoria”. Existen dos teorías al respecto. En primer lugar, tenemos la **teoría contractual** que explica que existen relaciones entre el Estado y los particulares, donde los últimos pagan al primero y tienen un derecho a recibir una contraprestación por parte de él (e.g se paga el IVA para luego recibir beneficios médicos).

Sin embargo, la práctica indica que lo que realmente caracteriza al tributo es que este se impone unilateralmente por la ley. Es de la ley que emana la facultad de imperio, de poder exigir coercitivamente el pago del tributo, y no hay ningún contrato de por medio (**teoría de la obligatoriedad del tributo**). Esto último se relaciona estrictamente con el principio de legalidad o de reserva legal en materia de orden público económico: no puede imponerse un tributo sino por ley, y nunca por acto administrativo (*nullum tributo sine lege*). En ese sentido, la ley debe claramente describir cual es el hecho gravado, la forma en determinar el valor del gravamen. Así, y al igual que en el derecho penal, hay un principio de tipicidad (es posible hacer una analogía al principio de legalidad en materia penal y las leyes penales en blanco).

(2) “Comúnmente exigida en dinero”. Se trata de una obligación de dar, y en la práctica exclusivamente de dinero. El tributo en otros bienes es un legado de los sistemas feudales donde se entregaban bienes diferentes, como parte de la cosecha.

En Chile tenemos un sistema integrado, que permite que las personas puedan oponer créditos por tributos ya efectivamente pagados ante nuevos tributos que en principio se deberían pagar.

El impuesto de primera categoría en Chile se paga anualmente, y vence el 30 de abril del año siguiente.

Otra definición posible es un vínculo jurídico cuya fuente mediata es la ley, que nace con motivo de ocurrir los hechos o situaciones descritas por la misma ley, en cuya virtud personas *determinadas* debe entregar al Estado *determinadas* sumas de dinero, para la satisfacción de necesidades colectivas.

Esta definición es similar a la de impuesto y a la de obligación tributaria.

(1) Vínculo jurídico. Se da entre el fisco y los particulares, y emana de la ley. Ahora, la ley es la fuente *mediata*. La fuente inmediata está dado por la verificación por parte del contribuyente del hecho gravado descrito por la ley.

- Así por ejemplo, el art. 20 de la ley de la renta describe una serie de actividades que dan lugar al impuesto a la renta de primera categoría. Luego, si el balance tributario de CMPC arroja un balance positivo, CMPC incurre en el hecho gravado por la fuente mediata: la ley.
- En el caso del IVA, el sujeto pasivo del impuesto es el vendedor, que vende *habitualmente* un bien corporal mueble dentro del territorio de la República.
- Otro caso sería el de las contribuciones, donde el hecho gravado es el hecho de ser propietario de un inmueble.
- Impuesto a la herencia: el hecho gravado es el hecho de recibir una herencia.
- En el caso de una tasa, por ejemplo la emisión de un pasaporte.
- Una multa: el hecho de incurrir en la conducta multada.
- Los aranceles (impuesto externo).

(2) Dándose el vínculo jurídico, el efecto es que un particular queda obligado a pagar una suma de dinero. Para estos efectos, la ley establece un procedimiento para calcular cuánto se adeuda por los tributos.

- IVA. La ley señala exactamente cómo se determina la suma a pagar, al establecer que lo que se paga es el 19% del precio.

- En primera categoría, existe una metodología para calcular el valor del impuesto. El hecho gravado es la renta líquida; el incremento patrimonial efectivo. El decreto ley 824 establece en sus art. 19 y ss. los pasos para la **determinación de la renta líquida imponible**.

La renta líquida imponible pasa a ser el valor del hecho gravado (*net taxable income*), y se obtiene después de descontar de los ingresos una serie de elementos que no constituyen un incremento patrimonial, como los **ingresos no renta**.

Así, se llega a los **ingresos brutos**, a los que luego se les debe descontar los **costos directos**. De eso se desprende la **renta bruta**, a la que se le debe descontar los **gastos necesarios** (e.g intereses bancarios, cuentas de luz, etc...).

De ello se obtiene la **renta líquida**, de la que se sigue una etapa de **corrección monetaria** (que pueden ser agregados o deducciones), lo que implica aplicar mecanismos de protección de inflación (la inflación no genera riqueza, por lo que se debe ajustar la cuenta patrimonial).

Con eso se consigue la **renta líquida ajustada**, a la cual hay que hacerle **agregados** o **reducciones**, que guardan relación con las correcciones a los resultados financieros.

Finalmente, se llega a la **renta líquida imponible**.

Luego, **R.L.I x Tasa = impuesto**.

A esta formula se le pueden descontar los **créditos por impuestos ya pagados**, que determina el monto a enterar o devolver.

Solo el que incurrió en la situación típica es quien debe pagar el impuesto.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

El concepto de tributo permite una subclasificación doctrinaria, que distingue **tasa, contribución, impuesto, y derecho habilitante**.

Tasa: ingreso ordinario de derecho público que obtiene el Estado en relación con alguna intervención o gasto de la administración pública, *motivado directamente por un particular*. Por ejemplo, pagar en el Registro Civil por un certificado.

Hay algunas relaciones que se dan en el ámbito del derecho privado donde el Estado actúa en su rol empresario, donde nos alejamos del concepto de tasa y llegamos al concepto de **tarifa**, que está regulado por el derecho comercial, y no por el derecho tributario.

En la tasa hay una relación directa entre el servicio y lo que se paga, lo que soporta la teoría contractual; no así las siguientes clasificaciones, que desvirtúan esa teoría.

Contribución: es un gravamen que tiene por objeto distribuir entre ciertos contribuyentes gastos de realización de obras o servicios que los benefician colectivamente de alguna manera más especial que al resto de las personas que integran la sociedad.

Por ejemplo, los derechos de aseo municipal, o los pagos por obra de alcantarillado.

Para distinguir entre tasa y contribución, en el caso de la primera quien se beneficia es la persona que requiere el servicio, mientras que en la contribución se beneficia un grupo de persona. Por eso, podemos inmediatamente corregir las “contribuciones de bienes raíces”, que no son contribuciones. Lo que sucedió es que se comenzó a recaudar conjuntamente los derechos de aseo, pero son dos ítemes separados. La contribución de bienes raíces es en realidad un impuesto que va a los fondos generales del país, y no a la municipalidad.

Inmediatamente ya es difuso quién es el beneficiario.

Impuesto: gravamen que se exige para cubrir los gastos del Estado, sin que el deudor reciba otro beneficio que aquél indeterminado que reciben todos los habitantes del país por el funcionamiento de los servicios públicos.

Vemos que se pierde toda relación directa entre el servicio y el pago, y se desvirtúa la teoría contractual del tributo.

Derechos habilitante: gravamen por cuyo pago el contribuyente queda habilitado para hacer algo que de otra manera la ley prohíbe. Por ejemplo, los impuestos aduaneros que gravan el tránsito. En este ejemplo, es importante recalcar que por la importación no estamos hablando de la compra necesariamente, porque hay situaciones donde el importador es mero tenedor, como lo sería quien importa máquinas sujetas a leasing. Luego, el arancel aduanero es un impuesto externo que grava el tránsito de mercaderías desde una jurisdicción a otra. De no pagarse el arancel aduanero, no se está facultado para incorporar el bien al territorio nacional. Así, han surgido las zonas francas donde los productos comprados ahí no pagan el arancel aduanero, mientras se mantengan en el territorio de la zona franca (e.g si se sale de la ZF de Iquique, se deberán pagar los impuestos correspondientes).

Otro ejemplo clásico del derecho habilitante es la patente comercial, la patente para alcoholes, el permiso de circulación, etc...

Se discute si el peaje podría ser un derecho habilitante o una tasa. El profesor estima que, no obstante el sistema de concesiones, se trata de un derecho habilitante.

»» La clasificación de los tributos es una cuestión de relativa indiferencia tanto para el Estado como para los contribuyentes. Si podría ser de relevancia para efectos de las normas constitucionales al respecto; pero en todo caso se trató de ser lo más general, y hablar siempre de tributos.

La CPR en su artículo 19 No. 20 menciona el principio de no afectación tributaria, que admite como excepción los tributos con clara identificación respecto de una actividad regional, o la defensa nacional. Lo que si es diferente es que, según la clase del tributo, el contribuyente tiene derecho a exigir una determinada contraprestación. Esto sería el caso de las tasas, la contribución (e.g la posibilidad de reclamar porque el camión de la basura no ha pasado), y los derechos habilitantes.

IMPUESTOS

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS

1. Ordinario y Extraordinarios

Son **ordinarios** aquellos que integran el sistema tributario de un país de modo permanente. Así en Chile, la ley de la renta o la ley del IVA.

Son **extraordinarios** aquellos que se establecen por una situación extraordinaria, y se caracterizan por su transitoriedad. En Chile, cuando ocurren catástrofes como terremotos se imponen impuestos extraordinarios. Ahora bien, la tendencia ha sido que estos impuestos transitorios se vayan volviendo cada vez más permanentes por leyes misceláneas o disposiciones transitorias que amplían su vigencia o plazos.

La estabilidad y claridad de los impuestos son un fuerte incentivo a la inversión. ¿Cuándo rinde más la ley de la renta? Cuando hay renta. En ese sentido, la demagogia política que busca subir los impuestos no necesariamente generará mayor riqueza para el Estado, toda vez que las empresas no querrán asumir mayores riesgos que entreguen mayor renta. El problema siempre está en la base imponible, no en la tasa; lo importante es que suba esa base imponible, no (necesariamente) la tasa.

2. Externos e internos

Son **externos** aquellos que gravan el comercio internacional de mercadería, y se llaman derechos o aranceles aduaneros. Por ejemplo, Falabella (R.C.H)⁶ importa productos Nike (U.S.A). El precio está en términos del CIF (Contiene seguro y flete, por las siglas en inglés) o aduanero (porque aduana podrá tasar lo que estima ser el valor real del bien), + el IVA⁷ + seguro y flete desde el puerto hasta el centro de distribución de Falabella. La base imponible es el CIF + el arancel aduanero (la suma de lo cual es base para el 19%). Este arancel aduanero (impuesto externo) no puede ser utilizado para pagar otros impuestos, como crédito. Lo que hará Falabella, es *activar* (término contable) el arancel, es decir, lo agrega al precio que pagó por el producto (**costo de adquisición**), para los efectos de determinar la renta su ulterior venta o enajenación. En definitiva, el impuesto externo tiene un efecto en la **determinación de la base imponible**.

Replicando el ejemplo:

- El precio que paga Falabella es de \$100.
- El arancel aduanero es del 6%; es decir \$6.
- Luego, el costo de Falabella fue de \$106. Si su precio de venta es de \$200, su utilidad es de \$94.

⁶ República de Chile. C.H se refiere a Suiza.

⁷ La ley del IVA establece que la importación está afecta a IVA; es un caso especial, porque el IVA ordinariamente aplica a una venta final.

- Pero no hemos considerado el IVA. El IVA de \$106 (recordar que el IVA grava la importación) es de \$20.14 (19%).

El IVA va completamente separado de la renta; son dos registros separados que no se cruzan **en el caso de un contribuyente de IVA**; si no lo fuera, podrían mezclarse inmediatamente. Para efectos del IVA, se lleva un libro de compras y ventas, que señala cuáles son los créditos fiscales y débitos fiscales. Estos dos rieles solo se podrían llegar a cruzar a la muerte de un contribuyente de IVA.

Son **internos** aquellos que gravan actividades o actos que se realizan dentro del territorio de la República. Estos admiten una subclasificación entre **impuestos internos fiscales** e **impuestos internos municipales**, según quien sea el que percibe el impuesto. Así, un interno fiscal sería el global complementario, el IVA, el impuesto a la renta, etc... mientras que un interno municipal sería el permiso de circulación, la patente comercial, entre otros.⁸

El arancel aduanero es siempre fiscal, jamás municipal.

3. Directos e Indirectos

Directos son aquellos en que el impacto económico del impuesto recae precisamente en el contribuyente que la ley ha querido gravar, y no se puede legalmente transferir el impacto. Por ejemplo, por el hecho de determinar un rendimiento positivo, CMPC tiene que pagar el impuesto a la renta de primera categoría, y no lo pueden pagar sus filiales, solo CMPC.

El impuesto directo lo puede ser **real** o **personal**. Es real cuando grava la riqueza en sí, sin tomar en consideración ninguna situación particular del contribuyente. Por ejemplo, el trabajador que gana su sueldo paga X impuesto independiente de su situación personal (por ejemplo, la existencia de un crédito hipotecario enorme). Será personal cuando para determinar el monto a pagar se consideran las circunstancias personales del contribuyente, por ejemplo si la ley estableciera que el padre de familia pague menos que el soltero. En Chile tenemos el impuesto a la herencia, que considera el grado de parentesco con el causante (entre más cercano, menor el impuesto). Lo esencial en definitiva es que la **calidad de sujeto pasivo no se traspasa** a otro.

El fenómeno de la traslación de la carga del impuesto lo podemos ver a propósito de un ejemplo. Don Urbano el agricultor tiene un bosque de eucaliptos, y vende la madera a empresas CMPC. Esta última vende resmas a cuadernos Torre, que vende a Lápiz López. Finalmente, los consumidores compran esos cuadernos. En el precio de venta de la madera, hay un precio + IVA, que tiene un doble componente. El IVA de Don Urbano es lo que se conoce como **débito fiscal**. El comprador (CMPC) financiará el IVA, y ese financiamiento será un **crédito fiscal**. El IVA que financió es para el comprador un crédito, pero el

⁸ Aunque estos ejemplos no los vimos a propósito de impuestos, en general se puede decir que los derechos habilitantes y contribuciones son impuestos (recordar que es una clasificación solo doctrinaria).

débito fiscal lo mantiene el sujeto pasivo de derecho (Don Urbano). El precio neto de la venta (el precio sin el IVA) es un costo de adquisición para CMPC (que es un tema de renta).

En la segunda venta de la cadena, CMPC agrega valor al producto, y tiene un nuevo precio neto de venta, sobre el que se carga IVA. Ese IVA es débito fiscal (**solo el vendedor puede tener débito fiscal**), y para el comprador será crédito fiscal. A su vez, el precio neto es el costo de adquisición para Torres. Este ejercicio lo podemos prolongar a las siguientes ventas, hasta llegar al **consumidor final**.

¿Qué es lo que se sucede en cada etapa de la cadena? Si miramos el caso de Torres, pero que es igual para los otros, lo que hará será comparar su débito fiscal con el crédito. **Podrá imputar como crédito aquella parte del débito que ha financiado**. Por ejemplo, tenía un débito de 1000 y un crédito de 500, por lo que solo tiene que declarar y enterar en arca fiscal \$500. Por eso es que a juicio de algunos se genera una compensación (pero esto no es tan preciso); en términos contables, hay un *neteo*.⁹

A fin de cada mes se hace la contabilización de cuánto se ha comprado y cuánto se ha vendido, para calcular débito y crédito. Pero, es posible tener un *carry forward*, es decir poder arrastrarlo: si por cualquier motivo sobró crédito fiscal al mes, se puede acarrear al mes siguiente, hasta que se termine por acabar. El arrastre podría ser de manera indefinida, e incluso llegar a cruzarse con el balance de la renta. En ese sentido, es importante que exista un motivo para que exista crédito fiscal sobrante, toda vez que eso implica falta de utilidades, y que a lo largo de los meses puede levantar sospechas desde el punto de vista tributario.

En resumen, normalmente $DF > CF = DF = IVA$ a pagar. Excepcionalmente, $DF < CF = CF$, **remanente de crédito fiscal**, que se protegerá de la inflación convirtiéndolo a UF. El remanente de crédito fiscal se puede pedir de vuelta según el art. 27 bis del DL 825.

Para utilizar el crédito fiscal, se debe pedir factura, donde el IVA va separado del precio. En cambio, el consumidor final debe pedir boleta, donde no se hace la separación.

La fiscalización del pago de IVA a lo largo de la cadena se hace en la venta final, pues ahí es cuando se mira si es que ha habido pago regular del impuesto, en base al CF y DF.

El consumidor final es siempre contribuyente de hecho, pues soporta el impacto económico.

El **impuesto indirecto** es aquél donde el *impacto económico* recae sobre un tercero *distinto* del contribuyente que la ley ha querido gravar. En el IVA, como ya vimos, la ley quiere gravar al vendedor de bienes corporales muebles, pero el vendedor traslada el impacto económico comprador. Sin embargo, jurídicamente **el contribuyente sigue siendo el vendedor**. De ahí que surja la clasificación doctrinaria entre contribuyente de hecho y de derecho, y lo que se conoce como el criterio de la traslación; criterio

⁹ ¿En qué momento no existiría un eslabón inicial de la cadena que no deba IVA? En el caso de una importación no afecta a IVA.

económico y no jurídico. El profesor estima que el **criterio de la traslación** es el correcto para determinar si estamos frente a un impuesto directo o indirecto. Otros autores dan criterios que el profesor estima no aplicables a la realidad chilena. Por ejemplo, el **criterio administrativo**, donde el contribuyente de un impuesto directo estaría inscrito en un rol, mientras que el contribuyente de un impuesto indirecto no lo tiene. En Chile esto **no existe**, la realidad no es así. Para que una sociedad nazca a la vida tributaria, se debe llenar un formulario de iniciación de actividades, que requiere indicar un **código de actividad**. Este se llena precisamente para saber si es un potencial contribuyente de IVA. Así, el criterio administrativo no sirve en Chile, porque desde el momento en que se inicia actividades ya se debe indicar la actividad, que apunta a mucho más que el IVA; no toda actividad de venta estará gravada por IVA.

Es importante no confundir traslación con la retención. La traslación es el traslado del impacto económico (del contribuyente de derecho al de hecho). En el impuesto único de segunda categoría en las rentas el trabajador dependiente, el empleador *retiene* y entera el impuesto por cuenta del trabajador, pero es este último quien sufre el impacto y no se lo traslada al empleador.

Los impuestos indirectos pueden ser **monofásicos** o **plurifásicos**, dependiendo de si se aplican en una o varias etapas de la fase de comercialización. En Chile el IVA es plurifásico, pues se aplica en cada venta.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS

Ventajas

- Cumplirían mejor con un ideal de justicia tributaria. Esto porque se logra que el contribuyente pague impuestos de acuerdo a su real capacidad económica, pudiendo quedar exento quienes tienen utilidades mínimas que solo sirven para subsistir. Esto lo podemos ver en el impuesto a la renta de segunda categoría y global complementario que tienen tasas progresivas.

- Estabilidad. En cuanto al rendimiento económico, durante épocas de crisis el rendimiento del impuesto baja lentamente.

Desventajas

- Estabilidad. De la misma forma en que el rendimiento baja lentamente, en épocas de bonanza el rendimiento del impuesto sube de manera lenta.

- Impopular u “odioso”. Se trata de impuestos bastante notorios, pues se pagan en fechas determinadas, por montos importantes que se pagan por todo, y no en partes que pasan desapercibidas. Todo esto genera la necesidad de invertir en fiscalización de impuesto.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Ventajas

- Elasticidad en su rendimiento. Se nota de inmediato su rendimiento, cuando la economía está rindiendo. El IVA, por ejemplo, se recauda de inmediato cuando el gasto privado comienza a aumentar.

- Poco ostensible. Su pago es disimulado, sobretodo en el caso del IVA para el consumidor final.
- Todos los pagan. Todo contribuyente concurre al financiamiento del Estado.

Desventajas

- Elasticidad. En época de recesión, el rendimiento baja drásticamente.
- Se opondría a un ideal de justicia tributaria. Se le cobra a todos por igual sin considerar la riqueza individual de cada contribuyente. A juicio del profesor, este tema, que es muy debatible, debe mirarse desde una perspectiva global. Ello involucra mirar a personas de escasos recursos que generalmente no pagan impuestos por la gran cantidad de exención que hay en Chile; y que el único impuesto que pagan en definitiva es el IVA (y otros indirectos). Si no hay una correcta focalización del gasto público, se pierde la justicia social; cuando una persona pobre paga, con mucho esfuerzo, un impuesto, lo hace porque luego recibirá un beneficio social como educación o salud.

4. Impuestos de tasa fija, proporcional y progresiva

De tasa fija son aquellos cuyo monto está establecido por la ley. Luego, la obligación tributaria está claramente determinada, que permanece invariable, cualquiera sea la base imponible. Por ejemplo, el impuesto de timbre y estampilla que se aplica a los cheques: se trata de un monto de unos 150 pesos por cada cheque específico, que lo retiene el banco al momento de entregar el talonario.

Podemos decir que más que una tasa fija, es un impuesto de **monto fijo**.

De tasa proporcional es aquél en que la tasa del impuesto permanece invariable, pudiendo variar la base imponible.¹⁰ Si varía la base imponible, varía el monto a enterar en arcas fiscales. Así por ejemplo, el impuesto de primera categoría (que grava las rentas descritas en el art. 20 de la ley de renta). Sobre el impuesto de primera categoría, perfectamente una persona natural puede ser contribuyente del mismo. El impuesto a la renta de primera categoría es del 25% o 27% dependiendo del sistema al que se está acogido, ya sea voluntariamente o por obligación.

Otro ejemplo es claramente el IVA. También lo es el impuesto adicional (art. 58 de la ley de la renta), como el impuesto que paga Scarlett Johanson por el dividendo que recibe de Copec, y que corresponde al 35%.

En el impuesto adicional del art. 59, que en realidad es un impuesto de retención, se grava la remesa de renta de fuente chilena. De acuerdo al art. 10, vamos a entender como fuente de renta chilena aquellas que provienen de bienes dentro de la república o actividades ubicadas dentro de ella. Ejemplo de esto sería un concierto de un artista extranjero que viene a Chile y recibe un honorario; o cuando se paga un interés a un acreedor extranjero, como cuando Entel pide un crédito a un banco extranjero (e.g BNP). En este último caso, BNP tiene una cuenta por cobrar, que es un activo. Hay dos pagos que se deben realizar: el

¹⁰ La base imponible se define como el “valor del hecho gravado”.

capital (k) y el interés (i). Solo el pago del interés constituye una renta para BNP, y sobre ese pago se aplica el impuesto de retención (withholding tax). El impuesto deberá pagarse **cuando la renta haya ingresado materialmente al patrimonio del contribuyente, o cuando la obligación se haya cumplido por un modo distinto del pago** (art. 2 de la ley renta). En ese sentido, si existe una novación por cambio de deudor, el impuesto del art. 59 se deberá pagar igualmente. ¿Qué pasaría si la deuda queda prescrita o condonada? Lo relevante es que nos referimos a modos de *cumplir* las obligaciones, no de *extinguir*, y no todo modo de extinguir es lo mismo que cumplir la deuda.

De tasa progresiva es aquél en el que la tasa aumenta a medida que aumenta la base imponible. Hay dos ejemplos de suma relevancia en nuestro sistema:

1. Impuesto único a las rentas del trabajo dependiente (impuesto único de segunda categoría). Son rentas del trabajo aquellas en que prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital.

2. Impuesto global complementario, que grava a las personas naturales (jamás una jurídica) con domicilio o residencia tributaria en Chile,¹¹ por sus rentas de fuente **mundial**. Así, la renta que recibe un chileno por sus acciones en una empresa depositada en una cuenta corriente francesa está afecta al impuesto; cuando ese cliente compra con la tarjeta de ese banco, se entiende que percibió la renta y debe pagar el global complementario en Chile. **No hay que confundir fiscalización con gravamen**; da lo mismo si el SII tenga acceso o no a esa cuenta.

En el impuesto global complementario, por disposición legal se incluyen las rentas del trabajo independiente.

Otro ejemplo es el impuesto de herencia, que va de 0 a 25%.

En los impuestos de tasa progresiva hay una diferencia entre la tasa marginal y la tasa efectiva. Esto lo veremos en base a un ejemplo:

Una persona tiene un sueldo de \$650.000. La ley dispone:

0 - 100,000 = exento

100,001 - 200,000 = 5%

200,001 - 300,000 = 10%

300,001 - 400,000 = 20%

400,001 - 500,000 = 30%

500,001 - 600,000 = 40%

600,001 - y más = 50%

¹¹ Art. 8 No. 8 CT ; art. 59 CC.

Vemos que hay **tramos (tax brackets)**, donde cada tramo tiene distinto tratamiento tributario. Esta persona pagará, por tramo:

- Tramo 1 – 0
- Tramo 2 – 5,000
- Tramo 3 – 10,000
- Tramo 4 – 20,000
- Tramo 5 – 30,000
- Tramo 6 – 40,000
- Tramo 7 – 25,000 (por lo que excede de 600,000 son 50,000)

Luego, paga en impuesto \$130,000.

La tasa efectiva (effective tax rate) es de un 20%, mientras que la tasa marginal (marginal tax rate) es del 50%. En razón de la tasa efectiva es que no es lo mismo estar en tramo 7 ganando \$600,001 vs \$10,000,000.

5. A la renta y al patrimonio

A la renta son aquellos que gravan los incrementos patrimoniales, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Así, podemos hablar de distintos ejemplos. Tenemos rentas que tienen como origen un servicio. También tenemos renta que se originan en una utilidad o “mayor” valor en la enajenación de determinados bienes. Esto último refiere a *capital gain tax*, que son impuestos a las ganancias capital, y que gravan la renta que se produce por la enajenación esporádica de bienes inmuebles, y que son generadores de rentas ordinarias como dividendos o frutos afectos a *income taxes*.

Ya veremos que la pérdida es un activo tributario.

La ley de la renta define lo que constituye renta. Cualquier incremento en el patrimonio cualquiera sea naturaleza, origen o denominación.

Al patrimonio son aquellos que gravan la fuente generadora de renta (gravan la existencia de un patrimonio en sí), sin tomar en cuenta si la fuente ha generado o no un incremento patrimonial. Por lo mismo autores han dicho que son impuestos regresivos, que hacen más pobre al contribuyente. El ejemplo más real en el caso chileno es el impuesto territorial, que grava un inmueble, independiente de su productividad. ¿Qué pasa con la plusvalía? ¿Acaso no es una utilidad? Esto es en realidad una mera expectativa, una utilidad virtual que solo se materializa en acciones concretas futuras. Es muy relevante la certeza jurídica en cuanto a lo que se está gravando, por eso es peligroso gravar una mera expectativa. El impuesto se aplica sobre la utilidad *realizada* o *realized gain* (la utilidad concretizada en por ejemplo una venta).

Otro ejemplo de impuesto al patrimonio es el pago de la patente municipal. La patente se aplica a determinadas actividades que regula la ley de rentas municipales, y en general grava a sociedades o contribuyentes que determinan renta según balance (contabilidad completa). Es en este proceso en que el contribuyente determina su renta según balance, donde se calcula el **capital propio tributario (CPT)**,¹² que se debe informar al SII. El CPT es activo (incluyendo utilidades retenidas) - pasivos, + algunas retenciones. Se asemeja así fuertemente al patrimonio de una empresa (activo - pasivo). El CPT es la base imponible para el cálculo de la patente municipal, que va de un 0,25 a 0,5% del CPT (tasa proporcional, *que depende de la municipalidad*).

La patente se trata de un impuesto al patrimonio porque se aplica independiente de la existencia de utilidades en la empresa, sobre el CPT.

Es muy relevante destacar que hay determinados contribuyentes de primera categoría que no están obligados a determinar su renta según balance; por tanto, no tienen CPT. Se trata de las denominadas rentistas de capitales mobiliarios, clasificadas en el art. 20 N° 2 de la Ley Renta, que solo obtienen rentas de capitales mobiliarios (acciones, bonos, debentures, etc.) y no desarrollan otra actividad. Para efectos de calcular la patente, se aplica la patente municipal mínima de 1 UTM. Ahora bien, el hecho de no determinar renta según balance trae aparejadas otras consecuencias tributarias.

Se derogó el art. 20 No.1 D) de la Ley Renta que presumía renta al dueño de un predio urbano, y que era otro ejemplo de impuesto al patrimonio.

El contribuyente que paga patente municipal sobre su CPT podrá deducirlo en el pago de su impuesto a la renta (se consolidará como crédito).

6. Mensuales y anuales

Mensuales son aquellos cuya determinación se hace en base a un periodo mensual. En base al sistema electrónico, se pagan prácticamente todos dentro de los primeros 20 días del mes *siguiente*. El ejemplo más importante es el IVA que deberá declarar el vendedor. Otro ejemplo importante es el impuesto único de segunda categoría que grava las rentas del trabajador dependiente. Aquí, el empleador deberá retener, declarar y enterar el impuesto. Tenemos a su vez el impuesto de retención a la remesa de rentas chilenas del art. 59 de la ley renta.

Anuales son aquellos cuya determinación se hace en base a un periodo anual. Así tenemos el impuesto de primera categoría y el global complementario. Hay un desfase entre el **año comercial** y el **año tributario**, lo cual es sumamente relevante para efectos de la prescripción.

El impuesto territorial es anual, pero se paga en cuotas: 30 de abril, 30 de julio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.

¹² Art.1 Ley Renta.

7. De retención y de declaración

De declaración es aquel donde el propio sujeto pasivo autodetermina el monto del impuesto a enterar en arcas fiscales. Una de las grandes vías de la determinación de la obligación tributaria es la que hace el propio contribuyente, y constituye la regla general. La obligación tributaria se puede determinar por el contribuyente, la justicia, o por actos coordinados (donde participa tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo, este último a través de los mecanismos de fiscalización).

Los más relevantes son el impuesto de primera categoría, donde es la propia compañía la que declara el formulario 22 al 30 de abril; el impuesto global complementario (ni siquiera el que le hizo la retención lo declarará).

De retención es aquél donde un tercero denominado sustituto o agente retenedor efectúa la retención, declaración y el entero del impuesto en arcas fiscales por cuenta de otro contribuyente. Ejemplo clásico es el impuesto único de segunda categoría a las rentas de trabajador dependiente, donde el empleador tiene que retener el tributo sobre la remuneración (base imponible) en su sentido amplio según lo que dispone el CT, pero excluidas las contribuciones sociales y otros ítemes que no constituyen remuneración y que la ley excluye (e.g la colación).

Otro ejemplo es el impuesto de retención a la remesa de renta de fuente chilena del art. 59. Será Entel quien retiene al impuesto sobre el interés que debe pagar al Banco de Paris por el crédito que retuvo; o la productora de eventos deberá retener el impuesto que paga la remuneración de Dire Straits cuando viene a Chile.¹³

¹³ Si ese artista exigiese un pago free of tax, la empresa deberá hacer un *gross up* (un enbrutecimiento). No cambia el sujeto pasivo de la obligación, sigue siendo el artista, pero hay una negociación contractual de por medio.

FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS

Se trata de cuatro grandes finalidades.

1. Financiera

Generan recursos para el Estado, que permiten financiar sus gastos.

2. Política

Algunos dicen que también es estratégica o geopolítica. Esto se refiere a que los impuestos sirven para establecer exenciones y/o franquicias tributarias, ello para que se desarrollen determinadas actividades o zonas geográficas, que pueden, a su vez, ser consideradas importantes desde un punto de vista geomilitar o político.

3. Económica

Se trata de una herramienta fundamental de **política económica**. Los impuestos pueden utilizarse para incentivar o desincentivar el consumo de determinados bienes. Aquí tenemos el tema todos los bienes suntuarios como el alcohol, el tabaco, etc...

Otro logro es el fomento del ahorro interno; o bien, el fomento de actividades como la reforestación a través de beneficios tributarios.

4. Redistribución de la riqueza nacional

Permiten pasar riqueza de quienes tienen más a quienes tienen menos. El Fisco puede financiar obras que normalmente benefician a personas de escasos recursos como hospitales y escuelas públicas.

FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO

Hemos hablado de las fuentes cuando nos referíamos a la verificación del hecho gravado por parte de un contribuyente. En ese sentido, podemos distinguir la fuente mediada de la inmediata. La inmediata era la verificación del hecho gravado, mientras que la fuente mediata era la ley por razón del principio de reserva legal en materia tributaria.

Cuando hablamos de la ley como fuente mediata, se podrían incluir todas las fuentes del derecho, pero en estricto sentido, en materia tributaria solo es fuente la ley en su sentido amplio (la pirámide normativa). Así, la CPR, las leyes, los DL, DFLs, y tratados internacionales ratificados y vigentes.

Constitución Política

Contiene cuatro normas de orden público económico en materia tributaria que limitan la potestad tributaria del fisco.

1. Principio de igualdad ante el impuesto (art. 19 No. 20 inc. 1)

*20°.- La igual repartición de los **tributos** en proporción a las **rentas** o en la **progresión** o forma que fije la ley, y la **igual repartición** de las demás cargas públicas.*

Al hablar de tributos, la ley habla en sentido amplio y contiene toda la clasificación que vimos antes. ¿Quedarían excluidos impuestos en base al patrimonio, si la CPR se refiere a las rentas?

Lo que se está asegurando es una igualdad ante el hecho gravado, que refiere a la generalidad que debe tener toda ley. Toda persona que se encuentre en una misma situación fáctica descrita por la ley debe pagar impuestos de la misma manera. Por tanto, todo quien transfiera el dominio de forma habitual un bien corporal mueble deberá pagar IVA. Las exenciones tributarias aplicables en ciertas regiones no suponen una discriminación arbitraria, porque esos contribuyentes están en una situación distinta. En cambio, una ley que grava específicamente a una empresa falla en ser general, y por lo tanto es discriminatoria.

Este principio de igualdad, por su correlato con la generalidad, es denominado como parte de aquellos principios meramente formales.

2. Principio de legalidad o reserva legal del impuesto (art. 63 No. 14 y 65 No. 1)

Artículo 63.- Sólo son materias de ley:

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

Art. 65 (...) Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1°.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

En definitiva, se aplica el principio de *nullum tributum sine lege* (al igual que lo que pasa en materia penal).

¿Por qué debe ser legal el impuesto? Porque las materias tributarias son de exclusiva iniciativa del Presidente, y toda materia de iniciativa exclusiva es materia de ley. Luego, no puede haber un ejercicio de potestad reglamentaria en materia tributaria cuando se impongan, supriman, reduzcan o condonan tributos.

¿Por qué el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva en materia tributaria? Esto tiene un origen histórico. Desde la época feudal, los caballeros cobraban impuestos a los campesinos que laboraban en su territorio bajo lo que podríamos denominar hoy contratos de medianería. El señor feudal estaba más cerca del pueblo y el Ejecutivo está “más cerca del pueblo” por haber sido elegido democráticamente.

Hoy en Chile, tenemos la siguiente estructura para un proyecto de ley tributario:

1. La Moneda: propone un proyecto tributario.

- Ministerio de Hacienda
 - Dirección de Presupuesto (DIPRES)
 - SII
 - Subdirección normativa
 - Subdirección de estudios
 - Subdirección de informática
 - Subdirección de fiscalización

2. C. Diputados » Comisión de Hacienda » vuelve a la Sala de la cámara.

3. Senado » Comisión de Hacienda » vuelve a la Sala.

4. Eventualmente, puede llegar a comisión mixta.

5. Vuelve el proyecto a la moneda para su promulgación

Elegido el Gobierno, la Moneda, a través de la SEGPRES, comienza a instruir al Ministro de Hacienda. Éste le solicita a su Jefe de Gabinete la coordinación de una reunión con el Director del SII, junto con el Subdirector Normativo y el Subdirector de Estudios, y también con el Director de Presupuesto. En esta reunión se distribuyen algunas cosas:

Subdirector Normativo: Normas que se deberán modificar. Se comienza a trabajar en el borrador del texto legal.

Subdirector de Estudios: estimar cuánto más/menos se va a recaudar.

Hablarán con informática y fiscalización para ver cómo se puede implementar.

Así se empieza a elaborar un proyecto de ley.

Preparar algoritmo que permita funcionar a la planilla y que identifique los bolsones de evasión y grupos de riesgo. Aquí se tomarán estadísticas, estudios comparados, informes de la OCDE.

Luego, se acompaña un informe financiero preparado entre la DIPRES y la Subdirección de Estudios, al igual que con todo proyecto de ley.

Una vez llegados al texto, éste será elevado a Hacienda, la cual volverá a la Moneda para el desarrollo de una serie de reuniones bilaterales con el Pdte. y algún otro ministro, en las que se discutirá cada frase, efecto, número y simulación.

Paralelamente, se está desarrollando un trabajo para conseguir votos.

Finalmente, el proyecto ingresa a la secretaría de la Cámara y se envía inmediatamente a la Comisión de Hacienda. Se produce la discusión del proyecto y vienen las invitaciones de la Comisión a los distintos expertos (abogados, profesores, economistas, auditores), gremios, asociaciones (SNA), etc. Con posterioridad, se vota en general el proyecto y, en segundo lugar, se vota en particular. Luego, pasa aprobado a la sala.

Una vez aprobado por la sala, el proyecto pasa a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se repite el proceso de la Cámara.

Aprobado el proyecto queda listo para su promulgación.

Como ya dijimos, “ley” incluye la ley propiamente tal, DL y DFL. En efecto, la mayoría de la regulación tributaria está hecha en base a DL:

- DL 830: Código Tributario
- DL 825: Ley de IVA
- DL 824: Ley Renta

A su vez, se tratan de leyes de quórum simple: 50+1.

¿En materia tributaria, el poder legislativo podrá iniciar alguna ley de carácter tributario? El poder legislativo no puede tener iniciativa que vaya a afectar los recursos del Estado. Sí puede dictar leyes tributaria que se refieran a otros aspectos, como plazos para pagar los impuestos u otras modalidades. Lo que no puede hacer es establecer, suprimir, modificar o condonar, pero sí podría tener iniciativa en cuanto a la administración de los mismos.

No puede el Fisco ejercer su poder de imperio (que se traduce en gravar un hecho) por medio de DS ni reglamentos. Eso no quita que puedan haber reglamentos, como el reglamento del IVA, pero que se limitan absolutamente en base a la ley correspondiente.

3. Principio de no discriminación (equidad)

Art. 19 No. 20 Inc. 2 En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

Pereira ve este principio de forma distinta que otros profesores. Para él, el énfasis está en la equidad, y se ve en el inciso segundo del No.20.

¿Cuándo estamos ante un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto? No hay una fórmula concreta, de modo que es una materia que queda entregada a los tribunales de justicia. En las actas constitucionales, se ve que la intención era evitar que la tasa del impuesto fuera de carácter expropiatorio. Hay una pugna entre el art. 19 No.20 y el art. 19 No.24, que da lugar a interpretaciones pro fisco o pro contribuyente (recaudación en razón del bien común vs propiedad).

Hay antecedentes históricos en relación a esto. Resulta que unos agricultores demandaron porque la indemnización que pagó el Fisco por expropiaciones se alejaba absolutamente del justo precio (acciones de retrocesión). Sin embargo, rápidamente y en forma paralela se pasó una ley que les aplicaba un impuesto del 95% sobre lo que excediera el valor de la indemnización original. La Corte Suprema determinó que ese impuesto era expropiatorio, contrario al principio de equidad.

A nivel doctrinario, se ha llegado al consenso de que los impuestos cercanos o superiores al 50% de la renta son *per se* expropiatorios. Lo interesante está en ver si es que acaso nuestra legislación, en particular la Ley Renta, considera la **teoría del socio**. Ésta se traduce en que el contribuyente sería socio del Estado (Fisco) con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas. Es decir, el particular tomaría conciencia de que debe participar en este proceso. ¿Qué implica ser socio del Fisco para satisfacer las necesidades colectivas? Básicamente, significa estar con el socio en las “duras y en las maduras”, sobre todo en las sociedades de capital.

Pereira estima que la legislación sí recoge esta teoría, pero no es una posición compartida por toda la doctrina. Para él, la teoría se ve reflejada en la norma que establece que su uno no determina utilidad, no paga impuesto. Se manifestaría a su vez en los **PPUA** (Pago Provisional por Utilidades Absorbidas), que guarda relación con el contribuyente que experimentó pérdida tributaria.

Lo veremos con un ejemplo,

Punta Mai SpA, que tiene el restaurant Villa Melelli, tiene acciones en Latam S.A. La junta de accionista de Latam aprueba repartir dividendos, y Punta Mai recibe utilidades tributables, descontado el IDPC que paga Latam (27% que se registra en el Saldo Acumulado Contable SAC). Al mismo tiempo, Villa Melelli se va a pérdida por la existencia de contaminaciones en la cocina.

(1) Una primera manifestación de la teoría del socio está en la pérdida tributaria. La pérdida tributaria (en simple, egresos > ingresos) es un activo, porque se puede imputar en contra de

las rentas que se obtengan en ejercicios siguientes, y así indefinidamente (carry forward of losses). El valor de esa pérdida corresponde a la tasa del impuesto de primera categoría de las utilidades futuras que se van a netear con esa pérdidas pasadas. Por ejemplo, en el año 1 se tiene una pérdida de 50, y en el año 2 una utilidad de 150. La renta líquida imponible del año 2 será de 100, porque la pérdida se neteará con las utilidades.

(2) Una segunda expresión de la teoría del socio se ve en el PPUA. Si el dividendo repartido por Latam fue de 100, ese dividendo acarrea un crédito, que es el 27% que se pagó por impuesto de primera categoría (en definitiva, Punta Mai recibe un ingreso de 100, repartido en 73 líquido y un 27 en crédito). Si la pérdida de Punta Mai fue de 100, puede solicitar a la TGR la devolución del impuesto de primera categoría pagado por las utilidades hasta el tope de su pérdida (si el crédito fuese mayor, el remanente quedara como crédito a favor de los accionistas de Punta Mai). Si Punta Mai recibió 100, y tenía pérdida de 100, se netean en 0, y se le devuelve el impuesto de primera categoría que pagó esa renta. Punta Mai perderá el activo que era la pérdida, y que podía usar en ejercicios posteriores, pero recibe a cambio el impuesto que devengó su utilidad. Se trata de una *suerte* de consolidación tributaria (porque en Chile no tenemos propiamente una consolidación tributaria).

Antes, el PPUA era un derecho del contribuyente. Hoy, la ley obliga a solicitar la devolución.

Si el crédito de la utilidad no se utilizará en el ejercicio de Punta Mai, se pasaría a los accionistas porque se trata de un **sistema integral**.

Dado que quien solicita la devolución del impuesto de primera categoría no es aquél contribuyente que efectivamente lo pagó, la ley considera que ese reembolso es para quien lo solicita un ingreso ordinario.¹⁴ Si es un ingreso ordinario, paga impuesto de primera categoría. Entonces, esos 27 constituyen ingreso ordinario, y se aplicará el impuesto de primera categoría: 27% de la renta líquida imponible de 27 = 7.29. Esto es lo que Pereira denomina **toll tax**. En definitiva, Punta Mai obtendría un neto de 19.71. Ese 7,29 será un crédito a favor de los accionistas de Punta Mai.

Cabe precisar que no hay un problema de doble tributación porque el 27% inicial lo pagó Latam, no Punta Mai.

El PPUA es un pago por utilidad absorbida, no por utilidad propia.

¹⁴ En términos sencillos, sin perjuicio de que este actor recibió solo \$73 líquidos, hay un crédito por \$27 que adquiere “gratuitamente”. Para efectos de calcular el impuesto que le corresponde, se entiende que tiene utilidad 100 (lo cual es independiente del líquido que tenga en caja) pero que en este caso se netea con la pérdida. Quedando en 0, ingresan \$27 líquidos a título de devolución de IDPC.

Estas dos situaciones son manifestaciones de la teoría del socio. La primera, porque el Fisco permite utilizar la pérdida y acarrearla a ejercicios futuros.

4. Principio de desafección (art. 19 No. 20 inc. 3 y 4)

Dice relación con el hecho de que se pierde el destino de los fondos recaudados: ingresan al erario nacional, a la Cuenta Única Nacional del Banco del Estado.

Estos fondos van al erario nacional sin responder a un fin específico. Esta garantía responde a razones históricas; existía un impuesto a las empresas del 5% que debía estar destinado necesariamente a la construcción de viviendas sociales.

Este principio admite excepciones:

- Impuestos destinados a fines propios de la defensa nacional.
- Impuestos que gravan una actividad o bienes que tengan una clara identificación local, se destinen al desarrollo de esa localidad.

» Los anteriores son los principales principios constitucionales, pero podemos destacar que el más importante es el principio de legalidad, porque da certeza a los impuestos.

Debemos recordar la pugna entre la potestad tributaria del Estado y el derecho de propiedad de las personas. De ahí derivan las diversas interpretaciones pro fisco o pro contribuyente.

Ley

INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA

La ley tributaria admite tres formas de interpretación.

- (1) Interpretación legal,
- (2) interpretación judicial,
- (3) Interpretación administrativa.

Históricamente, existían dos criterios a priorísticos de interpretación tributaria. Por un lado, el criterio *in dubio pro fisco*, pues los impuestos buscan satisfacer el bien común, e incluso la existencia del Estado mismo. Por el otro lado, *in dubio pro contribuyente*, porque existe un ataque contra el derecho de propiedad; más aún si consideramos que una de las partes no estaría contribuyendo con su obligación correlativa.

Hoy, estos criterios están bastante abandonados. La ley tributaria es una ley simple (de hecho, es de quórum simple), y por tanto debe interpretarse como toda otra ley: art. 19 - 24 del CC. Pero esto tiene una gran excepción, que está en línea con el principio de reserva legal: no se puede, por vía de interpretación analógica, llegar a crear, modificar o derogar un impuesto.

***Artículo 2 CT.-** En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales.*

El artículo 2 establece una prelación, en virtud de la cual primero se tiene que acudir a las normas del Código Tributario y otras leyes tributarias.

El Código Tributario es de naturaleza general, y sirve principalmente para delimitar “la cancha” en materia tributaria.

(1) INTERPRETACIÓN LEGAL

La interpretación legal es aquella que se realiza por medio de una ley interpretativa. Existe un problema de técnica legislativa, porque muchas leyes interpretativas se esconden en leyes misceláneas.

(2) INTERPRETACIÓN JUDICIAL

La interpretación judicial corresponde, evidentemente, al juez. Sin embargo, por mucho tiempo (40-50 años), la primera instancia en un reclamo tributario (juicio ordinario tributario) era el director regional del SII del domicilio del contribuyente que reclamaba. Era una jurisdicción otorgada por ley. A su vez, era el mismo director regional que fiscalizó y cuestionó administrativamente al contribuyente. Por lo tanto, era muy poco probable que el mismo director que cuestionó la liquidación del contribuyente, cambiara de su parecer en sede judicial.

Habían autores que defendían esta situación por temas de economía y por especialización.

El problema que se dio fue que el director regional se vio sobrecargado por sus labores de fiscalización y judiciales. Esto dio lugar a una figura de delegación de esta facultad en distintos miembros del organismo. Se cuestionó la constitucionalidad de esta delegación por vía de nulidad de derecho público, quedando miles de causas pendientes que debieron retrotraerse a su inicio, anulando toda actuación posterior.

Sumando este problema práctico a problemas de parcialidad y debido proceso, se llevó adelante una reforma al sistema judicial tributario, estableciéndose los tribunales tributarios y aduaneros (“TTA”). Son tribunales independientes, que se dedican exclusivamente a estos temas. Es más, el juez del TTA no tiene ninguna limitación en cuanto a dejar sin efecto resoluciones del SII. Cuando el director regional era juez, no perdía por este hecho su calidad de funcionario administrativo del SII; y el funcionario del Sin está obligado a seguir la interpretación del servicio, so pena de sumario. Luego, salvo un error manifiesto de carácter formal, las posibilidades de revertir una resolución del SII era imposible.

Además, con la reforma se estableció que la prueba en materia tributaria se ponderará según las reglas de la sana crítica.

Podemos establecer una línea de tiempo en materia judicial tributaria.

(1) Declaración de impuestos. El contribuyente deberá calcular la suma de dinero para cumplir con su obligación de dar.

De esto se puede seguir eventualmente una **(2) notificación**, por la que el SII avisa que ha notado diferencias en el cálculo del impuesto. Luego de la notificación, puede que se arregle el problema, y termine ahí.

Pero, si no se arregla, se llegará a la primera gran etapa de fiscalización, cual es la **(3) citación**. Se trata a su vez de la gran oportunidad para el contribuyente de “poner toda la carne a la parrilla”. El SII citará para que se explique y se aporten antecedentes sobre un tema específico. El contribuyente deberá efectivamente explicar, pues de lo contrario puede implicar la preclusión de ciertos derechos en un ulterior juicio tributario. Nuevamente, el SII puede estar de acuerdo con la explicación; o bien, el contribuyente puede reconocer que existe una diferencia, girar y pagar. Ante estas dos situaciones, se terminará el asunto.

Sin embargo, podría suceder que el SII no termine de convencerse. En este caso, procederá a una **(4) liquidación**, que consiste en una tasación de la base imponible en base a los antecedentes que aportó el contribuyente, y que serán los aportados por él a origen o a propósito de la citación.¹⁵ Ante esta situación, queda un recurso administrativo. El contribuyente podrá reconocer y pagar, o bien pagar después del recurso.

En este punto, termina la fase administrativa de fiscalización. Podría terminar además por lo que se denomina en doctrina determinación por actos coordinados (del contribuyente y del SII).

Si el contribuyente no está de acuerdo con la liquidación, puede oponer un **(5) reclamo** ante el TTA, para impugnar judicialmente la predeterminación que realizó el SII. El reclamo se terminará con una sentencia de primera instancia, que es susceptible de apelación. La sentencia de apelación es susceptible a su vez de casación en la forma y en el fondo. Desde el primer cobro, hasta la sentencia de CS, es un proceso que dura unos 6 años en promedio.

De forma paralela, el departamento de cobranza del SII despachará mandamiento de ejecución y embargo (cobranza judicial de la obligación tributaria). El contribuyente solo puede oponer como excepción el pago, prescripción y el no empecerle el título.

En materia tributaria, es muy difícil cambiar el criterio de la CS, porque hay un gran respeto por lo obrado por el TTA.

***Artículo 6°.-** Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.*

Dentro de las facultades que las leyes confieren al Servicio, corresponde:

¹⁵ Algunos estiman que es una re liquidación, sobre la que ya hizo el contribuyente.

B. A los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio:

5°. Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros de impuestos.

Sin embargo, el Director Regional no podrá resolver peticiones administrativas que contengan las mismas pretensiones planteadas previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional.

6°. Disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que incidan en materias de su competencia. Cuando dichas sentencias sean dictadas en procesos de reclamación, la facultad de disponer el cumplimiento administrativo de las mismas comprende la potestad de girar las costas que en ellas se decreten cuando resulte vencido el contribuyente.

Es muy importante tener presente el No. 5, pues se tendrá que decidir si trabar la litis, o proceder por la vía administrativa. En esto, es muy importante considerar los plazos de prescripción para los recursos judiciales (art. 200 y 201).

En la reforma, algunos defendían el sistema antiguo, pues era preferible que la materia fuera revisada por expertas. Sin embargo, se concluyó que lo óptimo era tener jueces especializados. Pereira estima que el argumento para no tener TTAs era meramente económico.

(3) INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA

La interpretación administrativa es aquella que emana del propio organismo fiscalizador. **Solo el Director Nacional** del SII tiene la facultad de interpretar administrativamente la ley tributaria. Luego, directores regionales, subdirectores, director de grandes contribuyentes, etc... no pueden interpretar la ley.

***Artículo 6°.-** Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.*

Dentro de las facultades que las leyes confieren al Servicio, corresponde:

A. Al Director de Impuestos Internos:

1°. Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos.

Podrá, asimismo, disponer la consulta pública de proyectos de circulares, o instrucciones que estime pertinente, con el fin de que los contribuyentes o cualquier persona natural o jurídica opine sobre su contenido y efectos, o formule propuestas sobre los mismos. Con todo, las circulares e instrucciones que tengan por objeto interpretar con carácter general normas tributarias, o aquellas que modifiquen criterios interpretativos previos, deberán siempre ser consultadas.

Las opiniones que se manifiesten con ocasión de las consultas a que se refiere este numeral serán de carácter público y deberán ser enviadas al Servicio a través de los medios que disponga en su oficina virtual, disponible a través de la web institucional. Las precitadas respuestas no serán vinculantes ni estará el Director obligado a pronunciarse respecto de ellas.

La ley contempla procedimientos consultivos, para escuchar al colegio de contadores, consultoras, expertos tributarios, entre otros, para que den su opinión sobre el borrador de circular u oficio que interprete administrativamente.

La interpretación se plasma en circulares, oficios, dictámenes y resoluciones exentas. Los **dictámenes** y **resoluciones exentas** son de naturaleza más procesal, de fiscalización. Por ejemplo, “a contar de 2019, la declaración se deberá hacer por formulario electrónico”. A su vez, los oficios y circulares son eminentemente interpretativos.

La **circular** es de naturaleza general, es decir, no da respuesta a una pregunta de un contribuyente en particular; luego, refiere a la forma en que debe aplicarse el contenido de una ley. Por eso generalmente las reformas tributarias vienen acompañada de una circular que interpreta cómo aplicará el Servicio la modificación. Podríamos decir que la circular es *erga omnes*.

El **oficio** en cambio es una respuesta a la consulta de un contribuyente en particular, que buscará la clarificación de una norma. En la práctica, el contribuyente va a la unidad respectiva: para que el director regional le pueda contestar, deberá seguir la interpretación del director nacional (normalmente, lo remite a una circular). El director regional también puede remitir la consulta a la oficina del director nacional, que será recibida por el jefe de gabinete, y que distribuirá la pregunta a la subdirección respectiva (e.g consulta sobre IVA - subdirección normativa, y el subdirector normativo la remitirá al jefe de impuestos indirectos). Esa respuesta será revisada por el Director Nacional, quien la podrá devolver o bien firmar. Luego, el Director Regional responderá a la consulta.

La importancia de la interpretación administrativa es que no procede el cobro de impuestos con efecto retroactivo cuando el contribuyente se ha ajustado de buena fe a una interpretación administrativa. Se entiende que el contribuyente está de buena fe cuando no ha existido un cambio de criterio por parte del SII. Se pierde la buena fe cuando ha habido un cambio, y éste cambio ha sido publicado conforme al art. 15 del CT.

Artículo 26.- *No procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada por la Dirección o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general o de uno o más de éstos en particular.*

El Servicio mantendrá a disposición de los interesados, en su sitio de Internet, las circulares o resoluciones destinadas a ser conocidas por los contribuyentes en general y los oficios de la Dirección que den respuesta a las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias. Esta publicación comprenderá, a lo menos, las circulares, resoluciones y oficios emitidos en los últimos tres años.

*En caso que las circulares, dictámenes y demás documentos mencionados en el inciso 1° sean modificados, se **presume de derecho** que el contribuyente ha conocido tales modificaciones desde que hayan sido publicadas de acuerdo con el artículo 15°.*

Artículo 15.- *Las notificaciones por avisos y las resoluciones o los avisos, relativos a actuaciones de carácter general que deban publicarse, se insertarán por una vez en el Diario Oficial, pudiendo disponer el Director, Subdirectores o Directores Regionales su publicación en extracto.*

Luego, si se determinó la renta líquida imponible descontando un ítem que el SII ha interpretado como gasto, y luego éste reclama ese gasto, no se podrá proceder a ese cobro. Pero, hay que recalcar que esto es para cobros retroactivos.

En relación a esta materia, son importante los artículos de 200 y 201, como normas sobre prescripción de la acción de fiscalización y la acción de cobro. La prescripción lo puede ser ordinaria, que dura 3 años desde que se debió haber pagado el impuesto (e.g se debía pagar al 30 de abril de 2019; se podrá citar hasta el 30 de abril de 2022). También lo puede ser extraordinaria, que dura 6 años desde que se debió haber pagado el impuesto. Será extraordinaria cuando la declaración no se presentó o cuando la presentación fue maliciosamente falsa.

La noción del art. 26 “no procede cobro con efecto retroactivo” es sumamente importante, y va de la mano de las normas de prescripción. La ley refiere a “*otros documentos oficiales*”, y algunos han entendido actos administrativos emanados del SII. Si una fiscalización cierra un punto en el cual se han acompañado documentos y el contribuyente ha solicitado al SII una resolución administrativa de que el SII cierre la fiscalización desde tal punto daría una suerte de derecho adquirido. De ese modo, estos documentos del SII, en juicio tributario podría servir para impedir el cobro de un impuesto con efecto retroactivo, basado en el art. 26 del CT.

La teoría anterior ha sido tanto aceptada como rechazada en tribunales.

No solo el art. 26 se debe ligar al art. 15 y los artículos de la prescripción, sino que también con la institución de la citación, entre otras razones porque la citación produce efectos en la prescripción. La citación debe ser específica respecto de los puntos sobre los cuales recae, y podría señalar que deja afuera todos los temas no mencionados en ella. La institución de la citación la encontramos en el art. 63 del CT.

Artículo 63.- El Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse.

El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario ampliará este plazo, por una sola vez, hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.

Cuando del tenor de la respuesta a la citación o de los antecedentes aportados resulte necesario solicitar al contribuyente que aclare o complemente su respuesta y, o presente antecedentes adicionales respecto de los impuestos, períodos y partidas citadas, podrá requerírsele para que así lo haga, dentro del plazo de un mes, sin que ello constituya una nueva citación. Los antecedentes requeridos en el ejercicio de esta facultad y que no fueren acompañados dentro del plazo indicado serán inadmisibles como prueba en el juicio, en los términos regulados en el inciso duodécimo del artículo 132 de este mismo Código.

La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 4° del artículo 200 respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella.

CONTIENDAS DE COMPETENCIA EN LA INTERPRETACIÓN

El SII solo interpreta la norma tributaria fiscal interna: pero no interpreta las normas de impuestos municipales, que lo hace la CGR. Las contiendas de competencia que se generen las resolverá la CS.

Artículo 7°.- Si en el ejercicio de las facultades exclusivas de interpretación y aplicación de las leyes tributarias que tiene el Director, se originaren contiendas de competencia con otras autoridades, ellas serán resueltas por la Corte Suprema.

Igual norma se aplicará respecto de las funciones que en virtud de este Código y del Estatuto Orgánico del Servicio deben o pueden ser ejercidas por los Directores Regionales o por los funcionarios que actúen "por orden del Director" o "por orden del Director Regional", en su caso.

APLICACIÓN DE LA LEY

1. APLICACIÓN ESPACIAL - TERRITORIAL DE LA LEY

No tenemos una norma general en el CT sobre aplicación territorial. Cada cuerpo legal (ley renta, ley IVA, ley timbre y estampilla, etc...) se ha encargado de indicar su aplicación territorial.

Podríamos decir que *en general*, la ley tributaria grava a las personas domiciliadas o residentes en Chile. Después tendremos que ver cuáles rentas se ven alcanzadas por este principio general.

Un ejemplo,

John Smith, australiano, viene contratado por Minera Escondida, y se viene a vivir por tres años a Chile con su señora Deborah y sus dos hijos (John jr. y Meredith). Smith arrendó una casa, y matriculó a sus hijos en el colegio.

Al no domiciliado o residente (que lleva menos de 6 meses), se le cobra el impuesto adicional sobre sus rentas. John Smith podría decir que por sus rentas de los primeros 6 meses, solo pagará impuesto adicional del 20%, sin deducción. Sobre esos 6 meses, y dado su contrato de trabajo, tendría que pagar el impuesto a la renta de segunda categoría por las rentas de su trabajo.

Ahora bien, el concepto de domicilio es diferente del concepto de residente. El CT no lo define, pero podemos acudir supletoriamente a la definición del CC. Si fuera ese el caso, de ser domiciliado tiene que pagar el impuesto de segunda categoría.

El SII da libertad para elegir al “régimen” que uno se acopla, por esos primeros 6 meses.

En el caso de la ley de la renta, se podría decir que lo paga toda persona domiciliada o residente en Chile, independiente del origen de la renta. Por ejemplo, es indiferente que la renta venga de acciones de IBM Corporation, o de L’Oreál Paris. Es decir, la fuente puede ser chilena o mundial (chilean source income y worldwide income). La ley se rige entonces por el principio de ubicuidad de la persona (su ubicación), y sería una regla territorial; pero en cuanto al origen de las rentas, sería una regla extraterritorial.

La ley de la renta perfectamente podría disponer a su vez que también se gravarán las rentas generadas por personas y actividades o bienes situados en Chile, aunque dichas rentas las obtengan personas domiciliadas en el extranjero. Caterpillar INC, Illinois, es accionista de Caterpillar Chile: su dividendo es fruto civil de un bien situado en Chile, cual es las acciones en la sociedad anónima (en virtud de los artículos 10 y 11 de la Ley Renta). En este caso, habría un principio de territorialidad en cuanto a la actividad o bien; pero respecto de la persona, habría un principio de extraterritorialidad.

Ahora bien, en estos casos en que hay extraterritorialidad respecto del contribuyente, será un impuesto de retención.

El problema de la doble tributación internacional (DTI)

Veremos la problemática desde el punto de la vista de un ejemplo asociado a la renta.

Toda persona domiciliada o residente en Chile paga impuesto por su renta tanto de fuente chilena como mundial. Resulta que en EE.UU, existe una norma similar que establece que todo residente o domiciliado en EE.UU pagará impuesto por sus rentas, independiente del origen.

Apple Inc. invierte en Chile, y obtiene una utilidad de \$1000 en Chile. Hay un impuesto que tiene una tasa de 50%, por lo que recibe \$500 en EE.UU. A su vez, en EE.UU, el IRS determinará que la utilidad fue de \$1000, y la tasa aplicable en EE.UU también es del 50%. Pero Apple tiene una caja de solo 500, por lo que su utilidad final será de \$0.

De este ejemplo podemos desprender ciertas consideraciones importantes:

- No hay que confundir utilidad con caja. No se tiene menos utilidad por haber pagado impuesto en Chile.
- Cuando dos leyes de impuesto a la renta tienen una disposición equivalente, se produce el problema de la doble tributación internacional, lo que atenta contra la inversión extranjera (operaciones cross borders; cross border transactions).

La inversión extranjera que recibe Chile se denomina **inbound**. A su vez, la inversión chilena en el extranjero se denomina **outbound**.

¿Cómo solucionamos la DTI? Existen varios mecanismos, pero podemos señalar dos vías.

1. Tratados internacionales

En estos convenios, ambos estados o uno de ellos hará concesiones o renunciaciones; por tanto, atenuarán el principio de domicilio/residencia y principio de la fuente. Por ejemplo, “la renta se gravará solo en la jurisdicción donde se encuentre la fuente” o “solo en el país del domicilio o residencia del contribuyente”. Al Estado que renuncia a cobrar el impuesto le puede interesar esta medida porque atraerá inversión extranjera al país, que generará trabajo y consumo. Estos tratados pueden serlo **bilaterales** o **multilaterales**. Cabe remarcar que las renunciaciones no suelen ser absolutas, sino que siempre con matices.

Celebrar un tratado no es necesariamente una tarea fácil, sobretodo considerando el grado de desarrollo de cada país. Entre países desarrollados, existirá probablemente un nivel de inversión recíproco; mientras que respecto de países en vías de desarrollo, su capacidad de exportar capital será menor y faltará esa reciprocidad.

Los modelos multilaterales no son la regla general, y apuntan más a los sistemas de intercambio de información entre los países, por sobre normas de solución de la DTI, sin perjuicio que hay tratados específicos a la DTI. Chile adhirió al Convenio Multilateral de Intercambio de Información Tributaria, al cual también está suscrito EE.UU. Por tanto, no obstante tener un tratado bilateral con EE.UU, via el convenio multilateral podríamos tener información sobre un residente o domiciliado en EE.UU con renta de origen chileno.

Los convenios sobre DTI **son ley** en Chile; pero la norma del tratado prevalece sobre la norma común cuando hay un conflicto entre los estados contratantes, por el principio de **especialidad**.

Los tratados bilaterales obedecen básicamente a dos modelos. El primero, una combinación del modelo OCDE (principalmente), ONU (algunos puntos) y Chileno (que ha agregado la “cláusula Chile”, en los tratados suscritos por nuestro país)¹⁶, grava de acuerdo al principio de domicilio o residencia. El segundo, que sigue el modelo de Pacto Andino (que hoy en Chile está derogado, y que regía la relación con Argentina), se regía por el principio de la fuente.

En los diversos aspectos que cubre el tratado, hay materias tales como beneficios empresariales, regalías, ganancias de capital, rentas por trabajos dependientes o independientes, rentas por asesorías técnicas, etc... Los estados contratantes negocian y reducen las tasas de impuesto fundamentalmente de retención, que son los últimos impuestos antes de la frontera, para reducirlas e incentivar la inversión.

¿Y qué pasa con la distribución de utilidades? Podemos analizarlo según el modelo en cuestión.

A. *Modelo OCDE - ONU - Chile*

Abertis España tiene una empresa Abertis Chile, que tiene a su vez Abertis Estacionamientos. Las utilidades de Abertis Estacionamientos tributan por un 27% de IDPC, que lo anotará en sus registros. Este registro es importante para el contribuyente final, que en este caso es Abertis España, pues es la última persona a la que Chile le puede cobrar un impuesto. Abertis Estacionamiento reparte dividendos a Abertis Chile, que no paga IDPC, porque sino la misma renta pagaría dos veces impuestos. Por tanto, se sigue teniendo en caja \$73 y un crédito de \$27 (asumiendo que la renta es 100).¹⁷ Cuando Abertis Chile reparte dividendos, esa renta está afectada al impuesto adicional de 35% (withholding tax). Pero como en Chile tenemos un **sistema integrado**, podrá oponer como crédito el 27% de IDPC, por lo que paga un 8%. El cheque final entonces es por el 8% de 100, es decir \$8.

¹⁶ La cláusula chilena no siempre está incorporada en el articulado del tratado, sino que muchas veces la encontramos “camuflada” en los protocolos anexos al tratado.

¹⁷ Recordar que esto se traduce en una utilidad de 100, porque la empresa no pagó ese 27%, y adquiere este crédito “gratuitamente”.

La integración consiste en que se puede imputar el impuesto efectivamente pagado como crédito. Hoy se discute reimplementar el sistema integrado en Chile, pero sucede que en Chile nunca se ha eliminado. Esto lo vemos bajo la siguiente lógica: si la utilidad original fue de \$100, está afecta a un 27% de IDPC, y queda en \$73. Como mecánica adecuada para aplicar los impuestos, la ley obliga a hacer un gross-up (embrutecer), es decir, agregar el monto que se pagó en impuesto. Como en Chile se puede imputar al impuesto la cantidad ya efectivamente pagada, **sí tenemos un sistema integrado**, y la discusión política actual de “restablecer la integración” es errónea.

¿Por qué en Chile se debate hoy sobre la integración? Se genera por la reforma 2014, que introdujo el siguiente régimen. Se puede estar, por opción u obligación, suscrito a un **sistema de renta atribuida del art. 14 A Ley Renta**, o a un **sistema de retiro del art. 14 B Ley Renta**.

Cuando se está en un **sistema de renta atribuida**, por disposición de la ley se considera que la renta generada *en un mismo ejercicio* ha sido retirada por el contribuyente final, aunque no lo haya hecho. Luego, al momento de tributar, debemos seguir el ejercicio anterior: ese dividendo que retire el contribuyente final (en nuestro ejemplo, Abertis España) estará afecto al IA del 35%,¹⁸ con crédito por $27\% = 8\%$.¹⁹

Cuando se está en un **sistema de renta diferida**, el contribuyente final podría no retirar utilidades en el mismo ejercicio. Cuando decida retirar utilidades, se le aplicará un **nuevo débito fiscal** (impuesto) de tasa 35%, donde la base imponible es igual al IDPC acreditado. Este impuesto fue lo que agregó la reforma tributaria. Así, el 27% pagado tributará un 35% (\$9.45). Luego, la carga tributaria será de $\$27 \text{ (IDPC)} + \$8 \text{ (IA [35\% - 27\%])} + \$9.45 \text{ (35\% x \$27)} = \44.45 , o 44.45% en nuestro ejemplo (pues todo está en una función de utilidad \$100).

Esta explicación de los sistemas del art. 14 en relación a la tributación lo vimos para llegar al modelo OCDE - ONU - cláusula Chile, que toma el principio de domicilio o residencia. Volviendo al ejemplo de Abertis, en principio solo España podría gravar las rentas (principio del domicilio o residencia).

Sin embargo, por negociación del tratado, se llegó a establecer una cláusula (la **cláusula Chile**) que dice “Chile tendrá derecho a gravar con impuesto adicional de retención, la distribución de utilidades con una tasa del 35% si y solo si (en la medida que) en contra de este impuesto adicional de retención se pueda utilizar como un crédito, el impuesto de primera categoría”.

¹⁸ Podría ser un IGC, según el caso. El sistema integrado permite oponer el crédito.

¹⁹ Como es un impuesto de retención, Abertis Chile retendrá el 35% de IA, descontará el crédito y enterará el monto en arcas fiscales. No confundir la traslación del impacto económico con la retención, pues en este caso (retención) Abertis España sigue siendo tanto sujeto pasivo de la obligación como a su vez quien carga con el impacto.

Si es que Abertis Chile está en el régimen de retiro del 14 B, no se le podría aplicar el impuesto adicional que vimos en nuestro ejemplo (al menos con la tasa del 35%), toda vez que por la reforma 2014, no puede imputar el 100% de su crédito por IDPC, sino que solo el 65%. La conclusión sería que a aquellos sujetos suscritos al sistema 14 B, Chile no podría imponer un impuesto adicional de retención con tasa de 35%, sino que tendrá que aplicar otra tasa que disponga el tratado, pues la empresa no puede imputar el 100% de su crédito por IDPC al 35% de IA. La cláusula Chile queda entonces sin efecto para estos casos.

El problema fue que la situación anterior no fue tomada en cuenta en la discusión de la primera reforma tributaria. La respuesta, poco maquiñeada, fue que este nuevo débito fiscal del 35% sobre el crédito de primera categoría no se aplicará para empresas domiciliadas o residentes en países con los que Chile ha suscrito, o esté negociando,²⁰ un tratado de doble tributación.

B. Modelo Pacto Andino

Chile tuvo un solo tratado basado en el principio de la fuente, por el modelo de Pacto Andino. Así, solo el país en cuya jurisdicción se generaron las rentas tendría derecho a gravarlas con impuesto. Lo veremos como un ejemplo.

Enel Italia es accionista de Enel España, que es accionista de Enel Chile Holdings. La última es accionista de Enel SA y ésta tiene dos subsidiarias, una en Argentina y la otra en Chile: Costanera SA (de Argentina) e Ingendesa SA (Chile). El señor Uldario es accionista de Enel Chile Holdings. Cristina Fernandez, la China Suárez y Benjamín Vicuña son accionistas de Costanera.

Asumamos que tenemos el antiguo tratado de 1978 con Argentina (derogado en junio de 2012), basado en el modelo de Pacto Andino. Resulta que Argentina no tiene un sistema integrado: a las utilidades de Costanera le aplica un solo impuesto de 35% (“impuesto a las ganancias”), independiente de si retiren o no los accionistas. Cuando Costanera distribuya dividendos a Enel SA (Chile), esa renta no paga ningún impuesto a la renta en Chile, por el principio de la fuente. Ese dividendo se anotaba en el registro FUNT (fondo de utilidades no tributables), que hoy se llama REX. En estos registros se anotan (1) ingresos no constitutivos de renta por ley, y (2) rentas exentas de impuestos por ley. En este caso, el dividendo es renta exenta por ley (el tratado tiene categoría de ley).

Cuando Ingendesa reparta utilidades a Enel, pagará IDPC, y esa renta se registrará por Enel en el registro FUT (hoy RAI). Si Enel recibe intereses de depósitos en el Banco, esas rentas son rentas propias, y pagará impuesto a la renta.

²⁰ La reforma del 2014 tuvo una segunda ley en febrero. Esto fue porque EE.UU reclamó, toda vez que no había un tratado de doble tributación con ellos, y sus empresas no iban a pagar un 44,45%. Se agregó a la reforma entonces que estarán exentos los países con los que Chile esté negociando un convenio de doble tributación, y éste se aprueba antes del 2025.

Enel Chile Holdings recibirá dividendos, parte de los cuales ya pagaron IDPC, y otra parte será renta REX. ¿Qué pasará cuando Enel Chile reparta utilidades a Uldarío (chileno, contribuyente de global complementario) y Enel España? La ley nos dice que lo primero que se imputarán son las unidades tributables (impuesto pendiente).

Es decir, para el caso de Uldarío, primero se sacarán las rentas que vienen de Ingendesa, que pagarán IGC, con crédito (en la medida que se haya pagado el IDPC, que hoy se mira en base al Saldo Acumulado de Créditos SAC). Por la parte del REX que se retire no se pagará global complementario, porque el tratado lo impide.

Respecto a Enel España, pagará impuesto adicional en la parte de renta y en la parte de REX no.

2. *Normas unilaterales*

Será la propia legislación interna la que dispone de mecanismos unilaterales, independientes de la ley extranjera, para resolver la DTI, porque para ese país es ventajoso evitarla. Por ejemplo, porque la inversión extranjera de LATAM, CMPC, etc... reportará para Chile una utilidad mayor que si invirtiera en Chile (por un tema de ventajas comparativas).

Ya sea que haya tratado entre las jurisdicciones correspondientes, o no habiendo tratado, podrían aplicarse normas unilaterales. Esto toda vez que gran parte de los tratados remiten a las normas unilaterales: de ahí la importancia de las normas unilaterales.

Hay distintos tipos de normas unilaterales.

2.1 *Tax Expense o impuesto gasto*

El impuesto soportado por las utilidades en el país de la fuente puede ser considerado como un **gasto necesario** para producir la renta imponible.

Está **aminorando** el efecto de la DTI por vía de una **reducción de la base imponible** sobre la cual aplica el impuesto a la renta. El efecto del tax expense es que disminuye la BI, pero no el impuesto a aplicar.

Por ejemplo. Tenemos una utilidad de \$1000, con impuesto de 50%, lo que deja en caja 500. En EE.UU, se tiene la utilidad de \$1000, un gasto de \$500 = impuesto soportado en Chile, y una nueva base imponible de \$500. A esa nueva BI, se le aplica el impuesto a la renta norteamericano de 50%, que da un total de \$250. Si volvemos a nuestro ejemplo original de Apple, pasamos de que ganara \$0 por DTI a \$250.

El concepto de gasto necesario en Chile está tratado a propósito del IDPC.

Esta solución la adopta el derecho interno de un país. Luego, surge la pregunta ¿qué pasa en Chile? Hace pocos años (10-15), Chile tenía un solo tratado de DTI, con Argentina, y no tenía normas sobre DTI. Para solucionar el problema de la DTI, se utilizaba la norma del art. 12 Ley Renta.

ARTICULO 12°.- *Cuando deban computarse rentas de fuente extranjera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 G, se considerarán las rentas líquidas percibidas, excluyéndose aquellas de que no se pueda disponer en razón de caso fortuito o fuerza mayor o de disposiciones legales o reglamentarias del país de origen. La exclusión de tales rentas se mantendrá mientras subsistan las causales que hubieren impedido poder disponer de ellas y, entretanto, no empezará a correr plazo alguno de prescripción en contra del Fisco. En el caso de las agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las rentas percibidas como las devengadas, incluyendo los impuestos a la renta adeudados o pagados en el extranjero.*

Cuando el contribuyente chileno deba considerar rentas de fuentes extranjeras, según la definición del art. 10 y 59 No.2, se considerarán las **rentas líquidas y percibidas**. La expresión líquidas apunta al “qué”, mientras que la expresión percibidas apunta al “cuándo”. La expresión líquidas refiere a rentas una vez cumplidas la obligación tributaria extranjera. La ley establece ejemplos que se consideran como rentas líquidas, tales como aquellas de las que no se pudo disponer por caso fortuito, fuerza mayor o disposiciones legales o reglamentarias. Justamente, las leyes tributarias son una disposición legal que impide que un contribuyente disponga de una parte de su renta., de modo que se puede excluir esa parte como gasto necesario para determinar la base imponible. En nuestro ejemplo de Apple, serían renta líquida solo \$500, por el artículo 12. Cabe hacer la precisión que esto solo aplica cuando estemos hablando de rentas de fuente extranjera.

¿Cuál es la regla general para incluir en mi base imponible una renta de fuente extranjera? ¿Cuándo debo incluir la renta de fuente extranjera en la determinación de mi renta líquida imponible chilena, como un ingreso bruto? Esto refiere a la segunda parte del art. 12, que no tiene relación con el *tax expense* (pero Pereira lo pasa igual).

Tendrá que ser cuando se **percibe** la renta extranjera. El art. 2 No. 3 Ley Renta define qué es una renta percibida, a saber: *por "renta percibida", aquélla que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago.*

Si esta renta solo se ha devengado, esto es, existe un título o derecho para el contribuyente independientemente de su actual exigibilidad (art. 2 N° 2 LIR), no se debe colacionar, verificándose solamente un diferimiento o postergación de la tributación de esa renta en el país del contribuyente. Si es que la renta no se ha percibido, por regla general no ingresa en la determinación de la renta líquida imponible del contribuyente chileno.

Existen excepciones a la regla de la percepción en las rentas extranjeras. En primer lugar, tenemos las **entidades controladas extranjeras** del art. 41 G Ley Renta, por ejemplo aquellas en que se tiene un 50% o más de la propiedad. En este caso, debe haber (1) control, (2) devengamiento o percepción de rentas pasivas. Cumplidos estos requisitos, cambia el principio, de “percibidas” a “devengadas” (definidas por el art. 2 No. 2). De modo tal que, si hay una renta pasiva (e.g interés) devengada por una sociedad extranjera controlada por una chilena, la chilena debe reconocer esa utilidad sobre una base devengada, sin tener que esperar a que esté percibida (por lo que la renta está fuera de Chile), y así colacionarla para determinar su base imponible.

Una segunda excepción se da cuando el contribuyente chileno tiene una **agencia** u otra clase de **establecimiento permanente**. Civilmente, la agencia es un mandatario de la casa matriz. Por tanto, si Entel tiene una agencia en Perú, todo lo que le pasa a esa agencia se reconoce en el mismo acto en la casa matriz, sin separación patrimonial. La agencia es el gran ejemplo de establecimiento permanente, que se pueden definir como un lugar fijo de negocios. Aquí, también se tributa por el principio de renta devengada.

En definitiva, el art. 12 reconoce al tax expense como una vía para animorar el efecto de la DTI.

Hace muchos años atrás, el SII realizó liquidaciones basados en el art. 31 Ley Renta. Este artículo refiere a una de las bases de la determinación de la base imponible, que se refiere a los **gastos necesarios** deducibles. El art. 31 consta de dos partes fundamentales. En primer lugar, el inciso primero que establece los requisitos necesarios. En segundo lugar, en el número 2, establece que son deducibles los impuestos dispuestos por la ley chilena.

En base a este artículo y su tenor literal, se puede entender que los impuestos extranjeros no son deducibles. Tenemos así una contradicción entre el art. 12 y el art. 31 No.2, pero que eventualmente fue resuelta por la CS, por el principio de la especialidad. El art. 12 se refiere expresamente a las rentas de fuente extranjera, por lo que prima por sobre el art. 31 No.2.

2.2 Tax credit

El impuesto soportado en el otro Estado no disminuye la base imponible, sino que se puede usar como un crédito en contra del segundo impuesto ya determinado. En nuestro ejemplo de Apple, el impuesto de \$500 se puede acreditar para compensar el impuesto de \$500 a pagar en EE.UU. Por lo tanto, su utilidad final será de \$500.

A diferencia del tax deduction, el tax credit no disminuye la base imponible, sino que disminuye el impuesto a pagar ya determinado (*tax due*). Entonces, ¿es lo mismo que sea un crédito o que sea un gasto? No, un gasto se usa en la determinación de la base imponible, por lo que el efecto es menor que el del crédito, ya que este se usa en contra del impuesto a enterar en arcas fiscales.

¿Qué pasa si el impuesto del país del primer impuesto es mayor al país de la residencia del contribuyente? Normalmente, el tax credit tiene como límite el impuesto del país de residencia.

En general, siempre convendrá más el tax credit en vez del tax deduction.

Pereira clasifica este sistema en tax credit directo, indirecto, “super indirecto”, y “plus”.

2.2.1 TC Directo

Asumamos que en Perú existe un business profit tax de tasa 30%, y en la remesa de dividendos hay un withholding tax de 4% cuando se trata de dividendo cross border. Ese 4% afecta la remesa de la utilidad de un Estado a otro, y no a la generación de dicha utilidad.²¹ Entel Perú distribuye un dividendo a Entel Chile. El tax credit apunta a la posibilidad que da la ley interna de utilizar como crédito aquel impuesto de retención que grava la remesa, o distribución de la utilidad (cuando es retirada por un no domiciliado o residente del país de la fuente).

Entel Chile está afecto al IDPC. Tiene como accionista a Rentas e Inversiones Ruleta, que a su vez tiene como accionistas a Jose Pedro y Francisca. ReI Ruletas está exenta del IDPC en las rentas que provienen de Entel, y Jose Pedro y Francisca pagan global complementario. El tax credit solo alcanza al impuesto de retención de la remesa de renta de fuente extranjera, por lo que Entel Chile solo podrá usar el 4% pagado en Perú (no el 30%).

El impuesto a la remesa es casi siempre un impuesto de retención, para asegurarse el Estado el pago del mismo (pues actúa el agente retenedor domiciliado en el mismo Estado). En algunos países es un impuesto de declaración, sin perjuicio de una retención provisoria para asegurar su pago (viene a ser lo mismo). Esa retención la va a imputar el contribuyente como un crédito, es decir, haría las veces de un PPM (pago provisional mensual).

Sin perjuicio de la existencia de un sistema integrado en el país de la fuente, para efectos del impuesto en el país de domicilio o residencia, solo importa ver cuál es la tasa del impuesto de retención. Así, para EE.UU lo relevante es ver que a Scarlet Johansson le cobran un IA de 35% por sus acciones en Copec Chile, independiente de su crédito por 27% por IDPC.

2.2.2 TC Indirecto

Permite no solo la utilización como crédito el impuesto de retención a la remesa, sino también el impuesto a la renta que grava la generación de la renta en el otro estado. Así, Entel Chile puede acudir no solo al 4% de impuesto a la remesa, sino también al 30% de impuesto a la ganancia. Ahora,

²¹ Si ese 4% se cobra respecto de la (Renta - 30%) o de la Renta embrutecida (Renta al 100%) dependerá de la legislación interna, sobre normas de determinación de la base imponible.

Entel se “comerá” el 27% del crédito, y el remanente (7%)²² podrá pasar por la cadena de propiedad para imputarse contra los impuestos finales en la medida que se distribuyan utilidades hacia los accionistas.

Recordar que el tax credit tiene un límite, que es solo se puede imputar contra rentas de origen externo, y el impuesto que sobre esas rentas se cobre.

2.2.3 TC “*Super Indirecto*”

Siguiendo con nuestro ejemplo de Entel, Entel Perú es accionista de Chabucadirect. Puede suceder que en algunas legislaciones, el 30% se aplique en Chabucadirect, de modo que Entel Perú está exento para evitar doble tributación, y se aplica el 4% a la remesa. Entel Perú, al igual que Rentas e Inversiones Ruleta, es un holding, es decir, solo tiene acciones de diversas sociedades, pero no es verdaderamente una empresa que produzca originariamente renta. Luego, el tax credit super indirecto permite pasar a través del holding y llegar a la fuente originaria de la renta (piercing the veil). En algunos casos, el impuesto super indirecto puede cubrir más de un nivel, lo que dependerá de la normativa particular. En algunas jurisdicciones, no se permite atravesar más de 2 niveles, mientras que otras permiten atravesar cuantas sean necesarias.

¿De qué serviría entonces tener una estructura con holdings y diferentes niveles? Mariano es accionista de Copec y Teresa de CMPC, donde las personas naturales pagan GC por la distribución de dividendos, y las personas jurídicas IDPC por su renta. Si ellos forman una sociedad, en la cual aportan sus acciones de Copec y CMPC (para nuestro ejemplo valen lo mismo), esa sociedad no pagará IDPC cuando se distribuyan utilidades. Mariano y Teresa estarán postergando el pago del GC. Esto porque en vez de retirar inmediatamente el 100%, pueden sacar una menor cantidad, y pagar GC sobre esto, que probablemente no será de 35% (o incluso si es 35%, se calcula sobre una menor base imponible), además de incluso usar el 27% como crédito (pues es un sistema integrado). Esto mismo pasa con quien tenga que pagar IA: para los impuestos finales (IA y GC), sin esta estructura no sería posible diferir, postergar el pago.

Sería útil para una persona atravesar el corporate veil, porque puede que en el primer nivel, la empresa en cuestión haya estado exenta de IDPC, y no habrá crédito para oponer (ya que no se trata de un sistema integrado a nivel internacional, esto es, fuera de Chile), por lo que se tiene que ir a buscar la fuente originaria de la renta.

2.2.4 TC “*Super Indirecto Plus*”

Entel Chile es accionista de Entel BVI, que es accionista de Entel España. En Entel España, se paga un impuesto de 35%, mientras que en Entel BVI no hay impuestos (paraíso fiscal). Entre el Estado generador de la renta, y Chile, exista a lo menos un tratado de intercambio de información, para verificar que esa renta se gravó con un impuesto equivalente al impuesto a la renta en Chile.

²² Para este ejemplo estamos asumiendo que la carga total era de 34%, pero eso dependerá de la legislación propia de cada país, según si contamos impuesto a la remesa sobre (Renta - impuesto a la renta) o sobre Renta total.

El “plus” se refiere a la posibilidad no solo de poder subir de nivel, como en el super indirecto, sino que de acceder a otra jurisdicción.

Podemos ver una evolución en las legislaciones: de gravar a la remesa, al impuesto a la renta, a la fuente originaria de la renta, llegando hasta la jurisdicción donde se gravó esa renta. Las legislaciones van imponiendo una serie de límites, asociados a la información y prueba de esos pagos e impuestos.

2.2.5 Situación en Chile

La Ley Renta, en los artículos 41 A y ss. ha regulado esta situación. En particular, es relevante el art. 41 AA No.1, 3 y 4, como también el art. 41 D y art. 41 E.

***Artículo 41 A.-** Los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile que obtengan rentas que hayan sido gravadas en el extranjero, en la aplicación de los impuestos de esta ley se regirán, respecto de dichas rentas, además, por las normas de este artículo, en los casos que se indican a continuación:*

Lo primero que se concluye de este artículo, es que el beneficiado del crédito es un residente o domiciliado en Chile que **percibe rentas gravadas en el extranjero**.

A.- Dividendos y retiros de utilidades.

Los contribuyentes que perciban dividendos o efectúen retiros de utilidades de sociedades constituidas en el extranjero deberán considerar las siguientes normas para los efectos de aplicar a dichas rentas los impuestos de esta ley:

En segundo lugar, se refiere a dividendos y retiro de utilidades que se perciben. Básicamente refiere a la distinción entre sociedades de personas (retirar) y de capital (percibir).

1.- Crédito total disponible.

*Dará derecho a crédito el impuesto a la renta que hayan debido pagar o que se les haya retenido en el extranjero por los **dividendos** percibidos o los **retiros** de utilidades efectuados de las sociedades, en su equivalente en pesos y reajustado de la forma indicada en el número 1 de la letra D siguiente, según corresponda.*

Este inciso se refiere a un tax credit **directo**, pues se da crédito por los impuestos que hayan debido pagar o se hayan retenido los dividendos o retiros de utilidades. Es decir, se trata de impuestos a la remesa, cuando se está extrayendo esa utilidad hacia Chile.

Podrá deducirse como crédito el impuesto pagado por la renta de la sociedad en el exterior. Este impuesto se considerará proporcionalmente en relación a los dividendos o retiros de utilidades

percibidas en Chile, para lo cual se reconstituirá la base bruta de la renta que proporcionalmente corresponda a tales dividendos o utilidades a nivel de la empresa desde la que se pagan, agregando el impuesto de retención y el impuesto a la renta de la empresa respectiva.

Sobre el crédito directo anterior, **podrá** deducirse como crédito el impuesto que pagó la sociedad exterior (la que realizó la distribución) por su renta. Es decir, estamos hablando de un tax credit **indirecto**.

También dará derecho a crédito el impuesto a la renta pagado por una o más sociedades en la parte de las utilidades que repartan a la empresa que remesa dichas utilidades a Chile, siempre que todas estén domiciliadas en el mismo país y la referida empresa posea directa o indirectamente el 10% o más del capital de las sociedades subsidiarias señaladas.

Se agrega como crédito el impuesto a la renta pagado por una o más sociedades (hasta el 2016, era hasta un máximo de dos sociedades), que repartan a la empresa que remesa hacia Chile. Por ejemplo, Chabucadirect que reparte a Entel Perú, que remesa a Chile.

Ahora bien, la ley establece limitaciones:

- Todas las sociedades deben estar domiciliadas en el mismo país.
- La referida empresa (que distribuye hacia Chile), posea directa o indirectamente el 10% o más de las sociedades subsidiarias. Es decir, por la cadena de propiedad hacia arriba, la empresa que hace la remesa va a tener que poseer indirectamente el 10% de ellas.

Estamos hablando entonces de un tax credit super indirecto.

(Continúa inciso anterior) También se aplicará dicho crédito, cuando las sociedades subsidiarias referidas estén domiciliadas en un tercer país con el cual se encuentre vigente un convenio para evitar la doble tributación internacional u otro que permita el intercambio de información para fines tributarios, en el cual se hayan aplicado los impuestos acreditables en Chile.

Aquí ya encontramos finalmente el tax credit super indirecto plus. **Pregunta pendiente:** ¿se aplica el requisito del 10% de propiedad directa o indirecta en el supuesto del *tax credit* plus? Uno podría pensar inicialmente que si se aplica el super-indirecto, entonces también debería aplicarse al plus. Sin embargo, pareciera darse tanta importancia al tratado internacional que se podría incluso abandonar el requisito del 10%. Esto ya ha sido objeto de algunos oficios del SII (buscar oficios y la historia de la ley).

2.2.6 Impuestos contra los que se puede impetrar el tax credit

¿En contra de qué impuestos contenidos en la Ley Renta se puede impetrar este tax credit? Este fenómeno lo podemos explicar con el **art. 41 AA No. 3**, que dice claramente que se trata de un crédito contra el impuesto de primera categoría. Por tanto, inmediatamente sé que el impuesto pagado

en el exterior lo puedo usar como crédito contra el impuesto que grava las rentas descritas en el art. 20 Ley Renta.

Debemos recordar que un empresario individual (distinto de una EIRL) puede impetrar el tax credit contra su IDPC. Este empresario determina renta efectiva según balance para efectos del IDPC. El empresario individual, persona natural, es una **ficción tributaria**: no hay separación patrimonial entre la persona natural y su empresa individual (y su contabilidad y balance asociado). Lo que lo hace ser un empresario es el hecho de que inicie actividades y asigne a una contabilidad determinados activos y pasivos (una declaración jurada). Respecto de ese patrimonio, él tributa como una sociedad fiscal.

Volviendo al art. 41 AA No.3., este además nos da normas para determinar ese crédito. Debemos tener en cuenta que estos créditos siempre se usan para mitigar el efecto de la doble tributación sobre el concepto de renta neta de fuente extranjera. Cabe precisar entonces, que no sirve para rentas de fuente chilena, que por lo demás no sería renta neta porque no se le han descontado los impuestos, sería renta bruta (bruto es una cantidad a la que no se le han deducido los impuestos, a contrario de neto).

En resumen, el primer paso para la utilización del tax credit es que se impetra contra IDPC. El segundo paso, está en que el tax credit remanente se puede imputar contra los impuestos finales: GC (contra personas naturales con domicilio o residencia tributaria en Chile) ²³ IA (contra personas naturales o jurídicas sin domicilio o residencia en Chile).

Esta conclusión se extrae del propio **art. 41 AA No. 4**, que dice “*Crédito contra los impuestos finales. La cantidad que resulte después de restar al crédito total disponible, el crédito de primera categoría determinado conforme a lo establecido en el número precedente (es decir, el crédito contra el IDPC), constituirá el saldo de crédito contra los impuestos finales , que podrá imputarse en contra de los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, en la forma que establecen los artículos 56 número 3) (GC) y 63 (IA), considerando las siguientes normas:...*” .

Luego, el art. 41 AA No.4 establece normas para aplicar el saldo de crédito contra los impuestos finales. ¿Por qué podría utilizarlo? Porque los impuestos finales tienen eventualmente una carga superior al 27% de IDPC: dependiendo del sistema al que esté adscrito, puedo tener una carga de 27 o 35%. ¿Qué pasa si estoy en una tasa efectiva de GC o IA superior? Voy a utilizar ese saldo de tax credit.

Imaginemos que hay una sociedad, Rentas Reco Limitada SpA, del que Antonia es dueña del 100% de las acciones. Ese capital que aportó se usó para comprar acciones de una tienda italiana La Sportiva. Se distribuyen dividendos de La Sportiva a Rentas Reco, y luego a Antonia. Ese saldo de tax credit, contra esa renta de fuente extranjera que llega a la Antonia y paga GC, podrá ser utilizado.

²³ Es importante destacar el “o”, pues o se está domiciliado o residente en Chile, o no.

Teníamos en Chile el problema de un loophole en la Ley Renta, que se corrigió el 2012. Consistía en lo siguiente: Chile devolvía vía PPUA impuestos pagados en el extranjero, es decir, impuestos que nunca entraron a arcas fiscales chilenas. Lo veremos con el siguiente ejemplo:

Antonia y Gianluca, chilenos, son dueños de Inversiones Liguria Limitada, que es accionista de Antonia Internacional SpA,²⁴ todas empresas chilenas. A su vez, Antonia Internacional es accionista de La Rinascence, empresa italiana.

La Rinascence paga 35% de impuesto corporativo en Italia, y envía dividendo a Antonia Internacional, que pagará su IDPC con un tax credit, y luego repartirá a su vez a Liguria.

El dividendo que recibe Liguria está exento de IDPC, por doble tributación. Pero imaginemos que tiene una pérdida tributaria. En principio, podría dar lugar a un PPUA. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Si Chile da ese PPUA, esa devolución, estaría devolviendo un impuesto que se pagó en favor de otro estado (Italia). La corrección que se hizo fue establecer que la devolución vía PPUA solo procede si el crédito utilizado para financiar el IDPC no es por un impuesto pagado en el exterior.

El art. 41 AA No.4 inc. final establece que si hubiera un remanente de crédito, éste no dará derecho a devolución o imputación a otros impuestos, ni podrá recuperarse en años posteriores (es decir, no se puede arrastrar).

¿Quién más podría impetrar un tax credit? Hay otras rentas que apuntan a las personas naturales, por el art. 41 AD. *Los contribuyentes que, sin perder el domicilio o la residencia en Chile, perciban rentas gravadas en el extranjero clasificadas en los números 1° y 2° del artículo 42, podrán imputar como crédito contra el impuesto único establecido en el artículo 43 o el impuesto global complementario a que se refiere el artículo 52, los impuestos a la renta pagados o retenidos por tales rentas, aplicando al efecto lo dispuesto en el número 3 del artículo 41 C.*

Estamos ante personas naturales que obtienen rentas fuera de Chile, por concepto de rentas del trabajo, esto es, aquellas en que prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital (es decir, no estamos hablando de dividendos). Por ejemplo, contratan a un chileno en Brasil, quien paga un impuesto allá. Ese impuesto lo podrá imputar luego como crédito contra el GC. Así, la persona natural que percibe rentas del art. 42 No.1 y 2, es decir, rentas del trabajo en carácter de dependiente o independiente, tiene acceso al tax credit.

Pero esto tiene un límite, pues tienen que ser impuestos equivalentes a los impuestos establecidos en la Ley Renta, y el crédito no podrá exceder del 32%.

²⁴ Antonia Internacional lleva su contabilidad en dólares o euros. Esto -a contrario de llevar contabilidad en peso- se hace para evitar el efecto de las *foreign exchange variations*, producto del tipo de cambio, que pueden generar tanto renta como también pérdida para las sociedades que tienen inversiones fuera de Chile.

El **art. 41 AE** establece normas comunes para la utilización del tax credit. Para efectuar los cálculos, hay ciertos requisitos de forma. Por ejemplo:

1. (41 AE No.2) Se debe estar inscrito en el registro de inversiones en el exterior de la dirección regional competente al contribuyente. De no cumplir con esto, no se puede impetrar el tax credit. Aquí vemos una obligación accesoria de hacer, accesoria a la obligación tributaria principal, de dar una suma de dinero.
2. Para tener derecho a crédito, los impuestos pagados o retenidos en el exterior deben ser equivalentes o similares a los de la Ley Renta, es decir, a aquellos sobre los cuales voy a impetrar el beneficio.
3. Los impuestos pagados en el extranjero deben acreditarse mediante el correspondiente recibo o bien por un certificado oficial expedido por la administración tributaria respectiva. Según el caso, además del certificado de pago, probablemente se pedirá un certificado de residencia o domicilio tributario de la empresa extranjera, lo cual hoy en día se ha automatizado bastante. Obviamente el Director de SII puede disponer de auditores públicos o privados, u otros ministros de fe, para verificar la efectividad de todo esto.
4. Se establece en general como limite el 32% de la renta neta extranjera de países sin convenio para evitar la doble tributación. Así, con países sin convenio el limite del tax credit es del 32%, mientras que para países con convenio sube al 35%.
5. (41 AE No. 7) *No podrá ser objeto de devolución a contribuyente alguno conforme a lo dispuesto por los artículos 31 (se refiere a los gastos), número 3 (se refiere a las pérdidas, que son gastos necesarios para determinar renta, y que se pueden arrastrar a futuro); 56, número 3 (GC), y 63 (IA), ni a ninguna otra disposición legal, el impuesto de primera categoría en aquella parte en que se haya deducido de dicho tributo el crédito que establece este artículo y el artículo 41 C. Tampoco otorgará tal derecho, cualquier otro crédito al que se impute el crédito por impuestos de primera categoría que haya sido pagado con el crédito que establece este artículo y el artículo 41 C.*

Lo que dice este numeral es que no se puede pedir PPUA cuando se pagó el IDPC cuya devolución se solicita con tax credit por impuestos pagados en el exterior.

No podemos olvidar lo que señala el **art. 41 B**. El tax credit se verifica en inversiones outbound, desde Chile hacia afuera. El art. 41 B nos dice que los contribuyentes que invierten en el exterior no estarán afectos en impuestos en Chile hasta el monto de su inversión original en el exterior: *estos contribuyentes podrán retornar al país el capital invertido en el exterior sin quedar afectos a los impuestos de esta ley hasta el monto invertido (...).*

Es muy importante entonces que esta suma de inversión en el exterior sea informada al SII, porque cualquier exceso sobre esta suma será reputada a renta y afecta a impuesto. Si Antonia invierte 1M en Italia, le informará al SII de tal inversión, y tendrá hasta 1M para retornar al país sin pagar impuesto. Por eso que el efecto del tipo de cambio también es interesante. Si no se informa de esta inversión de capital original, se reputará como utilidad esa devolución de capital. Ese capital, cuando ingresa a la empresa exterior, no se constituye como renta, es decir, no paga impuesto: contablemente, es un pasivo, respecto de los socios. Esos pasivos se anotan en una cuenta patrimonial, como pasivo no exigible. Cuando salgan todas las utilidades, y utilicen a ese 1M original, ¿se hace más rica la Antonia por la devolución de ese 1M? No, sino que viene a resarcir la situación original que se encontraba antes de hacer el aporte, es decir, no implica un incremento de patrimonio. Por lo demás, es un capital reajustado.

¿Qué pasa si ese 1M (dólares) valía originalmente 600M de pesos al aportarse (tipo de cambio \$600), y a su retorno vale 700M pesos (tipo de cambio \$700)? Si la contabilidad está en pesos, se podría decir que 700M es un ingreso no renta, pero las diferencias de cambio que se fueron produciendo durante toda la vida podrían haber significado una utilidad o una pérdida tributaria. La única posibilidad de que se produzca una diferencia por concepto de tipo de cambio es que se lleve contabilidad en pesos.²⁵ Todos los 31 de diciembre, se saca una foto del balance. En un ejercicio posterior, cuando se traiga el capital y (posiblemente) el retorno a Chile, se mirará a esas “fotos” anteriores: hasta el monto del capital invertido, no se pagará impuesto, mientras que el exceso de ello será considerado renta por diferencia de tipo de cambio.

El art. 41 C se introdujo con la ley del 2014. A los contribuyentes domiciliados o residentes en el país, que obtengan rentas afectas al impuesto de primera categoría provenientes de países con los cuales Chile haya suscrito convenios para evitar la doble tributación, que estén vigentes en el país y en los que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito por el o los impuestos a la renta pagados en los respectivos Estados Contrapartes, se les aplicarán las normas contenidas en los artículos 41 A y 41 B, con las excepciones que se establecen a continuación: (...)

Este primer inciso no nos dice nada nuevo. Lo interesante viene a continuación, esto es, que si es que hay convenio para evitar la DTI, el porcentaje o límite anterior (32%), será del 35%, es decir, el tax credit aumenta. Sin embargo, si los beneficiarios efectivos (beneficial owner) de las rentas de fuente extranjera afectas al IDPC tuvieron residencia o domicilio en el exterior, será necesario además que Chile tenga vigente un convenio para evitar la DTI con ese país de domicilio o residencia. Lo que nos dice esta norma, es que si tenemos una cadena Perú —> Chile —> España, y el beneficiario efectivo no está en Chile sino que en España, para impetrar ese 35% en Chile, tiene que haber un tratado vigente de DTI con España.

²⁵ Si llevo la contabilidad en euros, o dólares, no se genera un problema de tipo de cambio porque no se tiene que convertir el dinero. Si llevo la contabilidad en pesos, voy a tener que convertir al sacar la plata, y al traerla de vuelta, y ahí el tipo de cambio será importante y podría generar pérdida o utilidad.

»» Con el tax expense y el tax credit, hemos visto las dos principales normas unilaterales para aminorar los efectos de la DTI.

Aplicación territorial del IVA

Como dijimos antes, cada ley, en cierta forma, determinaba el ámbito territorial de su aplicación. Veremos una cuestiones principales sobre este tema en la Ley IVA.

Esta ley tiene dos hechos gravados básicos: las ventas y los servicios.

1. Sobre las ventas.

En general se gravan las ventas de bienes corporales muebles o inmuebles efectuadas por un vendedor dentro del territorio de la República. Entonces, respecto del hecho gravado básico venta, tenemos una aplicación territorial que apunta claramente a que la transferencia del dominio se realice dentro del territorio de la República, cuando se trata de un bien corporal mueble o inmueble por parte de un vendedor.

Que sea un vendedor se relaciona con el ánimo de habitualidad, la que se analizará, según el art. 14 Reglamento Ley IVA, al momento de adquirir (no al momento de enajenar) es decir, que existía un ánimo de reventa. Por eso es que el concepto de vendedor, desde la perspectiva contable, se une con el activo circulante, stock o de inventario, en contraposición al activo fijo, de capital o inmovilizado.

También hay hechos gravados especiales que se asimilan a venta, y que se tienen que regir por el criterio territorial República (art. 8 Ley IVA).

2. Sobre los servicios.

Se grava con IVA la remuneración por un servicio vinculado a las materias descritas en los números 3 y 4 del art. 20 DL 824 (Ley Renta). Es decir, no todo servicio está afecto a IVA. Ese servicio debe ser *prestado o utilizado* en Chile.

Podemos concluir que:

- (1) El servicio no requiere habitualidad.
- (2) El servicio pudo haber sido prestado en el extranjero, y utilizado en el territorio de Chile. Se tendría que pagar precio + IVA a esa persona extranjera.

En la Ley IVA, respecto de los servicios prestados en el exterior pero utilizados en Chile, hay una exención en el art. 12 E, para aquellos pagos, remuneraciones o remesas de fuente chilena que estén afectas al IA del art. 59 Ley Renta.²⁶ El art. 59 Ley Renta grava con retención muchos pagos al exterior, incluyendo al pago por remuneraciones por servicios prestados en el exterior. Entonces,

²⁶ Este impuesto es malamente denominado IA según Pereira, debería decir “al impuesto de retención a la remesa de renta chilena”.

puede que quede exento de IVA, pero igual la ley lo grava con impuesto de retención. Además, por una ley del 2012, si es que por alguna razón se está exento de IA, se tiene que pagar IVA. Es decir, se paga uno u otro de los impuestos, pero no ambos.

El art. 59 No. 2 grava las remuneraciones por servicios prestados en el exterior, y lo considera como una remesa de pago de *fuerza chilena*. Es decir, se está considerando un servicio prestado en el extranjero como si fuera de fuerza chilena. A juicio de Pereira, esta es una de dos normas extraterritoriales que encontramos en la Ley Renta.²⁷ Ello porque está gravando la remesa de un honorario por un servicio prestado en el extranjero (sin perjuicio de múltiples exenciones contenidas en el mismo artículo), es decir, por una renta que no es de fuerza chilena.

Si volvemos a la hipótesis de servicio prestado en Chile pero utilizado en el exterior, tenemos un problema ligado a la neutralidad de los impuestos en las operaciones internacionales que afecta la competitividad de los productos chilenos en el mercado internacional. Esto porque no existe un incentivo para las empresas internacionales para contratar con empresas chilenas cuando éstas tienen que pagar un 19% de IVA: el producto chileno se encarece un 19% comparativamente. Si se exporta con IVA, el mercado chileno pierde fuerza internacional.

Por lo tanto, la ley “eximirá” las exportaciones ya sea de bienes corporales muebles o de servicios, para mantener la neutralidad de los impuestos (gravar al importar, no exportar)²⁸. Técnicamente, las exportaciones sí están gravadas, pero con tasa cero. ¿Por qué se usa esta tasa cero? Para que ese exportador pueda utilizar el IVA financiado como un crédito fiscal: podrá recuperar el IVA que soportó en adquisiciones o servicios vinculados a la generación de débito fiscal. La exportación se deberá declarar como tal por el Servicio Nacional Aduanero para que se goce de la exención (por concepto de tasa cero).

Aplicación territorial de la ley de timbre y estampilla

Esta ley grava determinados documentos que dan cuenta de un acto o de un contrato celebrado en el país. Esta ley también grava en algunas ocasiones documentos que dejan constancia de un acto o contrato celebrado en el extranjero, pero que se les quiere hacer valer en Chile.

En términos generales, diríamos que tiene un ámbito territorial por documentos que dan cuenta de operaciones de crédito de dinero. Podría tener un ámbito extraterritorial, para dos situaciones fácticas (1)

²⁷ La otra es la del art. 10 inc. 3, que se refiere a las ventas indirectas, cuando un contribuyente le vende a otro (independiente del domicilio de cualquier de los dos) acciones o cuotas de una entidad off shore que indirectamente tiene activos sustanciales en Chile. Este artículo apunta a hacer una ficción jurídica, por cuanto se considera que esa actividad de venta como renta de fuerza chilena, cuando se cumplan una serie de requisitos que apuntan a que en el fondo, el precio esté determinado por la materialidad de activos subyacentes chilenos.

²⁸ La neutralidad se produce por el hecho de cancelarse la exención a la exportación con el impuesto a la importación.

emisión de ciertos documentos en el extranjero pero que se quieren hacer valer en Chile, cuando esos documentos reflejan alguna de las situaciones gravadas por la ley de timbre y estampilla.

(2) La segunda situación se relaciona a los créditos internacionales. Por ejemplo, Ripley contrata un crédito con el Republic National Bank (NYC). Basta la mera contabilización del pasivo por parte del deudor chileno, es decir, de esa cuenta por pagar ya sea de corto o largo plazo, para que se gatillo la obligación de pagar el impuesto de timbre y estampilla.

2. APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY (VIGENCIA DE LA MISMA)

La regla general es que la ley tributaria rige a contar de la fecha que la propia ley señale. En silencio de la ley, el art. 3 del CT establece normas supletorias. Ante ello, se debe distinguir el tipo de ley tributaria que se trata.

Artículo 3.- En general, la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, sólo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa.

La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos, entrará en vigencia el día primero de Enero del año siguiente al de su publicación, y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley.

La tasa del interés moratorio será la que rija al momento del pago de la deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuere la fecha en que hubieren ocurrido los hechos gravados.

1. Una primera norma general supletoria señala que toda ley que modifique, establezca o suprima un impuesto, regirá a contar del día primero del mes siguiente al de la publicación de la ley.

Por ejemplo, se dicta una ley en abril que rebaja la tasa del IVA a 18%. ¿Qué impuesto se pagará al 20 de mayo (el IVA se paga mensualmente)? La primera conclusión es que la ley comienza a regir a partir del 1 de mayo. En segundo lugar, el pago que se hace el 20 de mayo corresponde a hechos gravados anteriores a la entrada en vigencia de la ley el 1 de mayo. Por tanto, se deberá pagar el IVA con la tasa del 19%. Excepcionalmente, podría aplicarse la ley tributaria a hechos anteriores a su entrada en vigencia en una especie de principio pro contribuyente, cuando exime de sanciones o aplica una sanción menos rigurosa.

2. Cuando la ley modifica la tasa de impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos, entrará a regir al primero de enero del año siguiente al de publicación. Aquí tenemos

que unir esta materia con el proceso de determinación de la renta líquida imponible, que sigue la lógica de eliminar los costos.

En consecuencia, los impuestos que deban pagarse a contar de dicha fecha, deben sujetarse a la nueva ley.

Por ejemplo, el IDPC se paga el mes de abril de cada año por el ejercicio comercial anterior. Imaginemos que el 31 de diciembre de 2018 se cambió el IDPC a 30%. Acorde a una interpretación estricta de la ley, el IDPC debería pagarse acorde a la nueva tasa. Sin embargo, la mayoría de los hechos gravados se produjeron antes de la nueva ley. Esto se ha interpretado, porque no se quiere que las leyes tributarias tengan efecto retroactivo, por lo tanto regiría respecto de los hechos producidos después de la entrada en vigencia de la ley.

3. Sobre los intereses moratorios, la tasa de los mismos será la vigente a la fecha del pago, y no la vigente a la deuda original. Esa tasa se aplica por todo el periodo de mora. Es decir, si la obligación de pagar vence en abril, y el interés vigente era de 1,5% mensual, y se paga en agosto, cuando en mayo la tasa cambió a 2,5%, la tasa será esta última.

Esto hay que vincularlo con el art. 33 que trata el interés moratorio. Se paga un interés moratorio del 1,5% por mes del impuesto adeudado, debidamente reajustado, entre el vencimiento y el pago efectivo. Esto es un 18% real anual, que es altísimo.

Existe un plazo fatal de 90 días para recamar ante el TTA, el cual se puede ampliar a un año si dentro del plazo legal se paga el impuesto. Con este pago, el contribuyente se puede ahorrar el reajuste e interés, si es que en definitiva es condenado al pago. Sucede que muchas veces, para cuando se llega a la CA, se debe más por intereses que por el impuesto original.

3. DECRETOS Y REGLAMENTOS

Por el principio de legalidad, no son fuentes de tributos. Pero existen reglamentos importantes, sin duda el Reglamento IVA. Estos jamás pueden ir más allá de la ley, sino que deberán reglamentar materias dejadas por la propia ley a la potestad reglamentaria, que apuntan en general a forma y no fondo.

4. TRATADOS INTERNACIONALES

Si son fuentes del derecho tributario, en cuanto revisten el carácter de la ley, y además priman por el principio de especialidad.

5. COSTUMBRE

La costumbre no es fuente de derecho tributario. Ahora bien, en Latino América, hay ciertas costumbres producidas por desinformación que algunos han señalado erróneamente como fuentes. Por ejemplo, se solía decir: “señor, los intereses de los depósitos a plazo en los bancos no están gravados con impuesto o

no van a su global complementario” (información dada por ejecutivos bancarios). Entonces todo el mundo ponía su dinero en depósitos bancarios protegidos por el secreto bancario de antaño, no colacionaban en la renta bruta global de este contribuyente persona natural, con domicilio o residencia en Chile para efectos tributarios, los intereses, los que no solamente se devengaban, sino que se percibían y automáticamente se reinvertían (capitalización del interés percibido).

Esos intereses siempre estuvieron afectos al impuesto global complementario, pero muy pocas personas los declaraban pues era una declaración relativamente voluntaria y no lo hacían no porque no existiera la obligación legal de hacerlo, sino porque existía un problema de eficiencia y eficacia en la fiscalización de esos intereses, es decir, el SII tenía un mal acceso a la información. Así, no era un problema de que la costumbre señalara que no se debían pagar el global complementario por esos intereses, sino una mala fiscalización del SII. Luego se empezó a pagar el impuesto sobre estos intereses porque se estableció una declaración jurada obligatoria por parte de los bancos e instituciones financieras, en que en marzo deben enviar información respecto de todos los intereses que se han devengado o percibido respecto de todos aquellos que han efectuado depósitos en el banco, con una completa individualización y caracterización de los mismos. Entonces, esto va en un formulario especial bajo un código que tiene un algoritmo matemático que cruza la información con la declaración del formulario 22 del contribuyente. De ese modo es que cambió la costumbre y se empezó a declarar los intereses obtenidos.

6. JURISPRUDENCIA

Evidentemente no es fuente, pero el valor de la jurisprudencia especializada de hoy en día es muy alto y no se puede desconocer, sobretodo considerando que las instancias superiores suelen confirmar las sentencias de primera instancia en materia tributaria.

Uno podría preguntarse cómo enmarcamos la interpretación administrativa dentro de la jurisprudencia judicial. Es indudable en la práctica que la interpretación administrativa influye sobre los jueces, porque no existe mucha literatura tributaria. A juicio del profesor, las resoluciones del SII suelen ser interpretaciones correctas y razonables de la ley. Luego, que un juez se base en tales interpretaciones no es de suyo erróneo y motivo para una casación.

Luego, es difícil cambiar el criterio tributario de los tribunales superiores de la justicia, lo que hace que el principio de efecto relativo de la jurisprudencia tenga un efecto extensivo, y que se soporta en la interpretación administrativa.

ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FISCALIZACIÓN, APLICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

A. Servicio de Impuestos Internos

En primer lugar tenemos al SII, que es el organismo encargado de la fiscalización y aplicación de impuestos fiscales internos.

Comentarios al funcionamiento del SII.

1. Es el organismo encargado de la **fiscalización** de todos los impuestos fiscales internos, y residualmente de todo otro impuesto que la ley no haya otorgado en su fiscalización a otro organismo.
2. Su función es de fiscalizar el cumplimiento de la obligación tributaria. El proceso que desarrolla el SII se da fundamentalmente en la determinación de la obligación tributaria por actos coordinados, es decir, se detectan diferencias con la auto determinación que hace el contribuyente. La obligación tributaria se extingue por excelencia por el pago, de modo tal que la obligación tributaria trasciende a las funciones del SII, que se enfoca en la fiscalización de la misma.
3. Su estructura es la siguiente:
 1. Director Nacional. Sus facultades se contemplan en el art. 6A del CT, y la LOC SII.
 2. Gabinete del DN
 1. Jefe de gabinete
 2. Secretario que actúa como ministro de fe
 3. ACN, donde está la jurisprudencia (fundamentalmente oficios).
 4. Otros, como asesor de prensa y abogados.
 3. Subdirectores
 1. **Fiscalización**. Se concentra en normativa e instrucciones acerca de cómo fiscalizar a los contribuyentes. De aquí emana la “inteligencia tributaria”, pues es donde se analizan las técnicas de control tributario, y se evalúan también el rendimiento de las direcciones regionales. Se elabora también un presupuesto para cada dirección regional.
 2. **Jurídico**. Asesora en materia legal al Director Nacional, y así se van dando los criterios uniformes para la actuación de los abogados del SII en los tribunales a lo largo del país.

Las unidades jurídicas de toda dirección regional siguen los lineamientos de la subdirección jurídica nacional.

Lleva la defensa del SII cuando interviene en juicio.

También lleva una Oficina de Recopilación de Antecedentes que estudia el mérito de una eventual querrela por delito tributario.

3. **Normativo.** De esta emanan los oficios. Elabora las propuestas de interpretación administrativa de las normas tributarias. Además, Estudia y propone normas sobre cómo aplicar convenientemente los impuestos.
4. **Informático.**
5. **Recursos Humanos.** Apunta al personal del SII.
6. **Estudios.** Este hace análisis acerca de los índices de cumplimiento y de recaudación de los impuestos. Esta subdirección trabaja muy ligada a la OECD (índices macroeconómicos de Chile), la DIPRES, el Banco Central (BC).

Administra el registro de contribuyentes o RUT.

7. **Contraloría interna.** Vela por el correcto desempeño de las labores de los funcionarios del SII, que deben actuar dentro del marco de la ley.
8. **Atención al contribuyente.**
9. **Administración y finanzas.**
10. **Avaluaciones.** Guarda relación con los impuestos territoriales (bienes raíces).

4. Parte operativa del servicio. Decimos operativa porque es aquí donde se desarrolla la fiscalización y hay facultades operativas que solo las tienen los Directores Regionales y no el Director Nacional.

1. Direcciones regionales. Una por región, salvo en la RM que tiene las direcciones de Oriente, Centro, Sur, Norte y Poniente.
 1. Las direcciones regionales a su vez tienen unidades. Por ejemplo, Ñuñoa en Santiago Oriente, o San Fernando respecto de la Dirección Regional de Rancagua.
 2. Existen facultades que solo tienen los directores regionales, y no el director nacional, como la facultad de condonar multas e interés (jamás impuestos).²⁹ Las facultades del director nacional están en el art. 6 del CT, como también en la LOC del SII.

²⁹ Solo puede condonar el Director Regional, el Director de Grandes Contribuyentes y el Subdirector de Fiscalización en casos calificados.

2. Dirección de grandes contribuyentes. Atiende a grupos y grandes contribuyentes.

B. Municipalidades

Estas son las encargadas de la fiscalización y aplicaciones de los tributos internos municipales. Las municipalidades en este caso también recaudan a través del Tesorero comunal respectivo.

C. Servicio de aduanas

Se encarga de fiscalizar los impuestos externos (aranceles y derechos aduaneros).

D. TGR

Su función es la de recaudación, y tiene un rol vital en el proceso de cobro ejecutivo de la obligación tributaria, a través de tesoreros comunales, abogados provinciales y una serie de otros funcionarios.

E. CGR

Puede interpretar leyes tributarias municipales y de aduana. En el caso de existir una pugna entre CGR y SII en la interpretación de una norma, por no saberse si estamos ante un tributo municipal o no, resuelve la Corte Suprema.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

La obligación tributaria es un vínculo jurídico por el cual un sujeto denominado deudor debe dar sumas determinadas por ley a otro sujeto, denominado acreedor, quien actúa ejerciendo su poder de imperio.

Podemos mencionar que es una definición parecida a la de tributo. Destaca la existencia de dos sujetos, activo y pasivo. Los sujetos pasivos de la obligación tributaria son los contribuyentes, que estarán obligados a dar una suma de dinero determinada por ley: es decir, la obligación tributaria corresponde a la obligación civil de dar. El sujeto pasivo de la obligación no solo está obligado a dar sumas determinadas, sino que también está sujeto a las denominadas **obligaciones tributarias accesorias**, que se imponen al sujeto pasivo para coadyuvar al organismo fiscalizador en su obligación de fiscalizar. Vemos que la obligación tributaria accesoria no necesariamente se impone para asegurar el cumplimiento de la obligación principal; es decir, en general la obligación accesoria ayuda a la fiscalización de la obligación tributaria y no su extinción.

La obligación accesoria es una obligación civil de hacer. Tales son, por ejemplo:

- La obligación de aportar antecedentes cuando los solicite el SII,
- Llevar contabilidad (tan importante es esta obligación que incluso puede llevar a que no se tenga que pagar tributo por concepto de pérdida, lo que refuerza la idea de que la obligación tributaria accesoria no asegura el pago),³⁰
- Emitir boletas,
- Hacer la declaración de impuestos,
- Iniciar actividades,³¹
- Sacar RUT (no es lo mismo que iniciar actividades, pero el SII entrega los formularios en conjunto como si fuera una misma obligación),
- Emitir facturas (ello dará derecho a utilizar crédito fiscal, diferencia de la boleta que es propia para consumidores finales o entidades que no generan débito fiscal),
- Llevar la guía de despacho (cuando no hay transferencia de dominio de los bienes transportados),
- Nota de crédito y nota de débito (una nota de crédito sirve para disminuir el débito fiscal y las notas de débito para aumentar).

Sobre la obligación accesoria tributaria, podemos notar diferencias importantes con la obligación accesoria civil, a saber:

1. No se extingue por el pago de la obligación principal. Por ejemplo, aún cuando no se deban de pagar impuestos, igualmente se tiene que llevar a cabo la declaración.

³⁰ No toda persona está obligada a llevar balance.

³¹ No todo contribuyente está sujeto a iniciar actividades.

2. El objetivo persigue ayudar a fiscalizar, y no necesariamente a asegurar el pago. La doctrina ha propuesto que entre el fisco y el contribuyente hay una relación jurídica tributaria, dentro de la cual la obligación de dar es una de varias. Pereira rechaza esa teoría: la obligación tributaria es siempre la de dar una suma determinada, y toda otra será una obligación accesoría.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

1. Su fuente mediata es la ley, pero su fuente inmediata es la verificación del hecho imponible.

El hecho imponible o gravado es el hecho o acto jurídico típico descrito por la ley, cuya verificación sujeta al tributo en ella establecida a quien le fuere atribuible el mismo.

Este hecho gravado puede serlo de tres tipos:

- Hecho material. Por ejemplo, el hecho de pasar una mercadería por aduana, lo que apunta al tránsito internacional de bienes corporales muebles. Debemos recordar que la importación es el ingreso legal de bienes corporal muebles al territorio de la República, cuyo tránsito es un hecho gravado.
- Hecho jurídico. Por ejemplo, la celebración de un documento de aquellos descritos en la ley 18.010, que gatilla el impuesto de timbre y estampilla.
- Hecho económico. Por ejemplo, la obtención de utilidades, que no se debe confundir con la percepción de ingresos, pues no todo ingreso es utilidad.

2. La obligación tributaria es una obligación civil. Ello por cuanto da acción al fisco para exigir el cumplimiento forzoso de la obligación.

3. Es una obligación tributaria pura y simple, o sujeta a plazo, pero jamás modal o condicional. Que se admita el plazo explica toda la diferencia entre el devengamiento y exigibilidad del impuesto.

4. Obligación de dar.

5. Obligación de género, toda vez que su objeto es dar dinero. Por ello, no se extingue por la pérdida de la cosa debida.

6. Normalmente, la obligación tributaria es de objeto único, en oposición a las obligaciones alternativas y facultativas. Un caso de una obligación facultativa era un impuesto CORVI de 5% sobre las utilidades, y la ley permitía imputarle los gastos del contribuyente destinados a construir viviendas económicas (se podía o pagar el impuesto o pagar las viviendas, obligación facultativa).

7. **Normalmente, es una obligación de sujeto singular.** Excepcionalmente puede serlo de sujeto múltiple, como en el caso de los herederos en el impuesto a la herencia, en cuyo caso se obligan de manera simplemente conjunta por su cuota en la herencia. Contados 3 años desde la delación de la herencia, hay una ficción de que el causante sigue vivo para efectos tributarios. Pero además, sobre esta masa de bienes no partida, cada uno pagará impuestos sobre su cuota en la herencia.

Otro caso son las rentas de una sociedad de hecho, donde los socios responden solidariamente.

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Sujeto

1. **Activo**

1. **Fisco.** Para los impuestos fiscales internos y externos.
2. **Municipalidades.** Para los impuestos municipales.

2. **Pasivo**

1. **Contribuyente propiamente tal.** Se trata del deudor, que debe la suma de dinero determinada, al fisco o municipalidad.

El sujeto puede ser de derecho vs. de hecho, que es donde vemos el fenómeno de la traslación, propio de los impuestos indirectos. A contrario, en los impuestos directos el efecto económico no se traslada, lo cual nada tiene que ver con la retención, que es muy común en impuestos directos. La traslación es siempre económica, jamás jurídica.

Por la traslación, el acreedor de la obligación tributaria **no puede** perseguir jurídicamente al sujeto pasivo de hecho. Si vamos al IVA, el Fisco no puede perseguir al comprador por el incumplimiento del pago del IVA por parte del vendedor. Ello salvo situaciones extraordinarias en virtud de una disposición legal que así lo autorice y se produzca el cambio de sujeto, cuando el contribuyente de derecho es de difícil persecución. Por ejemplo, el pastor de ovejas que vive en la montaña y baja al pueblo a vender; el comprador emitirá una factura de compra y pagará el impuesto.

2. **Sustituto o agente retenedor (impuestos de retención).**

Es la persona obligada a retener impuestos que adeudan terceros, y que por tener esta obligación debe enterar estos impuestos en arcas fiscales una vez retenidos. Tal es el caso de impuesto único de segunda categoría que grava las rentas del trabajador dependiente (base imponible: remuneración en sentido amplio, excluyendo solo las contribuciones de seguridad social).

Este agente entonces deberá retener, declarar y enterar.

Caso.

Javiera y Felipe son socios de Agrícola Tomé, y su gerente de ventas es Matías. Javiera y Felipe pagan GC por sus rentas percibidas,³² mientras que la Agrícola paga IDPC por sus rentas percibidas.³³ Matías paga IUSC, que se paga por renta **percibida**. Si a Matías no le han depositado su sueldo, él no está afecto al IUSC por su sueldo que no ha recibido, no obstante que el ya tiene un título sobre ese sueldo.

Agrícola Tomé calcula su renta sobre base devengada o percibida. La doble partida nos indica que el gasto debe seguir la misma lógica que el ingreso; es decir, que el gasto también debería computarse sobre base devengada o percibida. Tomé debió haber descontado esa remuneración a la que estaba obligada a pagar por el contrato. Por tanto, *debe* deducirla como gasto *en ese ejercicio*. Se puede producir entonces una suerte de atemporalidad entre el minuto en que el emperador debe deducir la remuneración de la base imponible del IDPC, y el momento en que el trabajador debe tributar con el IUSC.

Si en el mes de diciembre no se le pagó a Matías, él no tiene que pagar IUSC, y lo deberá pagar en el ejercicio posterior; pero Tomé deberá deducirlo en el mismo ejercicio en que se devengó la remuneración, existiendo por tanto un desfase entre la deducción por parte del empresario y la afectación a impuesto por parte del empleador.

La obligación de retener del empleador se generará cuando le efectúe el pago de la remuneración, y deberá entonces declarar y enterar por cuenta de Matías, que no tiene nada que ver con que haya deducido esa remuneración como gasto necesario para generar la renta.

Otro ejemplo típico es el IA del art. 59 (que debería llamarse impuesto de retención). Ejemplo. El banco Crédit Agricole (francés), da un crédito a Horti Fruit Chile. Por los intereses que devenga ese crédito, se deberá pagar un IA del art. 59 inc. 4 1A (tasa 4%³⁴): ¿quién lo paga? Crédit Agricole, pero el monto es enterado por Horti Fruit en cuanto agente retenedor.

En definitiva, **quien paga el impuesto es siempre el sujeto pasivo**, sin perjuicio de que el agente retenedor, por mandato legal, retenga, declare y entere ese impuesto. Frente al Fisco,

³² La renta para efectos del GC puede ser percibida o atribuida, por ahora nos quedaremos con percibida.

³³ La renta puede ser devengada o percibida. Rentas devengadas son aquellas que existen y se tiene un título a ella independiente de su actual exigibilidad, mientras que percibida es aquella que ha ingresado al patrimonio. Para nuestro ejemplo asumiremos que es una renta percibida.

³⁴ Es una tasa baja para incentivar que Chile ingrese al sistema financiero mundial (créditos internacionales).

solo responde el sustituto, cuando se haya efectuado la retención. En cambio, si no ha efectuado la retención, el Fisco puede perseguir al contribuyente o al retenedor.

Que el retenedor haya retenido pero no declarado y enterado lo puede hacer incurrir en un enriquecimiento sin causa. De ello que se sancione fuertemente esta situación, porque puede suceder que los empleadores retengan y no enteren impuestos de trabajadores, lo que configuraría un delito tributario como también un delito común del código penal.

3. **Tercero responsable.** Es la persona a quien la ley hace responsable de un impuesto cuando éste se ha dejado de cumplir por el deudor directo o por el sustituto.

Tal es el caso del notario respecto del impuesto territorial y de timbres, como también el CBR respecto del impuesto territorial.

4. **Representación del sujeto pasivo.**

Artículo 9.- Toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación. El mandato no tendrá otra formalidad que la de constar por escrito.

El Servicio aceptará la representación sin que se acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá exigir la ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del plazo que él mismo determine, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación correspondiente. La persona que actúe ante el Servicio como administrador, representante o mandatario del contribuyente, se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de éste mientras no haya constancia de la extinción del título de la representación mediante aviso por escrito dado por los interesados a la Oficina del Servicio que corresponda.

Este artículo consagra la **representación administrativa**: el contribuyente puede actuar ante la administración por sí o legalmente representado, que no tiene otra formalidad más que constar por escrito, lo cual se acreditará en la primera actuación ante el SII. Si no consta, el SII da un plazo para que se regularice la situación. Es importante lo que se señala respecto del gerente o administrador, que se entenderá por ley siempre habilitado para representar, independiente de las limitaciones estatutarias.

Artículo 14.- El gerente o administrador de sociedades o cooperativas o el presidente o gerente de personas jurídicas, se entenderán autorizados para ser notificados a nombre de ellas, no obstante cualquiera limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de dichas personas jurídicas.

Respecto de la **representación judicial**, en los reclamos tributarios solo pueden ser actuar los contribuyentes por sí o por sus mandatarios legales, que se remite a la regulación general sobre tramitación en juicio.

***Artículo 129.-** En las reclamaciones a que se refiere el presente Título, sólo podrán actuar las partes por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios.*

Las partes deberán comparecer en conformidad a la normas establecidas en la ley N° 18.120, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a treinta y dos unidades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán comparecer sin patrocinio de abogado.

El art. 148 agrega que en toda materia no sujeta a disposición especial, se aplicarán en lo que sean compatibles con el procedimiento de reclamo tributario, las reglas del Libro I del CPC.

El SII ha interpretado que en materia tributaria no se admite la fianza de ratio, por el art. 129 del CT, que sería norma especial, sin que sea aplicable las normas de fianza de ratio por aplicación del art. 148 CT que se exceptúa por disposiciones especiales. Otros autores han opinado que sí valdría la fianza de ratio (agencia oficiosa). Recomendación práctica, siempre actuar por mandatario o por sí.

Causa

1. **Mediata:** ley
2. **Inmediata:** verificación del hecho gravado

En definitiva, la causa es la ley, en cuanto causa mediata. Como ya dijimos, es la ley incluyendo toda la pirámide de Kelsen y los TT.II (que priman por especialidad). La causa inmediata será la verificación del hecho gravado.

Objeto

1. **Obligación de dar**
2. **Sumas de dinero**
3. **Determinadas.** La suma se podrá determinar por la fórmula [Base Imponible + Tasa = Impuesto (menos crédito)]. Luego, se debe distinguir claramente la base imponible de la tasa. La base imponible es el valor del hecho gravado (definido anteriormente).

Este valor del hecho gravado, puede ser resultado de la determinación:

1. Por ley
2. Por la justicia
3. Por actos coordinados. En este caso, puede ser el resultado de una buena defensa del contribuyente en una citación; o bien de una tasación del SII, ya sea por antecedentes que tiene por terceros, entregada por el contribuyente, u obtenida por sus facultades de investigación.

1. Declaración
2. Liquidación o reliquidación. La reliquidación será el resultado de la tasación que haga el SII en base a los antecedentes que maneje.
 1. Fiscalización
 1. Notificación
 2. Citación
 3. Liquidación
3. Giro

En la **tasa**, nos remitimos a la clasificación de los impuestos.

El impuesto lo puedo pagar con créditos, dentro de los cuales podemos encontrar PPMs (pagos provisionales mensuales), otras figuras de compensación (e.g ser el contribuyente acreedor del Fisco), u otros mecanismos establecidos por ley (e.g el sistema integrado contra los impuestos finales).

Cabe mencionar que la obligación tributaria no tiene solemnidades.

DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Se han dado múltiples conceptos de la determinación, en cuanto acto o conjunto de ellos emanados de los particulares, de la administración, o de ambos conjuntamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración de tres elementos: (1) del presupuesto de hecho; (2) la medida de lo imponible; (3) el alcance cuantitativo de la obligación.

Se podría decir que los primeros dos elementos apuntan a la base imponible, mientras que el alcance cuantitativo sería el impuesto en cuanto suma de dinero a enterar.

Luego, el proceso de determinación consiste en:

1. Determinar en primer lugar que alguien ha incurrido en la conducta descrita por la ley (que un RUT específico ha incurrido en la conducta típica).
2. Determinar la base imponible. Por ejemplo, el precio de venta de un bien mueble en el caso del IVA
3. Determinar el impuesto a pagar.

En Chile tenemos tres alternativas para determinar la obligación tributaria, a saber: la determinación legal o por el propio contribuyente, la determinación judicial, y la determinación por actos coordinados.

1. DETERMINACIÓN QUE HACE LA PROPIA LEY O EL PROPIO CONTRIBUYENTE (AUTODETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA).

Requiere tan solo verificar que alguien incurrió en el hecho gravado, pues el alcance cuantitativo lo hace la propia ley, por ejemplo el impuesto de timbre y estampilla para cheques.

En el caso de la autodeterminación, puede que termine con el cálculo hecho por el contribuyente. Sin embargo, siempre está expuesta a fiscalización, por lo que fácilmente muta a la determinación por actos coordinados.

2. DETERMINACIÓN JUDICIAL

Está descrita para dos casos, y un tercer caso discutible. Tales son el impuesto de timbre y estampilla, impuesto territorial, y el impuesto de herencias, respectivamente.

Impuesto territorial (art. 149 y ss.)

Artículo 149.- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo los contribuyentes y las Municipalidades respectivas podrán reclamar del avalúo que se haya asignado a un bien raíz en la tasación general. De esta reclamación conocerá el Tribunal Tributario y Aduanero. Respecto del avalúo asignado a un bien raíz en la tasación general, será procedente el recurso de reposición administrativa en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley N° 19.880 y con las mismas modificaciones establecidas en el artículo 123 bis, salvo la de su letra b), en que el plazo para que se entienda rechazada la reposición será de noventa días.

La reclamación y la reposición, en su caso, sólo podrán fundarse en algunas de las siguientes causales:

1°.- Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones.

2°.- Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3°.- Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4°.- Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

La reclamación o la reposición que se fundare en una causal diferente será desechada de plano.

Este artículo señala la posibilidad de los contribuyentes de reclamar sobre el avalúo fiscal de un bien raíz. Podemos destacar que en primer lugar, ya no es solo parte de este reclamo el propietario contribuyente, sino que también la municipalidad correspondiente, a la cual se le da traslado (y se hace parte).

La base imponible está compuesta por el avalúo fiscal del bien, que es determinado periódicamente por el SII. El contribuyente puede reclamar ante el TTA, e incluso apelar ante tribunales especializados de alzada, formado por un ministro de CA y personas especializadas (e.g tribunal de alzada agrícola).

Las causales apuntan fundamentalmente al tipo de inmueble y características de construcción. Esto incide tanto para el impuesto territorial, pero aun para otros impuestos, como el impuesto de herencia. Ello porque se debe determinar a qué valor se colacionará el inmueble a la masa hereditaria, que será el avalúo fiscal al momento de la delación de la herencia.

En definitiva, ya sea en primera o única instancia, o por resolución de tribunal especializado de alzada, se puede modificar el avalúo fiscal, con lo cual la justicia está determinando la obligación tributaria, al fijar la base imponible de la misma.

Impuesto de timbre y estampilla

La ley establece un procedimiento para que el contribuyente que tenga duda acerca de sus montos pueda seguir.

***Artículo 158.-** El contribuyente y cualquiera otra persona que tenga interés comprometido, que tuviere dudas acerca del impuesto que deba pagarse con arreglo a las normas de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, podrá recurrir al juez competente, con arreglo al artículo 118, pidiendo su determinación.*

El Tribunal solicitará informe al jefe del Servicio del lugar, quien deberá ser notificado de la resolución personalmente o por cédula, acompañándosele copia de los antecedentes allegados a la solicitud.

El Servicio será considerado, para todos los efectos legales, como parte en estas diligencias, y deberá evacuar el informe dentro de los seis días siguientes al de la notificación.

Vencido el plazo anterior, con el informe del Servicio o sin él, el Tribunal fijará el impuesto.

Del fallo que se dicte podrá apelarse. El recurso, se conocerá en el solo efecto devolutivo, se tramitará según las reglas del Título II de este Libro y gozará de preferencia para su vista.

El pago del impuesto cuyo monto haya sido determinado por sentencia ejecutoriada, tendrá carácter definitivo.

***Artículo 160.-** No será aplicable el procedimiento de este párrafo a las reclamaciones del contribuyente por impuestos a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, cuando ya se hubieren pagado o cuando, con anterioridad a la presentación de la solicitud a que se refiere el inciso 1° del*

artículo 158, el Servicio le notifique la liquidación o cobro de tales impuestos. En estos casos se aplicará el procedimiento general contemplado en el Título II de este Libro.

El tribunal resolverá acerca del monto del impuesto, en cuyo caso también está determinado la obligación tributaria.

Impuesto de herencia

Antiguamente, el contribuyente proponía la liquidación al tribunal, quien de oficio pedía al SII emitir informe al respecto, con el cual el tribunal fijaba el monto.

Con la ley 19.903 del 2003, se distinguió entre la sucesión testada e intestada. La intestada se tramita completamente ante el oficial de registro civil, donde se acompañan los documentos que acrediten el dominio del causante sobre los bienes de la masa hereditaria, y además se llenan dos formularios.

El primero de esos formularios es la solicitud de posesión efectiva, y el segundo el formulario 4423. En el segundo, se auto determina la obligación tributaria. El registro civil emitirá y publicará vía decreto administrativo el auto de posesión efectiva. En la práctica, al inscribir los bienes sujetos a inscripción, los conservadores pedirán al peticionario certificado del SII que señale la exención o correcto pago del impuesto a la herencia. En esta etapa en que el conservador pide el certificado, el SII aprovecha de verificar la correcta determinación del impuesto. Pero como vemos, no hay intervención de tribunales en el caso de sucesión intestada para determinar la obligación tributaria.

Sin embargo, para el caso de la sucesión testada, o abierta en el extranjero, sí tiene una participación vital el tribunal. El proceso se inicia ante el tribunal civil competente (normas CPC), que oficiará al Registro Civil para que se certifique la calidad de heredero. Al igual que en el caso anterior se presenta el formulario 4423, pero esta presentación se efectúa en el tribunal civil competente. La resolución de posesión efectiva emitida por el tribunal se acompaña al Registro Civil para las inscripciones pertinentes. Cuando se deba hacer la inscripción que requieren un registro conservatorio (autos y bienes raíces), el Conservador va a exigir un certificado expedido por el SII señalando la exención o correcto pago del impuesto. En la práctica, esto puede gatillar una fiscalización del SII.

3. DETERMINACIÓN POR ACTOS COORDINADOS

En la determinación por actos coordinados es necesario tener presente la siguiente línea de tiempo.

1. Declaración
2. Notificación
3. Citación
 1. Fin (giro -orden de pago-)
 2. (Re)Liquidación
 1. Fin (giro)
 2. Reclamación ante el TTA

3. Reposición Administrativa Voluntaria (RAV)

Es decir, hay una primera **declaración** del contribuyente. De ella puede seguirse una notificación o eventualmente una citación. De la citación, puede que el contribuyente pague, reconociendo que hubo un error en la declaración, o en caso de que ello no suceda se desprenderá una (re)**liquidación** que hará el SII. De dicha liquidación, se seguirá el **pago**, ya sea porque el contribuyente pague inmediatamente, o luego de resolverse recurso administrativo o reclamo ante el TTA. Es con el reclamo que se traba la litis, en cuyo caso la obligación tributaria la determinará la justicia.

Hasta el momento antes de trabarse la litis, estaremos en un caso de determinación de la obligación por actos coordinados, en razón de la intervención del SII ejerciendo su rol fiscalizador.

Tenemos entonces 3 grandes etapas:

1. Declaración.
2. Liquidación.
3. Giro (orden de pago).

El pago no es una etapa de determinación de la obligación tributaria, sino que *el modo por excelencia de extinguir* una obligación predeterminada.

Entre la declaración y la citación, opera la prescripción de la acción de fiscalización (art. 200 y 201). La acción de fiscalización prescribe ordinariamente en 3 años desde que se debió haber enterado el impuesto en arcas fiscales. Por ejemplo, en IDPC, IA e IGC, sería desde el 30 de abril a las 11:59. La prescripción es extraordinaria (i) cuando la declaración no se ha presentado debiéndose haber presentado, o (ii) la declaración presentada fuere falsa o incompleta. En este caso será un plazo de 6 años desde que se debió haber pagado.

La prescripción se divide en la prescripción de la acción de fiscalización y de la acción de cobro (que tiene TGR). Ambas son un modo de extinguir la obligación tributaria.

Si ha mediado una citación (art. 63), ésta tiene el efecto de ampliar el plazo de prescripción de la acción de fiscalización.

1. Declaración

Los artículos 29 a 33 establecen las formas de declarar los impuestos. Se trata básicamente de una declaración jurada del contribuyente al SII. Hoy, eso consiste en una propuesta de determinación que envía digitalmente el SII al contribuyente en base a los antecedentes que posee respecto a ese contribuyente (e.g boletas emitidas, declaraciones juradas y formularios vinculados a inversiones exteriores y su rentabilidad, etc... en general se trata de antecedentes aportados por terceros). Dicha propuesta *no constituye derecho para el contribuyente*, del que se pueda amparar el contribuyente de buena fe.

La existencia o inexistencia de formulario no exime al contribuyente de tener que hacer declaración.

Los plazos se fijan por ley, ya sean mensuales o anuales.

En los art. 29 - 33, es importante notar que los directores regionales pueden hacer una prórroga específica a un contribuyente, por un máximo de 4 meses, e incluso más en el caso de contribuyentes en el extranjero. Esta facultad es solo para prorrogar el plazo de declarar, lo cual no quita el hecho de que se tendrá que pagar un reajuste e interés moratorio (1,5% por mes); es decir, la prórroga solo evita las multas. Si podría haber una prórroga general, decretada por el Presidente vía Ministerio de Hacienda.

Por resoluciones exentas del SII, los antecedentes permanecen en manos del contribuyente a disposición del SII. Luego, la declaración se resume en un formulario electrónico y un pago a la cuenta de TGR.

Por la declaración se está constatado el hecho de haber incurrido en el hecho gravado; se le da un valor al hecho gravado (base imponible); y finalmente se determina el monto a pagar. El pago, no es determinación, sino extinción.

La citación está contenida en el art. 63 del CT, y es una de las normas más importantes en materia tributaria (como también lo es el art. 26). Es una instancia que **no** determina la obligación tributaria, sino una para que el particular pueda confirmar, rectificar, o explicar su determinación por escrito. El SII puede poner término al proceso, cuando acepta la explicación del contribuyente. A su vez, el contribuyente puede rectificar su declaración. Si el servicio no está conforme, hace una nueva liquidación.

2. Liquidación

Se trata de una redeterminación de la obligación tributaria cuando no hubo acuerdo entre el SII y el contribuyente. El SII hará una nueva determinación, y el documento que emite y notifica al contribuyente recibe el nombre de liquidación.

En los art. 33 a 63, hay una serie de **medidas para fiscalizar** que deben ser unidas al art. 200-201 en cuanto modo de extinguir la obligación tributaria.

- Art. 34. Posibilidad del SII de citar a terceros para declarar bajo juramento.
- Art. 35. Posibilidad del SII de exigir que se confeccionen determinados antecedentes, y que se entregue información sustentatoria de la misma. Este artículo es importante porque se establece la obligación de confidencialidad del funcionario de SII, con las excepciones pertinentes.

Esta norma de secreto no se ha respetado mucho, y es en lo que el SII debe seguir trabajando. Se puede observar en la prensa información tributaria que sin duda se filtran desde el propio SII. Esto es relevante porque la filtración de información podría echar abajo todo un proceso de fiscalización.

La reserva no solo refiere al resultado positivo de un contribuyente, sino también al monto actualizado de la pérdida tributaria (que sabemos que es un activo tributario).

- Art. 60. El SII podrá examinar libros que lleve el contribuyente, agente retenedor, o terceros (para realizar fiscalizaciones cruzadas).³⁵

El SII también puede pedir un estado de situación: una relación de los activos y pasivos de la persona, para efectos de ver si calza la declaración con su “nivel de vida”. Si no hay una correlación, se produce una tasación y le pueden tasar impuestos no enterados.

Solicitud de inventarios. El SII podría realizar un inventario respecto de un contribuyente, que perseguirá comprobar si el inventario contable se condice con el inventario físico o real (apunta a la existencia de los bienes del activo fijo y de los de activo circulante³⁶).

Posibilidad de citar a testigos, salvo los parientes y quienes se amparen en secreto profesional.

- Art. 61 y 62.³⁷ Sufrieron una variación cuando Chile entró a la OCDE, en relación al secreto de la cuenta corriente bancaria. Concretamente, el art 62 fue introducido en dicho momento.

El artículo es fundamental, porque levanta el velo del secreto bancario al seguirse un procedimiento.

2.1 La citación

(1) Es el acto formal por el cual el SII llama al contribuyente para que este dé una explicación, aclaración o enmienda sobre la declaración de impuesto emitida, y eventualmente para que aporte antecedentes.

³⁵ Por ejemplo, Mariano emite boleta de honorarios a Falabella, que lo descontará como gasto necesario. Si Mariano no incluye ese honorario, el SII puede detectar que hay un gasto, identificado con un RUT, que no se condice con la declaración emitida por ese RUT.

³⁶ Por ejemplo, si no puedo justificar que falten 100 televisores supuestamente en inventario, se va a presumir que se vendieron, sin declararse IVA. El SII tasaré el valor según el valor de mercado, y se presumirá la renta.

³⁷ Pregunta de prueba, junto con el art. 200 y 201.

Artículo 63.- *El Servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieren adeudarse.*

El Jefe de la Oficina respectiva del Servicio podrá citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo. A solicitud del interesado dicho funcionario ampliará este plazo, por una sola vez, hasta por un mes. Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de las respectivas oficinas.

Cuando del tenor de la respuesta a la citación o de los antecedentes aportados resulte necesario solicitar al contribuyente que aclare o complemente su respuesta y, o presente antecedentes adicionales respecto de los impuestos, períodos y partidas citadas, podrá requerírsele para que así lo haga, dentro del plazo de un mes, sin que ello constituya una nueva citación. Los antecedentes requeridos en el ejercicio de esta facultad y que no fueren acompañados dentro del plazo indicado serán inadmisibles como prueba en el juicio, en los términos regulados en el inciso duodécimo del artículo 132 de este mismo Código.

La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 4° del artículo 200 respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella.

La citación se trata de la instancia formal de fiscalización. Vimos que inicialmente algún algoritmo de una alerta sobre un potencial error en la declaración, y el SII hace un llamado, el cual no constituye una citación formal con sanción en caso de no ir. Se trata más bien de un aviso al contribuyente, para que éste asista al SII y aporte los antecedentes solicitados. Si no va, no hay consecuencias jurídicas, a diferencia de lo que pasa cuando no se acata una citación formal.

La no concurrencia o la falta de notificación, no trae consecuencias jurídicas ni para el sujeto jurídico activo y pasivo. Distinto es el caso de la citación, que es un acto formal que ha de ser notificado por carta certificada al domicilio (y normalmente se emite además copia de la misma en la página del contribuyente).

Notificada que sea la citación, desde la fecha de la notificación, hay un mes de plazo para contestar dicha citación al jefe de la unidad respectiva. Dicha respuesta ha de ser por escrito, que es una formalidad clave.

El CT no señala que la respuesta deba ser por escrito, pero en la práctica sería una irresponsabilidad enorme, por los efectos procesales de la falta de respuesta a la citación.

El contribuyente deberá ser capaz de probar (1) el origen de los fondos y (2) la disponibilidad de los mismos, aportando antecedentes sustentatorios para ello. A juicio del profesor, es en la respuesta a la citación donde el contribuyente se las debe jugar por el todo, y “tirar toda la carne a la parrilla”, al punto de que será prácticamente idéntico a un eventual recurso de reclamo, apelación e incluso casación. En definitiva, lo que se responda es la columna de toda la defensa del contribuyente.

(2) El **objetivo** de la citación es que:

1. Se presente una declaración si no lo ha hecho y está obligado de ello.
2. Modifique la declaración por una incongruencia detectada por el SII.
3. Aclaración.
4. Ampliación.
5. Confirmación.

(3) El **plazo** de contestación es un plazo administrativo de meses (un mes), prorrogaba *hasta* un mes adicional. Esto es, se puede prorrogar por menos de un mes. La prórroga solo se podrá dar una sola vez. La facultad de prorrogar corresponde al Director Regional.

(4) En cuanto a los **efectos** de la citación, podemos mencionar los siguientes:

1. De no contestarse, el SII se encuentra habilitado para tasar la base imponible con los antecedentes que tenga en su poder. En virtud del art. 64, todas las transacciones pueden tasarse por su justo valor de mercado. Por el art. 63, se permite entonces tasar ante la no respuesta.

La tasación consiste en determinar el valor justo de una transacción. Dicho concepto ha ido variando, pero su norma matriz es el art. 64. Además hay una especie de tasaciones más específicas para operaciones determinadas, como precios de transferencias (art. 41E LIR);³⁸ los art. 36-37 y 17 LIR. Todas estas normas especiales emanan de la norma matriz del art. 64.

2. De no presentarse los antecedentes, habiendo sido solicitados en la citación, no se podrán hacer valer como medios probatorios posteriormente en juicio por reclamo tributario.

³⁸ Los precios de transferencia son un concepto dentro del concepto madre de tasación, y consiste en determinar el justo valor de una transacción entre partes relacionadas, cuando la transacción es cross-border. La relación no es necesariamente patrimonial, sino que también puede ser producto de un acuerdo patrimonial. Por ejemplo, Bayer Alemania vende aspirinas a Bayer Chile a un precio que no es de mercado; por las normas del art. 41E el SII puede tasar. El principio del SII se llama Armred Length Basis, en virtud del cual se estima que el precio debiese ser el que se habría cobrado entre dos partes no relacionadas. El precio de venta podría ser mayor o menor que el justo precio, porque las partes quieren buscar generar una pérdida o bien una utilidad: igualmente, el SII tasaré el precio.

El SII puede instruir que se acompañen antecedentes adicionales, cuando ello *se estime que resulte necesario* de la respuesta o los antecedentes aportados. Habrá un plazo de 1 mes, sin que ello constituya una nueva citación. Ahora, ¿si no constituye una nueva citación, el hecho de no acompañar esos antecedentes adicionales hace precluir el derecho del contribuyente para acompañarlos en un eventual juicio tributario? Pereira no tiene la respuesta a esto. El art 132 establece que de no acompañar la información sustentatoria que *específicamente* se pidió en la citación, no se puede presentar como medio de prueba en el juicio tributario, salvo la inexistencia de la información en el momento de la citación o fuerza mayor.

3. Aumento del plazo de prescripción de la acción de fiscalización, que se amplía en 3 meses (unir al art. 200 y 201). Esto se sumará a la prórroga que haya solicitado el contribuyente, es decir, podemos llegar a un plazo de prescripción de hasta 3 años y 4 meses, o 6 años y 4 meses.

La prescripción se aumentará solo respecto de los puntos incluidos en la citación.

Por lo tanto, cuando un fiscalizador está redactando una citación, debe solicitar antecedentes específicos, pues de lo contrario el contribuyente podrá alegar la nulidad de la misma por la falta de especificación, y además la prescripción.

Habría posibilidad de reformular la citación en la medida que se esté dentro del plazo de prescripción.

(5) La citación es un medio de fiscalización, pero por regla general es un **medio facultativo** del SII (el art. 63 dice “podrá citar”). Sin embargo, existen muchos casos en que éste trámite de fiscalización es obligatorio para el SII, como antecedentes de sustento de una liquidación o reliquidación. Es decir, en estos casos el SII no podría efectuar una liquidación si no ha mediado citación. En general, estas normas parten con el enunciado “previo al trámite establecido en el art. 63”. Algunos de dichos casos son:

1. Art. 22 CT.

***Artículo 22.-** Si un contribuyente no presentare declaración, estando obligado a hacerlo, el Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, podrá fijar los impuestos que adeude con el solo mérito de los antecedentes de que disponga.*

2. Art. 21 inc. 2 CT.

El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. En tal caso, el

Servicio, previos los trámites establecidos en los artículos 63 y 64 practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando la base imponible con los antecedentes que obren en su poder. Para obtener que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero.

Cuando los antecedentes presentados no sean fidedignos, antes de liquidar, el SII debe citar al contribuyente. “Antecedentes no fidedignos”, sentido y alcance:

- No es sinónimo de falsificación o antecedente incompleto. La falsedad habilitaría al SII para ampliar la prescripción desde la ordinaria hasta la extraordinaria (art. 200 inc. 2).

El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos, constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto.

La falsedad apunta a un actuar doloso del contribuyente, lo que lo distingue de la expresión del art. 21 de antecedente no fidedigno.

- Apunta a que estos documentos no han sido preparados ni presentados de acuerdo a las instrucciones impartidas por el SII, fundamentalmente a través de resoluciones exentas. En ese sentido, la declaración se podría presentar escrita en una servilleta, pero sería un caso evidente de citación por antecedente no fidedigno.

3. Art. 27 inc. 2

Cuando para otros efectos tributarios sea necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o de gastos y el contribuyente no esté obligado a llevar una contabilidad separada, el Servicio pedirá a éste los antecedentes que correspondan, haciendo uso del procedimiento contemplado en el artículo 63°. A falta de antecedentes o si ellos fueren incompletos, el Servicio hará directamente la separación o prorrateo pertinente.

Por ejemplo, tenemos ingresos de 5M afectos, 2M exentos, y un gasto de 3M. Por este artículo, si el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad y sea necesario separar o prorratear ingresos y gastos, el SII debe citarlos para que expliquen la forma de dicha separación o prorrateo. Esto se aplicará justamente en los casos de ingresos afectos y otros exentos.

Si miramos nuestro ejemplo, no podemos identificar el gasto claramente con uno u otro tipo de ingreso: no se sabe a cuál ingreso están relacionados/identificados. Si se tuviese claridad a

ese respecto, no se tendría que concurrir al prorrateo, sino que se aplicaría el 100% de esos gastos al 100% de los ingresos.

No siendo posible la identificación, se imputa a ambos proporcionalmente.

Puede pasar que un contribuyente de IVA sea a su vez generador de rentas afectas a IVA (generador de débito fiscal), y a su vez generador de rentas no afectas a IVA. Por ejemplo, una oficina de profesionales que se dedique a prestar asesoría legal, pero a su vez son comisionistas (la que lleva IVA, a diferencia de los servicios profesionales).

Asumamos que dicho contribuyente tiene un crédito fiscal. Si éste se identifica en un 100% con la generación del débito fiscal, se puede imputar todo el crédito por el débito. Cuando no sea posible dicha identificación, el crédito se puede imputar con el prorrateo (proporcionalidad del crédito fiscal en el IVA). El requisito para poder imputar el 100% es que se tenga claridad absoluta a nivel de causa efecto respecto de la generación del débito fiscal en base al crédito fiscal.

Así:

- Crédito fiscal se identifica completamente con el débito, se utiliza el 100% de él.
- Si el crédito fiscal está identificado en un 0% al débito fiscal, se utiliza el 0% del crédito, porque no está vinculado en absoluto a la generación del débito.
- No habiendo identificación certera, se recurre al prorrateo.

4. Art. 41 E No. 2 sobre los precios de transferencia. Se refiere a las transacciones entre partes relacionadas y se debe respetar el precio de mercado.

5. Art. 69 inc. 4. Se vincula al término de giro de oficio por inactividad del contribuyente. Cuando el SII observa esta inactividad, sin realizar declaraciones, podría decretar el término de giro previa citación para que el contribuyente explique su inactividad.

El término de giro podría implicar el pago de altos impuestos, como el Impuesto Único de 35% sobre todas las utilidades tributables retenidas al término del giro (art. 38 y 38 bis LIR). Luego, el término de giro probablemente irá acompañada de una liquidación para efecto del impuesto único.

6. Art. 4 quinquies, en casos de simulación. Este artículo refiere a la elusión y evasión tributaria. Para poder recalificar una operación con todos sus efectos tributarios, que son justamente los impuestos que se hubieran gatillo de no incurrir en fraudes o abusos a la ley, el SII deberá determinar cuáles hubieran sido esos impuestos, previa citación.

Cada vez que llegue un cliente con una liquidación, lo primero que debemos analizar es si es que acaso la liquidación es de aquellos casos en que la citación era obligatoria. Si tal era el caso y no se citó, consiste en una potente defensa para dejar sin efecto la liquidación.

2.2 Obligaciones accesorias de contribuyentes y terceros

Desde los art. 72 al 92, se tratan obligaciones tributarias accesorias que están establecidas para ayudar al proceso de la fiscalización. Estas obligaciones no son solo para el contribuyente, sino que también para las municipalidades (e.g tasación de bienes raíces, para efectos de las contribuciones), bancos, notarías, etc...

1. **Artículo 88.-** *Estarán obligadas a emitir facturas las personas que a continuación se indican, por las transferencias que efectúen y cualquiera que sea la calidad del adquirente:*

1°.- Industriales, agricultores y otras personas consideradas vendedores por la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; y

2°.- Importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas.

No obstante, cuando estos contribuyentes tengan establecimientos, secciones o departamentos destinados exclusivamente a la venta directa al consumidor, podrán emitir, en relación a dichas transferencias, boletas en vez de facturas. Asimismo, tratándose de contribuyentes de difícil fiscalización, la Dirección podrá exigir que la boleta la emita el beneficiario del servicio o eximir a éste de emitir dicho documento, siempre que sustituya esta obligación con el cumplimiento de otras formalidades que resguarden debidamente el interés fiscal y se trate de una prestación ocasional que se haga como máximo en tres días dentro de cada semana. Por los servicios que presten los referidos contribuyentes de difícil fiscalización, no será aplicable la retención del impuesto prevista en el número 2 del artículo 74 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando la remuneración por el total del servicio correspondiente no exceda del 50% de una unidad tributaria mensual vigente al momento del pago.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores y en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicio, la Dirección podrá exigir el otorgamiento de facturas o boletas respecto de cualquier ingreso, operación o transferencia que directa o indirectamente sirva de base para el cálculo de un impuesto y que aquélla determine a su juicio exclusivo, estableciendo los requisitos que éstos documentos deban reunir.

Asimismo, la Dirección podrá exigir la emisión de facturas especiales o boletas especiales en medios distintos del papel, en la forma que establezca mediante resolución.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por facturas y boletas especiales aquellas distintas de las exigidas en el Título IV del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

La Dirección determinará, en todos los casos, el monto mínimo por el cual deban emitirse las boletas. Estos documentos deberán emitirse en el momento mismo en que se celebre el ingreso que motiva su emisión, y estarán exentos de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

En aquellos casos en que deba otorgarse facturas o boletas, será obligación del adquirente o beneficiario del servicio exigir las y retirarlas del local o establecimiento del emisor.

Este es uno de los artículos más relevantes, que hay que vincular con la Ley IVA. Establece la obligación de emitir boletas o facturas según el caso. Todo contribuyente de IVA que quiera aprovechar el crédito fiscal deberá exigir factura. Dijimos que es una obligación accesoria de hacer, esto es, de emitir factura o boleta. El hecho de no dar boleta o factura está fuertemente sancionado en el CT. Tanto es así, que en el art. 97 No. 4 (y No. 10 en algunos casos), se establece que de haber repetición dentro del plazo de prescripción ordinaria, se configura un delito tributario.

Los requisitos formales de facturas y boletas se contemplan en la Ley IVA y su reglamento. Un contribuyente no dará boleta o factura probablemente cuando ha conseguido comprar el producto sin soportar el débito fiscal.

El inciso final también es relevante, pues un ciudadano podrá ser multado por el solo hecho de no exigir la boleta o factura (art. 97 No.19).

2. El art. 68, en su última parte.

Los contribuyentes deberán poner en conocimiento de la Oficina del Servicio que corresponda las modificaciones importantes de los datos y antecedentes contenidos en el formulario a que se refiere el inciso anterior.

Los contribuyentes deberán poner en conocimiento del SII la modificación de derechos sociales. Por ejemplo, cuando sale un socio, se deberán informar las condiciones de dicha salida, el precio de venta de esos derechos, etc... Todo para establecer si el precio es o no razonable. Lo mismo en el caso de los accionistas: si se han vendido o no acciones. Los contribuyentes deberán informar al SII el cambio que se produzca en los accionistas.

3. Art. 69 inc. 4, disminución de capital.

No podrá efectuarse disminución de capital en las sociedades sin autorización previa del Servicio. También se deberá dar este aviso en el caso de las disminuciones de capital o cuotas de fondos de inversión o en general patrimonios de afectación.

4. Art. 70, disolución de sociedades.

Artículo 70.- *No se autorizará ninguna disolución de sociedad sin un certificado del Servicio, en el cual conste que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus tributos.*

5. Art. 66.

Artículo 66.- *Todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Unico Tributario de acuerdo con las normas del Reglamento respectivo.*

El art. 66 es de carácter potencial, “que puedan quedar afectas a impuesto”.

Debemos ligar el art. 66 con el art. 68 y 69. El art. 66 cobra relevancia al momento de obtener RUT; el art. 68 cuando se inicien actividades; y el art. 69 al término del giro.

La obtención del RUT no necesariamente debe ir aparejada al inicio de actividades. El SII pasa ambos formularios juntos, pero no es una obligación para todo contribuyente iniciar actividades.

6. Iniciación de actividades.

La iniciación de actividades se trata de una declaración jurada, a la cual se está obligado por realizar determinadas actividades. Está íntimamente vinculado a rentas descritas en la LIR, y son los casos del

- Art. 20 No. 1A
- Art. 20 No. 3
- Art. 20 No. 4
- Art. 20 No. 5
- Art. 42 No. 2
- Art. 48

El plazo para iniciar actividades es de 2 meses a contar de aquél mes en que se iniciaron las actividades en la práctica. Luego, si se inician actividades el 3 de abril, el plazo no es hasta el

3 de junio, sino que hasta el 30 de junio. Con la sola iniciación de actividades, el SII inscribe automáticamente en todos los registros vinculados al código de actividad que indique el contribuyente. Por lo mismo, se descarta la teoría administrativa que mencionamos como criterio para distinguir impuestos directos e indirectos, pues la inscripción en Chile es automática tanto para impuestos directos como indirectos; para el registro de rentas como para el de IVA. Por ejemplo, si se trata de un código vinculado a la venta de artículos de escritorio, automáticamente aparte del tema renta, quedará vinculado al tema IVA.

***Artículo 68.-** Las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera y segunda categorías a que se refieren los números 1°, letra a), 3°, 4° y 5° de los artículos 20, contribuyentes del artículo 34 que sean propietarios o usufructuarios y exploten bienes raíces agrícolas, 42 N° 2° y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deberán presentar al Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquél en que comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación. El Director podrá, mediante normas de carácter general, eximir de presentar esta declaración a contribuyentes o grupos de contribuyentes de escasos recursos económicos o que no tengan la preparación necesaria para confeccionarla, o bien, para sustituir esta exigencia por otros procedimientos que constituyan un trámite simplificado. Los contribuyentes favorecidos con esta facultad podrán acogerse a la exención o al régimen simplificado dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la resolución respectiva, aun cuando no hayan cumplido oportunamente con la obligación establecida en este artículo, no siéndoles aplicable sanción alguna en ese caso. Sin embargo, el contribuyente beneficiado con esta eximición o sustitución podrá, optativamente, efectuar la declaración común de iniciación de actividades a que se refiere la primera parte de este inciso.*

El art. 68 inmediatamente nos remite a la LIR. El IDPC lo vamos a asociar a las rentas del capital (donde el empleo del capital prima sobre el trabajo físico o intelectual); y en el caso del IDSC, se refiere al caso de las rentas del trabajo *independiente*.

En el IDPC, las rentas sobre las cuales se debe iniciar actividades son:

(1) Art. 20 No.1A - La explotación de bienes raíces.

El art. 34 mencionado se refiere a la renta presunta agrícola,³⁹ si no se tributa por medio de renta efectiva según balance (contabilidad completa).

La tributación afecta a los bienes raíces desde dos ópticas. En primer lugar, desde la explotación del bien raíz, por la venta de los frutos que se produzcan. Este caso se grava con IDPC porque está descrita en el art. 20 (y art. 34), y son rentas ordinarias. En segundo lugar, desde la enajenación del bien raíz, por ese mayor valor en la enajenación.

³⁹ Se trata de un porcentaje del avalúo fiscal del bien raíz. No se está presumiendo el impuesto, sino que de la base imponible.

- (2) **Art. 20 No.3 y 4.** Son los casos de actividades comerciales, industriales, minería, pesca (en general, industria extractiva); y en el no. 4, bancos, seguros, aerolíneas, constructoras, agentes aduaneros, corredores determinados, etc....
- (3) **Art. 20 No.5.** Si la renta no está en otra categoría (IDSC), o exenta, o declarada como ingreso no renta, cae en el No. 5. Es luego el bolsón para rentas que no caigan en una categoría específica, el “imán”, en palabras de Pereira.

5°.- Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas.

Debemos recordar que las franquicias y exenciones deben interpretarse de manera restrictiva.

- (4) **Art. 42 No. 2.** Rentas del trabajador independiente. Por propia disposición legal, lo remite al IGC.
- (5) **Art. 48.** Podrá ser relevante donde está domiciliado o reside el director, pues en el caso de que existe un tratado de DTI con Chile y toca el punto de dietas de directores, podría implicar una carga inferior al 35% de IA, que es lo normal para estos casos (o IGC, en su caso).

ARTICULO 48°.- *Las participaciones o asignaciones percibidas por los directores o consejeros de las sociedades anónimas quedarán afectas a los impuestos del Título III o IV, según corresponda.*

El art. 20 No. 2 LIR se refiere a las rentas de capitales mobiliarios, y no lo incluimos en el listado anterior porque no se está obligado a iniciar actividades. Lo que se recibirá por las transacciones será un certificado de, por ejemplo, Copec por las acciones compradas; o un certificado del banco por el interés recibido. Es decir, (1) serán los terceros quienes estarían obligados a informar tanto a los contribuyentes como al SII por las rentas que reciban éstos por sus capitales mobiliarios. (2) Luego, como contribuyente no se está obligado a llevar contabilidad. (3) Por no estar obligado a la contabilidad, no se está obligado tampoco a hacer PPMs (como mecanismo de financiamiento del IDPC consistente en pagos mensuales). (4) Tampoco se determinará Capital Propio Tributario (CPT) (activos menos pasivos, + ajustes). (5) Finalmente, como consecuencia de ello, no se paga patente municipal basado en un porcentaje del CPT (que es un impuesto al patrimonio). Quedaría afecto a la patente municipal mínima de 1 UTM anual, lo que es un gasto necesario.

Las distintas 5 consecuencias anteriores se siguen la una de la otra.

Las rentas de capital por valores mobiliarios tributan sobre una base percibida (o atribuida en determinados casos), pero no devengadas. Será percibida si y solo si el contribuyente no desarrolla actividades descritas en los otros numerales del art. 20. De lo contrario, *se contamina el principio de tributación* (el “sida tributario”) y se tributará sobre base devengada, atribuida o percibida (porque al desarrollar esas otras actividades deberá llevar contabilidad -renta efectiva determinada según balance-, y se sabrá si el contribuyente ha aumentado su patrimonio dentro del año contable).

Ya vimos contribuyentes del art. 14 A y 14B. Pero los hay también del art. 14C, que son los de renta presunta, o los que no están obligados a llevar contabilidad, y además los pequeños contribuyentes (e.g por normas PYMES). De los que no están obligados a llevar contabilidad, sería el caso de las rentas de capitales mobiliarios. El 14C establece que se tributará de acuerdo a las normas del art. 14A. Eso significa que una sociedad, que no lleva contabilidad porque su giro exclusivo es la compra y venta de valores mobiliarios, deberá tributar su utilidad como renta atribuida. Los socios deberán incorporar todas las rentas de la sociedad que les corresponderían por atribución, en su global complementario.

Luego, el lado positivo será que no se paga patente municipal; pero por el otro lado, se tributará como renta atribuida.

7. Término del giro.

La primera parte del art. 69 contiene lo que es el término de giro “tradicional”, mientras que la segunda parte contiene el “nuevo” término por falta de actividad.

Se trata del aviso que da el contribuyente dentro de los dos meses siguientes al término de sus actividades. Podemos diferenciarlo del plazo para iniciar actividades: aquí no se cuenta desde el mes, sino que desde el día efectivo en que cesan las actividades que generan impuestos. Luego, si se cesa en actividades el 3 de abril, se tiene hasta el 3 de junio para dar el aviso.

El término de giro no es sino una declaración jurada que hace el contribuyente.

Pereira estima conveniente señalar en qué consisten el conjunto de obligaciones accesorias que implica este aviso de término de giro. El término de giro no se limita a la presentación de la declaración jurada, sino que hay un conjunto de obligaciones accesorias que acompañan a este aviso. Dicho conjunto, más el aviso en si mismo (que también es una obligación accesorias), podría resultar en la obligación principal: el pago de impuestos por el contribuyente que cesa en actividades.

Una cosa es el aviso de término de giro, y otra cosa distinta es la auditoría de término de giro. Esta distinción es propia de Pereira, porque otros autores confunden ambas cosas. No todo

aviso de término lleva aparejada una auditoría de término de giro. Por tanto, hay situaciones en que la propia ley dispone que uno podría diferir, postergar, la auditoría final de término de giro.

Esta auditoría es un proceso de fiscalización intensa, quizás la más intensa porque es la última posibilidad del SII de cobrar impuestos de ese contribuyente por las actividades que cesan. Luego, es un proceso que puede durar años, sin perjuicio del plazo legal, dada su importancia.

Tanto en el aviso de término propiamente tal como en el aviso de término oficioso hay otras obligaciones accesorias que se deben cumplir conjuntamente con la obligación accesoria de dar aviso (en el mismo plazo). En aviso propiamente tal se divide en el aviso y en la auditoría.

Estas otras obligaciones consisten esencialmente en acompañar balance de término de giro. Luego, se debe acompañar el balance al aviso, y eventualmente pagar los impuestos que se adeudan.

Artículo 69.- *Toda persona natural o jurídica que, por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecta a impuestos, deberá dar aviso por escrito al Servicio, acompañando su balance final o los antecedentes que éste estime necesario, y deberá pagar el impuesto correspondiente hasta el momento del expresado balance, dentro de los dos meses siguientes al término del giro o de sus actividades.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71°, las empresas individuales no podrán convertirse en sociedades de cualquier naturaleza, ni las sociedades aportar a otra u otras todo su activo y pasivo o fusionarse, sin dar aviso de término de giro. Sin embargo, no será necesario dar aviso de término de giro en los casos de empresas individuales que se conviertan en sociedades de cualquier naturaleza, cuando la sociedad que se crea se haga responsable solidariamente en la respectiva escritura social de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa individual, relativos al giro o actividad respectiva, ni tampoco, en los casos de aporte de todo el activo y pasivo o fusión de sociedades, cuando la sociedad que se crea o subsista se haga responsable de todos los impuestos que se adeudaren por la sociedad aportante o fusionada, en la correspondiente escritura de aporte o fusión. No obstante, las empresas que se disuelven o desaparecen deberán efectuar un balance de término de giro a la fecha de su extinción y las sociedades que se creen o subsistan, pagar los impuestos correspondientes de la Ley de la Renta, dentro del plazo señalado en el inciso primero, y los demás impuestos dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la responsabilidad por otros impuestos que pudieran adeudarse.

Cuando con motivo del cambio de giro, o de la transformación de una empresa social en una sociedad de cualquier especie, el contribuyente queda afecto a otro régimen tributario en el mismo ejercicio, deberán separarse los resultados afectados con cada régimen tributario sólo

para los efectos de determinar los impuestos respectivos de dicho ejercicio.

Claramente la norma distingue entre lo que es la obligación de dar aviso y la auditoría. Podemos señalar entonces que hay casos en los que a pesar de que se está poniendo término a las actividades, el CT autoriza a que no se realice la auditoría de término de giro (según la interpretación de Pereira). Esto porque habrá otro contribuyente que responderá dentro de los plazos de prescripción por los impuestos adeudados por el contribuyente que cesa en actividades. Estos casos son los de:

1. Cuando una empresa individual se convierte en una sociedad de cualquier naturaleza.

La empresa individual es distinta del empresario individual o EIRL. La empresa individual consiste en la persona natural que inicia actividades, y acompaña en el propio formulario un balance inicial con determinados activos. Respecto de ese patrimonio que conforma la contabilidad de la ficción de la empresa individual, pasará a tributar como si fuese una sociedad, esto es, con el IDPC.

Por ejemplo, Pedro tiene una oficina que arrienda, una caja por 50M, y acciones del Banco de Chile. El arriendo de esa oficina está afecta a IDPC, por ser renta derivada de una explotación de bien raíz (art. 20 -y eventualmente art.34- LIR). Pero esa renta también sigue siendo una renta que recibe una persona natural domiciliada o residente en Chile, que paga IGC. Pero por el sistema integrado, ese crédito de IDPC se imputa contra el IGC.

La caja le produce intereses, porque los tiene en depósitos a plazo. Esos depósitos están exentos de IDPC, pero afectos a IGC.

Finalmente, el dividendo va al global complementario de Pedro. Pero esa renta pagó IDPC, por lo que existe crédito.

En nuestro ejemplo, el IGC está llegando a una tasa efectiva del 35%. Es aquí donde la figura del empresario individual podría ser relevante. Digamos que asigna la oficina y las acciones a su empresa individual.

En la cadena de propiedad entre Banco de Chile y Pedro, hay un eslabón que es la empresa individual. Pero esa empresa es la misma que Pedro, es el mismo RUT porque no hay separación patrimonial. Lo que se busca con la empresa individual es diferir el GC. El dividendo de Banco de Chile va a caer en la contabilidad de la empresa individual, y esa contabilidad tributa con IDPC. Pero como esa renta ya pagó IDPC, entra como renta exenta, y solo está pendiente el impuesto final. Mientras Pedro no retire para su uso o consumo ese dividendo (y pasa lo mismo con las rentas de la oficina), no se gatilla el IGC

porque no ha percibido esa renta.

Perfectamente en esa empresa individual se podría tributar sobre base atribuida, pero eso no haría ningún sentido porque sería lo mismo que no haber constituido la empresa individual. Luego, la empresa se acogerá probablemente al art. 14B, base devengada. Ahora, sobre el art. 14B, se podría llegar a tributar hasta un 44,45%.

Las utilidades que se quedan en la contabilidad de la empresa individual, pueden ser perfectamente reinvertidas.

Cabe remarcar que en contabilidad, siempre es preferible diferir el pago del impuesto; esa es la fundamentación de la empresa individual.

La recomendación de Pereira es que la persona tenga dos cuentas corrientes; una para los gastos personales y otra para la empresa individual. Ninguna norma exige esto, pero facilitará enormemente el tema probatorio al momento de una eventual fiscalización, y para distinguir los ingresos. Cuando exista una transferencia de una cuenta a la otra, se entenderá que se gatilla el IGC (con o sin IDPC).

¿Por qué simplemente no hacer una SpA estipulando que las acciones pueden estar reunidas todas en una sola mano? El problema es que aquí si hay una separación de patrimonios formal, y el aporte que se haga es una enajenación en sentido lato, que se deberá hacer a valor de mercado, lo que probablemente gatillará impuestos. El SII argumentará que como se hizo una transferencia a otra persona, no se puede simplemente aportar a su costo reajustado, sino que a su valor de mercado, y hay una renta (incremento patrimonial). Ese aporte se le paga a Pedro con las acciones de la sociedad; jurídicamente se está verificando una dación en pago, de acuerdo al valor de mercado.

Esto no ocurre en la empresa individual porque en ella se puede asignar activos sin generar rentas, al costo de adquisición reajustado. Todo esto porque “nadie se puede vender a si mismo”. La tentación, al pasar el activo, era hacer un “step-up”: pasarlo al valor de mercado, y no a su costo reajustado. Por ejemplo, la oficina de Pedro costaba 100M. Al “crear” la empresa individual, la tentación sería hacer el step up y pasar la oficina a su valor de mercado actual (200M), lo que generaría una renta de 100M pero que no estaría tributando.

La jurisprudencia tributaria ha indicado que en la empresa individual no hay que pagar tributo en la medida que el traspaso del activo no se haga al valor de mercado (step up). Es decir, en la medida que no haya un abuso de la asignación a la contabilidad. De lo contrario, estaría perdiendo la posibilidad de gravar los 100M extra que se estaban ganando.

Hay que recordar en todo esto que el SII puede entrar a tasar conforme al justo valor de mercado.

La contabilidad no fidedigna constituye un delito de mera actividad; por eso que las empresas individuales no sean un mecanismo para evadir o eludir impuestos, sino solo para diferir.

2. Cuando una sociedad aporta a otra todos sus activos y pasivos: aporte del patrimonio. Se trata del caso de una fusión “perfecta” o “línea a línea”.
3. Fusión de sociedades, cuando se trata de fusión “imperfecta”, que es la que se produce por el solo ministerio de la ley por reunirse el 100% de las acciones en una mano, que no es una fusión “propia tal”. Cabe remarcar que se puede estipular en las SpA que la sociedad no se disuelve por reunirse todas las acciones en una sola mano; de lo contrario, opera supletoriamente la Ley de Sociedades Anónimas.

En estos tres casos anteriores, la primera entidad deja de desarrollar su giro y lo sigue desarrollando la segunda entidad. La sociedad nueva, en el caso de la empresa individual, o la sociedad absorbente. El requisito fundamental para que no exista a la auditoría de término de giro en estos casos es que la nueva sociedad se haga cargo, responsable, en la escritura respectiva,⁴⁰ del pago de todos los impuestos que adeude la nueva entidad.

Esta es la denominada “cláusula de responsabilidad solidaria”. Por eso no se va a una auditoría profunda, porque hay un contribuyente que responde, dentro de los plazos de prescripción. Esta cláusula no libera a la entidad que desaparece de la obligación de declarar el término de actividades y de confeccionar el balance de término de giro; pero la subsistente, deberá pagar los impuestos que la que dejó de existir dejó pendiente, dentro del plazo de 2 meses.

Se ha dicho que el débito fiscal es *intuitu personae*, luego, intransferible a la nueva entidad. Hay nueva jurisprudencia que ha dicho lo contrario. Lo mismo ocurre con la pérdida tributaria.

En resumen, como no se salta el aviso, pero se posterga la auditoría, Pereira distingue estas distintas obligaciones accesorias.

Además de estas 3 situaciones anteriores, el art. 69 se refiere a la transformación de sociedades. La transformación para efectos tributarios se define en el art. 8 No.13,

⁴⁰ En el caso de la empresa individual, no existe dicha escritura. El SII llegará a cobrarle a la persona natural, quien deberá señalar la existencia de esta empresa individual.

entendiendo por tal el cambio de especie o tipo social (naturaleza jurídica), por reforma de estatuto y permaneciendo la personalidad jurídica.

Ha habido una evolución respecto a lo anterior. Una posición decía que se extinguía la antigua sociedad, y nacía una nueva (e.g se extingue la SRL y nace la SA), por lo que se requeriría término de giro. La otra posición decía que el nuevo tipo social era el absoluto continuador legal de la antigua, sin cambiar la personalidad jurídica. Para evitar problemas, en la práctica sería mejor poner la cláusula de responsabilidad solidaria, sin perjuicio de que hoy es aparentemente claro de que no se requiere el término de giro (segunda postura).

Hay interpretaciones del SII para determinar la antigüedad de acciones o derechos, para distinguir que antes de transformarse era acción y no derecho, o vice versa; antes, había una diferencia sobre el gravamen de la utilidad en la venta de acciones o bien derechos. Por lo tanto, al cambiar a una SA, habría una adquisición de acciones, que no existían antes, porque solo habían derechos sociales. Luego, es mejor incorporar la cláusula solidaria para evitar problemas.

¿Qué pasa si la transformación conlleva a un cambio en el régimen tributario? Por ejemplo, hay una SRL con solo socios persona naturales, sujeta por opción al régimen de renta presunta del art. 34 (se presume que la base imponible era el 10% del avalúo fiscal del predio), y se transforma en SA. El art. 69 indica que se debe confeccionar balance hasta antes de la transformación, sobre el cual se tributará conforme al régimen antiguo; y en el nuevo balance se tributará conforme al nuevo sistema.

Luego, se divide el año comercial en dos balances (1 de enero - hasta fecha de la transformación); y el impuesto se pagará el 30 de abril del año siguiente. Esto está en el art. 69 inc. 3.

Término de giro de oficio (inc. 5)

Si el Servicio cuenta con antecedentes que permiten establecer que una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica, ha terminado su giro o cesado en sus actividades sin que haya dado el aviso respectivo, previa citación efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, podrá liquidar y girar los impuestos correspondientes, en la misma forma que hubiera procedido si dicha persona, entidad o agrupación hubiere terminado su giro comercial o industrial, o sus actividades, según lo dispuesto en el inciso primero.

Es un caso de citación obligatoria.

(continúa art. 69) No podrá efectuarse disminución de capital en las sociedades sin autorización previa del Servicio. También se deberá dar este aviso en el caso de las

disminuciones de capital o cuotas de fondos de inversión o en general patrimonios de afectación.

En tales casos, los plazos de prescripción del artículo 200 se entenderán aumentados en un año contado desde que se notifique legalmente la citación referida, respecto de la empresa, comunidad, patrimonio de afectación o sociedad respectiva, así como de sus propietarios, comuneros, aportantes, socios o accionistas.

El ejercicio de la facultad a que se refiere el inciso quinto procederá especialmente en los casos en que las personas y entidades o agrupaciones referidas, que estando obligadas a presentar declaraciones mensuales o anuales de impuesto u otra declaración obligatoria ante el Servicio, no cumpla con dicha obligación o, cumpliendo con ella, no declare rentas, operaciones afectas, exentas o no gravadas con impuestos durante un período de dieciocho meses seguidos, o dos años tributarios consecutivos, respectivamente. Asimismo, esta norma se aplicará en caso que, en el referido período o años tributarios consecutivos, no existan otros elementos o antecedentes que permitan concluir que continúa con el desarrollo del giro de sus actividades.

Cuando la persona, entidad o agrupación presente 36 o más períodos tributarios continuos sin operaciones y no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá reclamarse de acuerdo a las reglas generales. El Servicio deberá habilitar un expediente electrónico con los antecedentes del caso incluyendo la constancia de no tener el contribuyente deuda tributaria vigente, en la forma y plazos señalados en el artículo 21.

3. Giro

El giro no es sino una orden de pago, por medio de un documento dirigido al contribuyente. Se gira cuando ha existido una reliquidación de la obligación tributaria como consecuencia de un proceso de fiscalización. Si no ha mediado la fiscalización, la autodeterminación constituye a su vez un giro.

¿Cuándo está facultado el SII para emitir un giro?

1. Transcurrido el plazo que tiene el contribuyente para reclamar. El contribuyente tiene un plazo de 90 días de la liquidación efectuada por el SII. Transcurrido este plazo, por el art. 124, el SII puede emitir un giro.

En este plazo de 90 días, también podría el contribuyente deducir el recurso administrativo RAV (antes, RAF).

2. Cuando se ha dictado sentencia de primera instancia en el reclamo tributario, rechazándolo.

Cabe destacar que no es obligatorio pagar para poder apelar, porque el contribuyente puede solicitarle a la CAA la suspensión del cobro ejecutivo mientras esté pendiente la causa ante los tribunales superiores. Hay que tener cuidado, porque la comunicación entre el SII y TGR es muy rápida, que se manifiesta en un embargo sobre las cuentas corrientes pocos días después de que se dicte la sentencia. Luego, inmediatamente hay que tener que solicitar la suspensión.

3. Dentro del plazo del contribuyente para interponer el reclamo (90 días), el contribuyente pide el giro y lo paga. Esto será porque (i) está de acuerdo con la liquidación y se quiere ahorrar reajustes e intereses moratorios (art. 53), o (ii) porque quiere tener más tiempo para analizar la estrategia judicial. Lo anterior porque si se paga dentro del plazo, dicho plazo se extiende por 1 año desde la notificación de la liquidación. Así, se ahorra los reajustes e intereses, mientras se prepara el recurso.

Artículo 24.- *A los contribuyentes que no presentaren declaración estando obligados a hacerlo, o a los cuales se les determinaren diferencias de impuestos, el Servicio les practicará una liquidación en la cual se dejará constancia de las partidas no comprendidas en su declaración o liquidación anterior. En la misma liquidación deberá indicarse el monto de los tributos adeudados y, cuando proceda, el monto de las multas en que haya incurrido el contribuyente por atraso en presentar su declaración y los reajustes e intereses por mora en el pago.*

Salvo disposición en contrario, los impuestos determinados en la forma indicada en el inciso anterior y las multas respectivas se girarán transcurrido el plazo de noventa días señalado en el inciso 3° del artículo 124°. Sin embargo, si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán notificado que sea el fallo pronunciado por el Tribunal Tributario y Aduanero. Para el giro de los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación, dichos impuestos y multas se establecerán provisionalmente con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación. A petición del contribuyente podrán también girarse los impuestos con anterioridad a las oportunidades señaladas en el inciso anterior.

En los casos de impuestos de recargo, retención o traslación, que no hayan sido declarados oportunamente, el Servicio podrá girar de inmediato y sin otro trámite previo, los impuestos correspondientes sobre las sumas contabilizadas, como también por las cantidades que hubieren sido devueltas o imputadas y en relación con las cuales se haya interpuesto acción penal por delito tributario. En caso que el contribuyente se encuentre en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor, el Servicio podrá, asimismo, girar de inmediato y sin otro trámite previo, todos los impuestos adeudados por el deudor, sin perjuicio de la verificación que deberá efectuar el Fisco en conformidad con las normas generales.

Las sumas que un contribuyente deba legalmente reintegrar, correspondientes a cantidades respecto de las cuales haya obtenido devolución o imputación, serán consideradas como impuestos sujetos a retención para los efectos de su determinación, reajustes, intereses y sanciones que procedan, y para la aplicación de lo dispuesto en la primera parte del inciso anterior.

4. Impuestos de traslación o recargo (propio de los impuestos indirectos), o impuestos de retención. Así, el IVA, el IDSC por rentas del trabajador dependiente. Cuando el contribuyente no haya declarado oportunamente, el SII puede girar de inmediato el impuesto. Es decir, no requiere de liquidación previa. No se está discutiendo si se debe o no cobrar el impuesto, lo que está claro, porque el contribuyente ya ha retenido dicha cantidad que es del Fisco, y solo falta que la pague.

Por ejemplo, tenemos Coca Cola Chile, controlada por Coca Cola USA. Coca Cola Chile mantiene contratos de royalty con Embotelladora Andina S.A. Coca Cola Chile tiene una relación de propiedad con Coca Cola USA, pero además podría tener un royalty (por ejemplo, por la fórmula secreta), que en nuestro caso será un 4% de las ventas anuales. Ese royalty paga el IA del art. 59 porque se trata de una remesa por una renta de fuente Chile. La LIR declara expresamente que las regalías corresponden a una renta de fuente chilena (revisar art. 10 y 11 LIR).

¿Podría este royalty pagar IVA? El art. 8 de la Ley IVA establece que el uso o goce de derechos de propiedad se consideran como un servicio. Sin embargo, como esta renta está afectada al pago de IA del art. 59, no puede estar afectada a IVA.

Para Coca Cola Chile, ese 4% es un gasto necesario para producir la renta, porque se trata de una porción que no puede disponer por disposición legal (en este caso, la ley entre las partes). Sin embargo, el art. 31 N° 12 establece límites para lo que se puede descontar como gasto en operaciones entre partes relacionadas.

En el caso de Coca Cola Chile con Andina SA, ocurre lo mismo, hay un royalty (digamos 5%). Aquí, Coca Cola lo que hace es marginar, se queda con un 1% de utilidad (5%-4%). Esa renta paga IDPC, y se remesa a USA pagando IA de 35%, reteniendo un 8% (por el crédito de 27%). Coca Cola USA tratará de pagar usando un tax credit de 35%, que fue el impuesto total independiente de que parte se pagó con un crédito.

A diferencia del caso de USA, con Andina SA no hay una operación con parte relacionada, por lo que no hay límite para el descuento que se pueda hacer por esa regalía que paga, que es un gasto necesario.

Como Coca Cola Chile ya cobró la regalía a Andina con IVA, el SII podría emitir el giro si no se enteró el impuesto. Es decir, si Coca Cola Chile retuvo y no enteró, el SII puede emitir un giro de inmediato sin liquidación previa.

5. Caso de la Ley N° 20.720, nueva Ley de Quiebras.

6. Facultad de tasación en el art. 64 inc. final.

El SII puede tasar en la venta de inmuebles, cuando el precio sea notoriamente al inferior a los corrientes en plaza, y se puede girar de inmediato. En ese sentido, si es que llega a haber un reclamo, recaería en este caso sobre los elementos fundantes de un giro.

En igual forma, en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al valor comercial de los inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el Título II del Libro Tercero.

7. En cualquier momento a petición del contribuyente. El contribuyente podría percatarse de que le faltó pagar algo, y en vez de exponerse a una eventual fiscalización, podría pedir giro.

»» Con la declaración, liquidación y giro, termina la determinación de la obligación tributaria.

EFFECTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

EFFECTOS RESPECTO DEL FISCO

1. Derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación tributaria.

Se hará efectivo mediante el procedimiento ejecutivo de cobro, cuando la obligación no se cumple oportunamente o íntegramente (art. 168 y ss.)

2. Derecho a que se le indemnicen perjuicios, que se traduce en la obligación de pagar intereses (art. 53 - 56).

En estricto derecho, este efecto se traduce en la facultad de cobrar intereses, porque el reajuste es la protección de la inflación entre el periodo en que se debió enterar el impuesto en arcas fiscales y la fecha efectiva de pago. El Fisco, entonces, no está ganando y el cobro de intereses obedece al costo alternativo de no tener los recursos en tiempo y forma, es decir, le cobra al contribuyente el uso de su dinero.

¿Cómo se reajusta? Los impuestos se reajustan por la variación del IPC entre el último día del segundo mes que precede el vencimiento del impuesto, y el último día del segundo mes que precede al mes del pago de los impuestos. Por tanto, si el vencimiento es al 30 de abril, y se paga el 16 de agosto, el reajuste irá desde el 28 de febrero al 30 de junio.

¿Qué interés se cobra? Se cobra un 1.5% mensual por cada mes o fracción de mes de atraso en el pago de impuesto. En el mismo caso anterior, son 4 meses de interés moratorio, porque abril no se cuenta, toda vez que el 30 de abril era el último día de plazo para pagar.

Cuando un impuesto vence en día sábado, 31 de diciembre o feriado, la fecha de vencimiento se prorroga automáticamente al día hábil siguiente. Si no se paga en el plazo prorrogado, para ver cuál es el mes de vencimiento, se toma en cuenta la fecha de vencimiento primitivo, y no se considera la fecha de prórroga legal, por lo tanto se pagarán reajustes e intereses. Por ejemplo, si el 30 de abril era domingo, se prorroga legalmente al 2 de mayo (1 es feriado); si se paga el 25 de mayo, se pagan reajustes e intereses por las normas generales, y no se puede alegar que se pagó dentro del mismo mes del vencimiento.

Condonación. El art. 56 es uno de los más importantes de carácter recaudatorio. La facultad de condonar intereses (y multas) se reduce al pago del impuesto: el pronto pago tiene beneficios. Podría suceder que un contribuyente no tenía plata para pagar los impuestos, en cuyo caso podrá explicar las circunstancias de aquello al SII. Si no tiene antecedentes previos, y si su justificación es apropiada, el SII podría condonarle la deuda por concepto de intereses.

Artículo 56.- La condonación parcial o total de intereses penales sólo podrá ser otorgada por el Director Regional cuando, resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio

practicada por el Servicio, a través de una liquidación, reliquidación o giro, el contribuyente o el responsable del impuesto probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido.

Procederá también la condonación de intereses penales cuando, tratándose de impuestos sujetos a declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos, voluntariamente, formule una declaración omitida o presentare una declaración complementaria que arroje mayores impuestos y probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido.

En los casos en que el Servicio incurriere en error al girar un impuesto, el Director Regional deberá condonar totalmente los intereses hasta el último día del mes en que se cursare el giro definitivo.

El Director Regional podrá, a su juicio, condonar la totalidad de los intereses penales que se hubieren originado por causa no imputable al contribuyente.

Solo se pueden condonar intereses y multas, jamás un impuesto. El reajuste tampoco se puede condonar, porque es impuesto.

El único que puede condonar es el Director Regional, porque está a cargo de la unidad operativa a la que corresponde el contribuyente, es decir “conoce al contribuyente”. La mayor cantidad de condonación es a micro y pequeños empresarios.

También puede condonar el Subdirector de Fiscalización y el Subdirector de Grandes Contribuyentes. Asimismo, las condonaciones también pueden ser otorgadas por TGR, y ahí el contribuyente tiene que ver quién le da la mejor condonación. Pero en ningún caso puede condonar el Director Nacional.

Resoluciones exentas del SII han establecido criterios para determinar el porcentaje de la condenación, que pueden llegar al 100%. Condonar el 100% puede ser obligatorio, cuando el no pago ha sido culpa del SII.

Devolución de impuestos (art. 57).

Artículo 57.- Toda suma que se ordene devolver o imputar por los Servicios de Impuestos Internos o de Tesorería por haber sido ingresada en arcas fiscales indebidamente, en exceso, o doblemente, a título de impuestos o cantidades que se asimilen a estos, reajustes, intereses o sanciones, se restituirá o imputará reajustada en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del segundo mes que precede al de su ingreso en arcas fiscales y el último día del segundo mes anterior a la fecha en que la Tesorería efectúe el pago o imputación, según el caso. Asimismo, cuando los tributos, reajustes, intereses y sanciones se hayan debido pagar en virtud de una reliquidación o de una liquidación de oficio practicada por el Servicio y reclamada por el contribuyente, serán devueltos, además, con intereses del medio por

ciento mensual por cada mes completo, contado desde su entero en arcas fiscales. Sin perjuicio de lo anterior, Tesorería podrá devolver de oficio las contribuciones de bienes raíces pagadas doblemente por el contribuyente.

El Fisco devuelve el exceso del impuesto pagado o cantidades que se asimilan a impuestos (PPMs), de manera reajustada con la misma regla para el reajuste del pago del impuesto. En determinados casos, se devuelve con interés del 0,5% por mes completo (no por fracción), cuando el exceso se ha pagado por una reliquidación de oficio. El contribuyente pagó esa diferencia, pero reclamó y ganó el juicio.

Derechos auxiliares del acreedor

Los derechos auxiliares del acreedor no están tratados específicamente, pero se aplicarían por las reglas generales en virtud del art. 2 CT (prenda general, acción oblicua o subrogatoria, acción pauliana), y el art. 148 en caso de materias judiciales.

EFFECTOS RESPECTO DE LOS CONTRIBUYENTES

1. Obligación de pagar sus impuestos
2. Derecho a que le indemnicen los perjuicios.

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

1. EL PAGO DE UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO

Es el medio normal de extinción, y se hace normalmente en moneda de curso legal de Chile. El Director Regional podría exigir que el impuesto se pague en la misma moneda en que se realizan las operaciones del contribuyente. Tal es el caso de los exportadores.

Debemos recordar que cuando se lleva la contabilidad en moneda extranjera, evita tener que hacer la corrección monetaria. Llevar contabilidad en moneda chilena puede generar pérdida o utilidad por el tipo de cambio.

***Artículo 18.-** Establécense para todos los efectos tributarios, las siguientes reglas para llevar la contabilidad, presentar las declaraciones de impuestos y efectuar su pago:*

1) Los contribuyentes llevarán contabilidad, presentarán sus declaraciones y pagarán los impuestos que correspondan, en moneda nacional.

2) No obstante lo anterior, el Servicio podrá autorizar, por resolución fundada, que determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes lleven su contabilidad en moneda extranjera, en los siguientes casos:

a) Cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo justifique.

b) Cuando su capital se haya aportado desde el extranjero o sus deudas se hayan contraído con el exterior mayoritariamente en moneda extranjera.

c) Cuando una determinada moneda extranjera influya de manera fundamental en los precios de los bienes o servicios propios del giro del contribuyente.

d) Cuando el contribuyente sea una sociedad filial o establecimiento permanente de otra sociedad o empresa que determine sus resultados para fines tributarios en moneda extranjera, siempre que sus actividades se lleven a cabo sin un grado significativo de autonomía o como una extensión de las actividades de la matriz o empresa.

Dicha autorización regirá desde el primer ejercicio del contribuyente, cuando éste lo solicite en la declaración a que se refiere el artículo 68, o a partir del año comercial siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, en los demás casos.⁴¹

⁴¹ Antes de existir esta última norma, cuando durante el ejercicio se producían variaciones en el tipo de cambio, todos corrían a pedir la autorización, para obtener utilidades o pérdidas.

Los contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en este numeral deberán llevar su contabilidad de la forma autorizada por a lo menos dos años comerciales consecutivos, pudiendo solicitar su exclusión de dicho régimen, para los años comerciales siguientes al vencimiento del referido período de dos años. Dicha solicitud deberá ser presentada hasta el último día hábil del mes de octubre de cada año. La resolución que se pronuncie sobre esta solicitud regirá a partir del año comercial siguiente al de la presentación y respecto de los impuestos que corresponda pagar por ese año comercial y los siguientes.

El Servicio podrá revocar, por resolución fundada, las autorizaciones a que se refiere este número, cuando los respectivos contribuyentes dejen de encontrarse en los casos establecidos en él. La revocación regirá a contar del año comercial siguiente a la notificación de la resolución respectiva al contribuyente, a partir del cual deberá llevarse la contabilidad en moneda nacional.

Esta autorización será otorgada siempre que, además de cumplirse con las causales contempladas por este número, en virtud de ella no se disminuya o desvirtúe la base sobre la cual deban pagarse los impuestos.

Por ejemplo, CMPC lleva su contabilidad en pesos chilenos. Invierte 100M de dólares en una planta llamada Pañales do Brasil, a un tipo de cambio de \$600. Es decir, invirtió 60.000.000.000 de pesos. Si el dólar sube a \$700, esa inversión se traduce en 70,000,000,000, es decir, hay una utilidad de 10,000,000,000 de pesos afectas a IDPC solo por concepto de tipo de cambio. Si en cambio hubiera una pérdida, le serviría para netearla contra las utilidades de CMPC en Chile.

CMPC podría crear una filial, cuya contabilidad esté en dólares, e invertir a través de ella. Es decir, traspasa los 60,000,000,000 de pesos por acciones de la filial, y la filial aporta los 100M dólares.

También podría suceder que una empresa tenga todo su pasivo expresado en moneda extranjera.

Según el plazo para pagar, los impuestos son anuales o mensuales; los mensuales se pagan el día 20 del mes siguiente, mientras que los anuales se pagan el mes de abril del año siguiente. El plazo puede ser prorrogado de manera general por el Presidente de la República.

Si el plazo vence en día sábado o feriado, se prorroga para el día hábil siguiente.

Hoy, la mayoría de los casos se paga por transferencia electrónica a la Cuenta Única Nacional que mantiene TGR en el Banco del Estado. Esta cuenta no tiene límite para que los demás bancos le hagan transferencia. Se podría pagar también en dinero, o por cheques, vale vistas, letras bancarias, etc..

Cuando se paga con cheque, vale vista, etc... se debe identificar claramente al reverso el impuesto qué se está pagando y por qué periodos.

El pago se podría enviar por correo, en cuyo caso la carta debe entregarse al correo con 3 días de anticipación al vencimiento del plazo, para entenderse que se pagó dentro de plazo.

Hoy, el SII y TGR no reciben pagos, y dirigen a los contribuyentes a un banco. El impuesto se paga en los bancos e instituciones financieras autorizadas al efecto por decreto del Min. Hacienda.

Los artículos 38 al 49 refieren a detalles vinculados al pago de la obligación tributaria. Un tema que interesa destacar, es el del art. 47, que refuerza la idea de que pagos atrasados también se pagan en instituciones financieras autorizadas al efecto. El procedimiento a seguir es el siguiente:

Procedimiento para pagos atrasados

1. El contribuyente se dirige presencialmente o por medio virtual a la TGR para que se “actualice” la deuda. TGR calculará el reajuste, intereses y multas si procedieran. Generalmente el pago con retraso sigue a la condonación de intereses y multas: hay un incentivo para que las personas efectúen un pronto pago de la obligación atrasada, que es que se les condenará en general una parte importante de la deuda (70% automático en la mayoría de los casos).

El interés que cobra el Fisco por atraso es mayor que el interés que cobra el banco por pedir un préstamo. Es decir, es más conveniente cancelar el pago atrasado antes con un crédito del banco, en vez de exponerse a un eventual 18% anual de intereses.

2. El banco es un mero recaudador, que recibe el pago.

Pago parcial del impuesto

Artículo 50.- En todos los casos los pagos realizados por los contribuyentes por cantidades inferiores a lo efectivamente adeudado, por concepto de impuestos y recargos se considerarán como abonos a la deuda, fraccionándose el impuesto o gravamen y liquidándose los reajustes, intereses y multas sobre la parte cancelada, procediéndose a su ingreso definitivo en arcas fiscales.

Los pagos referidos en el inciso anterior, no acreditarán por sí solos que el contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ni suspenderán los procedimientos de ejecución y apremio sobre el saldo insoluto de la deuda.

Ejemplo. Se adeuda 1M por impuesto, 2M por reajuste y 3M por intereses. El contribuyente solo tiene 3M para pagar. Aquí volvemos a la teoría de la proporcionalidad. El pago se aplicará proporcionalmente a cada uno de los montos. Sobre los 6M de deuda, se identificará 1/6 a impuestos, 2/6 a reajustes, y 3/6 a intereses. Así, la deuda quedará en 500,000 por impuestos, 1M

por reajuste, y 1,5M por intereses. Se tiene una **nueva deuda** por los saldos. Sobre ese nuevo monto de impuesto se realizarán los nuevos reajustes e intereses.

2. LA COMPENSACIÓN

Aquí nos referimos al concepto civil de compensación. Para que proceda la compensación en materia tributaria se tienen que cumplir los requisitos propios del derecho común.

Art. 1655. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.

Art. 1656. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes:

1a. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad;

2a. Que ambas deudas sean líquidas;

3a. Que ambas sean actualmente exigibles.

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.

1. Deudores y acreedores recíprocos.
2. Ambas deudas son actualmente exigibles.
3. Se extinguirán las deudas recíprocamente hasta concurrencia de sus valores.

Hay 4 casos de compensación propiamente tal, y 2 casos discutidos en doctrina.

Casos de compensación propiamente tal

1. Art. 51 inc. 1.

Artículo 51.- Cuando los contribuyentes no ejerciten el derecho a solicitar la devolución de las cantidades que corresponden a pagos indebidos o en exceso de lo adeudado a título de impuestos, las Tesorerías procederán a ingresar dichas cantidades como pagos provisionales de impuestos. Para estos fines, bastará que el contribuyente acompañe a la Tesorería una copia autorizada de la resolución del Servicio en la cual conste que tales cantidades pueden ser imputadas en virtud de las causales ya indicadas.

Aquí el fisco adeuda al contribuyente cantidades que éste ha pagado en exceso, por concepto de impuestos. El contribuyente puede solicitar que esas cantidades se le imputen al cumplimiento de

otras obligaciones tributarias.

Esto debemos unirlo con el plazo para solicitar la devolución de los impuestos pagados en exceso, que es de 3 años⁴² contados desde que se realizó el pago (art. 126). Si dentro de dicho plazo se pide la devolución, y el SII “resuelve” que ha lugar la devolución, en ese minuto el contribuyente está habilitado para solicitar la compensación. Es decir, la compensación necesariamente requiere de una resolución administrativa del SII que accede a la devolución de impuestos solicitada dentro de plazo. La solicitud debe estar fundada principalmente en lo que dispone el art. 126.

2. Art. 51 inc. 2

Igualmente las Tesorerías acreditarán a petición de los contribuyentes y de acuerdo con la norma del inciso anterior, una parte o el total de lo que el Fisco les adeude a cualquier otro título. En este caso, la respectiva orden de pago de tesorería servirá de suficiente certificado para los efectos de hacer efectiva la imputación.

Este caso es aquel en que el Fisco debe al contribuyente una suma por una causa distinta de la relación tributaria. Es perfectamente posible que el Fisco y los particulares tengan relaciones de comercio y servicio, por ejemplo el caso de Pinturas Tricolor que vende pintura al Min. Hacienda. Si el Fisco adeudara una suma por concepto de ese contrato, el contribuyente puede pedir que se compense. Para que esto sea posible, el contribuyente debe tener en su poder el documento **orden de pago**, que lo emite el Fisco o la entidad fiscal deudora, y que ordena pagar la deuda. Con este documento, se puede concurrir a TGR para pedir la compensación.

3. Art. 51 inc. penúltimo - Compensación de oficio

Las cantidades que correspondan a pagos indebidos o en exceso, a título de impuestos, podrán ser imputadas de oficio por el Servicio a la cancelación de cualquier impuesto del mismo período cuyo pago se encuentre pendiente, en los casos que se dicte una ley que modifique la base imponible o los elementos necesarios para determinar un tributo y ella dé lugar a la rectificación de las declaraciones ya presentadas por los contribuyentes.

Jurídicamente, cancelar es dar por extinguida una obligación, lo que no necesariamente se hace por el pago (sino por operar cualquier modo de extinguir la obligación). Luego, el inciso, al usar la palabra cancelación, se refiere a la compensación.

La compensación de oficio requiere 4 elementos:

- Se dicte una ley que modifique la base imponible, o los elementos necesarios para determinar el

⁴² Antiguamente era un plazo de 1 año.

impuesto

- Que esta ley permita rectificar declaraciones de impuestos ya presentadas

- Que como resultado de estas rectificaciones, se constaten impuestos indebidos o pagados en exceso por el contribuyente.

- Que el contribuyente esté adeudando impuestos por el mismo periodo tributario comprendido por las rectificaciones permitidas por ley.

Podrá suceder que el SII no devuelva el exceso, aun cuando se haya solicitado, sino que compense de oficio con la deuda.

4. Compensación en el reclamo tributario, art. 127.

***Artículo 127.-** Cuando el Servicio proceda a reliquidar un impuesto, el interesado que reclame contra la nueva liquidación dentro del plazo que corresponda de conformidad al artículo 124, tendrá además derecho a solicitar, dentro del mismo plazo, y conjuntamente con la reclamación, la rectificación de cualquier error de que adolecieren las declaraciones o pagos de impuestos correspondientes al período reliquidado.*

Se entenderá por período reliquidado para el efecto del inciso anterior, el conjunto de todos los años tributarios o de todo el espacio de tiempo que comprenda la revisión practicada por el Servicio.

La reclamación del contribuyente en que haga uso del derecho que le confiere el inciso 1° no dará lugar, en caso alguno, a devolución de impuestos, sino que a la compensación de las cantidades que se determinen en su contra.

El contribuyente, al reclamar contra una liquidación del SII, pide que se compensen aquellas cantidades pagadas en exceso dentro del periodo reliquidado con aquellas cantidades que el SII le está cobrando producto de esta liquidación.

Por ejemplo, en octubre el SII hace una liquidación por el mes de abril del año anterior, por 1,5M. El contribuyente reclama dentro del plazo y solicita que se le compense 1,5M que pagó en exceso con ese 1,5M liquidado por el SII.

Cuando existía el plazo de 1 año para solicitar la devolución, y ya había pasado 1 año desde que se pagó en exceso, esta norma permitía ampliar dicho plazo. Hoy día podría suceder que me estén liquidando un impuesto por uso de la prescripción extraordinaria, habiendo caducado el plazo de 3 años para solicitar el impuesto pagado en exceso, y se recupere la posibilidad de pedir la devolución por medio de pedir la compensación. Pero, solo procede la compensación, no la

devolución, por lo que la cantidad que exceda a la primera, se perderá.

La norma del art. 127 se refiere al plazo de 90 días para hacer interpuesto el reclamo. Es decir, tenemos que unir el art. 127 con el art. 124 (90 días o 1 año cuando se paga, para reclamar) y con el art. 126 (que se refiere al plazo de 3 años para solicitar la devolución de impuestos pagados en excesos). Si estoy dentro de los 3 años, no estoy obligado a solicitar la compensación en la reclamación. Pero si estoy en el año 4, recupero el derecho a solicitar la devolución via compensación en el reclamo tributario.

Casos discutidos

Algunos autores precisan la operación de la compensación; no es que la nieguen derechamente.

1. Sistema de PPMs. Art. 84 y ss. LIR

Se trata de un pago provisional mensual, es decir, un mecanismo de financiamiento del impuesto, que no es un impuesto en si mismo. El CT, en el art. 97 *asimila* el no pago de un PPM estando obligado a hacerlo, con el no pago de un impuesto de retención, como una medida ejemplificadora (el art. 97 castiga fuertemente el no pago de un impuesto de retención). Ello no significa que estemos frente a un impuesto.

Por ejemplo, se forma una sociedad para poner un restaurante. En la escritura de constitución, se le dará un poder al abogado para obtener RUT, iniciar actividades, represente ante el SII, etc...

Si esta sociedad tuviese un socio extranjero, él le tendría que entregar al abogado poder con las “cláusulas tributarias”: sacar RUT, iniciar actividades, representación, etc... Además tendría la “cláusula cambiaria” que permite registrar su inversión extranjera en Chile. El banco que reciba el pago desde el extranjero (el aporte de capital) deberá imputar esa remesa a un determinado giro, informando al Banco Central. También se requiere de la “cláusula bancaria”, que da poder para que se solicite la liquidación de la moneda extranjera en pesos chilenos y se deposite luego el producto en la cuenta de la nueva sociedad chilena.

Sobre el PPM, la pregunta es con qué PPM parte esta sociedad. Será un 1% de sus ingresos. Siempre los ingresos son más que las rentas; al año 2 de actividad, se reajustará por medio de una fórmula, que tome los ingresos brutos del año 1 con la realidad de las rentas obtenidas en dicho periodo. Se reajustará la fórmula año a año para modificar el monto del PPM que deberá pagar la sociedad año a año para financiar el IDPC.

Luego, esa sociedad podría estar en una situación de estar pagando menos PPM o más del que corresponde. En esa situación de pagar más, se podría solicitar la devolución del exceso. Es interesante notar que si se cae en una situación de pérdida tributaria, se podría suspender el pago de PPM, y volver a la tasa de 1% sobre los ingresos.

Los ingresos que se toman en consideración son los del giro ordinario de este contribuyente. Luego, si soy una empresa agrícola, consideraré ingresos por venta de uva, lana, ganado, etc... Pero para efectos de los PPMs no voy a considerar los ingresos por la venta eventual de la máquina cosechadora, pues no es parte de mi giro agrícola. Ese ingreso será extraordinario y no se colaciona para los efectos del cálculo de ingresos que determinará el PPM.

Algunos autores discutían que se pudiese dar una la compensación. Pereira estima que la discusión no tiene mucho sentido en la práctica. Imaginemos que un contribuyente paga PPMs por los primeros meses del ejercicio, y en el segundo semestre revierte completamente el escenario de débito fiscal, y llega a pérdida. En abril del próximo año, la situación será probablemente de devolución. Eso ha dado pie para que algunos autores digan que en esa situación, solo sería deudor el Fisco, que deberá devolver los PPMs que se pagaron para financiar el IDPC.

Otros dicen que al no ser el PPM impuesto, no sería una deuda propiamente tal para el fisco. Este argumento es más débil, porque la ley obliga a pagar PPM sin perjuicio de no ser impuesto.

ARTICULO 84°.- *Los contribuyentes obligados por esta ley a presentar declaraciones anuales de Primera y/o Segunda Categoría,⁴³ deberán efectuar mensualmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales que les corresponda pagar, cuyo monto se determinará en la forma que se indica a continuación:*

a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20,⁴⁴ que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29. El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base del promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio indicado, sin considerar el reajuste del artículo 72.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

⁴³ El “y/o IUSC” refiere a trabajadores independientes, que también pagan PPMs (las retenciones en la boleta).

⁴⁴ Como vemos, no está el No. 2: rentistas de valores mobiliarios, que no deberán hacer PPMs.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se considerarán, para estos efectos, como ingresos brutos. En el caso de prestación de servicios, no se considerarán entre los ingresos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa;

2. Compensación en el caso del IVA.

Por ejemplo, el contribuyente paga 1M al comprar y soporta el IVA (\$190,000), anotando este último en su libro de compra y venta en la figura de crédito fiscal. El mismo contribuyente vende 3M y recarga el IVA. Al hacer la declaración mensual del IVA, debe al Fisco el impuesto recargado en el mismo periodo en que este contribuyente soportó IVA en sus compras, como contribuyente de hecho. Este IVA que soporta es debido al contribuyente por el Fisco, al ser un crédito fiscal (cuenta por cobrar del contribuyente - cuenta por pagar del Fisco). Luego, dichas cantidades se compensan y se paga solo la diferencia.

Lo que se ha discutido es que aquella parte no cubierta por el crédito no tiene con que compensarse, y sería solo débito fiscal. Sería solo una compensación parcial, hasta el tope del crédito fiscal.

3. PRESCRIPCIÓN⁴⁵

La prescripción está tratada a propósito de (i) la acción de fiscalización para determinar diferencias de impuestos y (ii) la acción de cobro.

La acción de fiscalización se plasma en un acto administrativo que es la liquidación del impuesto.

La acción de cobro se traduce en el cobro ejecutivo de la obligación tributaria por parte de TGR por un procedimiento reglado por el propio código, y cuyo título ejecutivo es la lista de deudores

⁴⁵ Recordar que es importante manejar la regulación de la prescripción en el derecho común, en virtud del **art. 2 CT** que es de suma importancia.

morosos. El primer trámite de la TGR será el requerimiento de pago. De no efectuarse el pago, se podrá trabar embargo sobre los bienes y llegar al remate. El contribuyente podrá oponer como excepción al requerimiento de pago la excepción de (i) pago, (ii) prescripción y (iii) no empecerle el título.

Algunos autores agregan como excepción la compensación, pero Pereira estima que no es una excepción propiamente tal al requerimiento de pago, pues para ser opuesta en el juicio ejecutivo, requiere de una resolución previa que es la orden de pago.

3.1 Acción de fiscalización

Prescribe ordinariamente en 3 años desde que legalmente se debió haber efectuado el pago. Esto tiene relevancia en los impuestos anuales, porque se puede producir un desfase entre año comercial y año tributario. La fecha relevante para dichos impuestos será el 30 de abril.

Prescribe extraordinariamente en 6 años, cuando no se presentó la declaración debiendo haberse hecho, o siendo la declaración obligatoria, la declaración fue maliciosamente falsa o incompleta. Ello implica la existencia de dolo, distinto del caso de antecedentes no fidedigno, que refiere a no seguirse las formas determinadas por el SII para la presentación.

En ambos casos de prescripción, se puede ampliar:

- Por la citación del art. 63, se amplía el plazo en 3 meses.
- Si se pide la prórroga para contestar la citación, se aumenta el plazo en igual tiempo (hasta 1 mes).
- Cuando el SII pide una aclaración en razón de la respuesta (art. 63 inc. 3).
- En el término de giro de oficio del art. 69, inc. 6, se podría ampliar incluso un año a contar desde la citación. Recordemos que la citación es obligatoria antes de liquidar y girar a la persona que ha cesado en actividades.

Art. 69 inc. 6 En tales casos, los plazos de prescripción del artículo 200 se entenderán aumentados en un año contado desde que se notifique legalmente la citación referida, respecto de la empresa, comunidad, patrimonio de afectación o sociedad respectiva, así como de sus propietarios, comuneros, aportantes, socios o accionistas.

Esta acción **no se interrumpe**.

3.2 Acción de cobro

Prescribe en los mismos plazos y mismas fechas que el caso de la prescripción administrativa. Pero en este caso, la acción **sí se interrumpe**. Los casos de interrupción son:

1. Cuando interviene reconocimiento u obligación escrita. En dicho caso, comienza a correr la prescripción de largo tiempo del art. 2515 (5 años).

2. Desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación. En este caso, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción de 3 años. Este nuevo término de 3 años solo se interrumpirá por reconocimiento u obligación escrita, o por el requerimiento judicial.
3. Desde que intervenga requerimiento judicial. Ello se traduce en la notificación del mandamiento de ejecución y embargo, que es el inicio formal del juicio ejecutivo del cobro de la obligación tributaria por del SII canalizado a través de la TGR.

Aquí ya se está ejerciendo la acción de cobro propiamente tal, más que se esté interrumpiendo.

3.3 Suspensión de la acción de fiscalización y de cobro

Ambas acciones se suspenden durante todo el tiempo en que el SII está impedido de girar los impuestos. Se trata de los casos en que el SII puede girar, pero interpretados a contrario sensu.

4. OTROS MODOS

Ya vimos los modos principales, pero podemos destacar otros:

1. Confusión

Se da en el caso del impuesto de herencia, cuando el Fisco es heredero de las obligaciones del causante.

2. Condonación

Sabemos que los intereses y multas son condenables, pero jamás los impuestos (por la vía administrativa). Sin embargo, se pueden condonar los impuestos por medio de una ley, en virtud de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En este proceso de cobranza tributaria ejercida por TGR, podría darse la situación en que TGR declare ciertas deudas tributarias como “incobrables” (por ejemplo, no le encontraron bienes al contribuyente), y las saca del listado de deudas. Dicha declaración como “incobrable” no debe ser confundida con una condonación, porque TGR puede hacer renacer el título ejecutivo, cambiando el status a “cobrable” en el minuto que aparezcan bienes suficientes para cobrarse. Es decir, la declaración de ser incobrable la deuda nunca queda firme y ejecutoriada, y el proceso de cobranza tributaria puede renacer.

3. Transacción

Algunos autores dicen que la ley no acepta este acuerdo. Sin embargo, ya hay un tipo de transacción dentro del reclamo tributario; es decir, no la hay a nivel extrajudicial. Todo esto no quita que en la práctica si se den las transacciones, por conveniencia para ambas partes.

En el reclamo tributario, el juez hace un llamado a una suerte de conciliación, por el art. 132 inc. 2:

Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya o no contestado el Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá llamar a las mismas a conciliación de conformidad al artículo 132 bis, citándolas para tales efectos a una audiencia oral. En dicha audiencia, el Juez Tributario y Aduanero propondrá las bases de arreglo, sin que las opiniones emitidas con tal propósito lo inhabiliten para seguir conociendo de la causa. La audiencia de conciliación se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Constituirán, para estos efectos, sesiones sucesivas, aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del Tribunal.

No es una transacción propiamente tal, porque en este caso el juez dictará la sentencia. Debe ser complementada con el art. 132 bis.

DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO (LIBRO III)

Es un área del derecho tributario que ha tenido una evolución importante, pues antes la jurisdicción en primera instancia recaía en el Director Regional, quien a su vez delegaba las funciones sin estar facultado legalmente para ello (era una cuestión fáctica, por una cuestión de la cantidad de causas que existían). Sin embargo, hubo un momento en que se pidió la nulidad de derecho público y fue concedida, que generó una avalancha de nulidades contra causas ya cerradas o en segunda instancia. Las que estaban pendiente de resolución en primera o segunda instancia fueron revestidas a su estado inicial. Ante esta situación, se revivió la discusión sobre una justicia tributaria autónoma.

Así, el 2009 surgen los TTA con la ley 20322. Se creó un TTA por cada región y 4 en Santiago, implementándose de manera gradual partiendo por las regiones extremas.

Uno de los objetivos entonces de la creación de los TTA era lograr la independencia de la judicatura. Precisamente, el problema del sistema antiguo era que el funcionario del SII se enfrentaba a la eventual situación de tener que fallar en contra de las propias interpretaciones administrativas del SII, que son vinculantes para los funcionarios. Es decir, se quería terminar con que el SII fuera juez y parte.

Un segundo objetivo era lograr tener una judicatura especializada en un tema legal y técnicamente complejo, sea en tema tributario o aduanero (competencia común). Ahora bien, las CAAs no tienen la especialización de los TTA.

COMPOSICIÓN DE LOS TTA

1. Juez

Es elegido por el Presidente de la República a partir de una terna presentada por cada CAA.

2. Secretario abogado del tribunal

Se elige de la misma forma que el juez.

3. Resolutor(es)

4. Profesional experto (contador auditor)

5. Funcionarios administrativos

6. Otros

Existe una unidad administradora para todos los TTA de Chile, a cargo de la parte administrativa (remuneraciones, suministros y abastecimiento, etc...). Esta unidad es parte del Ministerio de Hacienda.

RAV

El proceso tributario puede comenzar con el recurso de reposición administrativa voluntaria (RAV). Para los contribuyentes, es una reposición optativa que se presenta en sede administrativa.

Artículo 123 bis.- Respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley N° 19.880, con las siguientes modificaciones:

- a) El plazo para presentar la reposición será de treinta días.*
- b) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de noventa días contado desde su presentación.*
- c) La presentación de la reposición suspenderá el plazo para la interposición de la reclamación judicial contemplada en el artículo siguiente.*

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Los plazos a que se refiere este artículo se regularán por lo señalado en la ley N° 19.880.

La RAV se regula además en el art. 121 de la Ordenanza de Aduanas.

El contribuyente al que se le emite una liquidación o giro tiene 90 días para presentar el reclamo. Pero el legislador quería minimizar la judicialización, por lo que contempló la RAV, para poder llegar a una decisión no judicial.

Se presenta en contra de los mismos actos que son materia de un reclamo, que están indicados taxativamente en el art. 124. La RAV consagra el derecho de los contribuyentes de poder solicitar, antes de llegar al juicio, que la autoridad jerárquica de la entidad que emitió el acto administrativo revise el mismo, de forma tal que el mismo servicio la deje sin efecto o la modifique.

En la práctica, los RAV no suelen ser acogidas.

El objetivo de las RAV es que el propio servicio corrija los errores formales de la resolución, por ejemplo por defectos de la auditoría, o por no haberse ponderado la prueba, no darle valor a la contabilidad, etc...

Existe un **plazo** de 30 días hábiles administrativos⁴⁶ contados desde la notificación de la resolución que se impugna. Cabe destacar que dictada la liquidación o giro, nace un plazo administrativo y al mismo tiempo un plazo judicial (RAV y reclamo, respectivamente).

Si pasan 90 días de que se presenta la RAV, y el SII no se ha pronunciado, se entiende rechazada la RAV (teoría del silencio negativo).

Cabe destacar nuevamente que la RAV es voluntaria para el contribuyente, pero en caso de presentarse, siempre tiene que ser anterior al reclamo.

Presentada la RAV, se suspende el plazo para presentar el reclamo, lo que no siempre fue así (es una modificación reciente).

En definitiva, la RAV es un recurso administrativo, extraordinario y de revisión. Por lo mismo no proceden los recursos provistos en la ley 19.880.

La RAV apunta a los actos administrativos terminantes, esto es, liquidaciones y giro (este último en ciertos casos).

ACCIÓN DE NULIDAD

Desde noviembre de 2017, los TTA pueden conocer de las acciones de nulidad dirigidas en contra los mismos actos reclamables. Fue una aclaración legal necesaria, pues hasta entonces, habían TTAs que se declaraban incompetentes para conocer de una acción de nulidad, pues la ley de bases de los TTA no contemplaban la facultad de conocer de esas materias. Se producía el absurdo de que la causa pasaba a un tribunal civil, que no era especializado en derecho tributario. Luego, con la reforma se permite que los TTA concentren toda la competencia tributaria.

Esta nulidad tributaria es bastante *sui generis*, porque no es una nulidad de derecho público, según el propio proyecto de ley. La nulidad de derecho público opera de pleno derecho, es imprescriptible, insanable y puede ser declarada de oficio. En cambio, la nulidad tributaria solo se puede declarar a petición de parte, se debe haber afectado un requisito esencial con el vicio y se debe haber generado un perjuicio. Tampoco es una nulidad procesal, pues se reclama de un acto administrativo, ni una nulidad civil.

El efecto de la acción de nulidad en sede tributario no está contemplado por la ley. Pero se ha entendido que el efecto es retrotraer el procedimiento administrativo al momento en que se dictó el acto viciado. Por ejemplo, si se anula la liquidación, se deberá dictar una nueva. Con esto recupera importancia la prescripción de la acción de fiscalización y de cobro.

⁴⁶ Era un plazo de 15 días.

RECLAMO TRIBUTARIO

Equivale a la demanda civil, y procede contra determinados actos del SII, que se tratan de los mismos contra los que procede la RAV.

Artículo 124.- Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, siempre que invoque un interés actual comprometido. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

Son reclamables entonces

1. Liquidación, giros, pagos

Normalmente el giro accede a una liquidación, pero no necesariamente, y eso es importante pues el giro es reclamable cuando no fue precedido por una liquidación. Es decir, en general el giro no es reclamable cuando estuvo precedido de una liquidación, y la liquidación no se reclamó. Ello, porque si no se reclamó la liquidación, se entiende que tanto ella como su giro quedaron firmes.

Será en todo caso reclamable cuando haya una disconformidad entre el giro y la liquidación.

2. Resolución que deniegue la devolución pedida por el contribuyente

Sin embargo, cabe destacar que la solicitud de devolución no constituye reclamo. La solicitud se pide por medio del formulario F2117, y deben hacerse en el plazo de 3 años desde el pago.

3. Resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo.

Por ejemplo, una resolución que ordene rebajar la pérdida tributaria por no tenerla acreditada.

En ningún caso se podrá reclamar:

1. Resolución no reclamable, como la citación.
2. Actos que dicte el SII en su facultad de interpretación de la ley (art. 26). Cosa distinta es que un oficio o circular pueda ser argumento en un reclamo.
3. Peticiones de devolución (art. 126).⁴⁷

Para reclamar, se estima necesario que el contribuyente tenga un **interés pecuniario**.

Pago anticipado

Como ya hemos visto, el contribuyente, en el plazo para reclamar (90 días) puede pagar. Con eso, se evita pagar reajustes, intereses y multas, y además tendrá un año para reclamar.

Formalidades del reclamo

Se debe señalar

1. Nombre del reclamante
2. Fundamentos de hecho y derecho del reclamo
3. Acompañar los antecedentes fundantes del reclamo. Algunos estimaban que esto implicaba aportar toda la prueba, lo que no hace sentido porque hay un periodo probatorio.
4. Petitorio

Están contempladas en el art. 125. De faltar cualquiera, el tribunal pedirá que se subsanen. De no hacerse en el plazo, la liquidación o giro quedarán firmes.

Notificaciones

El sistema de notificaciones judiciales es diferente del sistema administrativo (separata). La regla general es la notificación por correo electrónico que consigna cada parte al inicio del proceso. A su vez, en la página de los TTA se cargan todas las actuaciones.

Por excepción, algunos actos, *además* de notificarse por correo electrónico, se notifican por carta certificada. Corresponden a las actuaciones más importantes:

1. La que declare inadmisibile el reclamo
2. La que notifica la interlocutoria de prueba

⁴⁷ A contrario, la resolución que niegue esa devolución, si es reclamable.

3. La sentencia
4. Notificaciones a terceros intervinientes, como los testigos.

Procedimiento (art. 132)

En todo aquello no previsto por el título III, se aplica supletoriamente el Libro I del CPC (art. 148). En la práctica, en los juicios tributarios se aplica todo el CPC, como el tema probatorio que está en el Libro II.

***Artículo 132.-** Del reclamo del contribuyente se conferirá traslado al Servicio por el término de veinte días. La contestación del Servicio deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero.*

Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya o no contestado el Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá llamar a las mismas a conciliación de conformidad al artículo 132 bis, citándolas para tales efectos a una audiencia oral. En dicha audiencia, el Juez Tributario y Aduanero propondrá las bases de arreglo, sin que las opiniones emitidas con tal propósito lo inhabiliten para seguir conociendo de la causa. La audiencia de conciliación se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Constituirán, para estos efectos, sesiones sucesivas, aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del Tribunal.

Vencido el plazo a que se refiere el inciso primero, cuando la conciliación o parte de ésta fuere rechazada, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra, sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba.

En los primeros cinco días del probatorio cada parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Se podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella.

Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por punto de prueba. El Tribunal Tributario y Aduanero dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información

pertinente sobre los hechos materia del juicio, debiendo señalarse específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el informe.

Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.

Los mismos plazos indicados en el inciso precedente regirán para los peritos, en relación a sus informes, desde la aceptación de su cometido.

El Director, los Subdirectores y los Directores Regionales no tendrán la facultad de absolver posiciones en representación del Servicio.

Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe.

No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El reclamante siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables, incluyendo el caso de haber solicitado al Servicio prórroga del plazo original para contestar la referida citación y ella no fue concedida o lo fue por un plazo inferior al solicitado.

El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia sobre esta inadmisibilidad.

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación.

La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad.

Vencido el término de prueba, y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Cumplido este plazo, se hayan o no presentado escritos, el Tribunal Tributario y Aduanero, a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación de conformidad al artículo 132 bis, citándolas para tales efectos a una audiencia en los términos del inciso segundo.

Si se rechaza la conciliación, existan o no diligencias pendientes, el Tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde que el Tribunal dicte la resolución a que se refiere el inciso anterior.

En resumen:

1. Se presenta reclamo
2. Se declara admisible
3. Se da traslado al SII para contestar en 20 días.
4. Vencido el plazo de contestación, el TTA debe llamar a conciliación de oficio o a petición de parte, incluso si no hubo contestación.

Esta es una norma nueva en materia tributaria, pues al legislador tributario le interesaba que cobrara el impuesto en el menor tiempo posible.

Hay materias conciliables y otras no.

5. Frustrada la conciliación, el TTA tiene que de oficio o petición de parte dictar el auto de prueba, que se notifica por carta certificada además del correo electrónico.
6. Apertura del probatorio, 20 días. Se debe acompañar lista de testigo dentro de los primeros 5 días, y en esos mismos 5 días se presenta recurso de reposición, con apelación en subsidio. La apelación se conoce en cuenta y no suspende.
7. Se admiten todos los medios de prueba. Sin embargo, los antecedentes solicitados por el SII en el proceso administrativo que no se presentaron no serán admisibles como medio de prueba. Sin embargo, el SII debe haber pedido precisamente estos documentos, y debe alegarlo en juicio.

8. No hay tachas a los testigos, y se admite un máximo de 4 por punto de prueba.
9. Estándar probatorio: sana crítica. El tribunal deberá siempre expresar por escrito las razones jurídicas, lógicas, de experiencia y ciencia por las cuales arriba a la conclusión.

Los actos y hechos solemnes solo podrán ser acreditados por la solemnidad legal.

10. Terminado el probatorio, existe un plazo de 10 días para realizar observaciones a la prueba, para que la parte explique al tribunal sobre el significado de cada una de las pruebas presentadas.
11. Terminado el plazo de 10 días, se abre una nueva etapa de conciliación, solo a petición de parte. El tribunal podrá aceptar o rechazarla.
12. Citación a oír sentencia. Después de esto no se podrán presentar documentos. Hay 60 días para dictar sentencia.
13. Se admite, a favor del SII, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos del contribuyente. La petición debe estar fundada, por ejemplo en que las facultades del contribuyente no ofrecen suficiente garantía o se sospeche está ocultando bienes.
14. Procede también la acción pauliana
15. Contra la sentencia se podrá recurrir:
 1. Rectificación, aclaración y enmienda
 2. Apelación y reposición. Hay plazo de 15 días ante el mismo TTA. Se pueden dirigir en contra de la resolución que declare inadmisibile un reclamo o haga imposible su continuación.
 3. Casación: solo procede contra la sentencia definitiva en segunda instancia, nunca contra la del TTA.
16. La apelación se verá en cuenta, salvo que se pidan alegatos.

Suspensión de cobro del giro

Cuando se dicta la sentencia condenatoria en primera instancia, el director regional queda desde ya facultado para girar el impuesto. El art. 147 permite solicitar a la CAA la suspensión de cobro del giro, y procede contra todos los impuestos salvo los de recargo y retención. No procede contra ellos, porque en ellos alguien actuó como retenedor de un impuesto ajeno (como el pagador de honorarios, que retiene el 10%).

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS

La ley 20.322 del 2009 creó este procedimiento especial, el “recurso de protección tributario”. Procede en contra de todo acto u omisión del SII cuando un particular considera vulnerado su derecho a desarrollar cualquier actividad económica (contemplada por el art. 19 No.21), la igualdad que debe dar el Estado en materia económica (art. 19 No.22) y el derecho de propiedad (No. 24).

Este procedimiento especial nos dice que se puede recurrir ante el TTA en cuya jurisdicción haya ocurrido el acto u omisión, siempre y cuando no sea una materia que la ley contemple en un procedimiento distinto. Está contemplado en los arts. 155 y ss y art. 129 k Ordenanza Aduanas.

Admisibilidad

La acción debe ser presentada por escrito en el plazo fatal de 15 días hábiles contados desde el acto u omisión, o desde que se haya tenido conocimiento cierto lo que deberá constar en autos.

El juez hará un examen de admisibilidad: plazo y fundamentos suficientes. Si adolece de manifiesta falta de fundamentos o ha sido presentada fuera de plazo, será declarada inadmisible por resolución fundada.

Tramitación

Se le dará traslado al SII por 10 días, y vencido el plazo, se abrirá un término probatorio de 10 días en caso de haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. La prueba se apreciará conforme a la sana crítica.

Sentencia

Vencido el término probatorio, el juez dictará sentencia en plazo de 10 días. El fallo contemplará todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Recursos

Solo procede el recurso de apelación en el plazo de 15 días, que se conocerá en cuenta y en forma preferente en la CAA, a menos que cualquiera de las partes pida alegatos en el plazo de 5 días desde el ingreso de los autos a la Secretaría de la Corte. Se podrá decretar una ONI en cualquier estado de tramitación.

Incompatibilidad con el recurso de protección

Si se interpone el recurso de protección a que se refiere el art. 20 de la CPR, no se puede recurrir en conformidad a estas normas.

Normas supletorias

Son las normas que regulan el reclamo tributario; por lo mismo, aplican también las normas del CPC.

PROCEDIMIENTOS INFRACCIONALES

La ley 20.322 no introdujo mayor modificación en los procedimientos para la aplicación de sanciones. Hay un procedimiento general en los arts. 161 y ss, y procedimientos especiales para la aplicación de ciertas sanciones.

En la práctica, el procedimiento general pasó a ser excepcional por la cantidad de procedimientos especiales que hay.

Procedimiento general

Las sanciones que no constituyan una sanción penal, son aplicadas por los TTA previo el cumplimiento de los trámites que veremos.

ACTA, NOTIFICACIÓN Y DESCARGO

Si se ha tomado conocimiento de una infracción o de haberse reunido los antecedentes que hagan verosímil su comisión, se levanta un acta timbrada por el funcionario competente del SII (fiscalizadores).

El acta se notificará personalmente o por cédula. El afectado tiene 10 días para formular sus descargos. En el escrito de descargos deberá además indicar con claridad y precisión los medios de prueba que piensa hacer valer. En las causas de cuantía igual o superior a 32 UTM, se requiere patrocinio y representación de mandatario judicial.

El art. 161 No.3 indica que estando pendiente el procedimiento, se pueden tomar las medidas conservativas necesarias para evitar que desaparezcan los antecedentes que prueben la infracción, o que se consuman los hechos que la constituyen.

Contra la resolución que decreta las medidas conservativas, se podría concurrir al juez de letras de mayor cuantía en lo civil. Es decir, podemos tener una actuación del juez del TTA y un recurso ante el juez civil. El juez civil, para resolver, deberá citar al jefe del servicio del lugar donde se haya cometido la infracción (el jefe de la unidad). El fallo del juez civil es apelable en el solo efecto devolutivo.

PROBATORIO, SENTENCIA Y RECURSOS

El tribunal, recibido los descargos, confiere traslado al SII por diez días. Vencido el plazo, se podrá recibir la causa a prueba (si es que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos). Luego, el juez TTA dictará sentencia, contra la que solo procede la apelación. En contra de la apelación, procede la casación.

No procede este procedimiento general, respecto de los intereses pecuniarios o multas que establece el SII en relación a una liquidación o reliquidación, ni tampoco los que proceden en relación al art. 161 No. 10 (infracciones que el CT sanciona con multa y además penas privativas de libertad, en cuyo caso estamos frente a un delito tributario).

NORMAS SUPLETORIAS

Normas del reclamo tributario ; por esa vía, llegamos al CPC.

COBRO EJECUTIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Está regulado en los arts. 168 - 199.

Este procedimiento es una consecuencia de la obligación tributaria: la posibilidad de que el Fisco pueda exigir coercitivamente el pago.

El juicio ejecutivo tiene varias etapas y sub etapas. En términos macro:

1. **Etapas ante TGR**

Se pueden subclasificar en:

1. **Etapas administrativas**

No estamos frente a un juicio ejecutivo, sino que TGR intenta conseguir que el contribuyente pague sus obligaciones tributarias. No hay coerción, en el sentido de juicio: es lo que se denomina “**gestiones administrativas de cobro**” »» mail, carta y llamada telefónica (la información se obtiene de lo que ha declarado el contribuyente).

***Art. 170 inc. final** Sin perjuicio de la ejecución, la Tesorería Regional o Provincial podrá, en forma previa, concomitante o posterior, enviar comunicaciones administrativas a los deudores morosos y efectuar las diligencias que determinen las instrucciones del Tesorero General.*

La gestión administrativa de cobro se puede hacer de manera previa, concomitante o posterior a la etapa judicial.

2. **Etapas judiciales**

Si no se consigue el pago, TGR inicia el **procedimiento de ejecución** (el inicio de la etapa judicial por parte de TGR). La etapa judicial inicia con el **título ejecutivo**. ¿Qué constituye título ejecutivo para el cobro de la obligación tributaria? La lista de deudores morosos que confecciona TGR respecto de cualquier impuesto.

El antecedente de la lista de deudores es el hecho de no haberse pagado dentro del plazo estipulado en el giro. Si no se paga, automáticamente se incluye al contribuyente en la lista.

Con este título ejecutivo, TGR (tesorero regional o provincial) puede despachar el **mandamiento de ejecución y embargo**.

El art. 169 señala qué se entiende por título ejecutivo. Debemos recordar que solo la ley otorga mérito ejecutivo.

***Artículo 169.-** Constituyen título ejecutivo, por el solo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentren en mora, las que contendrán, bajo la firma del Tesorero Regional o Provincial que corresponda, la individualización completa del deudor y su domicilio, con especificación del período y la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número en el rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces.*

El Tesorero General de la República determinará por medio de instrucciones internas la forma como deben prepararse las nóminas o listas de deudores morosos, como asimismo todas las actuaciones o diligencias administrativas que deban llevarse a efecto por el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de las disposiciones del presente Título.

El Tesorero General podrá, por resolución fundada, excluir del procedimiento ejecutivo de este Título, aquellas obligaciones tributarias en que por su escaso monto o por otras circunstancias calificadas, no resulte conveniente efectuar la cobranza judicial, resolución que podrá modificar en cualquier momento. Decretada la exclusión y durante el tiempo que ésta dure, no se devengarán intereses moratorios ni multas, cuando estas últimas procedan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tesorero General de la República, por resolución interna, podrá ordenar la exclusión del procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título de los contribuyentes que, se encuentren o no demandados, tengan deudas morosas fiscales cuyo valor por cada formulario, giro u orden, no exceda de 2 UTM vigente a la fecha de la mencionada resolución.

Así, el juicio ejecutivo se inicia con el mandamiento de ejecución y embargo. Este inicio se encuentra plasmado en el art. 170.

***Artículo 170.-** El Tesorero Regional o Provincial respectivo, actuando en el carácter de juez sustanciador, despachará el mandamiento de ejecución y embargo, mediante una providencia que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza del proceso.*

El mandamiento de ejecución y embargo podrá dirigirse contra todos los deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno.

El embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarias mensuales.

Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula a la persona natural o jurídica que por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al contribuyente moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero, a fin de que retenga y/o entregue la suma embargada directamente a la orden del Tesorero Regional o Provincial que lo decretó, el que las ingresará a una cuenta de depósito mientras quede a firme la ejecución, caso este último en que las cantidades embargadas ingresarán a las cuentas correspondientes a los impuestos adeudados.

Si para obtener el pago de la cantidad adeudada fuere necesario efectuar más de un descuento mensual en los sueldos o remuneraciones del contribuyente moroso, la notificación del embargo para la primera retención será suficiente para el pago de cada una de las próximas retenciones hasta la cancelación total del monto de lo adeudado, sin necesidad de nuevo requerimiento.

En caso que la persona natural o jurídica que deba efectuar la retención y/o proceder a la entrega de las cantidades embargadas, no diere cumplimiento al embargo trabado por el recaudador fiscal, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener.

Sin perjuicio de la ejecución, la Tesorería Regional o Provincial podrá, en forma previa, concomitante o posterior, enviar comunicaciones administrativas a los deudores morosos y efectuar las diligencias que determinen las instrucciones del Tesorero General.

El MEE se deberá notificar al deudor, y en ese mismo momento requerirle el pago.

Si el deudor no paga en ese momento, se **traba embargo** sobre los bienes suficientes para asegurar el pago (art. 170, 171 y 173). El embargo lo hará el **recaudador fiscal**.

Los bienes pueden ser raíces, muebles, remuneraciones⁴⁸. El embargo sobre bienes sujetos a registro deberá ser inscrito.

¿Qué puede hacer el contribuyente? **Oponerse a la ejecución.** Tiene el plazo fatal de 10 días

⁴⁸ Por ejemplo, se puede obligar al empleador a retener parte del sueldo, y si no lo hace, pasa a ser solidariamente responsable por las sumas que debió haber retenido.

hábiles contados desde el requerimiento de pago para oponerse a la ejecución. Sólo proceden 3 excepciones: el pago de la deuda, la prescripción de la acción de cobro y el no empecerle el título al ejecutado. En esta tercera excepción, no se está discutiendo sobre la existencia de la obligación, y debe tener fundamentos plausibles (se entiende que debe fundarse en antecedente escrito).

A juicio de Pereira, solo estas tres situaciones son excepciones. Algunos sostienen que la compensación podría ser una excepción, cuando el contribuyente es acreedor del fisco. Pereira estima que el contribuyente puede en cualquier momento solicitar la compensación por vía administrativa, pero la compensación propiamente no se opone como una excepción dentro del juicio ejecutivo de cobro. La solicitud administrativa se hace fuera del juicio ejecutivo. Acreditada que sea la compensación (con el documento administrativo que de cuenta de la calidad de acreedor), se podrá solicitar el término del juicio o que continúe solo por el exceso (compensación parcial).

La opinión de Pereira se funda en el inc. 4 del art. 177. *Sin perjuicio de las excepciones enumeradas en este artículo, el ejecutado que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.*

Siempre hay que tener en cuenta la solicitud de suspensión de cobro (*).

Si no hay oposición, se procederá al remate.

Si hubo oposición, el tesorero regional o provincial solo tiene competencia para pronunciarse respecto de la excepción *de pago*, y solo para acogerla. Por tanto, si las excepciones son distintas, o la excepción de pago no es para acogerla, el juicio sale de la esfera del tesorero regional o provincial, y pasa el expediente al abogado provincial (es funcionario de la tesorería general). Esto está en el art. 178 inc. 1-3.

El tesorero regional o provincial tiene un plazo de 5 días para pronunciarse sobre la oposición conforme al art. 178 (no se cumple en la práctica).

El abogado provincial tiene también 5 días para pronunciarse sobre las excepciones. Si las acoge, se termina el juicio. Si el abogado las rechaza, remitirá el expediente a la justicia ordinaria (art. 179-180). Con esto entramos a la segunda macro etapa.

Artículo 180.- *El expediente y el escrito a que se refiere el artículo anterior se presentarán ante el juez ordinario civil competente correspondiente al domicilio del demandado al momento de practicársele el requerimiento de pago.*

Será competente para conocer en segunda instancia de estos juicios, la Corte de Apelaciones a cuya jurisdicción pertenezca el Juzgado referido en el inciso anterior.

En estos juicios, la competencia no se alterará por el fuero de que pueda gozar el ejecutado.

2. Etapa ante justicia ordinaria

El resumen de la ley es que la justicia ordinaria interviene cuando se han rechazado las excepciones opuestas.

Aquí proceden todos los recursos conforme a las reglas del CPC. Sin embargo, respecto de la apelación, el art. 180, 182 y 184 hacen que la apelación suspenda la ejecución. El ejecutado deberá consignar el valor de la deuda.

Ejecutada la sentencia del tribunal ordinario, se procederá al remate de las especies para que se pague el fisco con el producto.

FACULTAD DEL TESORERO GENERAL

***Artículo 196°.-** El Tesorero General de la República podrá declarar incobrables los impuestos o contribuciones morosos que se hubieren girado, que correspondan a las siguientes deudas:*

1°.- Las deudas semestrales de monto no superior al 10% de una unidad tributaria mensual, siempre que hubiere transcurrido más de un semestre desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

Las de un monto superior al 10% de una unidad tributaria mensual, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a) Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se hayan hecho exigibles;*
- b) Que se haya practicado judicialmente el requerimiento de pago del deudor, y*
- c) Que no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas.*

2°.- Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, con tal que reúnan los requisitos señalados en las letras b) y c) del número anterior.

3°.- Las de los contribuyentes fallidos que queden impagos una vez liquidados totalmente los bienes.

4°.- Las de los contribuyentes que hayan fallecido sin dejar bienes.

5°.- Las de los contribuyentes que se encuentren ausentes del país tres o más años, siempre que no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas.

6°.- Las deudas por impuestos territoriales, que no alcanzaren a ser pagados con el precio obtenido en subasta pública del predio correspondiente.

7°.- Las que correspondan a contribuyentes que hayan deducido querella por haber sido estafados o defraudados en dineros entregados para el pago de impuestos determinados, y siempre que se haya condenado a los culpables por sentencia que se encuentre ejecutoriada.

La declaración de incobrabilidad sólo podrá efectuarse por aquella parte que no exceda, en los impuestos mensuales o esporádicos, de 50 unidades tributarias mensuales por cada período o impuesto; y en los impuestos anuales, en aquella parte que no exceda a 120 unidades tributarias mensuales por cada período.

Los contribuyentes que hayan deducido la querella a que se refiere el inciso primero de este número, podrán solicitar al tribunal que la esté conociendo la suspensión del cobro judicial de los impuestos respectivos.

El tribunal podrá ordenar la suspensión total o parcial del cobro de los impuestos, por un plazo determinado que podrá ser renovado, previo informe del Servicio de Tesorerías y siempre que se haya dictado auto de procesamiento.

La suspensión cesará de pleno derecho, cuando se deje sin efecto el auto de procesamiento o se dicte sobreseimiento temporal o definitivo o sentencia absolutoria. El tribunal deberá comunicar de inmediato la ocurrencia de cualquiera de estas circunstancias, al Servicio de Tesorerías, mediante oficio.

Decretada la suspensión del cobro judicial no procederá el abandono del procedimiento en el juicio ejecutivo correspondiente, mientras subsista aquélla.

Las sumas que en razón de los impuestos adeudados se hayan ingresado en arcas fiscales no darán derecho a devolución alguna.

En el caso que los contribuyentes obtengan de cualquier modo la restitución de todo o parte de lo estafado o defraudado, deberán enterarlo en arcas fiscales dentro del mes siguiente al de su percepción. Para todos los efectos legales las sumas a enterar en arcas fiscales se considerarán impuestos sujetos a retención.

No será aplicable el inciso segundo del artículo 197, a lo dispuesto en este número.

Como ya vimos, al hablar de los modos de extinguir la obligación tributaria, es relevante el art. 197:

Artículo 197°.- *El Tesorero General de la República declarará la incobrabilidad de los impuestos y contribuciones morosos a que se refiere el artículo 196, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de Cobranza del Servicio de Tesorerías, y procederá a la eliminación de los giros u órdenes respectivos. La nómina de deudores incobrables se remitirá a la Contraloría General de la República.*

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Tesorería Regional o Provincial podrá revalidar las deudas en caso de ser habido el deudor o de encontrarse bienes suficientes en su dominio.

Transcurrido el plazo de tres años a que se refieren los artículos 200 y 201, prescribirá, en todo caso, la acción del Fisco.

El art. 197 por lo tanto debe relacionarse con los arts. 200-201.

DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Hoy, la norma general anti elusiva (2014) se sustenta en prácticas elusivas (no necesariamente evasivas), en el marco de dos figuras del derecho sustantivo: fraude a la ley (abuso de derecho) y la simulación. Esto se traduce en una citación, y en definitiva una tasación de los impuestos que se hubieren debido sin mediar la elusión.

Mencionamos lo anterior porque existe una especie de línea en el análisis a realizar, que parte de la planificación tributaria (la legítima opción) y termina con el delito tributario. Entremedio, tenemos la elusión y la evasión.

Tradicionalmente, en el derecho tributario chileno se analizaba la evasión, cuyo castigo era una sanción pecuniaria (multa, reajuste e interés moratorio), y el delito tributario, que podía ser la misma figura evasiva, pero con una pena corporal. Para que se configure el delito tributario, se debía configurar la hipótesis típica del art. 97 No. 4 y No. 10 CT.

Con la Norma General Anti Elusiva (2014), se incorporó la elusión en el esquema anterior. Sin embargo, todavía no tenemos en Chile jurisprudencia de la CS sobre la NGAE.

En el delito tributario aplica todo el derecho penal en su parte general, es decir, dolo, tipicidad, autoría, agravantes, etc...

El derecho penal tributario toma relevancia porque hoy día siempre se debe distinguir si se está en un escenario de dinero o en un escenario de “ver el sol entre barrotes”: penas pecuniarias o penas privativas de libertad. En el mundo del derecho penal económico, algunas conductas podrían mirarse dentro del gran paraguas del fraude al fisco. Como una gran parte de los ingresos del Estado proviene de los impuestos, algunos autores señalan su no pago afecta en última instancia la existencia del Estado.

Se dice también que el no pago afecta a los particulares; pero como ya sabemos, esta teoría no se condice con la realidad, con la real percepción de una contraprestación. En ese sentido, se genera muchas veces una “rabia” en el contribuyente, que lo lleva a la evasión. Se produce una suerte de desazón para el particular que ve que tiene que pagar, sin ver una contraprestación por parte del Estado. El problema que se genera es que el Estado trata de lograr que el contribuyente pague, y por el otro lado, el contribuyente quiere pagar lo menos posible. El no pagar impuestos bajo esta lógica aparecía como un acto de legítima defensa para ciertos autores.

Todo lo anterior se traduce en una situación de dificultad para la recaudación.

Más aún, la persona que no cumple con la obligación tributaria no siempre es rechazada socialmente. El problema está que por la evasión se crean reformas tributarias que buscan recolectar más, por un problema de recaudación y de gasto público.

En doctrina se ha clasificado la evasión tributaria: lícita o ilícita.

Es **evasión ilícita** (o “burda”) aquella que implica dejar de cumplir con la evasión tributaria. Derechamente no se paga el impuesto a pesar de haber incurrido en el hecho gravado. Es la evasión que tradicionalmente ha sido sancionada por ley.

Es **evasión lícita** el realizar determinadas operaciones por las cuales el contribuyente se coloca en una posición ventajosa en relación a la obligación tributaria. El contribuyente aprovecha la propia ley tributaria, para pagar menos impuesto. Pero, ello porque (i) no incurre en un hecho gravado, o (ii) incurre en un hecho gravado con menor impuesto.

Por ejemplo, asumamos que la LIR dispone que las utilidades devengadas o percibidas por una persona jurídica organizada bajo la LSA tributa con tasa de 30% de IDPC. La misma ley señala que las rentas devengadas o percibidas por una persona jurídica organizada como sociedad de persona, tributa 20%. Lo lógico sería asumir que una SA trataría de transformarse en una sociedad de persona. Sin embargo, el tipo social puede ser importante por ejemplo por quórums, por requisitos formales, etc.. Es decir, hay que tener consideraciones no solo tributarias al analizar un problema tributario.

El constituirse como sociedad de persona en nuestro ejemplo es legítimo, está dentro de las “economías de opciones”.

En ese sentido, el cuándo de la actuación es esencial en el tema de la evasión.

En otro ejemplo, la ley tributaria dispone hipotéticamente que la utilidad en la venta de un bien raíz paga impuesto. Hay otra disposición que dice que el mayor valor en la venta de derechos o cuotas de una comunidad no paga impuestos por la utilidad. Una constructora ofrece comprar un determinado bien raíz en 100M. Lo lógico ahí sería formar una comunidad primero, y luego vender los derechos sin tener que pagar impuestos.

Formalmente, es legal; además, no hay simulación civil (no hay un acto real y otro aparente). ¿Es ético? La doctrina ha encontrado que el momento en que se hace es relevante para la ética. Cuando una persona está pensando en vender, lo más probable es que forme la comunidad, y luego recibe la oferta. Distinto sería que por el hecho de la oferta, se forme la comunidad, que se acercaría a lo inmoral. Es decir, el cuándo marcaría el ejercicio de un derecho vs el abuso de un derecho.

INFRACCIÓN TRIBUTARIA

Se trata de toda violación dolosa o culpable de una obligación, deber o prohibición tributaria sancionada por ley. Podemos extraer 3 elementos fundamentales:

1. Elemento material

Se trata de un acto o hecho típico descrito por la ley como constitutivo de infracción.

2. Elemento psíquico

La culpa o dolo. De ello se puede derivar la infracción o un delito (culpa o dolo).

3. Elemento jurídico

Exista una sanción o pena descrita por ley.

En ese sentido, podemos clasificar las infracciones tributarias según la pena que la infracción contenga

1. **Delitos o infracciones penales:** son sancionadas con penas corporales.
2. **Delitos o infracciones administrativas:** tienen una pena administrativa. Es decir, están enfocadas en los funcionarios públicos.

Tenemos por ejemplo la amonestación, suspensión y el despido.

En la práctica, cuando un funcionario del SII comete una infracción administrativa, esta es investigada por un actuario dependiente de la subdirección de contraloría interna (ya sea de oficio o por denuncia). Esto es típico cuando un funcionario se mete a la carpeta SIC de un contribuyente sin tener derecho a hacerlo: se ganará un sumario administrativo.

El sumario está completamente reglado por circulares internas del SII, y tiene una etapa investigativa, probatoria y resolutoria. Se aplicará la sanción correspondiente: amonestación, multa, sanción o despido. Dependiendo de la gravedad de la sanción, ésta va a CGR para su toma de razón.

3. **Infracciones tributarias civiles:** se sancionan con multa.

El CT art. 105 y ss. establece normas comunes a toda sanción.

Concurso de infracciones

La doctrina ha dicho que cuando un hecho constituye diversas infracciones, se aplican todas ellas de forma independiente. Por ejemplo, pena corporal, sanción administrativa y multa.

Pero, la doctrina ha precisado que cuando estamos frente a sanciones de la misma naturaleza, hay que distinguir. Si un solo hecho constituye dos o más delitos, o uno de ellos es medio para cometer el otro, solo se impone la pena mayor del delito más grave.

Si un mismo hecho constituye infracción tributaria de la misma naturaleza pero que no sea delito, se aplican todas las sanciones de forma independiente.

Eximentes de responsabilidad

Se aplica el art. 10 del Código Penal en materia tributaria. Pero además, el art. 110 del CT exige que para que sea aplicable la causal eximente de incurrir en omisión por haberse impedido por causa legítima o insuperable, se necesitan ciertos requisitos. El tribunal apreciará en conciencia los hechos constitutivos de la causal eximente, y el tribunal podrá incluso usarla como una causal agravante.

Reincidencia

A su vez, la reincidencia en infracción de la misma especie o semejante se puede usar como eximente, cuando no haya reincidencia, o agravante cuando si la haya (art. 107).

***Artículo 112.-** En los casos de reiteración de infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal, se aplicará la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal.*

Sin perjuicio de lo dispuesto en el N° 10 del artículo 97 en los demás casos de infracciones a las leyes tributarias, sancionadas con pena corporal, se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de ellas en más de un ejercicio comercial anual.

La lectura literal del art. 112 lleva a concluir que hay reiteración cuando se comete la infracción en periodos distintos. Por tanto, una infracción expone a reiterar en cualquier año posterior. Es decir, si cometo una infracción hoy, y otra en 20 años más, estaría expuesto a reiteración. La jurisprudencia ha confirmado sin embargo la siguiente interpretación: hay reiteración cuando se comete dos o más infracciones en un mismo ejercicio comercial anual.

El “sin perjuicio del art. 97”, que podría constituir un delito tributario, se refiere al no emitir facturas, boletas, etc... (documentación propia del IVA), y se entiende que hay reiteración en esos casos cuando se configuran dos o más infracciones dentro de un plazo de 3 años desde la infracción. En ese sentido, cuando se descubre que su vendedor no emitió una boleta, aparte de la sanción de multa y clausura, “queda con tarjeta amarilla” por tres años. En ese caso, lleva pena corporal, y lo transforma desde una sanción civil tributaria (multa) a un delito tributario.

El art. 112 reafirma el principio de que la reiteración puede ser agravante, pero en su defecto, se podría considerar como circunstancia atenuante.

Atenuantes y agravantes

El art. 107 da una serie de causales que pueden ser agravantes o atenuantes, como por ejemplo del grado de cultura del infractor, o del conocimiento legal (incluso cuando la ley se presume conocida por todos), el perjuicio fiscal que pueda causar la infracción (por ejemplo, lo que se dejó de pagar en un impuesto se pagó en otro que en principio no se habría pagado de evadir el primero).

No presentar una declaración, cuando se debe pagar un impuesto (es decir, cuando hay ganancia), es eminentemente grave y constituye agravante. Pero no presentarla cuando se tiene pérdida, no es tan grave, y lo ponderará el juez.

También es atenuante o agravante el grado de cooperación con el fisco, o el grado de negligencia o dolo.

Existe una causal genérica: cualquier antecedente o elemento análogo a los anteriores, o que parezca justo tomar en consideración atendida a las circunstancias. Esta causal se ha utilizado generalmente para atenuar la responsabilidad.

***Artículo 107.-** Las sanciones que el Servicio o el Tribunal Tributario y Aduanero impongan se aplicarán dentro de los márgenes que corresponda, tomando en consideración:*

1° La calidad de reincidente en infracción de la misma especie.

2° La calidad de reincidente en otras infracciones semejantes.

3° El grado de cultura del infractor.

4° El conocimiento que hubiere o pudiere haber tenido de la obligación legal infringida.

5° El perjuicio fiscal que pudiere derivarse de la infracción.

6° La cooperación que el infractor prestare para esclarecer su situación.

7° El grado de negligencia o el dolo que hubiere mediado en el acto u omisión.

8° Otros antecedentes análogos a los anteriores o que parezcan justo tomar en consideración atendida la naturaleza de la infracción y sus circunstancias.

Artículo 111.- *En los procesos criminales generados por infracción a las normas tributarias, la circunstancia de que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal, como también el haberse pagado el impuesto debido, sus intereses y sanciones pecuniarias, serán causales atenuantes de responsabilidad penal.*

Constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal que el delincuente haya utilizado, para la comisión del hecho punible, asesoría tributaria, documentación falsa, fraudulenta o adulterada, o se haya concertado con otros para realizarlo.

*Igualmente constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal que el delincuente teniendo la calidad de productor, no haya emitido facturas, facilitando de este modo la evasión tributaria de otros contribuyentes.*⁴⁹

¿Quién es responsable?

Por la sanción pecuniaria, el contribuyente y las demás personas obligadas. Aquí entran las personas que no son el contribuyente propiamente tal, pero que sí podrían ser infractores, por ejemplo, el sustituto o agente retenedor.

Por las sanciones corporales, responde quien debió haber cumplido la obligación. Si es una persona jurídica, responde el gerente general o quien haga de sus veces, en definitiva, el representante legal.

Los arts. 98 y 99 son relevantes en esto.

Si la sanción solo tiene pena pecuniaria, la sanción la aplica el SII. Pero si se sanciona con pena corporal, la aplicará la justicia criminal. Si la sanción fuera pecuniaria y criminal, también la aplica la justicia criminal.

Artículo 105.- *Las sanciones pecuniarias serán aplicadas administrativamente por el Servicio o por el Tribunal Tributario y Aduanero, de acuerdo con el procedimiento que corresponda del Libro Tercero, excepto en aquellos casos en que de conformidad al presente Código sean de la competencia de la justicia ordinaria civil.*

La aplicación de las sanciones pecuniarias por la justicia ordinaria se regulará en relación a los tributos cuya evasión resulte acreditada en el respectivo juicio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 162°, si la infracción estuviere afecta a sanción corporal o a sanción pecuniaria y corporal, la aplicación de ellas corresponderá a los tribunales con competencia en lo penal.

⁴⁹ Esto trae a colación la cadena de IVA.

El ejercicio de la acción penal es independiente de la acción de determinación y cobro de impuestos.

Artículo 106.- *Las sanciones pecuniarias podrán ser remitidas, rebajadas o suspendidas, a juicio exclusivo del Director Regional si el contribuyente probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la acción u omisión en que hubiere incurrido o si el implicado se ha denunciado y confesado la infracción y sus circunstancias.*

Sin perjuicio de lo anterior, el Director Regional podrá anular las denuncias notificadas por infracciones que no constituyan amenazas para el interés fiscal u omitir los giros de las multas que se apliquen en estos casos, de acuerdo a normas o criterios de general aplicación que fije el Director.

NORMAS GENERALES ANTIELUSIVAS

Lo primero que podemos decir es que aquí no se trata de una evasión. Se trata entonces de la evasión lícita o elusión, que no obstante la licitud de las conductas que traen aparejado una obligación tributaria, el CT las sanciona pecuniariamente.

En nuestro esquema, estamos entre lo que es la planificación tributaria y la evasión. La planificación tributaria responde a la idea de la autonomía de la voluntad: el ejercicio de las opciones.

Dicho ello, las normas antielusivas fueron incorporadas a la ley chilena por la ley 20.780 (2014), la cual fue modificada por la ley 20.899. Dado que son normas tan recientes, no tenemos jurisprudencia la respecto. Existe la circular 65 de 2015 del SII, donde se impartieron instrucciones administrativas. Su relevancia debe ser unida al art. 26 del CT.

Con las normas generales antielusivas nos referimos a que el SII no estará obligado a reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos que eludan los hechos impositivos establecidos en la ley. Esto se desprende de los art. 4 bis - 4 quinquies del CT.⁵⁰

El art. 4 bis nos permite concluir que el SII puede llegar a desconocer determinados efectos de ciertos negocios, cuando eludan los hechos impositivos. Sin embargo, no hay una libertad absoluta para desconocer, sino que debe existir (i) simulación o (ii) abuso de derecho. En ambos casos, deben ser acreditados por el SII (materia de onus probandi).

⁵⁰ Esta es la gran materia de la indicación que ingresó el ejecutivo a la reforma tributaria el lunes 6 de mayo como indicación, la cual propone establecer una Alta Comisión que califica la calidad de una conducta elusiva como una especie de examen de admisibilidad.

ABUSOS DE FORMAS JURÍDICAS

Los distintos hechos imposables contenidos en la ley pueden ser eludidos mediante el abuso de formas jurídicas. Existirá abuso en materia tributaria cuando los actos o negocios jurídicos efectuados por el contribuyente no produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes. Entonces, lo que producen son 3 resultados:

1. Se evita total o parcialmente la realización del hecho gravado
2. Se disminuya la base imponible o la obligación tributaria
3. Se postergue o difiera el nacimiento de una obligación tributaria

Estos actos o negocios jurídicos producen efectos jurídicos o económicos no relevantes, y sólo tienen por finalidad los tres resultados anteriores.

El SII ha entendido que sería lícito concluir que en la medida que estos actos generen otros efectos jurídicos o económicos relevantes, aparte de los tres anteriores, no se estaría en presencia de un abuso de forma jurídica.

Si se lee la norma del CT, dice que además, el abuso requiere que se produzca mediante “actos o negocios jurídicos que individualmente considerados, o en su conjunto, no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero *que sean distintos de los meramente tributarios*”. Por lo tanto, la defensa del contribuyente es clara: buscar efectos que no sean solo los tributarios, vale decir, que la autonomía de la voluntad haya estado dirigida a buscar otro efecto.

El mismo CT establece (y lo reafirma la propia circular 65) que es legítima “la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria”. Es decir, sí se puede planificar tributariamente. El SII confirmó esta idea, y dijo que “no constituye abuso que el acto o conjunto de actos o negocios jurídicos por los que ha optado un contribuyente no genere efectos tributarios, los genere de forma diferida, o los difiera en el tiempo, si tales efectos han sido expresamente previstos por el legislador para cada forma de organizar los negocios o actividades”.

Por ejemplo, Antonia y Teresa tienen una sociedad, que posee acciones de Inmobiliaria Hornitos SA. Hornitos tiene rentas por enajenación y explotación de bienes raíces. Una tercera persona, Inversiones Dubronik SpA (está en el sistema 14B) también tiene acciones de Hornitos, es la sociedad controladora, que es controlada a su vez por Andrónico Luksic. Cuando Hornitos distribuya utilidades, no tiene efectos para Luksic, pero Antonia y Teresa deben pagar GC.

Antonia y Teresa podrían formar una sociedad entre las dos, aportando sus acciones, para emular la situación de Luksic (Rentas e inversiones Ahuenco SpA). Eso genera un problema justamente de que se tiene que estipular el capital social y pagarlo, por medio de una dación en pago que sería aportar las acciones. Ese aporte deberá hacerse al valor de mercado; si se hace al valor del costo, el SII podrá **tasar** el valor de las acciones. El costo original para la Antonia y la Teresa pudo haber sido muy bajo, mientras

que las utilidades de Hornitos eran altísimas, es decir, cada acción de Hornitos vale mucho. En definitiva, existe un riesgo de tasación que generaría un impuesto por el mayor valor en la enajenación de las acciones.

Cabe destacar que si la sociedad se está formando al comienzo de Hornitos, o cuando no ha habido un cambio material importante en el patrimonio de Hornitos, la formación de la sociedad no tendría el riesgo de la tasación. En el fondo, lo relevante es la existencia de una variación patrimonial. De la misma manera, si la acción se ha devaluado, tampoco existiría este riesgo.

Otra opción sería que Antonia y Teresa se conviertan en empresarias individuales, asignando sus acciones al costo reajustado a una contabilidad separada. Luego, al repartir Hornitos su dividendo, la empresa individual está exenta de IDPC, y se consigue el mismo efecto que Luksic. Se elimina por esta forma el riesgo de tasación, porque no ha existido transferencia de propiedad de las acciones, y se consigue el mismo efecto: diferir el pago del GC.

La pregunta que uno se puede hacer es si es que acaso existe un riesgo de aplicación de la norma general antielusiva.

Recordando lo que ha dicho el SII: no constituye abuso que el acto o conjunto de actos o negocios jurídicos por los que ha optado un contribuyente no genere efectos tributarios, los genere de forma diferida, o los difiera en el tiempo, si tales efectos han sido expresamente previstos por el legislador para cada forma de organizar los negocios o actividades.

La situación a analizar es la naturaleza de la asignación de acciones. A la luz del abuso de forma jurídica, ¿qué eventuales hechos gravados y qué impuestos podrían aplicarse? En nuestro ejemplo:

1. Primer hecho gravado: el mayor valor en la enajenación de acciones (art. 17 No. 8 LIR). Como se debe enajenar al valor de mercado, cuando es mayor al costo se genera utilidad. En el caso de la EI, no ocurre este hecho gravado porque no hay enajenación.

El inicio de actividades de una persona natural como EI y la asignación de acciones de una SA no constituye enajenación (así lo abala la jurisprudencia e interpretaciones administrativas del SII). Por tanto, no se puede generar un mayor valor en la disposición de los títulos. Hay una “mera asignación patrimonial”.

2. Postergación del GC (o IA, según el caso): es común a ambas opciones de nuestro ejemplo.

Como vemos, hay dos de los tres pilares del abuso de forma jurídica. Sin embargo, en el primer caso, la Empresa Individual *solo* existe en la legislación tributaria: es decir, justamente está contemplada en la ley. Luego, además de no verificarse el hecho gravado de la enajenación, está es una opción contemplada por

la ley y aceptada por el SII. Parecería entonces como una opción legítima, no constitutiva de abuso de forma jurídica.

En España, se ha dicho que el principio de opción solo puede darse cuando la ley ofrece expresamente dos formas jurídicas igualmente válidas. Parece ser justamente el caso de la Empresa Individual.

El segundo tema que vimos es la postergación del GC. Nadie discute que la interposición de una EI entre las personas naturales y activos subyacentes difiere el pago de los impuestos finales. Cuando se retiren las utilidades (ingreso material al patrimonio), se gatillará el pago. La Norma General Antielusiva dijo que los actos jurídicos no deben producir efectos jurídicos o económicos relevantes, sino que solo efectos tributarios. ¿La interposición de una EI generará, además de la postergación del GC, un efecto económico relevante para Antonia y Teresa? ¿La EI es o no es de libre disponibilidad para la Antonia y Teresa? La respuesta es no, pues si es que hacen lo que quieran con los dividendos contenidos en esa EI, gatilla el pago. El uso del patrimonio de la EI se encuentra limitado: se puede reinvertir solo en cosas que van a derivar en un IDPC, pues si se usa para otra cosa aparece el **retiro** real o presunto, que gatillará el pago del GC (con o sin crédito; probablemente con, porque serían rentas derivadas de Hornitos que ya pagó IDPC).

El sistema tributario chileno es integrado, de dos etapas. Mientras las rentas se mantengan en la etapa empresarial, no se afectan con los impuestos finales. Por lo tanto, el propio sistema permite el postergamiento o diferimiento. Pereira estima que entender una cosa distinta podría implicar que la totalidad de las sociedades holding serían contrarias a la norma tributaria, como entidades abusivas.

SIMULACIÓN

Artículo 4° quáter.- Habrá también elusión en los actos o negocios en los que exista simulación. En estos casos, los impuestos se aplicarán a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o negocios simulados. Se entenderá que existe simulación, para efectos tributarios, cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento.

En el caso revisado aparece claro que no hay una situación de simulación. No se oculta nada. Todas y cada una de las etapas de constitución de la empresa individual se rigen por las normas de comunicación, registros y publicidad de la ley. La percepción de dividendos desde Hornitos a nivel de la empresa individual va a ser informada al SII.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ya sabemos que el IVA se trata de un impuesto indirecto donde se aplica el criterio de la traslación. Tradicionalmente en las economías en desarrollo el IVA es el gran impuesto recaudatorio, porque apunta a la transferencia de bienes y servicios en la cadena de producción. Además, porque por su propia mecánica de crédito y débito fiscal es fácil de fiscalizar.

El IVA es un impuesto de declaración. No hay que confundir el que sea un impuesto de traslación o indirecto, con el que sea un impuesto de declaración, porque el sujeto pasivo de derecho no cambia.

Se le ha calificado como un derecho facturario, pues el elemento vital es la emisión de la factura.

Hay muchos antecedentes históricos sobre el IVA. Existió impuestos a las ventas desde el principio de la era cristiana, remontándonos a Roma. En la Edad Media, hubo diversos impuestos que atacaron las ventas, como el *maltot* francés o *alcabala* español. La última de estas fue introducido en Chile en 1639 (4% de la venta).

A partir del año 1956, se dictó una ley que modificó una serie de normas, y configura de forma autónoma la ley del IVA. Esta ley, 12.120, mantuvo su vigencia hasta el 1 de marzo de 1975, con el DL 825, publicado el 31 de diciembre de 1974. Con este último, tenemos una ley de IVA propiamente tal. Han habido numerosas modificaciones al DL 825.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CHILENO DEL IVA

Chile ha seguido el modelo francés, y las recomendaciones de la OEA.

1. Impuesto indirecto
2. Se ha tratado de reducir al máximo las hipótesis de exenciones

Los art. 12 y 13 de la LIVA contemplan las exenciones. El art. 12 tiene las exenciones reales, que no apuntan a las características del sujeto, sino que a la operación propiamente tal (sean hechos gravados básicos, o especiales. Dentro de estos últimos, hay muchos que se asimilan a ventas, y otros a servicios).

3. El conjunto de hechos gravados (ventas y servicios), en términos generales, dan cuenta de la mayor parte de los bienes y servicios que se producen, importan, venden o consumen en el mercado chileno. Es decir, son muy pocas las situaciones de ventas o servicios vinculados a muebles o inmuebles que se dejan fuera de la cobertura del IVA.

4. Opera con una tasa única, generalizada, y proporcional. Actualmente, es del 19%. Esto ayuda para no producir distorsiones en el precio relativo de los bienes y servicios que podrían volverse alterados de haber tasas diferenciadas.
5. Utiliza el método de “impuesto contra impuesto” en la determinación de la base imponible, también conocido como la medición del valor agregado. Esto se traduce en el mecanismo de imputación crédito/débito.

Lo relevante es recordar que el crédito fiscal (IVA financiado) sólo puede ser utilizado por contribuyentes de IVA. Es decir, solo beneficia a vendedores y prestadores de servicios, y en forma muy excepcional, a los exportadores. Se desconoce por tanto el derecho de crédito al consumidor final, pues este no genera débito fiscal.

El consumidor final soporta el impacto económico, de un intermediario en la cadena productiva. Por eso es que el IVA está basado en “impuesto contra impuesto”: el crédito fiscal solo puede ser utilizado por un sujeto pasivo de derecho, mientras que el sujeto pasivo de hecho no es un contribuyente, no genera un débito.

6. Como consecuencia de lo anterior, y en resguardo del interés fiscal, en Chile se sigue el “método contable del IVA chileno” o el “derecho facturario”. Esto se traduce en que se impone al contribuyente la obligación accesoria de llevar un libro auxiliar contable que se llama “de compra y ventas” (hoy se hace en forma electrónica). El IVA agrega una contabilidad especial al contribuyente.

Se impone a su vez la obligación de emitir documentos tributarios especiales: factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, guía de despacho.

Además de emitir, existe la obligación de imprimirlos o enviarlos en forma electrónica al SII por medio de los “software autorizados”. Para muchos contribuyentes, sobretudo PYMES, el propio SII a través de su servicio electrónico les permite emitir estos documentos. Esa impresión o emisión debe cumplir con una serie de formalidades, señaladas en el reglamento del IVA, que de no cumplirse pone en riesgo el uso del crédito fiscal.

Impone también la obligación de conservar y custodiar no solo el libro de compras y ventas, sino también los documentos tributarios emitidos por el plazo de prescripción máximo (6 años y 4 meses). Incluso, custodiar y conservar documentos tributarios timbrados sin emitir. Existe lo que se denomina un timbrado foliado. Hoy, con la emisión electrónica es más fácil, porque hay un archivo virtual.

Impone la obligación de contabilizar los documentos tributarios que emitan respecto de los demás emisores, y declarar este impuesto, con un pago simultáneo si lo hubiere, a través del formulario 29 (impuesto mensual).

Todo lo anterior tiende a facilitar los procesos de fiscalización del SII. Existe una serie de terceros coadyuvantes en el correcto uso del crédito fiscal, que son todos aquellos integrantes de la cadena productiva que no sean consumidores finales.

En un estudio de 1999 del SII se comprobó que un 75% de la evasión de IDPC y de GC, se explica por la evasión de IVA.

7. La tentación del vendedor de evadir no emitiendo el documento de venta, importa para el adquirente que sea contribuyente de IVA, no tener un crédito fiscal. Esto genera la **autofiscalización** del impuesto, que propende a una menor evasión.
8. Propende a la neutralidad, tanto en el comercio interno como en el comercio externo. Es una característica especial que el sistema chileno logra en gran medida.

Todos los impuestos cumplen con una finalidad de recaudación: siempre constituye una transferencia de riqueza particular al Estado. Ello afecta los costos, gastos, precios relativos y el poder adquisitivo. La neutralidad en el IVA trata de minimizar estas distorsiones: mientras menor sea el impacto de los tributos en las decisiones y disponibilidades económicas, mayor será la neutralidad de los tributos.

Pero es imposible concebir tributos absolutamente neutros.

Neutralidad de los impuestos

La neutralidad desde una perspectiva tributaria debe ser mirada desde una triple perspectiva: (i) neutralidad distributiva, (ii) neutralidad respecto de la competencia, (iii) neutralidad respecto de los precios.

(1) Neutralidad distributiva. La imposición de un tributo no debe alterar la proporción de la distribución de los ingresos. Debe mantener el equilibrio del poder adquisitivo existente con anterioridad su establecimiento.

(2) Neutralidad respecto de la competencia. Los impuestos no deben afectar las reglas de competencia en los mercados, favoreciendo o desfavoreciendo el desarrollo de los mercados. Es un mecanismo que ayuda a acercarse a competencia perfecta.

(3) Neutralidad respecto de los precios. En materia de impuestos indirectos, se sostiene que entre menor sea el traslado del impuesto a precio, mayor es su neutralidad. Se consigue gravando solo el valor agregado, y no desviando el impuesto a precio.

El modelo chileno está bien enfocado en cuanto a respetar la neutralidad. La neutralidad en el modelo chileno se proyecta en dos ámbitos:

(1) Comercio exterior. En las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, se exige neutralidad.

1. Exportaciones

A la hora de exportar, lo que se debe hacer es exportar los productos, pero no exportar los impuestos. Tenemos que descontaminar de los precios de exportación los impuestos soportados en los distintos insumos de la actividad, pues de lo contrario se afecta la competitividad internacional de los productos (quedamos al menos un 19% más caro). Esto porque aquí no tenemos tax credit, que es solo para impuestos a la renta. Lo único que vamos a tener en este caso es un costo mayor o menor para el adquirente del producto.

No se trata tan solo de declarar exenta de IVA la venta de productos al exterior. Pues en ese caso, no tendría derecho a recuperar el exportador el crédito fiscal por los impuestos que ya ha soportado en los insumos de la actividad exportadora. Al exportador no le basta la exención, sino que requiere tener un “derecho especial” de recuperar el crédito fiscal. Es allí donde nace la “teoría de la tasa cero”. Es decir, el modelo chileno finge que la exportación se encuentra gravada, por tanto dando derecho a crédito fiscal: no genera débito fiscal a pagar, pero está afecta a IVA.

De esto se deriva la teoría de la devolución del IVA exportador (art. 36 LIVA y DS 348 art. 1 y 6).

El modelo chileno ha ido incorporando el sistema de tasa cero a los servicios de exportación, como maestranzas, astilleros, turismos... en general servicios que se prestan a no residentes y que se califiquen como servicios de exportación por el Servicio Nacional de Aduanas.

2. Importaciones

Los productos exportados hacia Chile han salido de sus países con el mismo mecanismo de tasa cero. Por tanto, en su origen, esos productos vienen descontaminados de impuesto, lo que daría una ventaja competitiva al importador vs. los productores chilenos que han tenido que soportar IVA en su cadena productiva y deben vender con dicho impuesto.

Luego, la competitividad de la industria nacional se juega en gran medida en el respeto a la neutralidad. Producto de ello, el modelo chileno coloca en aduanas una barrera tributaria: barrera de entrada, cual es, gravando la importación, ya sea habitual o no, de bienes corporales muebles la territorio de la República. Esto lo hace sobre una base imponible especial: el valor CIF incluyendo los impuestos aduaneros que afectaron la importación.

(2) Comercio interno. La neutralidad se hace presente en la circulación interna de bienes y servicios: se quiere que el impuesto no altere la estructura de los precios internos.

El ideal de neutralidad sea aquél en que el impuesto no sea costo ni gasto para el vendedor del producto. Esa neutralidad se construye en los modelos de IVA en torno al mecanismo débito/crédito fiscal.

La mayor neutralidad existirá cuando (i) todas las ventas generen débito y (ii) el contribuyente tenga derecho a crédito por todas las compras que realice en su actividad. Por lo tanto, donde existe una exención y deje de generarse un débito, no habrá derecho a crédito, y deberá resarcirse de los impuestos ya pagados simplemente subiendo los precios (se pierde la neutralidad).

Las operaciones exentas y las no gravadas atentan contra el principio de neutralidad. Tienen una evidente influencia en el alza de precios y servicios.

CLASIFICACIÓN DEL IVA

EN CUANTO IMPUESTO

1. Fiscal
2. Interno
3. Indirecto
4. No es de retención, sino que de traslación o recargo económico
5. De determinación, declaración y entero mensual (día 20 de cada mes, formulario 29)

MÉTODO TRADICIONAL Y MÉTODO CASCADA

Separata.

HECHOS GRAVADOS POR IVA

El DL 825 grava fundamentalmente dos cosas: la venta y los servicios. Estos son los **hechos gravados básicos** (art. 2 DL 825).

***Artículo 1º**- Establécese, a beneficio fiscal, un impuesto sobre las ventas y servicios, que se regirá por las normas de la presente ley.*

***Artículo 2º**- Para los efectos de esta ley, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá:*

1º) Por "venta", toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta.

2º) Por "servicio", la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s. 3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3º) Por "vendedor" cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Con todo, no se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias así como la enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado; y los demás casos de ventas forzadas en pública subasta autorizadas por resolución judicial. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.

Se considera también "vendedor" al productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no utilice en sus procesos productivos.

4º) Por "prestador de servicios" cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que preste servicios en forma habitual o esporádica.

5º) Por "periodo tributario", un mes calendario, salvo que esta ley o la Dirección Nacional de Impuestos Internos señale otro diferente.

Se incluye además los hechos que la ley asimile a la venta o servicios, que son los **hechos gravados especiales** (art. 8).

Artículo 8º- El impuesto de este Título afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos serán consideradas también como ventas y servicios según corresponda:

La ley del IVA contempla un factor de territorialidad.

Hechos gravados básicos

1. LA VENTA

No toda venta está afecta a IVA, sino aquellas ventas definidas en el DL 825. Debe ser una venta efectuada por un vendedor (elemento subjetivo del tipo), y además debe estar comprendida en las operaciones gravadas con IVA bajo el criterio de territorialidad.

Artículo 2º- Para los efectos de esta ley, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá:

1º) Por "venta", toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta.

ARTICULO 2º Reglamento IVA *Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:*

k) Venta: toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles o inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la ley equipare a venta;

ARTICULO 3º Reglamento IVA *Dentro del concepto de "venta" señalado en el N° 1 del artículo 2º de la ley, se comprenden los siguientes actos jurídicos:*

1) Las convenciones a título oneroso, independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir el dominio de bienes corporales muebles o inmuebles, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos;

2) Todo acto o contrato que conduzca al mismo fin indicado en el número anterior, y

3) Cualquier otro acto o contrato que la ley equipare a venta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley.

Las donaciones de bienes corporales muebles o inmuebles no quedan afectas a los impuestos establecidos en el decreto ley 825, salvo los casos contemplados en la letra d) del artículo 8º de la ley.

La característica del hecho gravado básico es la concurrencia de **requisitos copulativos**:

1. Convención, independiente del nombre que le den las partes.

Se trata de un acto jurídico bilateral que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Pero, ampliando esa latitud de la definición, el concepto del DL se encarga de agregar todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la ley equipare a venta.

Así lo señala el art. 3 No.2 del Reglamento IVA. No se trata de una ley en blanco, sino que una “hipótesis de incidencia orientada teleológicamente por su finalidad”. Atiende a capturar el valor agregado en contratos innominados, que son propios de la autonomía de la voluntad, en los cuales se genere un título traslativo de dominio.

Es decir, si existe un título traslativo de dominio, independiente de la designación que las partes le den, habrá IVA.

2. La convención debe servir para transferir el dominio. Debe constituir justamente un título traslativo de dominio.

La transferencia de dominio es resultado de dos actos distintos: un título traslativo y un modo de adquirir el dominio.

3. A título oneroso. La venta supone que no se esté en presencia de donaciones u otros actos traslativos gratuitos.

Sin embargo, el art. 8 (d) contiene algunas asimilaciones (hechos gravados especiales), donde se contienen ciertas donaciones que se incorporan a venta, por excepción, y son normas de control: se le pide la contribuyente abstenerse de realizar ciertas conductas.

El art. 3 del Reglamento IVA admite excepcionalmente que ciertas donaciones se consideran asimilaciones a venta.

Pero la regla general es que el título sea oneroso, y se excluyen las donaciones.

4. La convención debe recaer en cosas corporales muebles o inmuebles.

La incorporación de los inmuebles es reciente, pero se sigue excluyendo el terreno.

Lo que se excluye son los bienes incorpóreos o derechos. Por ejemplo, los derechos de sociedad de personas o acciones de sociedad de capital no están gravados por IVA; los derechos de autor, de edición, marcas, patentes, regalías, cesión de permisos o concesiones, cesión de derecho de aguas.

Sobre el derecho de aguas, lo que se vende es el derecho a usar tantos litros por segundo. No se está vendiendo el agua, que sería un bien corporal inmueble. El agua es BNUP, por lo que no es

enajenable. Por eso es que la cesión de derechos de aprovechamiento de aguas no es un hecho gravado por IVA. De la misma manera, la cesión de concesiones mineras, o la de permisos y derechos de pesca. Todo porque no constituyen el requisito de venta a la luz del art. 2 No.1 DL 825.

El que queden fuera las acciones y derechos sociales es sumamente relevante porque nos da alternativas para la organización. Por ejemplo, hay un comprador de una empresa. Es diferente si le compra todo su activo o pasivo (gravado con IVA), vs. que se compren las acciones o derechos de esa empresa. Pero se supone que ese IVA constituirá un crédito fiscal, y que se podrá imputar contra los futuros débitos fiscales que se genere. Sin embargo, debemos incluir en nuestro análisis el factor del tiempo. El financiamiento del IVA tiene un costo de oportunidad: el no poder usarlo para otro fin. En el tiempo en que ese activo adquirido no esté generando frutos, se está sintiendo el costo de oportunidad. La compra de las acciones o derechos podría implicar en último término una fusión imperfecta.

Ahora, no siempre convendrá vender derechos o acciones, porque el costo originario de ellos fue bajo, pero su valor actual es alto, por lo que el impuesto a pagar por el vendedor sería importante. En ese sentido, al comprador le conviene porque no paga IVA, pero al vendedor no le conviene porque pagará IDPC.

Por ello es importante siempre analizar qué conviene comprar y qué conviene vender.

5. La venta debe ser hecha por un vendedor.

Aquí tenemos todo el fenómeno de la habitualidad. La habitualidad es de la esencia del hecho gravado con IVA, porque el impuesto se preocupa de gravar el valor agregado en la cadena productiva. Las utilidades que hacen los contribuyentes de forma esporádica no son propias de la LIVA. Esto es muy válido respecto de las ventas, pero no respecto de los servicios.

Art. 2 3º) Por "vendedor" cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Con todo, no se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias así como la enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado; y los demás casos de ventas forzadas en pública subasta autorizadas por resolución judicial. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.

Se considera también "vendedor" al productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no utilice en sus procesos productivos.-

El vendedor puede ser cualquier persona. No es necesario que el giro de una persona jurídica señale “la compra y venta de bienes...”, sin perjuicio de que sea una prueba fuerte para el SII.

El onus probandi sobre la habitualidad corresponde al SII. En el sistema tributario chileno, el término de habitualidad no solo lo vemos en la LIVA, sino también en la LIR, y concretamente en la tributación del mayor valor en la enajenación de ciertos bienes. La LIR también tenía presunciones simplemente legales y de derecho, ligadas a la venta de inmuebles, subdivisión de predios agrícolas y urbanos: hay habitualidad cuando entre la fecha de adquisición y enajenación de un predio que ha sido subdividido han mediado menos de cuatro años.

La existencia de habitualidad nos lleva a concluir que estamos frente a un hecho gravado. En el caso de venta, la falta de habitualidad nos lleva a excluirla como hecho gravado.

El SII puede analizar la cantidad y frecuencia de las ventas (art. 4 Reglamento IVA).

Apunta a determinar el ánimo que guió al contribuyente al momento de la adquisición de los bienes. El SII debe determinar si el ánimo que lo guió fue adquirirlos para su uso o consumo personal, o para su reventa.

Para calificar la habitualidad, el Reglamento IVA exige determinar el ánimo inicial a la época de la adquisición. Es un juicio subjetivo, pero los autores indican que es “objetivado”, en términos tales que la naturaleza, cantidad y frecuencia apuntan a acreditar esta disposición subjetiva.

Obviamente hay una presunción fuerte de habitualidad de todas las transferencias o retiros que realiza un vendedor dentro de su giro, pero es una presunción simplemente legal.

El oficio 432 de 1977 indica que “la entrega de premios especiales efectuados por instituciones de beneficencia no está gravada con IVA por no revestir dicha institución la calidad de vendedor habitual”. Así, hay muchos otros oficios en esta materia, como el 4337 de 1982, que excluye la entrega de combustible por no tratarse de una operación habitual.

6. Territorialidad en la venta.

Los bienes corporales muebles o inmuebles deben ubicarse en el territorio nacional, con independencia del lugar en que se celebre la convención respectiva.

Artículo 4°- *Estarán gravadas con el impuesto de esta ley las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención respectiva.*

Para los efectos de este artículo se entenderán ubicados en territorio nacional, aún cuando al tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él, los bienes cuya inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile.

Asimismo, se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se celebre el contrato de compraventa, los respectivos bienes ya se encuentren embarcados en el país de procedencia.

La primera norma de control la encontramos en el inciso segundo: bienes que están transitoriamente fuera de Chile. Esto se complementa con el régimen de salida temporal del Servicio Nacional de Aduanas.

La segunda norma de control se refiere a aquella venta no habitual, que sería una importación, y por eso se grava con IVA. Son bienes que están en tránsito hacia Chile. En el fondo, se está refirieron al hecho gravado especial del art. 8 A), que como hecho gravado especial, y ser calificado como importación y no venta no requiere habitualidad, y por eso se incluye la expresión “esporádica”.

Hay una circular, 126 de 1977, en la que profundiza en materia de mercadería en tránsito.

2. LOS SERVICIOS

Se gravan aquellos servicios *definidos por la ley como afectos a IVA*, sin que importa la habitualidad, siempre que estos estén prestados o utilizados en Chile.

Artículo 2°- *Para los efectos de esta ley, salvo que la naturaleza del texto implique otro significado, se entenderá:*

2°) *Por "servicio", la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N°s. 3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.*

4°) *Por "prestador de servicios" cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que preste servicios en forma habitual o esporádica.*

Artículo 5° Reglamento- *El impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero.*

Se entenderá que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile, independientemente del lugar donde éste se utilice.

1. La definición de servicio como afecto a IVA en la ley, nos remite finalmente al art. 20 No. 3 y 4 LIR.
2. No se requiere habitualidad.
3. Los servicios deben ser prestados o utilizados en Chile.

El art. 2 No.2 nos define servicios; pero por su parte, el No. 4 indica qué se entenderá por prestador de servicios. Es en el No. 4 donde encontramos el fundamento legal que hace prescindir del elemento de habitualidad.

Por último, al margen del concepto del art. 2 No. 2 y 4, el art. 5 consagra el principio de territorialidad. Se gravan los servicios prestados o utilizados en Chile, independiente de dónde se paguen. Se entenderá que el servicio es prestado en Chile cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile.

Al igual que en la venta, hay **requisitos copulativos**:

1. **Tratarse de un servicio.** Se trata de toda acción o prestación que una persona realiza para otra.
2. **La acción o prestación debe ser remunerada.** Esto, cualquiera sea la denominación que se le de a la remuneración (prima, pago, cánon, etc...).
3. **Cumplimiento de un atributo personal.** Hay una necesidad de que concurra una especial circunstancia de parte del prestador de servicios: es un atributo personal desde la perspectiva del prestador. Se debe estar en presencia, para el prestador, de una actividad clasificada para él en los numerales 3 o 4 art. 20 LIR.

El art. 5 del Reglamento IVA señala que debe tratarse de una actividad cuya tributación la sujete al art. 20 No. 3 y 4 LIR, aunque en el hecho no pague el IDPC, porque hay una exención o un impuesto especial sustitutivo que en algunos casos establece la LIR. Es decir, basta la mera clasificación conceptual del servicio en el marco del art. 20 LIR.

Cuando la actividad se clasifique en los numerales 3 y 4 del art. 20, debemos entender verificado el hecho gravado. *A contrario sensu*, si el prestador se ubica en cualquier otro numeral del art. 20 o en una disposición diversa del art. 20, estaremos en presencia de un servicio no gravado con IVA.

Por ejemplo, el arriendo de un semental o de abejas, o el servicio de engorda de animales, la preparación de suelos, la poda, el contrato de talaje de animales, no son servicios gravados con IVA, porque clasifican en el art. 20 No. 1 LIR.

El arriendo de predios urbanos no amoblados también cae en el art. 20 No. 1 LIR.

La renta proveniente de la actividad consultora, análisis financieros, estudios de mercado, asistencia técnica, prestación de servicios odontológicos ambulatorios, no están afectas a IVA, porque no están descritos en los No. 3 y 4. Todas estas actividades caben en el art. 20 No. 5.

Las rentas provenientes del ejercicio de profesionales liberales y actividades lucrativas, clasificadas como rentas del trabajo independiente, al igual que los servicios dependientes de trabajadores (rentas del trabajo dependiente), no pagan IVA, porque están descritas en el art. 42 LIR. Por eso es que un estudio de abogados emite una boleta de honorarios, no afecta a IVA.

Hay casos en que la determinación de este atributo personal representa problemas: casos límites. Por ejemplo, los comisionistas. El distingo estaría en si tiene oficina establecida, en cuyo caso cae en el art. 20 No. 4, mientras que sin oficina establecida cae en la hipótesis de trabajo independiente. Dicha clasificación limite dará resultado a que estemos o no frente a un servicio gravado con IVA.

Otro caso son los promotores de seguro, que se gravan de ordinario con IVA pero no siempre.

En estos casos limites es menester analizar cada componente del IVA.

4. **No es de la esencia de los servicios la habitualidad, a diferencia de la venta.** Pereira dice que la habitualidad no está llamada a jugar rol alguno a la hora de tipificar el servicio. Por tanto, no se tiene la necesidad de definir al sujeto pasivo como un “prestador de servicio”, pues cualquier persona puede definirse como tal por una sola actuación para efectos tributarios. Ahora bien, no hay que confundir tipificación con fiscalización. Realizando un servicio que reporte una renta descrita en el art. 3 o 4 LIR, deberá pagar IVA.
5. **Territorialidad.** El servicio debe ser prestado o utilizado en Chile. El art. 5 LIVA atiende al lugar en el que el servicio se presta o se utiliza.

Artículo 5°- El impuesto establecido en esta ley gravará los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero.

Se entenderá que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile, independientemente del lugar donde éste se utilice.

La regla de aplicar IVA al servicio prestado en el extranjero pero utilizado en Chile es criticada por muchos autores. Se entiende que la ley quiera gravar con IVA el servicio prestado en Chile, y el prestado y utilizado en Chile; pero no se entiende la regla extraterritorial de gravar el servicio prestado fuera del país.

Siendo una renta de fuente extranjera, porque la actividad se desarrolló fuera del territorio nacional por una persona que no es residente ni domiciliada en Chile, el IVA genera más problemas y

exenciones. Presenta problemas que atentan contra el desarrollo tecnológico e intelectual del país. La mayoría de estos servicios están vinculados a la transferencia tecnológica, regalías, fletes internacionales, comunicaciones, contratos de ingeniería y asistencia técnica, comisiones, y toda la gama de servicios prestados en el exterior que conllevan remuneraciones pagadas por domiciliados o residentes en Chile.

El art. 12 LIVA contempla una serie de exenciones, como las rentas que se remesan al exterior cuando están gravadas con IA. La salida a esta aplicación extraterritorial del IVA desde la perspectiva de la Ley de la *Renta* es vía exenciones o franquicias.

Hechos gravados especiales

Son las denominadas *asimilaciones*, esto es, situaciones especiales que la ley reputa como servicios o como venta para gravarlas con IVA. Están contempladas en el art. 8.

El propósito de estas normas es gravar situaciones que no son *per se* ventas o servicios según la definición legal, pero que la ley equipara como tales. Son situaciones de derecho estricto.

Artículo 8°- El impuesto de este Título afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos serán consideradas también como ventas y servicios según corresponda:

1. LA IMPORTACIÓN

a) Las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales.

Asimismo se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.

Los Notarios no podrán autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto al impuesto que grava la operación establecida en el inciso anterior, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo. A su vez, el Servicio de Registro Civil e Identificación no inscribirá en su Registro de Vehículos Motorizados ninguna transferencia de los vehículos señalados, si no constare, en el Título respectivo el hecho de haberse pagado el impuesto;

La importación no necesariamente implica transferencia de dominio. Ésta se aparta del concepto tradicional de venta. Por ejemplo, Caterpillar Inc Illinois podría firmar un leasing internacional con Minera Escondida, en cuyo caso la importación gravaría el valor CIF⁵¹ (base del IVA). No hay que

⁵¹ Contains insurance and freight.

pensar que la base del IVA es el precio del bien corporal importado, pues no necesariamente se está vendiendo.

El IVA a la importación se cargará sobre el valor CIF o valor aduanero.

Importación equivale a la introducción legal de mercadería para su uso o consumo en Chile, y no necesariamente implica una compraventa.

Debemos recordar la neutralidad en materia de importaciones, en relación a las exportaciones. De aquí surge el principio de reciprocidad, para no afectar internacionalmente los precios.

2. APORTES A SOCIEDAD

b) Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales muebles e inmuebles, efectuados por vendedores, que se produzcan con ocasión de la constitución, ampliación o modificación de sociedades, en la forma que lo determine, a su juicio exclusivo, la Dirección Nacional de Impuestos Internos;

La ley toma la palabra aporte en sentido amplio, como enajenación. Si la hace un vendedor, esa enajenación está gravada con IVA. Se comprenden en esta regla especial los aportes en la medida que ese socio aportante sea “vendedor” de los bienes aportados. Así, deben concurrir los requisitos del hecho gravado básico venta respecto del aportante, que está vendiendo (en el fondo). Esto se da en situaciones de aumentos de capital que se pagan con especies (daciones en pago).

Así, el sujeto pasivo será el aportante, no la sociedad.

El SII ha reforzado que los aportes gravados son aquellos que recaen en bienes del activo realizable del socio aportante cuando se está hablando de un comerciante que determina renta según balance. La idea de activo realizable se vincula a giro, y giro se vincula a habitualidad.

Hay interpretación administrativa (Oficio 1637 de 1997) para el caso de ciertas reorganizaciones societarias que no generan hechos gravados con IVA, por ejemplo, los casos de divisiones, fusiones por absorción o por incorporación, ni en el caso de transformaciones. En algunos casos, porque no hay venta ni transferencia de dominio (e.g divisiones, donde hay una mera asignación patrimonial o transformación del tipo social).

Se podría producir un problema en la conversión de un empresario individual en una sociedad, sobretudo si este empresario es vendedor. Pereira cree que hay argumentos jurídicos para sostener que no se generaría IVA, siguiendo la misma teoría que en los casos anteriores, siempre y cuando en esta asignación se respete el valor tributario de los activos que se asignan a la contabilidad del empresario individual. En otras palabras, en la asignación no se podría verificar una revalorización del costo tributario de los activos. Para Pereira, tal como ese step up generaría renta, la misma teoría podría aplicarse para el caso del IVA.

3. ADJUDICACIONES DE BIENES CORPORALES MUEBLES E INMUEBLES

c) Las adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles de su giro, realizadas en liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual norma se aplicará respecto de las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades hereditarias y provenientes de la disolución de la sociedad conyugal;

Debemos relacionarlo con el art. 9 del Reglamento IVA.

ARTICULO 9° *Para los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 8° de la ley, se entenderá por "bienes corporales muebles e inmuebles de su giro", aquellos respecto de los cuales la sociedad o comunidad era vendedora.*

Igual sentido y alcance tiene la misma frase usada en la letra f) del mismo artículo de la ley, respecto de la venta de establecimientos de comercio o de otras universalidades de hecho.

Se adjudica a una venta, cuando corresponda al giro.

Se excluye la adjudicación de la comunidad hereditarias y en la sociedad conyugal: en estos casos carecemos del componente de giro, de habitualidad. Nunca existió un ánimo de adquirir un bien con el ánimo de revenderlo.

4. RETIROS DE BIENES CORPORALES MUEBLES E INMUEBLES

d) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, directores o empleados de la empresa, para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa, o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador de servicios y cuya salida de la empresa no pudiese justificarse con documentación fehaciente, salvo los casos de fuerza mayor, calificada por el Servicio de Impuestos Internos, u otros que determine el Reglamento.

Igualmente serán considerados como ventas los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles destinados a rifas y sorteos, aún a título gratuito, y sean o no de su giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los vendedores afectos a este impuesto.

Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o distribución gratuita de bienes corporales muebles e inmuebles que los vendedores efectúen con iguales fines.

Los impuestos que se recarguen en razón de los retiros a que se refiere esta letra, no darán derecho al crédito establecido en el artículo 23°.

Guarda concordancia con los art. 10 y 11 Reglamento IVA.

ARTICULO 10° *Podrán tener el carácter de "documentación fehaciente", a que se refiere la letra d) del artículo 8° de la ley, que justifica la falta de bienes corporales muebles en los inventarios del vendedor, las siguientes:*

a) Anotaciones cronológicas efectuadas en el sistema de Inventario Permanente, directamente relacionado con la contabilidad fidedigna que mantenga el vendedor; b) Denuncias por robos o accidentes de cualquier naturaleza formuladas en Carabineros, Investigaciones y ratificadas en el Juzgado respectivo;

c) Informes de liquidaciones del seguro;

d) Mermas, reconocidas por disposiciones legales vigentes y organismos técnicos del Estado.

En todo caso, será condición prioritaria e ineludible que las cantidades y valores correspondientes a los casos y documentos señalados en las letras a), b) y

c) se encuentren contabilizados en las fechas que se produjo la merma, pérdida, etc., de los bienes corporales muebles o inmuebles de que se trate.

ARTICULO 11° *No están afectos al impuesto al valor agregado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8°, letra d), inciso 2° de la ley, los retiros de bienes corporales muebles, cuando éstos no salgan de la empresa o negocio, sino que sean destinados por el vendedor a ser consumidos en el giro de su negocio o a ser trasladados al activo inmovilizado del mismo.*

Tampoco se considera retiro la afectación de bienes corporales muebles del giro del vendedor a la construcción de un inmueble, sin perjuicio de la aplicación de la norma contenida en el artículo 23°, N° 2 de la ley.

Nos habla del caso de retiros. Hay 4 hechos gravados especiales bajo el concepto de retiro, que son asimilaciones a venta. Son “normas de control estructural de las ventas”.

1. Los retiros propiamente tales.

Se trata de retiro de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por el vendedor, socios, directores, empleados, etc... para su uso o consumo personal.

Por ejemplo, la empresa El Emporio Ltda tiene como socios a Felipe y Joaquín. Felipe saca herramientas del almacén, que estaban en el activo realizable de la empresa (stock). Lo que se ha verificado es una venta. Son bienes “distráídos del giro” para el uso personal o de la familia.

Para quedar afecto, el retiro debe recaer en el activo realizable. Por ello la ley alude a bienes de la propia producción o adquiridos para la reventa.

2. Faltantes de inventario no justificados fehacientemente.

Se exceptuarán los casos de caso fortuito, o los determinados por el reglamento (art. 10 y 11). Tales documentos fehacientes podrían ser los comprobantes de denuncias, informes de liquidadores de seguros, mermas reconocidas conforme a la propia disposición tributaria, pérdida por contaminación, diferencias volumétricas por cambios de temperatura en líquidos almacenados, mermas en transmisión de energía, etc... El ejemplo clásico es el terremoto en una viña donde se pierden miles de botellas que se quiebran. Se podría solicitar a un notario que vaya a levantar acta.

En el caso de las mermas técnicas, éstas exigen satisfacer las exigencias contables adicionales. La circular 3 de 1992 señala que debe haber un registro cronológico de las mermas que sirva de antecedente en las correcciones de contabilidad del contribuyente. Así, existirá un orden racional en la disminución de un activo realizable.

Un ejemplo clásico de merma son los productos vencidos.

No se considerará como retiro los bienes distraídos para ser consumidos en el giro de la propia empresa. Por ejemplo, el caso de la tinta utilizada para elaborar las facturas de la empresa.

3. Retiros de bienes destinados a rifas y sorteos.

Se considerarán como venta, aún a título gratuito, y sean o no de su giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los vendedores afectos a este impuesto. Es otra norma de control que grava incluso las donaciones de bienes que no forman parte del activo realizable del vendedor.

4. Otras entregas promocionales.

Se refiere a toda entrega de bienes corporales mueble o inmuebles que se realicen con fin promocional: lo que se grava son las donaciones. Por ejemplo, el caso de ventas en paquete.

5. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

e) Los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción;

Concordancia art. 12 Reglamento.

Históricamente se gravó con IVA los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción, por ejemplo, por administración delegada. En el fondo, se gravaron los contratos generales de construcción por suma alzada que en una época se consideraron hechos no gravados.

En la actualidad, los contratos de construcción, cualquiera sea su modalidad, serán gravados con IVA. El que sea a suma alzada o por administración delegada no interesa para efectos de gravar con IVA; solo interesa para efectos de determinar la base imponible.

El **art. 12** Reglamento IVA define contrato de instalación o de confección de especialidades como aquellos que tienen por objeto la incorporación de elementos que adhieren permanentemente a un bien inmueble, y que son necesarios para que éste cumpla cabalmente con la finalidad específica para la cual se construye. Por ejemplo, la instalación de ascensores, pinturas, pisos, marcos de ventana, instalación eléctrica, etc... Se trata de incorporar bienes muebles que pasan a constituir inmuebles por destinación.

Este es un caso de evasión importante, especialmente en caso de PYMES.

Los contratos generales de construcción no los definió el Reglamento, pero el SII se ha encargado de hacerlo. Ha señalado que son aquellos en que concurren dos o más especialidades en la ejecución de una obra civil nueva. Es un concepto pobre desde la perspectiva teórica.

6. VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y OTRAS UNIVERSALIDADES

f) La venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles e inmuebles de su giro. Este tributo no se aplicará a la cesión del derecho de herencia;

Es un hecho asimilado a venta, porque es la venta de un establecimiento de comercio (“on-going concern”) o cualquier otra universalidad. Lo que se grava es la venta de bienes del activo realizable, es decir, los bienes del giro. También, comprende además la venta de bienes del activo fijo del vendedor, porque estos están comprendidos en esta universalidad de hecho.

Aquí hay un hecho especial gravado que debe ser vinculado con el art. 8 M) en relación al activo fijo. Éste último ha sido modificado varias veces. Antes, para gravar o no con IVA la enajenación de un bien del activo fijo (aquellos bienes en que no hubo ánimo de reventa), un criterio era atender a cuánto tiempo se tuvo como activo fijo. Por ejemplo, si se vendía en menos de 4 años, no se consideraba que se compró sin ánimo de reventa y se gravaba con IVA, independiente de si se hubiera usado o no el IVA financiado. El factor temporal de permanencia como activo fijo determinaba el ánimo inicial de compra y reventa.

La ley se simplificó, y se mirará si se usó como crédito fiscal el IVA financiado al adquirir el activo fijo, independiente del plazo en que se tuvo activado como bien de capital. El art. 8 M) dice “por estar sujeto a las normas de este título”: se está claramente señalando que se gravará al que venda el bien del activo fijo siempre y cuando sea un generador de débito fiscal por la venta, no del activo fijo, sino que por la venta del activo realizable, y haya utilizado el crédito fiscal en contra del débito vinculado al activo realizable. Si no se fuere contribuyente de IVA, nunca se generó débito fiscal, y ese IVA financiado al adquirir el bien de capital, haya sido considerado un gasto necesario para producir la renta en la determinación de la renta líquida imponible (pues “no había nada que hacer” con el IVA soportado).

El art. 8 F) es más amplio que el M): basta que el activo fijo forme parte del establecimiento de comercio, y ni siquiera exige haber utilizado crédito fiscal emanado de la venta habitual del activo realizable. El art. 8 F) se ve reforzado por la nueva redacción del M).

Cuando se analiza si vender un establecimiento de comercio, se tienen que hacer simulaciones. En cuanto a renta, porque cada activo tiene un valor tributario (respetar el valor de mercado), que puede generar pérdida o utilidad. También en cuanto a IVA, porque puede ser un factor relevante al determinar el precio. Ese 19% entrará a la cuenta corriente, y en los siguientes 20 días llegará al Fisco.

Hay que analizar si es que conviene vender el establecimiento de comercio, donde pueden haber intangibles (marcas, derecho de llaves, etc...) que no necesariamente están actualizados en su valor tributario [generaría renta por el mayor valor]. Los intangibles probablemente tengan un bajo costo al momento de haberse activado, pero que su actual valor de mercado es mucho mayor.

La inclusión de los bienes que no forman parte del activo del giro es un elemento esencial de este numeral.

¿Cuál será la base imponible del hecho gravado especial de la venta del establecimiento de comercio?

Artículo 16⁵²- *En los casos que a continuación se señalan, se entenderá por base imponible:*

d) En el caso contemplado en la letra f) del artículo 8°, el valor de los bienes corporales muebles e inmuebles comprendidos en la venta, sin que sea admisible deducir de dicho valor el monto de las deudas que puedan afectar a tales bienes.

Si la venta de las universalidades a que se refiere el inciso anterior se hiciere por suma alzada, el Servicio de Impuestos Internos tasaré, para los efectos de este impuesto, el valor de los diferentes bienes corporales muebles e inmuebles del giro del vendedor comprendidos en la venta.

⁵² Este es un artículo muy importante porque establece la base imponible respecto de los distintos hechos gravados especiales.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable, asimismo, respecto de todas aquellas convenciones en que los interesados no asignaren un valor determinado a los bienes corporales muebles e inmuebles que enajenen o el fijado fuere notoriamente inferior al corriente en plaza;

Se podría pensar que el precio del establecimiento de comercio sería un valor cercano al patrimonio financiero del establecimiento (activo - pasivo), que se refleja en el balance de la sociedad respectiva. Esto, desde un a perspectiva de Renta es lógico. De hecho, en el proyecto de ley (reforma tributaria) toma el valor patrimonial como el justo valor de mercado de sociedades que no se transan (e.g SA cerrada, SRLs, SpAs).

Sin embargo, el art. 16 nos dice que no se pueden deducir de la base imponible los pasivos; no se puede deducir de los bienes las deudas asociadas. Luego, por especial prevención del art. 16 F), no se permite deducir las deudas que pudieran afectar *tales bienes*. Además, hay una norma de tasación: el SII podrá tasar el valor de los bienes comprendidos en la venta, *cuando se trate de una venta a suma alzada*.⁵³

En el proyecto ley se establece un impuesto único de 20% al mayor valor en la enajenación de acciones o derechos. Por ser bienes incorporales, no están afectos a IVA. Luego, se tendrá que comparar la alternativa de vender por medio de una sociedad (venta de acciones o derechos), o vender el establecimiento de comercio por suma alzada, o venta ítem por ítem.⁵⁴ Tendremos que comparar los impuestos que se generan en uno u otro caso.

7. ARRENDAMIENTO Y OTRAS FORMAS DE CESIÓN DE USO O GOCE

g) El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquiera otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio;

Art. 13 Reglamento.

Hay una asimilación al hecho gravado básico de servicio, por la cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles e inmuebles.

Lo que se está gravando es la remuneración por el derecho de usar y gozar sobre una **base temporal**. La temporalidad es el elemento clave, cualquiera sea el título. Aquí no importa el atributo personal del prestador del servicio.

⁵³ Se hace un precio por todo (en vez de una venta ítem por ítem).

⁵⁴ En el caso de venta ítem por ítem, sí se podría rebajar el pasivo por vía de precio.

La remuneración por el uso de inmuebles está exento de IVA, cuando no esté amoblado. Por el otro lado, el arrendamiento de muebles si está gravado con IVA. Lo que quiere gravar la ley en el caso del inmueble es el componente mobiliario; tanto es así, que se puede rebajar del monto afecto a IVA (base imponible) el 11% del avalúo fiscal del inmueble.

El art. 13 Reglamento, en relación a los inmuebles, pone una serie de ejemplos: **ARTICULO 13°** *Entre los inmuebles con instalaciones y/o maquinarias que permiten el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, a que se refiere la letra g) del artículo 8° de la ley, se consideran incluidos los hoteles, molinos, playas de estacionamiento, barracas, cines, etc.*

8. ARRENDAMIENTO DE MARCAS, PATENTES, ETC...

h) El arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales y otras prestaciones similares;

Caso.

Coca Cola Inc es dueña de Coca Cola Chile, y la última tiene contratos con Andina. Entre Coca Cola Inc y Coca Cola Chile hay un primer contrato de royalty por know-how (fórmula secreta de la coca cola) equivalente a un 4% de las rentas (no se trata de un dividendo). Se trata de un contrato que involucra la cesión del uso o goce temporal de la formula, celebrado por un contribuyente sin domicilio o residencia tributaria, y uno con domicilio o residencia en Chile.

Esa remuneración del 4% paga el mal denominado IA. Ello porque el art. 10 inc. 2 de la LIR define expresamente que la explotación de marcas en Chile constituye renta. A su vez, el art. 59 inc. 1 se refiere a la explotación de marcas, patentes, etc... y grava la remesa de renta de fuente chilena al exterior. El art. 8 H) también grava la cesión temporal del uso o goce, por lo que está remuneración debería estar afecta a IVA. Sin embargo, el art. 12 E LIVA exime del pago del IVA porque la actividad está afecta a IA (“uno u otro pero no ambos”).

¿Si Coca Cola Chile compra la marca, e inscribe el dominio, cambia el análisis anterior?

- De partida, no aplica el art. 8H), ni el hecho básico venta, porque (1) se trata de un comprador (Coca Cola Chile), y además (2) porque es un bien incorporal.⁵⁵
- Tampoco se aplica el art. 59 inc. 1, que grava la remesa de renta de fuente chilena: no se trata de un bien ubicado en Chile, ni tampoco constituye una renta para Coca Cola Chile (que queda igual, porque está cambiando un activo por otro de igual valor). Si es que hubiere una renta, sería una renta de fuente norteamericana, donde el sujeto pasivo es Coca Cola Inc.

⁵⁵ Si fuera el caso al revés, que Coca Cola Chile vende hacia afuera, tampoco habría IVA porque es un bien incorporal. Pero, si vendiera el establecimiento comercial, si habría IVA.

- No cabe la enajenación en el art. 10 LIR, porque el bien no está en Chile.

Luego, esta venta no paga impuesto en Chile. “Generalmente las inversiones no pagan impuesto, lo que paga impuesto son las explotaciones”.

En relación a Andina, Coca Cola Chile le hace un subleasing de la marca. Aquí aparece el elemento temporal, sin transferencia de dominio, y desaparece el IA y por tanto la exención del art. 12. Luego, aquí si hay IVA: CCC debe facturar “+ IVA”, y Andina adquiere un crédito fiscal que imputará cuando venda la botella.

9. ESTACIONAMIENTO DE AUTOS

i) El estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin;

10. PRIMAS DE SEGUROS

j) Las primas de seguros de las cooperativas de servicios de seguros, sin perjuicio de las exenciones contenidas en el artículo 12;

k) SUPRIMIDA

11. CONTRATOS DE ARRIENDO CON OPCIÓN DE COMPRA

l) Los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor. Para estos efectos, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurra un plazo igual o inferior a un año;

Este es el caso del leasing inmobiliario, que debe ser realizado por un vendedor en los términos del art. 8 L). La habitualidad hace que se asimile al hecho gravado básico *venta*, no *servicio*.

Hay una presunción de habitualidad, pero no es una presunción de derecho.

12. VENTAS DE BIENES DEL ACTIVO INMOVILIZADO

m) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que, por estar sujeto a las normas de este título, el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción.

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, no se considerará, para los efectos del presente artículo, la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de treinta y seis meses contado desde su adquisición, importación, fabricación o término de construcción, según proceda, siempre que dicha

venta haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la ley sobre Impuesto a la Renta, a la fecha de dicha venta.

La regla general es que no obstante sea un bien del activo fijo, si es que se aprovechó el crédito fiscal, se está afecto a IVA en la venta de ese bien, independiente de cuánto tiempo pasó entre la compra y la venta.

Se establece una excepción: siendo un activo fijo, y no obstante haber aprovechado el crédito fiscal en su adquisición, se debe mantener, para no quedar afecto a IVA, a lo menos 36 meses. Es decir, se incorpora el elemento de temporalidad para eximirlo de IVA.

Además, hay un sujeto de hecho calificado, cual es, el que el comprador sea un contribuyente del art. 14 ter LIR. Esto último significa que se trata de un pequeño contribuyente, que determina su renta mediante contabilidad simplificada: [ingresos - egresos](no según balance completo). El “ingresos menos egresos” significa que todos los activos son gastos, porque se toma la depreciación de los activos fijos, y el inventario que se tiene también se considera como egresó, porque ya se compró. Luego, en contra de ese gran pasivo se imputa cualquier ingreso, y se determinará si se tiene utilidades.

Hay un franquicia escondida: el hecho de que el comprador sea del art. 14 ter hace más barata la venta, porque no se recargará el IVA, cuando el vendedor tuvo el bien por 36 meses. Sin aplicar esta franquicia, se haría más cara la compra para el pequeño contribuyente.

»» Visto los hechos gravados especiales, cabe destacar que el propio CT señala que es preciso atender a la figura de la **permuta, y a las “operaciones complejas”**. Se trata de situaciones en que:

- El precio de la venta se paga por dación en pago de bienes corporales muebles o inmuebles.
- El precio de un servicio se paga por la dación en pago de muebles o inmuebles.
- El precio de venta se paga por la dación en pago de otro servicio.
- El precio de un servicio se paga por la dación en pago de otro servicio.

Estas situaciones se resuelven al tenor de los art. 18 y 19 LIVA, *mirando aisladamente cada componente de la operación compleja*, para concluir si respecto de cada una de ellas se satisface el hecho gravado respectivo.

Artículo 18°- *En los casos de permutas o de otras convenciones por las cuales las partes se obligan a transferirse recíprocamente el dominio de bienes corporales muebles o inmuebles, se considerará que cada parte que tenga el carácter de vendedor, realiza una venta gravada con el impuesto de este Título, teniéndose como base imponible de cada prestación, si procediere, el valor de los bienes comprendidos en ella. Lo dispuesto en este inciso será igualmente aplicable a las ventas en que parte del precio consiste en un bien corporal mueble o inmueble, y a los préstamos de consumo.*

Si se tratare de una convención que involucre el cambio de bienes gravados por esta ley, el impuesto de este Título se determinará en base al valor de los bienes corporales muebles e inmuebles

incluidos en ella, sin perjuicio de la aplicación de los tributos establecidos en ésta u otras leyes que puedan gravar la misma convención.

En estos casos, y en los del artículo 19, se aplicará lo dispuesto en la letra g) del artículo 16 y en los incisos segundo y siguientes del artículo 17.

Artículo 19°- *Cuando se dieren en pago de un servicio bienes corporales muebles o inmuebles, se tendrá como precio del servicio, para los fines del impuesto de este Título, el valor que las partes hubieren asignado a los bienes transferidos o el que, en su defecto, fijare el Servicio de Impuestos Internos, a su juicio exclusivo.*

En los casos a que se refiere este artículo, el beneficiario del servicio será tenido como vendedor de los bienes para los efectos de la aplicación del impuesto cuando proceda.

Igual tratamiento se aplicará en los casos de ventas de bienes corporales muebles o inmuebles que se paguen con servicios.

EXENCIONES

Se clasifican en reales y personales, y están en los arts. 12 y 13. Desde el punto de vista profesional, vale la pena referirse a dos exenciones concretas, de carácter económico. Ya hemos visto el caso de las personas afectas al IA o al art. 42 No.2 LIR.

Algunos autores clasifican las exenciones de la siguiente manera:

- 1.De tipo social.
- 2.De tipo económico.
- 3.De tipo político.
- 4.Otras

Caso del art. 12 B No. 10

Es una exención al hecho gravado especial de la importación.

Artículo 12°- *Estarán exentos del impuesto establecido en este Título:*

B.- La importación de las especies efectuadas por:

10.- Los inversionistas, sean estos establecidos, residentes o domiciliados en el país o aquellos que califiquen como inversionistas extranjeros y las empresas receptores de inversión extranjera, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile, respecto de los bienes de capital importados que destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre otros, que

impliquen inversiones por un monto igual o superior a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La exención a que se refiere este número, se aplicará únicamente respecto de la importación de bienes de capital que se destinen a proyectos de inversión que, por sus características de desarrollo, generen ingresos afectos, no afectos o exentos del impuesto establecido en el Título II de esta ley transcurridos, al menos, doce meses contados desde la internación al país o adquisición en Chile de los primeros bienes de capital cuya exención de Impuesto al Valor Agregado se solicite, o desde la dictación de la respectiva resolución de calificación ambiental otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental conforme lo dispuesto en la ley N° 19.300, o desde el otorgamiento de la concesión de uso oneroso de terreno otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales conforme a lo establecido en el decreto ley N° 1939 de 1977.

Para el otorgamiento de la exención a que se refiere este número, el inversionista deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Hacienda, debiendo cumplir para tales efectos con los requisitos establecidos en este número. En el caso de los inversionistas extranjeros, deberán acompañar a esta solicitud el certificado de inversionista extranjero a que se refiere el artículo 4° de la ley marco para la inversión extranjera directa en Chile.

El Ministerio de Hacienda deberá pronunciarse respecto de la referida solicitud dentro del plazo de sesenta días corridos, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y dicho Ministerio deberá, sin más trámite, proceder a la emisión de una resolución en que se otorgue el beneficio, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que venció el plazo de sesenta días mencionado.

En caso que se presente una nueva solicitud de exención respecto de bienes de capital destinados a proyectos que se realicen por etapas, o que tengan por objeto complementar o expandir un proyecto de inversión sobre el cual se haya otorgado la exención en una etapa inicial, bastará, para que el Ministerio de Hacienda extienda dicha exención a los nuevos bienes de capital, que se acompañe copia de la resolución que haya otorgado la exención original y los antecedentes que permitan acreditar que se trata de distintas etapas de un mismo proyecto o de proyectos complementarios o de expansión.

Facúltase al Ministerio de Hacienda para que, mediante decreto supremo, precise las características de los bienes de capital y proyecto de inversión a que se refiere el presente número, así como la forma y procedimiento en que deberán presentarse los antecedentes que deban acompañarse para efectuar el análisis de la solicitud de exención a que se refiere este numeral.

El Ministerio de Hacienda deberá enviar al Servicio de Impuestos Internos copia de la resolución que otorgue la exención y de los antecedentes presentados por el contribuyente, dentro del plazo de veinte días corridos contado desde la emisión de la referida resolución.

Cuando, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos determine que la exención ha sido otorgada sobre la base de documentos u otros antecedentes erróneos acompañados por el contribuyente, previa citación practicada conforme a lo dispuesto por el artículo 63 del Código Tributario, deberá liquidar el impuesto que hubiese correspondido aplicar de no haberse otorgado la exención, con los reajustes e intereses penales establecidos en el artículo 53 del mismo código. En este último caso, se podrán aplicar las sanciones establecidas en el número 20 de su artículo 97.

De la liquidación que se dicte, así como de la multa aplicada, el contribuyente podrá reclamar conforme al procedimiento general establecido en el Libro III del Código Tributario. El Impuesto al Valor Agregado que haya pagado el contribuyente con motivo de haberse dejado sin efecto la exención que establece este número, constituirá crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado del período en que se lleve a cabo el pago, en la medida que se trate de un contribuyente de este Título.

Cuando el contribuyente haya obtenido maliciosamente la exención de que trata este número, mediante la presentación de documentos u otros antecedentes erróneos, incompletos o falsos, será sancionado en la forma prevista en el párrafo segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, sin perjuicio del pago del impuesto evadido, con los respectivos intereses penales y multas, el que, una vez pagado, no constituirá crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Antiguamente en el DL 600, esta exención estaba establecida para los aportes de capital efectuados por un inversionista extranjero materializados en bienes del activo fijo o bienes de capital. Por ejemplo, Minera Escondida tiene 3 accionistas extranjeros A (33,3%), B (33,3%) y C (34%). Cada una de esas empresas concurre a un aumento de capital en Minera Escondida por 300M, donde cada uno aporta 100. A y B aportan con caja efectiva. Podrían concurrir también con los créditos subordinados a un contrato de inversión extranjera, en que parte es capital y parte es crédito (crédito con parte relacionada o con parte no relacionada), pero todo computado bajo el cupo de la inversión extranjera autorizada. Aquí surgían las relaciones deudas - capital. Yo podía traer un 25% de capital propiamente tal, y un 75% de deuda.

C aporta activo fijo que se valorizará de consuno con el Comité de Inversión Extranjera, en un monto que sea equivalente a los 100M. Por ejemplo, 50 máquinas retroexcavadoras.

Es decir, bajo el DL 600 había un cúmulo de vías para materializar el aumento de capital. Pueden haber flujos inbound o outbound, ya sea como aportes de capital o créditos. El capítulo XIV del CNCICBC define la naturaleza de capitales inbound (vienen hacia Chile); el capítulo XII a su vez regula los capitales outbound. Uno se podrá eximir de IVA en la exportación de determinados bienes de capital: se debe tratar de bienes calificables como bien de capital según la legislación nacional.

El caso concreto del art. 10 B No. 10 lo veremos a partir de un caso. Central Calbún SA necesita una turbina, que se la compra por 10M USD a Siemens en Alemania. Aquí en principio habría un IVA de 1,900,000 USD. Pero este bien es un bien de capital, generará una actividad industrial, supera el monto de

5M USD. Colbún importará la turbina, y ahorrará el IVA, porque la legislación quiere incentivar la importación de estos bienes (por eso es una exención económica).

Si no se optara por esta exención, se tendrían que pagar 1,900,000 USD al Fisco al momento de realizar el desaduanamiento del bien. Otro efecto sería que desde el punto de vista de renta, el costo sería el mismo: 10M. Pero desde un punto de vista de IVA, se tendría un crédito fiscal de 1,900,000 USD, por el IVA financiado. Ese crédito fiscal, que es un activo, se puede imputar en contra del débito fiscal que cobre Colbún a las distribuidoras eléctricas por la venta de megawatts que hace.

Asumamos que Colbún es una empresa nueva. Tenemos que analizar el costo de oportunidad de tener ese crédito fiscal: por mucho que sea un activo, habrá un periodo en que no se esté generando débito fiscal, y en el intertanto habrán costos que solventar. El tener esa plata congelada como crédito fiscal puede tener un costo enorme.

En todo el caso anterior, la solución tiene un trasfondo muy importante: se le soluciona al gerente general un problema político que se le generó: el haberse pasado en el presupuesto presentado. Él solo tenía 10M para la operación, y se le había encarecido en un 19%.

Imaginemos que no se optó por la exención, Colbún se enfrenta al problema de que el activo (crédito fiscal) ha estado estancado mucho tiempo. ¿Habrá alguna norma que permita recuperar anticipadamente los remanente de crédito fiscal vinculados a la adquisición de bienes de capital? Efectivamente, el art. 27 bis LIVA toca directamente este punto.

Artículo 27 bis.- *Los contribuyentes gravados con el impuesto del Título II de esta ley y los exportadores que tengan remanentes de crédito fiscal, determinados de acuerdo con las normas del artículo 23, durante seis períodos tributarios consecutivos como mínimo originados en la adquisición de bienes corporales muebles o inmuebles destinados a formar parte de su activo fijo o de servicios que deban integrar el valor de costo de éste, podrán imputar ese remanente acumulado en dichos períodos, debidamente reajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, a cualquier clase de impuesto fiscal, incluso de retención, y a los derechos, tasas y demás gravámenes que se perciban por intermedio de las Aduanas u optar porque dicho remanente les sea reembolsado por la Tesorería General de la República. En el caso que en los seis o más períodos tributarios señalados se originen créditos fiscales en adquisiciones distintas a las anteriores o en utilizaciones de servicios de los no señalados precedentemente, el monto de la imputación o de la devolución se determinará aplicando al total del remanente acumulado, el porcentaje que represente el Impuesto al Valor Agregado soportado por adquisiciones de bienes corporales muebles o inmuebles destinados al Activo Fijo o de servicios que se integran al costo de éste, en relación al total del crédito fiscal de los seis o más períodos tributarios.*

Los contribuyentes señalados en el inciso anterior, restituirán las sumas recibidas mediante los pagos efectivos que realicen en Tesorería por concepto del Impuesto al Valor Agregado, generado en la operaciones normales que efectúen a contar del mes siguiente del período al cual esas sumas

corresponden. En el caso de que en cualquiera de los períodos tributarios siguientes existan operaciones exentas o no gravadas, deberán adicionalmente restituir las sumas equivalentes a las cantidades que resulten de aplicar la tasa de impuesto establecida en el artículo 14°, que se determine de multiplicar las operaciones totales del mes por la proporción de operaciones gravadas usada para determinar el crédito fiscal en el mes de adquisición del activo fijo que originó la devolución y restar de dicho resultado las operaciones afectas del mes. A los contribuyentes que no hayan realizado ventas o prestaciones de servicios en dicho período de seis o más meses, se les determinará en el primer mes en que tengan operaciones si han importado o adquirido bienes corporales muebles o inmuebles o recibido servicios afectado a operaciones gravadas, no gravadas o exentas aplicándose la proporcionalidad que establece el reglamento, debiendo devolver el exceso, correspondiente a las operaciones exentas o no gravadas, debidamente reajustado en conformidad al artículo 27°, adicionándolo al débito fiscal en la primera declaración del Impuesto al Valor Agregado. De igual forma, deberá devolverse el remanente de crédito obtenido por el contribuyente, o la parte que proceda, cuando se haya efectuado una imputación u obtenido una devolución superior a la que corresponda de acuerdo a la ley o a su reglamento, y en el caso de término de giro de la empresa. Las devoluciones a que se tengan derecho por las exportaciones, se regirán por lo dispuesto en el artículo 36°.

Para hacer efectiva la imputación a que se refieren los incisos anteriores, los contribuyentes deberán solicitar al Servicio de Tesorerías que se les emita un Certificado de Pago por una suma de hasta el monto de los créditos acumulados, expresados en unidades tributarias. Dicho certificado, que se extenderá en la forma y condiciones que establezca el Reglamento, será nominativo, intransferible a terceras personas y a la vista, y podrá fraccionarse en su valor para los efectos de realizar las diversas imputaciones que autoriza la presente disposición.

Para obtener la devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes que opten por este procedimiento, deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste verifique y certifique, en forma previa a la devolución por la Tesorería General de la República, la correcta constitución de este crédito. El Servicio de Impuestos Internos deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha en que reciba los antecedentes correspondientes. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y el Servicio de Tesorerías deberá proceder a la devolución del remanente de crédito fiscal que corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que se le presente la copia de la referida solicitud debidamente timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.

INCISO DEROGADO

La infracción consistente en utilizar cualquier procedimiento doloso encaminado a efectuar imputaciones y obtener devoluciones improcedentes o superiores a las que realmente corresponda, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, según se trate de imputaciones o devoluciones.

La no devolución a arcas fiscales de las sumas imputadas o devueltas en exceso según lo prescrito en el inciso cuarto de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha en que se emitió el Certificado de Pago que dio origen al derecho a la imputación, o desde la fecha de la devolución en su caso.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo fijo, los bienes corporales muebles importados en virtud de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra, respecto del impuesto pagado en la importación, siempre que dichos bienes, por su naturaleza y características, correspondan a los que normalmente se clasifican en el citado activo.

Luego, habrá una opción: (1) imputar el remanente de crédito fiscal a cualquier tipo de impuesto fiscal (IUSC, impuesto aduanero, etc...) o (2) solicitar la devolución, con las cauciones requeridas.

Consecuencias de la exención

No hay que confundir la exención con que el hecho no esté gravado con IVA. El art. 12 en algunos casos viene a reforzar, con una mala técnica legislativa, que un determinado servicio o venta no está afecta a IVA por no cumplir los requisitos básicos. Sobre todo para el caso de los servicios, que requieren rentas que se deriven del art. 20 No. 3 y 4 LIR. Siempre hay que analizar entonces para el caso de los servicios si es que son rentas del No. 3 y 4, que en el fondo refieren a actos de comercio propio del art. 3 CCom.

1. No liberan al sujeto pasivo de derecho de cumplir obligaciones tributarias accesorias, como emitir factura y boleta, hacer la declaración mensual, incluir operaciones exentas en el libro de compras y ventas. La diferencia consiste en que el sujeto pasivo de derecho se exonera del débito fiscal propio de la venta o servicio. Se libera del recargo del IVA por el valor añadido en la transacción exenta.
2. Rompe el equilibrio del sistema de etapas en una cadena productiva. El tradente o prestador de servicios exentos ya no podrá recuperar el monto del IVA que soportó en compras como un crédito fiscal: es decir, pierde el derecho a usar el crédito fiscal.

Luego, en este tipo de operaciones, ¿qué constituye el 19% financiado? Este es uno de los momentos en que nos podemos “cambiar de riel”, y nos trasladamos a Renta. Ese 19% pasa a ser un costo, pues es identificable claramente con un bien o servicio. ¿Cómo distinguimos los gastos necesarios de los costos? El criterio es el de la identificación directa. Es decir, cuando claramente se puede identificar un desembolso efectivo de dinero con un determinado bien, y no se es generador de débito fiscal, no se puede utilizar el crédito fiscal soportado. Luego, este crédito se activa, y como consecuencia de ello se incrementa el costo de adquisición del bien.

En resumen: ¿Qué pasa con aquellos sujetos pasivos de hecho, cuando no son generadores de débito fiscal? ¿Les sirve para algo ese crédito fiscal soportado? Desde una perspectiva de IVA, no. Pero no

significa que se pierda, como si se fuera un consumidor final. Ello, porque desde una perspectiva de Renta, podrá activar el crédito como costo, o lo activa en bienes que ya son de su propiedad en los que el servicio incidió en la elaboración de esos bienes. Activar, esto es, aumentar el costo, genera dos beneficios.

1. Si fuera un bien del activo realizable que de manera extraordinaria no queda afecto a IVA, habrá una menor utilidad al venderlo. Eso implica hacer una revalorización del costo tributario al incluir el crédito fiscal que no se puede imputar al débito fiscal.
2. Si fuera un bien del activo fijo, al activar el crédito, sube el valor tributario de ese bien. Se generará un gasto por la vía de la depreciación de ese bien de capital. Los bienes de capitales se gastan por su uso. Significa una pérdida en la vida útil de ese bien adquirido en 10, con vida útil de 10 años: ahora será un bien adquirido en $10 + (19\%)$ con vida útil de 10 años. Por ejemplo, adquiero un bien en $100 + 19 = 119$. La ley permite costear el bien en 119, en vez de 100. Luego, todos los años se podrá tomar un porcentaje de 119 como gasto, a título de depreciación.

Como vemos, se rompe el equilibrio en la etapa. El tradente o prestador de servicios exento no podrá recuperar el monto del IVA soportado, el cual pasa a constituir un costo o gasto. Este costo o gasto lo voy a traspasar a la etapa siguiente de comercialización, vía precio. Por eso se dice que la exención degenera el sistema, transformando el impuesto en cascada.

3. Aplica la regla de la prorrata en el caso de un contribuyente que tiene operaciones exentas y operaciones gravadas. Regla de la que formalmente tampoco se excluyen las exportaciones, que tienen el régimen de tasa 0. En virtud de la tasa 0, puede, como franquicia, recuperar el exportador el crédito fiscal asociado a la adquisición de bienes y servicios que integran el bien exportado, para respetar la neutralidad.
4. Desde el punto de vista de la clasificación de las exenciones, la exención en la exportación sería de carácter real.

La introducción de mercaderías nacionales o nacionalizadas hacia zonas francas se consideran exportaciones.

La exportación debe ser facturada, como toda otra operación exenta. El exportador continua sujeto a todas las obligaciones formales que impone el régimen común. La alternativa de recupero del crédito fiscal por parte del exportador se resume en:

(1) Para exportadores que además de la exportación realizan ventas gravadas (ventas locales), se les permite incluir el IVA soportado en la actividad exportadora como un crédito fiscal, tal como si fuera una venta gravada. De existir remanente podrá obtener devoluciones de TGR.

(2) Requerir de TGR la devolución del IVA soportado en relación a los embarques realizados, con toda la documentación tributaria, bancaria y aduanera pertinente. En el caso de exportadores con ventas mixtas, se estará a la proporcionalidad.

Esta segunda alternativa tiene una variante. Autores la subclasifican en cuanto al momento en que esta opción se ejerce. Distingue entre la recuperación ex ante y ex post: antes de consumir la exportación presentando un proyecto de exportación, o con posterioridad a la consumación de la exportación con la documentación respectiva (art. 36 LIVA, Reglamento IVA art. 1 y 6).

DEVENGAMIENTO DEL IMPUESTO

La doctrina tributaria nos enseña que el devengo en el IVA, es que como consecuencia de la verificación del hecho gravado, se determina subjetivamente la obligación tributaria. Esto último significa que sabremos quién es la persona sujeto pasivo del impuesto: el vendedor, el prestador de servicios.

Sabemos a su vez los terceros sustitutos o terceros civilmente responsables en casos excepcionales. Por propia disposición de la ley, se puede generar incluso un cambio de sujeto de derecho. Se trata de aquellos casos en que el sujeto de derecho es de difícil fiscalización. Por ejemplo, el campesino que baja a vender los quintales de trigo al molino más cercano. O el caso del pescador artesanal que vende su pesca del día a un intermediario de mayor envergadura. Esto se permite para facilitar la fiscalización, y en muchos casos está ligado a una atenuante que dice relación con el bajo nivel cultural del sujeto pasivo. El comprador se hará responsable de una retención del IVA, su declaración y entero en arcas fiscales.

Tan excepcional es la situación anterior, que periódicamente el SII va determinado cuándo hay cambio de sujeto. Uno de los criterios que se ha utilizado es el que el vendedor no sea facturador electrónico. Por ejemplo, a ese mismo campesino se le pudo haber capacitado para acceder al portal MiPYME y facturar. Luego, ese sujeto dejará de ser de difícil fiscalización, y su comprador puede eximirse de la “retención del IVA” respecto del campesino.

En el modelo chileno del IVA, pasa algo curioso en la ventas respecto del devengo de la obligación. De acuerdo a los criterios generales del sistema, se requiere un título traslativo de dominio y un modo de adquirir el dominio. Pero el modelo chileno, tratándose del hecho gravado básico venta, tuvo que optar entre el momento en que se celebra la convención (título traslativo), normalmente consensual (pues se trata de bienes muebles) y el momento en que ocurra la tradición. Por aplicación del modelo facturario chileno (también conocido como el modelo contable), se prescinde de ambas opciones. En el fondo, al tenor de la ley se prescinde a la hora de precisar o determinar la oportunidad del devengo tanto del título traslativo como del modo de adquirir, y los sustituye a ambos por la oportunidad de la emisión del documento tributario respectivo: factura, boleta o guía despacho que importe venta.

En otras palabras, el IVA en las ventas se devenga en la oportunidad en que se emita la boleta o factura.

En relación a los servicios, la remuneración, ya sea en efectivo o que se ponga en cualquier forma a disposición del prestador, sustituye por analogía la tradición en el caso de la venta.

Así, el IVA en las ventas y prestaciones de servicio se devenga en la fecha de emisión de la boleta o factura.

ARTICULO 9°- *El impuesto establecido en este Título se devengará:*

a) En las ventas de bienes corporales muebles y prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la factura o boleta. En la venta de bienes corporales muebles, en caso que la entrega de las especies sea anterior a dicha fecha o bien, cuando por la naturaleza del acto que da origen a la transferencia no se emitan dichos documentos, el impuesto se devengará en la fecha de la entrega real o simbólica de las especies.

El art. 16 del Reglamento complementa la situación en que la entrega del bien corporal mueble objeto de la venta sea anterior a la emisión de la boleta o factura: **ARTICULO 16°** *En las entregas de mercaderías en consignación que efectúe un vendedor a otro, no se devenga el impuesto al valor agregado mientras el consignatario no venda las especies afectas a este tributo.*

(continúa letra a) En las prestaciones de servicios, si no se hubieren emitido facturas o boletas, según corresponda, o no correspondiere emitirlos, el tributo se devengará en la fecha en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio.

¿Cuándo corresponderá emitir la factura o boleta, o la guía de despacho (cuando permita el traslado que en definitiva corresponda a una entrega real del bien)? El sistema chileno responde en un conjunto de normas que podemos denominar “de la administración del impuesto”.

ARTICULO 55°- *En los casos de ventas de bienes corporales muebles, las facturas deberán ser emitidas en el mismo momento en que se efectúe la entrega real o simbólica de las especies.*⁵⁶ *En caso de prestaciones de servicios, las facturas deberán emitirse en el mismo período tributario en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio.*

Tratándose de los contratos señalados en la letra e) y en la letra l) del artículo 8°, la factura deberá emitirse en el momento en que se perciba el pago del precio del contrato, o parte de éste, cualquiera que sea la oportunidad en que se efectúe dicho pago. En el caso de la venta de bienes inmuebles, la factura deberá emitirse en la fecha de suscripción de la escritura de compraventa por el precio total, incluyendo las sumas pagadas previamente que se imputen al mismo a cualquier título.

⁵⁶ Estamos optando por el **modo de adquirir**.

Cuando se trate de los contratos indicados en el inciso segundo de la letra c) del artículo 16, la factura deberá emitirse por cada estado de avance o pago que deba presentar el concesionario original o el concesionario por cesión, en los períodos que se señalen en el decreto o contrato que otorgue la concesión respectiva. Respecto de los servicios de conservación, reparación y explotación de obras de uso público a que hace referencia la letra h) del artículo 16, la factura correspondiente deberá emitirse dentro del mes en el cual el concesionario perciba los ingresos provenientes de la explotación de las obras.

Sin embargo, los contribuyentes podrán postergar la emisión de sus facturas hasta el décimo día posterior a la terminación del período en que se hubieren realizado las operaciones, debiendo, en todo caso, corresponder su fecha al período tributario en que ellas se efectuaron.

En caso que las facturas no se emitan al momento de efectuarse la entrega real o simbólica de las especies, los vendedores deberán emitir y entregar al adquirente, en esa oportunidad, una guía de despacho numerada y timbrada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta guía deberá contener todas las especificaciones que señale el Reglamento. En la factura que se otorgue posteriormente deberá indicarse el número y fecha de la guía o guías respectivas.

Las boletas deberán ser emitidas en el momento de la entrega real o simbólica de las especies, en conformidad a las disposiciones reglamentarias respectivas. En caso de prestaciones de servicios, las boletas deberán ser emitidas en el momento mismo en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio.

La guía de despacho a que se refiere el inciso cuarto, o la factura o boleta respectiva, deberá exhibirse, a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, durante el traslado de especies afectas al Impuesto al Valor Agregado, realizado en vehículos destinados al transporte de carga. Para estos efectos, el vendedor o prestador de servicios deberá emitir guías de despacho también cuando efectúe traslados de bienes corporales muebles que no importen ventas. La no emisión de guías de despacho oportunamente, será sancionada en la forma prevista en el N° 10 del artículo 97 del Código Tributario, siendo responsable solidario quien transporte las especies cuando no identifique al vendedor o prestador del servicio sujeto del impuesto.

Lo que tenemos en definitiva es un conjunto de reglas que fijan el devengo en la oportunidad de la emisión del documento. Pero nuestro sistema tiene “curiosidades”, tales como:

1. Se puede emitir facturas sin existir entrega de la cosa o pago de la remuneración. En estos casos han habido varias investigaciones por delitos tributarios, porque lo que se quiere revisar es que no se trate de operaciones inexistentes o ficticias que podrían dar derecho a devoluciones, o incrementen los créditos fiscales.

Artículo 23°- *Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se*

establecerá en conformidad a las normas siguientes:

5°.- No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto.

Lo establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando el pago de la factura se haga dando cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio.

b) Haber anotado por el librador al extender el cheque o por el banco al extender el vale vista, en el reverso del mismo, el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta. En el caso de transferencias electrónicas de dinero, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, se deberá haber registrado en los respaldos de la transacción electrónica del banco.

Con todo, si con posterioridad al pago de una factura ésta fuese objetada por el Servicio de Impuestos Internos, el comprador o beneficiario del servicio perderá el derecho al crédito fiscal que ella hubiere originado, a menos que acredite a satisfacción de dicho Servicio, lo siguiente:

a) La emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia electrónica, mediante el documento original o fotocopia de los primeros o certificación del banco, según corresponda, con las especificaciones que determine el Director del Servicio de Impuestos Internos.

El art. 23 es muy relevante porque consagra el derecho al crédito fiscal para quienes han soportado el débito al vender bienes corporales muebles o realizado servicios de aquellos gravados con IVA. Esas personas podrán imputar el IVA soportado económicamente contra el débito fiscal que generen posteriormente en su ejercicio. Es un requisito sine qua non que quien impetra el crédito fiscal sea un generador de débito fiscal.

En ese sentido, el No. 5, norma muy importante, nos indica que no habrá derecho a crédito fiscal, por **documentación ideológicamente falsa**. No se trata del caso de la emisión de facturas *materialmente* falsas, que son aquellas que no cumplen con las formalidades descritas en el reglamento del IVA; sería aquella que ha sido timbrada por cuño o timbre falso. Los documentos ideológicamente falsos son formalmente correctos, pero que no dan cuenta de una operación real. El mundo de la facturación electrónica vino a atacar fundamentalmente el fenómeno de la facturación materialmente falsa, pero no atacó la falsificación ideológica, donde se inventa un servicio o una venta.

Pero el No. 5 si dará crédito fiscal, si el comprador que quiere impetrar el crédito de buena fe recibió

y pagó la factura. Todo esto, independiente de la ulterior responsabilidad fiscal o penal. Para que esto proceda, se deberán cumplir una serie de formalidades en la documentación de pago, que acreditarían la buena fe en el pago.

El 23 No. 5 regula el crédito respecto de facturas no fidedignas o falsas. El SII ha interpretado que no dan derecho a crédito fiscal las facturas que adolezcan de falsedad material o ideológica. Este último caso responde a facturas que solo tiene una *apariencia*, correspondiente a una operación aparente o inexistente.

Reglas complementarias de devengo

Son normas (art. 9) que resuelven las situaciones de los hechos gravados especiales: importaciones, servicios periódicos, contratos de construcción, retiros, etc... (las mencionadas serían las más importantes para Pereira).

ARTICULO 9°- El impuesto establecido en este Título se devengará:

b) En las importaciones, al momento de consumarse legalmente la importación o tramitarse totalmente la importación condicional. Las Aduanas no autorizarán el retiro de los bienes del recinto aduanero sin que se les acredite previamente la cancelación del respectivo tributo, salvo en el caso de las importaciones con cobertura diferida a que se refiere el inciso cuarto del artículo 64 y las indicadas en los incisos segundo y siguientes del artículo 104 de la Ordenanza de Aduanas. Las especies que ingresen al país acogidas a regímenes aduaneros especiales causarán, al momento de quedar a la libre disposición de sus dueños, el impuesto que corresponda por la diferencia de base imponible que se produzca, salvo en el caso de las importaciones a que se refiere la letra B del artículo 12°;

c) En los retiros de mercaderías e inmuebles previstos en la letra d) del artículo 8°, en el momento del retiro del bien respectivo;

e) En las prestaciones de servicios periódicos, al término de cada período fijado para el pago del precio, si la fecha de este período antecediere a la de los hechos señalados en la letra a) del presente artículo.

Sin embargo, tratándose de los suministros y servicios domiciliarios periódicos mensuales de gas combustible, energía eléctrica, telefónicos y de agua potable, el impuesto se devengará al término de cada período fijado para el pago del precio, independiente del hecho de su cancelación.

También se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior a los servicios periódicos mensuales de alcantarillado, siempre que éstos, por disposición legal o reglamentaria, usen el procedimiento de cobranza establecido para los suministros y servicios domiciliarios referidos, y

f) En los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°, en las ventas y en los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, en el momento de emitirse la o las facturas.

BASE IMPONIBLE DEL IVA

Es una materia fundamental para la determinación de la obligación tributaria. El IVA es un impuesto de tasa proporcional.

Artículo 15°- *Para los efectos de este impuesto, la base imponible de las ventas o servicios estará constituida, salvo disposición en contrario de la presente ley, por el valor de las operaciones respectivas, debiendo adicionarse a dicho valor, si no estuvieren comprendidos en él, los siguientes rubros:*

1°.- El monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo, incluyendo los intereses moratorios, que se hubieren hecho exigibles o percibido anticipadamente en el período tributario. En todo caso deberá excluirse el monto de los reajustes de valores que ya pagaron el impuesto de este Título, en la parte que corresponda a la variación de la unidad de fomento determinada por el período respectivo de la operación a plazo;

2°.- El valor de los envases y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución; El Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, podrá autorizar en casos calificados la exclusión de tales depósitos del valor de venta e impuesto, y

3°.- El monto de los impuestos, salvo el de este Título.

Los rubros señalados en los números precedentes se entenderán comprendidos en el valor de la venta o del servicio prestado aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada, y se presumirá que están afectos al impuesto de este Título, salvo que se demuestre fehacientemente, a juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos, que dichos rubros corresponden o acceden a operaciones exentas o no gravadas con este tributo.

No formarán parte de la base imponible el impuesto de este Título, los de los Párrafos 1°, 3° y 4° del Título III, el establecido en el Decreto Ley N° 826, de 1974, sobre impuesto a los Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, y aquellos que se fijen en virtud de la facultad contenida en el artículo 48, sobre impuestos específicos a los combustibles, que graven la misma operación.

Tenemos una regla de oro: el valor de las operaciones respectivas. Pero, puede que hayan ciertos elementos que hagan variar la regla.

El art. 26 del reglamento da una definición interesante, y dice que la base imponible es la suma sobre la cual se debe aplicar la tasa respecto de cada operación gravada. En el fondo, el reglamento señala que la

base imponible está constituida por el precio de la venta o el valor de los servicios prestados. Es el propio art. 15 el que establece ciertas normas que deben considerarse para determinar el valor de la operación.

Asimismo, el art. 16, 17 y 19 LIVA señalan particularidades para determinar la BI en los hechos gravados especiales. Son **reglas complementarias de base imponible**. Por ejemplo:

1. **(art. 16) a)** *En las importaciones, el valor aduanero de los bienes que se internen o, en su defecto, el valor CIF de los mismos bienes. En todo caso, formarán parte de la base imponible los gravámenes aduaneros que se causen en la misma importación.*

Para determinar el impuesto que afecta la operación establecida en el inciso segundo de la letra a) del artículo 8°, se considerará la misma base imponible de las importaciones menos la depreciación por uso. Dicha depreciación ascenderá a un diez por ciento por cada año completo transcurrido entre el 1° de enero del año del modelo y el momento en que se pague el impuesto, salvo que en el valor aduanero ya se hubiese considerado rebaja por uso, caso en el cual sólo procederá depreciación por los años no tomados en cuenta;

MECÁNICA DEL IVA

Débito fiscal

¿Quién es el que debe pagar IVA? Aquél quien genere debito fiscal, esto es, el contribuyente de derecho. Nuestro sistema legal, al considerar aislada cada venta o servicio generador de IVA, genera un concepto que aglutina la sumatoria total del impuesto total a enterar por el conjunto de operaciones, trasladado en el periodo respectivo (recargado al precio). Ese conjunto de traslados conforman el débito fiscal.

La ley nos da un concepto de débito fiscal.

Artículo 20⁵⁷- *Constituye débito fiscal **mensual** (IVA es un impuesto mensual) la suma⁵⁸ de los impuestos recargados en las ventas y servicios efectuados en el período tributario respectivo.*

El impuesto a pagarse se determinará, estableciendo la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, determinado según las normas del párrafo 6°. Respecto de las importaciones, el impuesto se determinará aplicando la tasa sobre el valor de la operación señalado en la letra a) del artículo 16° y teniendo presente, cuando proceda, lo dispuesto en el inciso final de ese mismo artículo.

⁵⁷ Artículo fundamental.

⁵⁸ Refiere al fenómeno de la aglutinación de todos los impuestos recargados en las ventas y servicios en el periodo tributario respectivo (1 mes).

El art. 35 y 36 del reglamento complementan esta definición. El reglamento distingue entre contribuyentes que deben emitir facturas o aquellos que emiten tanto boletas como facturas, o solo boletas. Los que emiten solo boletas, el débito será la suma de las boletas; o de las boletas y facturas; o de las facturas.

Pero, este débito fiscal considera otras cosas. Considera además las notas de débito y notas de crédito emitidas en el periodo. En ambos casos nos interesan las notas emitidas por el contribuyente; no interesan las notas recibidas, que afectan el crédito fiscal.

Las **notas** son documentos tributarios formales por los cuales se corrigen las diferencias entre el valor efectivo de las operaciones y el valor facturado. Estas notas, dependiendo de la naturaleza de la diferencia entre el valor consignado en la factura y el monto real de la operación, puede ser de débito o de crédito. El SII ha dicho que el mecanismo tributario para modificar el precio de una convención y en consecuencia el monto de un tributo, es a través de estas notas de crédito o débito, para disminuir o aumentar dichos montos (oficio 950 de 1990).

Según el art. 36 Reglamento, la nota de debito se agrega al débito fiscal. Es decir, éstas deben agregarse dentro del mismo periodo tributario. La nota de debito se emite por una razón muy simple: porque el valor de la transacción respectiva fue superior al reflejado en el documento originario. ¿Por qué puede generarse la diferencia? El SII ha dicho que se puede deber a “circunstancias sobrevivientes o coetáneas” a la emisión del documento matriz (factura o boleta). En estos casos, si el precio fue mayor, el vendedor debe emitir una nota de débito, que de cuenta de las diferencias. Las causas pueden deberse a gastos de financiamiento en operaciones de plazo, intereses moratorios, equivocaciones al facturar, diferencias de precios, intereses, etc... Las notas de débito siempre se emiten complementando una factura anterior, porque va a aumentar el débito fiscal del contribuyente.

En el caso de las notas de crédito, estas disminuirán el débito fiscal, cuando la operación tiene un valor real inferior al previamente señalado en la factura o boleta. Hay dos artículo específicos a este caso: 21 y 22 LIVA, estableciendo los casos en que es necesario emitir la nota de crédito.

Artículo 21°- *Del impuesto determinado, o débito fiscal, se deducirán los impuestos de este Título correspondientes a:*

1°.- Las bonificaciones y descuentos otorgados a los compradores o beneficiarios del servicio sobre operaciones afectas, con posterioridad a la facturación;

2°.- Las cantidades restituidas a los compradores o beneficiarios del servicio en razón de bienes devueltos y servicios resciliados por los contratantes, siempre que correspondan a operaciones afectas y la devolución de las especies o resciliación del servicio se hubiere producido dentro del plazo de tres meses establecido en el inciso segundo del artículo 70°. Igual procedimiento corresponderá aplicar por las cantidades restituídas cuando una venta o arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, gravadas con esta ley, queden sin efecto por resolución, resciliación, nulidad u otra causa;

pero el plazo de tres meses para efectuar la deducción del impuesto se contará desde la fecha en que se produzca la resolución, o desde la fecha de la escritura pública de resciliación y, en el caso que la venta o arriendo con opción de compra quede sin efecto por sentencia judicial, desde la fecha que ésta se encuentre ejecutoriada, y

En el caso de que una operación quede sin efecto por resolución, resciliación, nulidad u otra causa, dentro de los 3 meses entre la entrega y la devolución, este fenómeno opera automáticamente previa emisión de la nota de crédito. En este caso no se requiere solicitar por la vía administrativa una devolución del débito fiscal pagado en exceso. Por eso las tiendas ofrecen un plazo de 90 días para las devoluciones.

¿Qué pasa si entre la entrega y la restitución han pasado más de 3 meses? En ese caso, se tendrá que seguir el procedimiento general para solicitar la devolución de impuestos pagados en excesos, por el contribuyente de derecho (art. 126 y 128 CT). En este punto es importante leer el art. 22 inciso final, porque pareciera que la ley exige, no obstante haber transcurrido el plazo de 3 meses, emitir la nota de crédito extemporánea como sustento de la solicitud de devolución del impuesto pagado en exceso: *la nota de crédito emitida con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo también será requisito indispensable para que los contribuyentes puedan obtener la devolución de impuestos pagados en exceso por errores en la facturación del débito fiscal.*

3°.- Las sumas devueltas a los compradores por los depósitos a que se refiere el número 2° del artículo 15°, cuando ellas hayan sido incluidas en el valor de venta afecto a impuesto.

Crédito fiscal

El art. 23 No. 1 LIVA define el crédito fiscal, y establece como elemento esencial para su utilización el que el contribuyente esté afecto a débito fiscal. Es decir, que sea contribuyente de IVA. Hay una relación causa efecto entre ser contribuyente de IVA, generador de débito, con la posibilidad de usar el crédito fiscal.

Artículo 23°- *Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado por el mismo período tributario, el que se establecerá en conformidad a las normas siguientes:*

1°.- Dicho crédito será equivalente al impuesto de este Título (IVA) recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios, o, en el caso de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo período. Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del

contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o un contrato de arriendo con opción de compra de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.

Inmediatamente concluimos que del concepto del art. 23 No. 1 se desprende un requisito formal esencial: que el impuesto recargado conste en una factura que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios.

Es decir, el crédito es la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios. Básicamente, vemos que se verifica una compensación total o parcial (generalmente será parcial) entre el débito y el crédito.

Hay una serie de requisitos para usar el crédito, de forma y fondo.

Requisitos de fondo

Hay muchas situaciones que trata el art. 23: las facturas y boletas donde se recarga un impuesto son prueba de una determinada operación. Este impuesto recargado debe acreditar adquisiciones o prestaciones de servicios afectas a IVA.

Lo que se quiere entonces es que no se pueda usar el crédito fiscal cuando la factura o boleta cumpla con los requisitos formales, pero no los de fondo: instrumentos ideológicamente falsos.

(art. 23 No. 1) Por consiguiente, dará derecho a crédito el impuesto soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios destinados a formar parte de su Activo Realizable o Activo Fijo, y aquellas relacionadas con gastos de tipo general, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente dará derecho a crédito el impuesto de este Título recargado en las facturas emitidas con ocasión de un contrato de venta o un contrato de arriendo con opción de compra de un bien corporal inmueble y de los contratos referidos en la letra e) del artículo 8°.

Luego, el impuesto debe recaer sobre:

1. Especies corporales muebles o inmuebles o servicios destinados a formar parte del activo realizable.
2. Especies corporales destinadas a formar parte del activo fijo.

El histórico criterio de utilización del crédito fiscal ha sido de carácter restrictivo, y ha hecho una separación entre el crédito fiscal asociado a la enajenación de bienes de capital (donde no hay ánimo de reventa) respecto de los bienes del activo stock o circulante. Por tanto, no se podría usar el crédito fiscal respecto de aquellos bienes cuya enajenación no produce débito.

Pero, poco a poco se ha ido avanzando en aras de la neutralidad, hacia una procedencia generalizada y amplia del crédito fiscal que cubra todas las adquisiciones que guarden relación directa o indirecta con el giro generador de débito fiscal, lo que podría incorporar bienes de capital. Luego, hay

interpretaciones administrativas a favor de usar el crédito fiscal por bienes de capital cuya enajenación no genera débito.

Hoy tenemos el art. 8 M) que reconoce la utilización de crédito fiscal asociada a bienes de capital.

3. Gastos de tipo general.

Se evidencia con mayor claridad la discusión entre la procedencia amplia o restringida del crédito fiscal. Pereira estima que se toma partido por la procedencia amplia. El contribuyente debe incurrir en muchos tipos de gastos, como luz, cuenta de teléfono, artículos de oficina, etc... Incurre también en gastos de publicidad, propaganda o representación.

La línea divisoria entre gastos de tipo general que dan derecho a crédito fiscal por guardar relación con el giro del negocio, y aquellos que no lo dan por no relacionarse, está trazada por una cantidad infinita de interpretaciones administrativas. Esto va de la mano del análisis que hace el SII sobre la procedencia de una deducción en la determinación de la renta líquida imponible como gasto necesario. En otras palabras, el análisis de si un gasto general es deducible como tal para la generación de la RLI en el IDPC es análogo para el examen de utilización del crédito fiscal asociado a esos gastos. Por lo tanto, un gasto no deducible para el IDPC, probablemente el crédito fiscal no podrá imputarse contra el débito.

¿Qué nos guiará en este análisis? El art. 23 LIVA debemos relacionarlo al art. 31 inc. 1 LIR. En su versión actual, el art. 31 establece los requisitos mínimos que debe cumplir un gasto para ser deducible para efectos de la renta: (i) necesario, (ii) acreditado fehacientemente (por vía de la boleta, factura o contrato⁵⁹), (iii) deducido como tal y no activado como costo en el periodo tributario correspondiente, (iv) dicho gasto no esté prohibido por la ley.

Se genera por tanto una simetría entre el gasto general para los efectos de IVA y el gasto necesario para los efectos de determinación de la RLI.

4. Otros casos.

No dará derecho a crédito fiscal, desde el punto de vista de los requisitos de fondo (hay casos dentro del art. 23 y fuera de él):

1. Compras o servicios documentados con boleta. Este documento es propio del consumidor final.
2. Art. 8 e) inc. final.

⁵⁹ Si solo se tiene la boleta, no se cumple el requisito de forma y el análisis en cuestión es inútil.

Impuesto recargado en razón de los bienes corporales retirados por el vendedor, dueño, socio, director, o empleados para su uso o consumo personal o de su familia. Es decir, se considera como hecho gravado y no otorga derecho a crédito fiscal.

Se trata de impedir que el beneficiario del retiro goce del crédito fiscal. Por eso, al leer el inciso final, llama la atención que se refiere al impuesto “recargado” en razón de los retiros. La prohibición de utilización del crédito apunta al beneficiario del retiro.

3. Las adquisiciones o servicios no relacionados con el giro de la empresa.
4. Adquisición de bienes o servicios por operaciones no gravadas.
5. Operaciones exentas.
6. Adquisición de bienes o servicios en la parte del IVA de utilización común en que no hay crédito.

Se abre el mundo de la proporcionalidad, del art. 23 No. 3:

3°.- En el caso de importación o adquisición de bienes o de utilización de servicios que se afecten o destinen a operaciones gravadas y exentas, el crédito se calculará en forma proporcional, de acuerdo con las normas que establezca el Reglamento.

En el fondo, la regla de proporcionalidad impide a estos contribuyentes gozar del crédito por aquella parte de sus ventas exentas o no afectas a IVA. Podemos relacionar entonces el 23 No. 3 con el art. 40 y ss Reglamento que establece el cálculo de la proporcionalidad. Es un ejercicio de **identificación directa** entre el IVA soportado en las operaciones gravadas y soportado en sus operaciones no gravadas o exentas.

Si tengo identificación, no hay que seguir la regla de la proporcionalidad. Cuando no se pueda identificar, debemos recurrir a la proporcionalidad.

El cálculo de proporcionalidad es un regla de 3, y es el mismo cálculo que hace el exportador en esta situación.

7. Facturas no fidedignas, falsas o que no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios. El mismo art. 23 No. 5 da un listado de facturas que no dan derecho al crédito, como las emitidas por personas no contribuyentes de IVA.

Existen requisitos formales para que la persona que de buena fe pagó esa factura inutilizable pueda usar el crédito.

Factura falsa la podemos definir como aquella que falta a la verdad en los datos contenidos en ella. La falsedad puede ser material, cuando la falta de verdad dice relación con el documento mismo, o bien ideológica, cuando lo señalado sea falso o mentiroso. Por ejemplo, indicar un nombre o domicilio o RUT inexistente o que no corresponde al emisor o receptor de la factura. También sería el caso de falsear timbres del SII (cuños), o mentir sobre los montos transados.

8. Otros casos.

Requisitos de forma: art. 25

Artículo 25°- Para hacer uso del crédito fiscal, el contribuyente deberá acreditar que el impuesto le ha sido recargado en las respectivas facturas, o pagado según los comprobantes de ingreso del impuesto tratándose de importaciones, y que estos documentos han sido registrados en los libros especiales que señala el artículo 59°. En el caso de impuestos acreditados con factura, éstos sólo podrán deducirse si se hubieren recargado separadamente en ellas.

1. Debo estar preparado para **acreditar** que el impuesto ha sido recargado en la respectiva factura o pagado, según los comprobantes de ingreso en el caso de las importaciones.

El art. 25, junto con el art. 39 Reglamento, dice que en la factura que acredita los impuestos recargados, debe consignarse en forma separada el impuesto respecto del precio de la venta o servicio.

El requisito formal en el fondo apunta a ser capaz de acreditar con un documento que dispone la ley y en la forma que prescribe.

2. Adicionalmente, **acreditar** de haber cumplido con una obligación tributaria accesoria de hacer: anotación en un registro contable dispuesto por la ley. El Reglamento IVA establece que los contribuyentes de IVA deben llevar un libro de compras y ventas, para registrar diariamente las compras, ventas, importaciones, exportaciones, prestaciones de servicios, operaciones exentas, etc...

Art. 59 LIVA en relación al art. 74 Reglamento: **Artículo 59°- Los vendedores y prestadores de servicios afectos a los impuestos de los Títulos II y III, con excepción de los que tributen de acuerdo con el párrafo 7° del Título II, deberán llevar los libros especiales que determine el Reglamento, y registrar en ellos todas sus operaciones de compras, ventas y servicios utilizados y prestados. El reglamento señalará, además las especificaciones que deberán contener los libros mencionados.**

Agregaciones y deducciones

En el proceso de determinar el crédito fiscal, pueden haber deducciones y agregaciones dentro del mismo. Apuntan a determinar el monto final del crédito disponible. Es decir, tenemos un crédito fiscal “borrador” al que se le deben hacer agregaciones y deducciones para llegar al crédito fiscal disponible para imputar contra el débito fiscal.

Las agregaciones y deducciones responderán a las notas de débito y crédito fiscal registradas durante el mes.

Remanente de crédito fiscal

Se trata del crédito a favor del contribuyente cuando el crédito ha sido superior al débito fiscal. Se arrastrará para ejercicios siguientes hasta su total utilización, y se traduce a UTM para protegerlo de la inflación.

La no utilización oportuna de los reajustes por los remanentes de crédito implica la pérdida del derecho a invocar el reajuste en ejercicios posteriores.

El art. 27 bis establece normas especiales para el aprovechamiento del crédito fiscal. Otorga un derecho alternativo, para imputar el remanente a cualquier clase de impuesto fiscal, incluso de retención, o bien, para solicitar el reembolso del remanente por parte de TGR. Esta última alternativa tiene ciertos requisitos, que se pueden resumir en:

1. Constatar un remanente que cumple los requisitos de forma y fondo.
2. Que este remanente se tenga durante 6 o más periodos consecutivos como mínimo.
3. El origen del remanente sea la adquisición de bienes corporales muebles o inmuebles destinados al activo fijo del contribuyente, o bien, de servicios que deban integrar el costo de dichos activos.

Por ejemplo, la central hidroeléctrica Hidro Balmaceda compra una turbina a Siemens Alemania, que paga IVA como importación. Celebra un contrato de construcción con la constructora Salfa, para construir la central, que también genera IVA. En la construcción de la sala de máquinas, hubo servicios afectos a IVA vinculados con el ensamblaje de la turbina dentro de la sala de máquinas, que van con IVA, pero que se puede agregar como crédito fiscal porque en el fondo el precio de ese servicio se activó al costo de adquisición de la turbina o de la construcción de la sala de máquinas.

Esta es una norma de financiamiento de proyectos: evita tener que acudir a los accionistas, bancos, inversionistas, etc... para obtener nuevos ingresos. Al recuperar anticipadamente el crédito fiscal, se podrán pagar los sueldos, cosos de operación, etc... sin tener que pagar a su vez intereses por el mutuo.

El art. 27 bis se pone en el caso de que con posterioridad a que el contribuyente ejerza la opción pidiendo la devolución, genere operaciones exentas o no gravadas. Por ejemplo, Hidro Balmaceda obtiene la devolución y con posterioridad genera operaciones gravadas, exentas y no gravadas. En el fondo, se podría haber producido una suerte de enriquecimiento sin causa para el contribuyente, en perjuicio del fisco, porque se solicitó una devolución anticipada, y el 100% de las operaciones no eran gravadas con IVA. Por lo anterior, la norma establece una obligación para el contribuyente de reintegro del monto de la

devolución excesiva. Se considera para estos casos un mecanismo de cálculo proporcional del monto a reintegrar, incluso hasta el término del giro.

Se entiende vía ficción legal que forman parte del activo fijo los bienes muebles por un arrendamiento internacional, siempre y cuando el bien arrendado corresponda a los que normalmente se consideran como un bien de capital.

Cabe destacar que este derecho de opción solo puede ser ejercido por el contribuyente que ya ha comenzado a operar. Es decir, el contribuyente que todavía no ha facturado un peso no tiene esta opción.

¿Qué puedo hacer si tengo un remanente de crédito al momento del término de giro? Aquí nuevamente nos podemos cambiar de riel a Renta. El art. 28 establece que este remanente:

1. Puede imputarse al IVA que se genere como motivo de la venta o liquidación del negocio.
2. Si aún quedara remanente de crédito, este podría ser imputado al IDPC que se adeudare en el último ejercicio correspondiente al término de giro. Del balance de término de giro puede emanar un impuesto a pagar, y se pagará con el remanente del crédito.

Esto es distinto de activarlo como costo, o deducirlo como gasto, lo que redundaría en ambos casos en una mayor o menor BI para el IDPC. Aquí, se tratará de una menor cantidad de dinero a enterar al Fisco porque se usa como crédito.

3. Si aún así sobrara un remanente de crédito fiscal, se pierde.

IMPUESTO A LA RENTA

Renta es cualquier aumento de patrimonio cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. El art. 2 LIR define también renta atribuida, devengada y percibida. Puede tratarse de una renta del trabajo, del capital producto del azar, de la adquisición de un res nullius, ya sea de fuente extranjera o fuente chilena.

Ingreso no es sinónimo de renta, pues podría ser por ejemplo un reembolso de gastos, que solo viene a resarcir un daño injustificado al patrimonio. Un ingreso para una empresa que determina renta efectiva según balance podría ser un aumento aparente, pues aparejado a esos ingresos la empresa tiene gastos necesarios para producir la renta. Así, si tiene ingresos por 1M, pero gastos necesarios de 2M, está lejos de tener una renta, sino que todo lo contrario. Ejemplos de estos gastos necesarios serán la cuenta de la luz, del teléfono, remuneraciones, intereses de créditos bancarios, depreciación del activo fijo, gastos de organización y puesta en marcha de la empresa, de publicidad, etc...

Hay ingresos que no aumentan en el patrimonio, sino que lo dejan en su estado anterior: por ejemplo una indemnización o un reembolso. Si la empresa tiene una cuenta por cobrar de 100 y le pagan 100, no hay una renta, y a lo más ese activo “cuenta por cobrar” se podrá cambiar a “caja”.

La ley tiene dos grandes vías para acotar el concepto de renta, que de suyo es muy amplio. (1) Una de ellas es la propia ley vena a reforzar el concepto de que si no se verifica el incremento de patrimonio y no hay renta, y por tanto no hay impuesto. Por ejemplo, la ley puede declarar que cumplidos ciertos requisitos, ciertas indemnizaciones no se consideran renta por el solo ministerio de la ley (está constatando algo que el concepto general ya nos dice). (2) Otra línea es que el legislador puede declarar que ciertos incrementos patrimoniales efectivos no sean constitutivos de renta, como una medida de política económica (franquicias tributarias). Así, si se le quiere dar profundidad al mercado de acciones, la renta por determinadas acciones no pagará impuesto, porque se quiere que las sociedades sean capitalizadas.

Así, partiendo del concepto de ingreso, tenemos que determinar si estamos frente a renta o no. En caso de estarlo, algún impuesto de aquellos de la LIR se va a aplicar, no obstante las exenciones que puedan existir. Si el ingreso en cambio no está afecto a renta (ingreso no renta INR), ningún impuesto de la LIR podrá aplicarse, independiente del lugar donde esa renta se genere o se colaciona. Si es un ingreso no renta para una empresa, será un INR para todos sus accionistas hacia arriba llegando hasta el contribuyente final (el curriculum vitae del ingreso).

El primer análisis que hará un contribuyente es revisar las normas sobre ingresos - rentas, para tratar de calificar el ingreso como INR. Es decir, buscar dónde están los ingresos no constitutivos de renta. Si se encuentra una norma de aquellas, ya no será necesario hacer ningún análisis bajo la LIR. Este es un paso a su vez importante para el Fisco, porque quiere que ese ingreso no esté cubierto por una norma que lo califique como INR.

El artículo fundamental aquí el art. 17 de la LIR: no constituyen renta (...). Cuando el art. 17 no es claro, hay que volver al art. 2 que tiene las definiciones generales. El art. 17, que se supone establecer claramente los INR, en realidad contiene INR, ganancias de capital, y rentas ordinarias (se afectan con todos los impuestos). Es decir, refleja una pésima técnica legislativa (el “camarín sucio”).

Así, el análisis es el siguiente:

1. Revisar si uno está en los casos claros del art. 17. En dicho caso, el ingreso no es renta y salimos de la LIR.
2. Sino, ya sabemos que el tema es renta. Luego, vamos al art. 2. Esto sin perjuicio de la posibilidad de que exista una exención especial.⁶⁰
3. Trataremos de identificar el ingreso renta con la fuente trabajo (rentas del trabajo), en el art. 42 LIR. ¿Por qué? Porque es más fácil: es aquella renta en que prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital.
 1. El primer paso será tratar de identificar la renta con el trabajo dependiente (art. 42 No. 1): identificar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia desde la perspectiva del derecho laboral. Por tanto, estamos frente a una remuneración en su sentido amplio (sueldo, bonos, asignaciones que no cumplan con los requisitos para ser declaradas no renta, casos de stock options, etc...).

Estaremos frente a un impuesto único, de retención, de tasa progresiva creciente, mensual, sobre base percibida.

Debemos recordar que el contrato de trabajo es consensual, no requiere estar escrito.

Así, John Smith, australiano, que trabaja en la firma australiana BHP y se viene a Chile como residente para efectos tributarios, al que le pagan todos los meses una remuneración. Él pagará, por el pago que le hace BHP desde australiana en un banco en Miami, el ISUC. Esto porque su actividad está desarrollada en Chile (art. 10). El problema es que este es un impuesto de retención, pero el retenedor está fuera de Chile, pero eso en nada afecta la naturaleza del impuesto. En este caso, se deberá hacer la autoretenención del impuesto, por el mismo John Smith.

Si a una persona le dieron un bono, vamos a tener que ver si está en el art. 17, luego el art. 2, luego analizar la **causa del bono**. Si es el trabajo dependiente, veremos si es que ya le pagaron ese bono (percepción de la renta), y en dicho caso, deberá pagar IUSC.

⁶⁰ Renta exenta no es lo mismo que ingreso no afecto, entre cosas porque los ingresos no constitutivos de renta no se colacionan para efecto de la determinación de los impuestos finales, mientras que las rentas exentas si se colacionan, entre otras cosas para subir la tasa del GC.

2. Si es una renta del trabajo independiente (art. 42 No. 2). Si no se puede verificar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, llegamos al trabajo independiente. Ya sabemos que es renta del trabajo porque prima el esfuerzo físico o intelectual por sobre el empleo del capital, pero hay que analizar la siguiente alternativa de tributación: GC, por ser domiciliado o residente en Chile para efectos tributarios, o IA (art. 59 y 60), por no ser domiciliado o residente.

En el caso del GC, es un impuesto de declaración, anual, de tasa progresiva creciente, final.

4. Si no es una renta del trabajo, será una renta del capital: prima el empleo del capital por sobre el esfuerzo físico o intelectual. Las rentas del capital se pueden gravar de distintas formas.

1. Casos del art. 59 IA (el mal denominado adicional). Se trata de un impuesto de retención, mensual, aplicado a la remesa⁶¹ de rentas de fuente chilena para el no domiciliado o residente en Chile, de tasa proporcional, y es único, sobre base bruta.

Son varios los casos del art. 59, por ejemplo royalties por uso de marcos, intereses bancarios, el leasing internacional, fletes, derechos de autor. Quien haga la remesa desde Chile deberá hacer la retención del impuesto.

2. Si no estaba en el caso del art. 59, llegamos al caso de la renta de capital exenta de IDPC por disposición de la LIR (art. 39), pero gravada con IA o GC según sea el caso. Un ejemplo son los intereses en los depósitos a plazo que toman las personas naturales, que están gravados con GC.

Respecto de estos casos, no cabe aplicar el sistema integrado: no existirá crédito contra el impuesto final porque no se pagó IDPC.⁶²

3. De no estar en el caso anterior, llegamos a las “ganancias del capital” (capital gains).⁶³ Este tipo de utilidades se gravan con un impuesto especial, distinto de la mecánica integrada de IDPC con IA/GC. Generalmente este impuesto se aplica con una tasa proporcional única, y apunta a la enajenación de ciertos bienes que de suyo producen rentas ordinarias (ordinary incomes).

En algunas legislaciones, la utilidad por el mayor valor en la enajenación de una casa se grava con un capital gains tax de 10%. En otras, por la enajenación de acciones se aplicaba un impuesto único cuya tasa era la vigente para el IDPC. Son impuestos que atacan a la *fente generadora* de

⁶¹ Si no hay remesa, no hay exigibilidad, solo devengo.

⁶² El debate actual sobre el sistema integrado se genera a partir del nuevo impuesto que se creó el 2014. Cuando la renta está exenta del IDPC, ese nuevo impuesto queda en 0, y la carga total máxima será de un 35%.

⁶³ Si llegamos hasta este punto, luego de haber descartado todos los puntos anteriores, lo normal es decir que esa renta es una renta ordinaria y paga IPDC, independiente de si es una persona natural o jurídica, porque lo importante es que sea una renta descrita en el art. 20.

las rentas ordinarias (por ejemplo, los dividendos de las acciones son rentas ordinarias, que provienen de su *explotación*. Es el mismo caso del arriendo de la casa). Así, en el caso de la casa, hay que irse al art. 17 No. 8 B) (por eso es que el art. 17 no es verdaderamente solo de INR). En el caso de las acciones, está en el art. 17 No. 8 A).

El art. 107 contiene franquicias escondidas, que también tiene ingresos no renta.

4. No estando en el caso anterior, llegamos a la renta ordinaria, que paga IPDC + impuestos finales, en un sistema integrado.

¿Por qué es una renta ordinaria? Porque está claramente definida en el art. 20 como renta afecta al IDPC, impuesto de declaración, anual, sobre base neta (sigue un procedimiento para determinar la RLI).

El art. 20 No. 5 contiene el bolsón de la primera categoría, de modo tal que cuando hay una renta que no es declara ingreso no renta (art. 17), que no está exenta (principalmente art. 39 respecto del IDPC, art. 58, 60 y 63), y que no hay otra categoría que la grave, se grava como renta ordinaria con IDPC + impuestos finales, con crédito. Así, la persona natural o la persona jurídica pueden quedar afectos a IDPC y tener crédito contra los impuestos finales. Por ejemplo, la Florencia declara en el año 2020 su IDPC por el 2019, e inmediatamente se genera el crédito contra su GC.

Aquí se da lo que se conoce como “carga tributaria total”, la mejor alternativa para el Fisco y la peor para el contribuyente. El Fisco recibirá un 35% de esa renta, en la medida en que el contribuyente esté adscrito al art. 14A (renta atribuida) o 14C, o incluso un 44,45% en caso de contribuyentes del art. 14B.

ARTÍCULO 14 LIR

Tenemos una Operational Company, parte de una Holding Company, donde el accionista es una persona natural. La OpCo paga IDPC, la HoldCo está exenta, y la persona natural paga GC con un crédito. Hay un primer momento relevante en este análisis, que es ver la naturaleza de la renta de la OpCo, pues ello puede determinar toda la tributación hacia arriba, el “curriculum vitae de la renta”. Un segundo momento relevante es ver si la Hold Co es del sistema del art. 14 A o B, porque ahí sabremos cuánto y cuándo se va a pagar el impuesto final por la persona natural.

El art. 14 es un “artículo bisagra”: establece cuándo se van a tributar los impuestos finales, si es que se tiene crédito, y a qué impuesto se quedará afecto. Tenemos que sabe a su vez qué está retirando la persona natural: capital, ingresos no renta, rentas ordinarias. Así, podría alegar que solo está sacando el capital reajustado, pero la LIR tiene una norma pro fisco que dice que se imputará lo retirado primero a una renta.

Este artículo regula el tránsito desde que la renta nace y se determina su naturaleza, hasta que se paguen los impuestos finales.

El art. 14A es de renta atribuida, sin posibilidad de diferir, a contrario del art. 14B.

IMPUESTO MULTA ART. 21

“Un sapo de otro charco”

El art. 21 LIR castiga dos cosas sobre la base de gasto rechazados o retiros presuntos.

1. Los gastos deducidos en la determinación de la RLI de un contribuyente de IDPC, que no son necesarios para producir la renta. En otras palabras, castiga a quien intenta disminuir artificialmente la base imponible vía deducción de gastos que no sirven para determinar la renta. Es un impuesto del 40% sobre dicho monto deducido artificialmente, como “impuesto multa”.

En doctrina se discute que esto sea un impuesto, porque no se trata de una renta, sino un gasto rechazado. Luego, sería una multa.

2. En caso de poder identificar al beneficiario de dicho desembolso de dinero o retiro de especies, por ejemplo un préstamo a un socio cuando la sociedad tiene unidades tributables positivas. La ley lo considera como un retiro presunto, y será castigado el contribuyente final.

Hay gente que dice que esto no es un impuesto, ya que desde la perspectiva de la sociedad no hubo un aumento patrimonial, sino que un retiro o gasto

Un contribuyente podría estar identificándose con distintas hipótesis de este gran cuadro o análisis en el Formulario 22 al momento de efectuar su declaración en abril.

INGRESOS NO RENTA

Lo primero es saber si es que ese ingreso es o no renta. La definición legal de renta es muy amplia, y podríamos considerar los regalos de matrimonio como renta, las pensiones obligatorias pagadas para la manutención de la familia, la asignación de colación a los trabajadores dependientes, el aporte de capital a una sociedad, el kino, etc... En definitiva, cualquier cosa podría quedar gravada con todos o algunos de los impuestos de la LIR.

Consciente de ello, el legislador excluye determinados hechos económicos de la definición legal de renta: ingresos no constitutivos de renta. Son “rentas no renta” en muchos de sus casos.

Es tan la importancia de los INR, que una vez identificados se termina con el análisis de su tributación, y solo será relevante cuándo se podrán imputar los retiros a INRs. Por eso es que se deben registrar estos

INR en el registro REX (registro de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, antiguo FUNT [fondo de utilidades no tributables]), para que en el orden de imputación se sepa cuándo se está echando mando a ellos. En el registro REX se anotan las rentas exentas de impuestos finales e ingresos no renta.

Los INR afectan la deducibilidad de gastos y costos generados en el proceso de la determinación de la RLI, en el sentido de que los gastos y costos generados en la obtención de INR o rentas exentas deben deducirse de los INR, y no de las rentas gravadas. “Las peras con las peras y las manzanas con las manzanas”: puedo deducir gastos ordinarios de rentas ordinarias, gastos no renta solo de ingresos no rentas, pero en ningún caso puedo cruzar estos temas, porque eso atrae rechazos en cuanto a la deducción y recargos en la tributación. Si se trata de deducir un gasto para generar un INR, para disminuir la base de la RLI, el Fisco lo va a rechazar.

Algunas interpretaciones del SII han establecido un sistema de proporcionalidad en la deducción de los gastos en la tributación común: aquellos que se vinculan tanto a INR como también a rentas gravadas.

La mayoría de los INR están en el art. 17, pero no todos. Es un “listado taxativo traicionado por el propio art. 17 y la misma LIR”.

ARTICULO 17°.- No constituye renta:

29°.- Los ingresos que no se consideren rentas o que se reputen capital según texto expreso de una ley.

Es decir, el No. 29 abre un abanico de posibilidades, pues cualquier **ley** puede declarar un ingreso como no renta, o reputarlo como capital (siempre y cuando no se refiera a unidades tributables que hayan sido previamente capitalizadas). Por ejemplo, el Código de Trabajo establece determinadas indemnizaciones por años de servicio como ingresos no renta (art. 178). El No. 29 es una “norma de reenvío”.

A su vez, a propia LIR consagra INR de cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, el art. 17 no consagra la utilidad en la venta de acciones como INR, y la grava en el No. 8 con GC o IA. El art. 107 establece determinados requisitos para que esa utilidad sea un INR independiente de quién la haga (persona jurídica, natural, comunidad, sociedad de hecho, establecimiento permanente, etc...). O el caso del art. 104 por el mayor valor en la enajenación de instrumentos de deuda pública.

Si la ley puede determinar qué constituye un hecho gravado, perfectamente puede determinar lo que no es un hecho gravado. En el fondo, emana de la potestad tributaria en la forma prevista por la CPR.

Las razones que llevan al establecimiento de INRs son múltiples: políticas, económicas, sociales, técnicas.

Clasificación de los INR

Para los efectos del curso, podemos clasificar los INR del art. 17 en 5 grupos:

1. Ciclos de vida de la empresa. Por ejemplo, los ingresos que percibe la sociedad como aporte, devoluciones a los socios, que podrían incluir utilidades que fueron capitalizadas, cuotas que eroguen los asociados.

Este primer grupo es ciertamente de carácter técnico y económico.

2. Vinculados a la relación laboral. Son las sumas pagadas a los trabajadores en calidad de compensaciones, como gastos de movilización, alimentación, alojamiento, indemnizaciones por años de servicio por el término de la relación.

Se trata de criterios socioeconómicos.

3. Ganancias de capital (art. 17 No. 8). Son pocos los casos que quedan, pero en el proyecto actual de reforma vuelve a surgir la idea.
4. Indemnizaciones (no laborales) (art. 17 No. 1, 2 y 3). El carácter INR se ampara en el carácter de compensación que tiene el ingreso: restituir al contribuyente a su estado previo al siniestro.
5. Misceláneos. Aquí hay distintos tipos de INR, inconexos y mezclados, desde los gananciales y compensaciones económicas en caso de divorcio, hasta investigaciones vinculados a gastos de “I + D”.

1. VINCULADOS AL CICLO DE LA EMPRESA: ART. 17 NO. 5, 11, 6 Y 7.

1. APORTES DE CAPITAL (NO. 5 Y 11)

Teresa y Sebastián forman la sociedad “Hornitos SpA”. El aporte de capital que contribuyen los socios a Hornitos como capital de trabajo es un flujo. Se trata de aportes de capital a sociedades u otras formas de organización empresarial.

El aporte de capital lo estamos analizando desde parte de la empresa, como incremento del patrimonio por concepto de un flujo de capital. Contablemente, es el abono de la cuenta capital contenida en el patrimonio empresarial (pasivo no exigible).

Hay 6 casos de aportes de capital o situaciones equivalentes que constituyen INR de conformidad a la ley.

ARTICULO 17°.- No constituye renta:

5°.- *El valor de los aportes recibidos por sociedades, sólo respecto de éstas, el mayor valor a que se refiere el N° 13 del artículo 41 y el sobreprecio, reajuste o mayor valor obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, mientras no sean distribuidos. Tampoco*

constituirán renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación, sólo respecto de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente.

A. Valor de los aportes recibidos por las sociedades

El Código Civil define la sociedad,⁶⁴ y dice que no hay sociedad sin el aporte. El 17 No. 5 mira la situación de la sociedad receptora de este aporte (el “algo en común”), toda vez que desde la óptica del art. 2 hay un incremento de patrimonio. No estamos analizando la situación desde la perspectiva de los socios.

Por tanto el INR es solo respecto de la sociedad receptora. La LIR asume que la Teresa y Sebastián consiguieron estos aportes ya habiendo cumplido la totalidad de la tributación de los flujos. Cabe destacar que el aporte no se asimila en caso alguno a un mutuo, que lejos de constituir un aumento de patrimonio se anota como un pasivo de la sociedad.

Al mirar solo a la sociedad receptora, este INR no beneficia la devolución posterior de capital. La devolución de capital en cuanto INR está tratada en el art. 17 No. 7. Luego, no lo debemos analizar en este momento, porque el art. 17 No. 5 no se refiere a esto. Luego, ¿qué pasa con el aporte? art. 17 No. 5, ¿qué pasa con la devolución del aporte? art. 17 No. 7.

La ley no restringe la naturaleza de los aportes, y puede ser en dinero o en especies. En especies, debe hacerse al justo valor de mercado.

Ya sea en dinero o en especies, pueden estar sujetos a modalidades, como un plazo para enterarse, en cuyo caso la sociedad ha simplemente devengado un INR pero no lo ha percibido. Sujetos a condición suspensiva, **no son aportes**, mientras no se verifique la condición, pues no ha habido incremento de patrimonio alguno. Sujeto a condición resolutoria si es un aporte, y de verificarse la condición, se verificará una disminución del capital.

Aportes en especie

1. Las especies deben ser valoradas al precio de mercado, porque se verifica una dación en pago.
2. Respecto del aportante, esta enajenación en sentido amplio puede producir efectos tributarios. Por ejemplo, la Tere decide aportar un inmueble o acciones de Copec. Ese aporte puede producir respecto de ella un efecto tributario, porque podría producirse una utilidad por un mayor valor en la enajenación, por lo que debemos revisar el artículo pertinente, pues podría tratarse un ingreso

⁶⁴ **Art. 2053.** *La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.*

La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.

no renta. Lo claro es que podría haber un aumento patrimonial.

3. El hecho de que el valor deba ser el de mercado, va de la mano de la facultad del SII para tasar por el art. 64 CT.⁶⁵ Se puede tasar el valor de la enajenación para el aportante, o el costo de dicho aporte. Es decir, se puede tasar un mayor valor o un menor valor. Podría ser relevante analizar el costo porque Hornitos podría en los siguientes días enajenar las acciones y verificar una pérdida artificial a nivel de la determinación de su RLI.

Si el valor es notoriamente superior, respecto de la Tere podría haber una franquicia que la exima del pago de impuesto, mas no respecto de Hornitos. A la Tere no le importará aportar las acciones a un valor notoriamente superior, por ejemplo en 1000 en vez de 100 (precio de mercado), y el día siguiente Hornitos las vende en 110, para tener una pérdida artificial de 890, que será un activo financiero para Hornitos ya sea en el mismo ejercicio o en los siguientes.

4. ¿Qué pasa con los aportes de muebles e inmuebles corporales? Tenemos que revisar el mundo del IVA. Puede que la Tere sea contribuyente de IVA para ciertos productos. Imaginemos que la Tere actúa como empresaria individual, u otra sociedad que está formando una nueva sociedad, que podría hacer el aporte con el activo realizable, y se verificaría IVA. O podría hacerlo con activo fijo, en cuyo caso hay que revisar el art. 8 M LIVA (hecho gravado especial), y probablemente se gatillo el IVA (salvo que fuera un 14 ter).
5. No obstante que los aportes constituyen un INR para la empresa que lo recibe, en el caso en que se estén aportando créditos o cuentas por cobrar, derechos personales, podría producirse un ingreso renta. ¿En qué caso?

La Tere aporta una cuenta por cobrar en 100, pero el documento es por 150. La sociedad acepta que se le pase un “cacho”, con posibilidades inciertas de que se vaya a cobrar 150 (pensar en sociedades de factoring). En el fondo la sociedad lo castiga al aceptarlo. Si la gestión de cobro es exitosa, va a haber pagado con acciones 100, pero adquirió un delta de 50. Solo serían INR los 100 contabilizados al momento del aporte, pero no los 50 “extra” que se lograron cobrar.

Esto es muy importante, sobretodo si la sociedad no es solo una rentista de capitales mobiliarios, sino que además desarrolla actividades de los No. 3 y 4 del art. 20 LIR. Aparecen obligaciones accesorias, como llevar contabilidad, iniciar actividades, pagar PPMs, pagar patente municipal según CPT, y tributará sobre renta devengada o percibida cualquiera ocurra primero. Por lo tanto, si recibe un documento a 100, pero el documento es por 150, debería tributar por los 150 porque tiene un título independiente de su actual exigibilidad.

⁶⁵ Hay circunstancias extraordinarias que podrían impedir al SII tasar, “las reorganizaciones libres de impuesto” cuando hay una reorganización sin flujo efectivo de dinero, como en caso de fusiones o “legítima razón de negocio”. Son las reorganizaciones intra grupos, en que, respetándose los valores tributarios, se posterga la revalorización del activo

El SII ha señalado que el aporte verificado en la constitución de una fundación, por tratarse de un acto inicial de dotación a una nueva persona jurídica, es asimilable a los aportes de capital referidos, y por lo tanto son INR. Esto hay que unirlo respecto de otro INR que veremos más adelante, referido a las cuotas que erogan los asociados. Si pensamos en la Fundación La Rosa, nadie va a registrar cuotas o derechos de la fundación, porque la fundación es una suerte de patrimonio de afectación, sin dueño. Cuando una persona jurídica o natural aporta a este tipo de instituciones reguladas en el CC, no recibe nada a cambio, no puede contabilizar en su activo derechos o acciones de la fundación, porque no tiene propietarios, en cuanto patrimonio de afectación separado e independiente. Nadie va a consolidar en sus estados financieros resultados de la fundación.

Ahora bien, si la fundación explota esos aportes (e.g pone la caja a interés en el banco, arrienda un inmueble aportado, etc...) esa renta es ordinaria y paga IDPC con una tasa especial de 25%. Luego, la fundación sí es contribuyente de IDPC, pero no por los ingresos que recibe como aporte. Pero las rentas que provienen de la explotación de esos activos si están afectos y se debe llevar una contabilidad.

Si una persona jurídica quiere efectuar un aporte a una fundación, es una complejidad: ¿a qué título sale ese retiro? Lo más probable es que exista un gasto rechazado y aparezca el art. 21 LIR, más allá del impuesto a la donación. En el fondo es una donación, porque no hay una contraprestación por el retiro. Si consideramos además que en algunos casos podría no haber exención al impuesto a la donación, se hace carísima la operación.

B. Sobrepuestos, reajustes o mayor valor obtenido por las sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión mientras no sean distribuidas

Hortifruit SA tiene como accionistas a Juan Sutil, Victor Moller, General Foods. Los aportes de capital pueden realizarse de distintas formas. Por ejemplo, un aumento de capital vía colocación de acciones de su propia emisión (acciones de pago).

¿Cómo se realiza un aumento de capital vía emisión de acciones de pago?

1. El gerente general se reúne con el gerente de finanzas, quien va a determinar un presupuesto para el listado de inversiones que le permitirán obtener, dentro del giro, una rentabilidad esperada. Se hace una valorización del capital de trabajo para materializar estas inversiones. Dentro de estas valorizaciones están los aspectos tributarios.
2. Se presenta el tema al directorio.
3. Si se aprueba por el directorio, el directorio cita a Junta de Accionistas Extraordinaria porque la LSA manda a ello. Se le propone un “valor de colocación de las acciones en el mercado”, que deberá ser suscrito y pagado dentro de los plazos legales (3 años en el caso de la SA).

El SII no se puede meter a tasar el valor de la colocación, a juicio de Pereira, porque la propia LSA dice que la Junta es soberana en determinar el precio de la colocación. Obviamente los accionistas controladores van a exigir una razonabilidad, porque ello podría implicar una dilución en su participación, dependiendo de dicho valor (si ingresan muchos nuevos accionistas, ellos se ven diluidos en su participación).

Asumamos que cada acción se va a colocar a 100. El mercado reacciona de manera positiva y se llegan a recibir 200 pesos por acción. La pregunta tributaria es qué sucede con el mayor valor en la colocación de las acciones de propia emisión en cuanto mecanismo de aumento de capital. La ley nos dice que es un INR, *mientras éste no se distribuya*. ¿Dónde va a registrar tributariamente Hortifruit el diferencial de 100? Lo registrará separadamente de los otros 100, en el REX.

Apenas lo distribuya, pasa del REX al RAI, que son las unidades tributables de ese ejercicio. Es decir, hay un registro temporal del mayor valor de las acciones *para Hortifruit*, hasta que lo distribuya.

Desde una perspectiva de la LSA, hay una discusión interesante. El art. 26 LSA dice que el mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago, por sobre el valor que se obtenga de dividir el capital a enterar por el número de acciones emitidas, aumentará el capital de la sociedad, y *no podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas*. En definitiva, se trata de una norma que considera esta diferencia como más capital. Por esta vía, al ser más capital, un INR. *A contrario sensu*, el menor valor en la colocación constituiría una disminución del capital de la sociedad. Pero debemos recordar que el mayor valor, desde una perspectiva tributaria, es un INR mientras no sea distribuido. Como consecuencia de la distribución, la sociedad que la efectúa deberá incluir en la BI del IPDC este sobreprecio, reajuste o mayor valor, como un ingreso más, y gravarlo con IDPC. Se traslada en ese ejercicio desde el REX al RAI (FUNT a FUT): del minuto en que se registra en el RAI, los accionistas finales deberán incluirlos en su GC o IA, con un crédito por el IDPC pagado.

El art. 14 regula el tránsito impositivo. Con la reforma del 2014 se estableció el sistema de Last In First Out. Luego, lo más probable que es a medida que se vayan generando utilidades tributables que se distribuyan, no estarán saliendo como INR, sino que se imputarán en primer lugar a rentas gravadas con impuesto pendiente.

C. Sumas o bienes que tengan el carácter de aportes entregados por el asociado al gesto de una cuenta en participación, solo respecto de la asociación, en la medida que se acrediten fehacientemente.

En la cuenta en participación, el gestor la representa. Se trata de un mandato, normalmente remunerado, porque el gesto tendrá derecho a un porcentaje de las utilidades que se generen, aportando él su administración.

Aquí tenemos a dos personajes: el gestor y el asociado/partícipe. El RUT de la ACP es el del gestor. Entre el gestor y el asociado hay un contrato en que se establece el porcentaje que lleva cada uno de la

gestión. Es un contrato que se da entre comerciantes, y es el gestor quien emprende a su propio riesgo una empresa frente a terceros: el asociado no existe para los terceros (incluyendo al Fisco), y el gestor es mirado como único dueño.

***Artículo 28.-** El gestor de una asociación o cuentas en participación y de cualquier encargo fiduciario, será responsable exclusivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias referente a las operaciones que constituyan el giro de la asociación u objeto del encargo. Las rentas que correspondan a los partícipes se considerarán para el cálculo del impuesto global complementario o adicional de éstos, sólo en el caso que se pruebe la efectividad, condiciones y monto de la respectiva participación.*

La contabilidad será el gran medio de prueba en la ACP, y deberá guardar relación con el contrato. Por eso el art. 28 indica que el gestor es responsable exclusivo de las obligaciones tributarias *derivadas del giro de la operación*. Las rentas derivadas se van a calcular para el GC o IA, en la medida que se pruebe la efectividad, condiciones y monto de la respectiva de participación. Esto se prueba con el contrato y con la ACP.

Para la ACP, los aportes que haga el partícipe serán INR. La norma tipifica esta situación, que solo repite la regla general del aporte de capital, para que no haya duda al respecto toda vez que el partícipe no existe para el mundo tributario.

El CT distingue entre los ingresos que corresponde a la asociación, y los que corresponden al partícipe y al gestor.

La última tendencia, no obstante el texto expreso, señala que “si se prueba la efectividad, condiciones y monto de la respectiva participación, tanto el gestor como el partícipe asumirán todas las referidas obligaciones tributarias de forma separada respecto del resultado que se determine por la asociación o encargo fiduciario que corresponda”. Luego, podría llegar a tener efectos tributarios para el partícipe en la medida que se prueben los elementos señalados.

La ACP se da usualmente en actividades de alto riesgo inicial, como la explotación minera, petrolera y de gas.

D. Revalorización del capital propio

Estamos frente a un contribuyente cuyo patrimonio (activo - pasivo) se valoriza, se determina, se corrige o actualiza según el mecanismo de corrección monetaria. Se trata de un ajuste por inflación, para proteger el verdadero valor de los activos y pasivos y no se afecten artificialmente por la inflación.

El art. 41 No. 13 LIR contempla este proceso de corrección monetaria para proteger la contabilidad. Nos dice que los contribuyentes de IDPC que determinan renta según balance deben revalorizar el

patrimonio tributario o capital propio tributario y sus variaciones (aumentos o disminuciones), para ajustarlo por la variación de la moneda. Se recoge la fluctuación del IPC en el ejercicio correspondiente.

El capital propio es exclusivo de la materia tributaria, y corresponde al [activo - pasivo]. El art. 41 No. 1 LIR define al CPT: la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha de iniciación del ejercicio comercial. De este monto, se deben rebajar previamente ciertos valores, “valores INTO”: intangibles, nominales, transitorios, de orden (y otros que determine la dirección nacional), que no representen inversiones efectivas.

Este monto, fotografía de cierre del 31 de diciembre o de 1 de enero, se debe reajustar, o incluso durante el año en caso de haber retiros o aumentos/disminuciones de capital durante el ejercicio. Dentro del activo están el capital y las utilidades retenidas, que pueden ser utilidades tributables. La distribución de dividendos o retiros de utilidades disminuye tanto el patrimonio financiero como el CPT.

El CPT inicial debe ser reajustado por la variación del IPC, entre el ultimo día del mes anterior a la iniciación del ejercicio (normalmente el 30 de noviembre) y el último día del mes anterior al del balance. Los aumentos de capital propio durante el ejercicio deben ser corregidos por el porcentaje de variación del IPC, entre el ultimo día del mes anterior al del aumento y el ultimo día del mes anterior al del balance.

A contrario sensu, las disminuciones de capital durante el ejercicio se reajustan entre la variación del IPC entre el ultimo día del mes anterior al retiro y el ultimo día anterior al balance (30 de noviembre).

Lo que nos dice la norma es que la persona no se ha hecho más rica ni más pobre, sino que es solo un tema de inflación. El art. 41 No. 13 nos dice que el mayor valor que resulte de la revalorización del CPT y sus variaciones no estará afecto a impuesto, y será considerado como CPT, a contar del primer día del ejercicio siguiente, pudiendo traspasarse su valor al capital y/o reserva de la empresa. Es decir, esa revalorización producto del IPC, se considera CPT, y al considerarla como tal queda definida como INR.

Hay que tener en mente la incompatibilidad del art. 18 con el art. 41: si se lleva la contabilidad en moneda extranjera, no aplica la corrección monetaria.

La revalorización del CPT es una pérdida para el contribuyente. El ajuste se carga a una cuenta de resultado denominada corrección monetaria. La lógica contable de la LIR penetra con fuerza en materia de corrección monetaria. Se trata de un gasto necesario en la determinación de la RLI como consecuencia de la corrección monetaria (complementar con el art. 41 No. 12 A LIR). Es decir, si se tiene un INR, para corregirlo se crea una pérdida en el estado de resultado: todo esto para neutralizar la “utilidad” generada por la variación el IPC.

E. Cuotas que eroguen los asociados (No. 11)

Se trata de aportes a clubes, corporaciones, fundaciones... tiene una gran relevancia, porque el mecanismo de muchas organizaciones intermedias sin fines de lucro recae justamente en este tipo de aportes.

La ley no distingue, y el SII ha señalado que para la calificación de estas cuotas carece de importancia si el carácter de las cuotas es ordinario o extraordinario, ni que sean fijas o variables. También se hace extensivo este análisis a las cuotas pagadas por los trabajadores asociados a los sindicatos, que no pagan impuestos. Lo mismo sucede con las mutualidades, los traspasos de bienes a corporaciones y fundaciones con posterioridad a su constitución.

F. Asignaciones a empresas individuales y establecimientos permanentes (No. 7)

No se trata propiamente tal de aportes, ya que no existe una enajenación, sino una mera asignación de capital a una empresa individual. Lo mismo sucede en el caso de un establecimiento permanente. Pero desde la perspectiva contable éstas asignaciones a las EI y EP son aportes de capital; se pueden amparar en los INR que hacen mención a los capitales respecto de los aportantes.

Ese aporte asignado será un INR.

Las EI y EP constituyen “una especie de patrimonio de afectación tributaria”. El flujo de utilidades desde la EI a su titular se rige por las normas del art. 14 LIR.⁶⁶

Respecto del EP, se define por la OECD en el art. 5 de su Modelo de Convenio como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Se trata de un hecho, y no de una persona distinta de la empresa. Algunos autores han dicho que estamos frente a una actividad desarrollada por una empresa principal en una jurisdicción distinta. En el fondo, el EP comparte la personalidad jurídica de la empresa. De ahí que un ejemplo clásico del EP sea la agencia, que es el ejemplo dado a modo de concepto por la LIR en el art. 58 No. 1. Así, cualquier tipo de mandato en virtud del cual el mandatario se encuentra expresamente facultado para cerrar negocios frente al mandante. Atrae la potestad tributaria para que la primera jurisdicción grave (de la jurisdicción de la matriz).

La situación de los EP, la asignación de capital a ellos, si bien constituye un aumento de patrimonio contable también podría ser tratado como un INR.

La situación de la EP es sin embargo más compleja. Por ejemplo, tenemos ABB Suiza que manda a su EP a Chile. Entre ABB y Colbún hay un contrato de EPC; (engineering, procurement, construction and management contract).

⁶⁶ El art. 14 A, B y C, 14 ter y 34 LIR regulan el cuánto y cuándo se aplican los impuestos finales. Regulan “el tráfico intestinal tributario”.

1. De conformidad al art. 38 LIR, la asignación de activos por parte de la matriz exterior al EP son tasables por el SII, por el art. 64 CT (no está dentro de las excepciones que establece el propio art. 64 para la libre reorganización empresarial).
2. Las EP deben solicitar RUT e iniciar actividades. Pero a diferencia de EI, el RUT es distinto del RUT de la matriz: hay una ficción al respecto.
3. Los EP deben mantener una contabilidad en la que registren sus activos y capital. Son asignados de la misma forma que se verifica en la EI.
4. Hay que tener cuidado en las normas sobre precios de transferencia (art. 41 E). Se está realizando una transacción, aunque sea asignación, con valores entre empresas relacionadas y crossborder. Al ser la EP un contribuyente distinto, debe respetarse el valor internacional del activo asignado, como si esa asignación se estuviera realizando con un tercero independiente siguiendo el principio de Armed Length Basis .

En definitiva, la asignación de capital a un EP, si bien constituye un incremento patrimonial para el mismo, es tratado como un INR.

2. DISTRIBUCIÓN DE CIERTAS UTILIDADES (NO. 6)

6°.- La distribución de utilidades o de fondos acumulados que las sociedades anónimas hagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las acciones, todo ello representativo de una capitalización equivalente, como así también, la parte de los dividendos que provengan de los ingresos a que se refiere este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 respecto de los números 25 y 28 del presente artículo.

Este artículo fue derogado por la primera ley tributaria de Bachelet, y luego fue reinstaurado. Busca consagrar como INR determinadas distribuciones de utilidades efectuadas por SA y SpAs. Lo que caracteriza a estas distribuciones de utilidades constitutivas de INR es que no existen flujos desde la sociedad a los accionistas.

La ley trata las distribuciones de utilidades en forma de acciones crías (o liberadas de pago), o aumento del valor nominal de las acciones. A su vez, trata la distribución de utilidades con cargo a INR.

Por ejemplo, Copec SA tiene utilidades del ejercicio, que va a distribuir a sus accionistas. La ley le plantea alternativas para cómo distribuir las mismas.

Este artículo se puede analizar desde dos líneas. Una primera línea es distribuir utilidades sin mediar flujo: se materializa a través de acciones crías, o bien por medio de aumentar el valor nominal de las acciones existentes. Luego, los accionistas de Copec van a recibir o (i) más acciones que no tuvieron costo, o (ii) mantener el número de acciones pero con un aumento de su valor nominal.

Lo que busca Copec es mantener la caja dentro de la sociedad, como capital de trabajo. Así, si quiere abrir un nuevo local, en vez de llamar a los accionistas a concurrir a un aumento con nuevos aportes, capitaliza la caja que ya tiene para financiar el aumento.

Distribución de crías

No es renta la distribución de rentas o fondos retenidos en forma de acciones total o parcialmente liberadas de pago, manifestadas en una capitalización equivalente. En el fondo, este INR es un mecanismo de financiamiento empresarial, porque la utilidad permanece dentro de la sociedad. Cada accionista tendrá derecho a un dividendo que se expresará en un número proporcional de acciones. La sociedad capitaliza utilidades y emite acciones crías, donde cada accionista obtiene a título de acciones una cantidad proporcional al aumento, en base a las acciones madres.

El INR pasa a ser una franquicia tributaria para que por un lado el accionista quede contento, y por el otro lado, lograr el aumento de capital. Este accionista incrementa su patrimonio, pero no hay un flujo de caja a su favor. El INR está limitado al monto de la capitalización.

Cuando este accionista decida vender sus acciones, madres y crías, el costo de las crías no tienen un costo porque nunca se pagó un precio por ellas. Por eso, se aplicará la regla de la proporcionalidad: el costo de las acciones madres se distribuye entre todas las acciones. Luego, por el hecho de emitirse acciones crías, automáticamente baja el valor de las madres.

La forma en que la mayoría de los grupos empresariales se han organizado ha sido por medio de HoldCos y OpCos. Lo que hacían los accionistas controladores era primero distribuir utilidades. Los accionistas minoritarios persona natural debían pagar el GC. Luego, inmediatamente aprobaban un aumento de capital, para el cual los minoritarios debían conseguirse un crédito para concurrir al aumento, además de pagar su GC. Esto se iba haciendo continuamente cada tantos años, con lo que se lograba diluir a los minoritarios.

El art. 17 No. 8 dice que las crías únicamente incrementarán el número de acciones de propiedad del contribuyente, manteniéndose como costo de adquisición del conjunto solo el valor de adquisición de las acciones madres. Otra forma de decir esto es que si bien no se altera el costo global de las acciones para efectos tributarios, si se afecta el costo unitario de las mismas.

En el IDPC, hay dos opciones: art. 14 A (atribuido) o B (parcialmente integrado). Supongamos que estamos en el art. 14A (renta atribuida -en realidad, parcialmente atribuido-), de modo tal que devengada o percibida la renta, inmediatamente ésta se atribuía a los contribuyentes finales en el mismo ejercicio en que se devengó o percibió la renta. Esto, independiente de que se haya distribuido el flujo de caja o no.

Considerando que la distribución de utilidades previamente atribuidas en el caso de las sociedades 14A, ¿qué pasa si se han emitido acciones crías? En el sistema 14A, ya se atribuyó esa utilidad, aunque no se haya distribuido la caja. Es decir, los contribuyentes finales ya colacionaron en su GC esa unidad

tributable aunque se haya quedado como capital de trabajo en la sociedad. La ley sin embargo previene que en este caso, tendrán derecho de deducir del mayor valor de la utilidad, la proporción correspondiente a las utilidades previamente atribuidas, pero retenidas en la sociedad. En otras palabras la ley le está dando un costo al mayor valor. La ley está solucionando una inequidad que se generaría al momento de vender las crías, para los accionistas a quienes se le disminuyó el costo de sus acciones por la emisión de acciones crías, y que deberá pagar GC por ese mayor valor.

Ej. Si la caja permaneció en Hornitos SpA (acogida al régimen 14A), cuando la Tere venda las acciones, la ley le permite deducir de su utilidad (le da un costo) por la venta de las acciones crías la proporción correspondiente a las utilidades previamente atribuidas pero que se retuvieron en la sociedad y que fueron causa del aumento de capital que se tradujo en la emisión de acciones crías.

Aumento del valor nominal de las acciones

A las acciones se les podría dar un valor estatutario. Aquí, el accionista no recibe acciones nuevas (crías), sino que sobre el mismo numero de acciones, el valor estatutario de cada una de ellas aumenta.

El aumento del valor nominal no genera efecto en el costo de las mismas: no hay nuevo costo.

Carácter real de los INR

“(...) como así también, la parte de los dividendos que provengan de los ingresos a que se refiere este artículo”

Esta parte del artículo reitera el carácter real de los INR. Reconoce que el INR generado por la sociedad mantiene ese carácter para los accionistas o socios una vez que éste se distribuya. Por tanto, si se ha caracterizado un ingreso como INR a nivel de Hornitos SA, cuando salga ese ingreso (siguiendo el orden de prelación), no se va a colacionar para el GC o IA, porque mantiene en toda su vida el carácter de INR.

Tanto en el sistema 14A como el 14B, se establece un registro especial para contabilizar los INR: el REX, antes FUNT. Los contribuyentes de IDPC que determinen renta según balance (e.g EI), que obtengan INR, deben registrarlos en el REX, y dentro del mismo, en la columna “INR”. El REX tiene dos columnas: rentas exentas e INR. Hay distintos efectos para el contribuyente el sacar de una u otra columna.

La propia ley excluye del tratamiento de INR a los dividendos distribuidos con cargo a ciertos reajustes que son no-rentas en los números 25 y 28 del art. 17 LIR. La razón de esta exclusión radica en que en la etapa de corrección monetaria hay una deducción por estos conceptos. La exclusión se efectúa con la finalidad de no verificar una doble deducción (la corrección monetaria ya se verificó en la determinación de la RLI).

3. DISMINUCIONES DE CAPITAL (ART. 17 NO. 7)

Está íntimamente ligada a la prelación en la distribución de actividades que regula el art. 14.

Lo que nos dice este artículo es que a los contribuyentes se les está devolviendo el pasivo no exigible que pusieron inicialmente y que no constituye aumento de patrimonio (reajustado). Pero, no toda disminución de capital es un INR.

Una modificación a los estatutos sociales que para todos los efectos legales, incluidos los tributarios, es una disminución de capital social no necesariamente constituye total o parcialmente un INR para el socio o accionista que lo percibe.

Para la calificación como INR en una disminución de capital, la ley dispone de una serie de requisitos, es decir, no es automático.

1. No debe tratarse de utilidades tributables capitalizadas. El capital de la sociedad se encuentra en los estatutos, donde se consigna el monto del capital legal. Este capital legal puede tener diversos orígenes, entre estos, el aporte original o de aumentos posteriores.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, las utilidades distribuidas podían ser utilizadas para aportar en otra sociedad, sin pagar impuesto final (había una franquicia). Se trataba de una utilidad tributable que nacía en una sociedad y terminaba en otra, pendiente el impuesto. Esta franquicia fue derogada.

Otra fuente podría ser la capitalización del capital original o sus aumentos.

Por último, podría ser una capitalización de utilidades financieras o tributarias que hayan estado retenidas.

Luego, el capital estatutario de una sociedad es una cosa, pero la suerte tributaria del mismo depende de múltiples factores, siendo el más importante determinar si es capital propiamente tal, u otra cosa que fue capitalizada por la sociedad. Por eso la LIR dice que la calificación de INR no se extiende a las devoluciones de capital imputadas a “utilidades sociales capitalizadas que deban pagar impuestos”. Porque la ley está consciente de que existen una heterogénea conformación del capital legal. Luego, hay que determinar si se trataba de un verdadero INR, o si se trataba de “disfrazar” bajo el nombre de capital, utilidades con impuesto pendiente. Por tanto, hay reglas especiales para determinar lo que constituye devolución de capital INR.

En el fondo, por la exclusión de las utilidades capitalizadas, la LIR se asegura que las distribuciones de INR sean capital propiamente tal.

7°.- Las devoluciones de capitales sociales y los reajustes de éstos, efectuados en conformidad con esta ley o con leyes anteriores, siempre que no correspondan a utilidades capitalizadas que deban

pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas, remesadas o distribuidas por estos conceptos se imputarán y afectarán con los impuestos de primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la forma dispuesta en el artículo 14, imputándose en último término el capital social y sus reajustes, sólo hasta concurrencia del monto aportado por el propietario, socio o accionista perceptor de esta devolución, incrementado o disminuido por los aportes, aumentos o disminuciones de capital que aquellos hayan efectuado, cantidades que se reajustarán según el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes que antecede a aquél en que ocurrieron y el mes anterior al de la devolución.

Cualquier retiro, remesa, distribución o devolución de cantidades que excedan de los conceptos señalados precedentemente se gravarán con los impuestos de esta ley, conforme a las reglas generales.

Esta norma nos dice que la devolución de capital reajustada es INR. Salvo, cuando existan utilidades tributables capitalizadas, en cuyo caso salimos del art. 17 y la ley nos remite al art. 14. Esto, porque esas utilidades pueden tener pendiente desde el IDPC hasta el GC o IA. Se establece el orden de prelación, por el cual las utilidades que se saquen de la sociedad se imputarán primero a rentas afectas.

2. Seguir el orden de prelación del art. 14. Con independencia del nombre que se le puso a las distintas cuentas de patrimonio, éstas pueden corresponder a cantidades con distinta naturaleza tributaria. En el patrimonio de la empresa pueden coexistir rentas gravadas con IDPC, rentas exentas de IDPC pero afectas a los finales, rentas afectas a IDPC pero exentas de los finales, utilidades financieras en exceso de las tributarias, capital puro, y otras cantidades no identificadas (la ley castiga este último caso).

A la LIR le interesa establecer un orden de prelación en la distribución del patrimonio, con independencia de la denominación que se haya usado en la cuenta patrimonial. Primero, se deben distribuir cantidades afectas a impuestos (norma pro fisco), y solo posteriormente las no afectas. Así, si el contribuyente final sacó una cantidad equivalente a su aporte original, primero debe imputarlo al GC cuyo pago está pendiente.

El tratamiento tributario de las devoluciones de capital va a depender del sistema al cual se esté adscrito dentro del art. 14 (A, B y C), ya sea por opción u obligación legal. Tenemos que ver “qué es lo que sale”, porque como ya vimos, podría ser una renta gravada, exenta, gravada por IDPC y no por impuestos finales, etc... Es el art. 14 el que nos ayudará en el orden de prelación para determinar en definitiva si es un capital propiamente tal o una utilidad disfrazada bajo el nombre de capital.

Registros para el sistema de atribución

Caso. Hornitos Ltda., con accionistas Teresa y Sebastián, está adscrito al sistema 14 A de renta atribuida. La última reforma tributaria eliminó el FUT. Era un curriculum del crédito del IDPC pagado, y es propio de los sistemas integrados, total o parcialmente. La simplificación que buscaba la reforma corría entre otras

cosas por eliminar el FUT, pero lo único que se logró fue cambiarle el nombre a RAI, porque seguimos en un sistema integrado y eso requiere de un curriculum de la renta.

Hay varios registros, para saber qué cosa estoy retirando, si tiene o no crédito (si pagó IDPC), sus características, y cuándo debe colacionarse para los impuestos finales.

1. **Rentas Atribuidas Propias (RAP).** Son rentas que a fin de año ha recibido o devengado Hornitos, y que se atribuyen. Lo que se anota es el saldo o resultado de la RLI; las rentas exentas de IDPC pero afectas a impuestos finales; y cualquier otra cantidad que por cualquier motivo no pague IDPC pero no esté exenta de impuestos finales (serán un incremento patrimonial para el contribuyente final).

Las rentas del RAP se atribuyen automáticamente; no es necesaria la correlación entre la atribución y la distribución de las rentas.

El incentivo para tener renta atribuida es que la carga tributaria máxima es de un 35%. Así, quienes optan por este sistema son aquellos que consumen la totalidad de las rentas que genera este contribuyente. Si les sobrase mucho, el incentivo para diferir aumenta, evitando la atribución. La Tere y Sebastián necesitan las rentas de la sociedad para su día a día, por lo que no dejan nada dentro de la misma sociedad, no tienen un excedente.

Por el contrario, uno empieza a analizar si es conveniente ir al 14 B cuando lo que se saca desde la empresa es muy poco, y no se saca como retiro sino que como sueldo, y lo que no se saca queda dentro de la sociedad.

La critica doctrinaria al sistema de renta atribuida es justamente que hay un desincentivo para mantener las utilidades dentro de las empresas.

2. **Diferencias entre depreciación acelerada y depreciación normal (DDAN).** Se trata de cantidades que no han sido gravadas con IDPC, pero que adicionalmente se van a afectar con GC o IA al momento de su distribución.
3. **Rex.** Aquí se anota las rentas exentas de GC o IA, y también los INR. Excepcionalmente podrían anotarse otras cantidades que por disposición expresa de la ley han cumplido con la totalidad de su tributación. Por ejemplo, las ganancias al capital (capital gains tax), que tiene un impuesto único, de modo que tal que, si es un impuesto único, no puede afectarse esa cantidad con otros impuestos (como los finales).
4. **Saldo Acumulado de Crédito (SAC).** Es el curriculum de las rentas. No es un registro propio del sistema de atribución, sino que del sistema parcialmente integrado, porque las cantidades anotadas en él corresponden por regla general al traspaso de créditos, y en el fondo, cuando se atribuye, se atribuye también con el crédito subyacente. Por lo tanto, no queda crédito para futuras atribuciones.

Sin embargo, podría quedar un crédito histórico de algún FUT que se traspasó cuando se hizo el cambio del sistema.

5. **Fondo de utilidades reinvertidas (FUR).** Es un fondo histórico porque se dejó de hacer reinversión de utilidades. Se anotaba en este registro justamente dichas utilidades reinvertidas.

En un mismo ejercicio, las rentas de Hornitos se atribuyen a la Tere y Sebastián. Queda ver entonces cómo funciona en el 14A “el vaso precipitado”, es decir, el orden de prelación. El orden de prelación correspondiente a las devoluciones de capital en un sistema de 14A es el siguiente:

1. Por una norma transitoria de la última reforma, lo primero que sale es el **FUR**, es decir, devoluciones de capital de un inversionista que hubiere efectuado reinversiones, en la medida que no haya vendido, transferido o cedido sus derechos o acciones.
2. **RAP.** Son rentas atribuidas que ya han agotado su tributación en la LIR. Por ejemplo, estoy haciendo una disminución de capital en el año 4, y su atribución fue del año 1. ¿Está afecta esa disminución de capital a impuesto final? No, porque ya pagaron, ya completaron su tributación en el año 1 cuando se atribuyó por el solo ministerio de la ley. Luego, no se imputan a los impuestos finales al retirarlas.
3. **DDAN.** Son una suerte de utilidad financiera sobre la utilidad tributaria. Es una utilidad financiera que generó un gasto tributario mayor, y por tanto no pagó IDPC; luego, no tendría derecho a crédito. Sin embargo, la ley, no obstante saber que no pagó IDPC, le otorga un derecho a crédito. En el fondo, va a implicar tener que echar mano al SAC: se puede utilizar el crédito disponible en el SAC, disminuyéndolo.
4. **REX.** Podemos notar que no es fácil llegar al REX en una disminución de capital o devolución, porque primero tenemos que agotar todos los otros registros. Sobre todo porque después de la última reforma, se aplica el sistema Last In First Out, por lo que algún impuesto se generará antes de llegar al REX.
5. **STUT.** Se refiere a utilidades heredadas del sistema antiguo, donde podríamos encontrar el crédito FUT, o también utilidades financieras en exceso de las tributables.
6. **Devoluciones de capital que constituyen INR.** Recién ahora llegamos al art. 17 No. 7.
7. ¿Qué pasa si se han distribuido por cualquier motivo cantidades superiores a las señaladas anteriormente? Es decir, se han agotado todos los registros y todavía queda caja o activos, que pueden ser utilidad o no (e.g al término del giro). Antiguamente, eso era un INR, porque no estaba descrito dentro de los registros anteriores. ¿Qué se produce para la Tere, Sebastián y la Scarlett en este caso? Un incremento patrimonial, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. Ni siquiera puede

considerarse capital inicial porque ese ya se retiró antes en los registros. Podría catalogarse como una renta del art. 20 No. 5, que llegaba a una persona natural, afecta a impuestos finales.

8. **Impuesto sustitutivo al FUT.** Era una norma transitoria de la reforma. Como la reforma cambió las reglas del juego al pasar de First In First Out a Last In First Out, se estableció un mecanismo para que las empresas pagaran un impuesto único sustitutivo. En el fondo, buscaba no discriminar entre la empresa de hoy que iba a poder usar el crédito y la empresa mas vieja que iba a tener que pasar por todo el orden de prelación.

La empresa tenía un FUT con crédito, que probablemente no iba a poder usar porque ahora la regla era LIFO y tenían que agotarse todos los registros anteriores antes de llegar al FUT. La ley, que necesitaba además recaudar, estableció una fórmula win-win. Al contribuyente le podía convenir sacar utilidades limpiando ese FUT histórico. Con la tasa promedio del GC de los últimos 5 años, por ejemplo 20%, se podía echar mano a esa utilidad pagando la diferencia entre ese 20% con el crédito promedio del FUT (e.g 15%): se pagaba un impuesto único de 5%. Si se pagan esos 5% hoy al contado (de ahí el incentivo del Fisco para establecer esta norma), entonces ese FUT sustitutivo se puede anotar en el REX y sacarse cuando se quiera sin respetar el orden de prelación.

Alternativamente, se podía pagar un 30% de impuesto con descuento del crédito promedio. Ahí, el contribuyente tenía que comparar qué le convenía.

Para acogerse a esta norma, era necesario pagar todo al contado, justamente porque el Estado necesitaba plata.

Ahora, esto de limpiar el FUT no implicaba que el contribuyente dejaba de pagar un 30%. Lo que pasa es que lo pagó con un crédito, que había pagado hace muchísimo tiempo.

En el nuevo proyecto también hay una norma sustitutiva de este estilo, porque se necesita caja.

El problema es que cualquier persona rica se asesoró e hizo la simulación, acogiéndose al FUT sustitutivo. Los que se vieron afectados realmente eran las personas de clases media, que no supieron cómo aprovechar esta franquicia.

Registros para el sistema de retiro o parcialmente integrado del 14B

Los registros DDAN, REX, FUR y SAC son comunes para ambos sistemas. Son propios del art. 14 B los siguientes.

1. **Rentas Afectas a Impuestos (RAI).** Se trata de rentas afectas a impuestos **finales**. Aquí, vamos a contabilizar todo lo que se afecte con IA o GC, y este registro se basa en el CPT de la empresa para su confección. Hay todo un procedimiento para determinar el RAI, que Pereira lo resume en: [CPT - (Rex (incluye al FUNT antiguo) + Capital Propiamente Tal + FUR)]. En la determinación del RAI, se

le resta el STUT (ex FUT).

La ley definió como RAI todo aquello que no haya cumplido totalmente su tributación. Por tanto, equivale al CPT (activo - pasivo), descontado todo lo que es renta exenta, el capital propiamente tal, y las utilidades reinvertidas. A ese resultado, se le elimina el STUT, que queda en el registro STUT.

Luego, en el 14 B la prelación es la siguiente:

1. FUR (por eso se saca del RAI)
2. RAI. Así, una sociedad nueva llega rápidamente al RAI.
3. DDAN
4. REX
 1. Rentas exentas
 2. INR
5. Cantidades no contabilizadas en registro alguno: son utilidades financieras en exceso, con crédito que estará en el SAC. En rigor, son utilidades financieras, no tributarias, distintas de las registradas en el DDAN.
6. Capital propiamente tal (art. 17 No. 7: INR).
7. Si queda algo, será renta ordinaria del art. 20 No. 5.
8. También tenemos el FUT sustitutivo ya visto.

Estas disminuciones o devoluciones de capital tienen que cumplir con todas las formalidades legales; de lo contrario, nunca se podrá decir que se está frente a una disminución de capital y alegar un INR del art. 17 No. 7.

El art. 69 CT dispone una autorización previa del SII para realizar una disminución de capital, que hoy es muy rápida pero antiguamente implicaba una revisión de todo los registros y el orden de prelación.